



'

في

العقود الادارية

دراسة في ضوء احكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

2024/2025

دكتور

ايمن محمد ابو حمزة

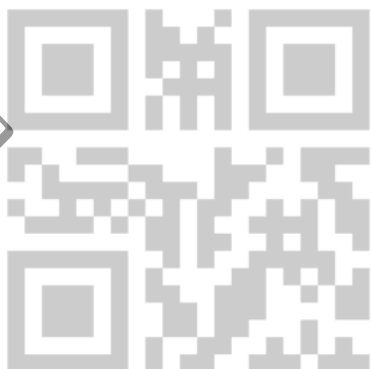
مُرئیس قسم القانون العام

كلية الحقوق - جامعة طنطا

الناشر

دار النهضة العربية

٣٢ ش عبد الخالق ثروت – القاهرة



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي

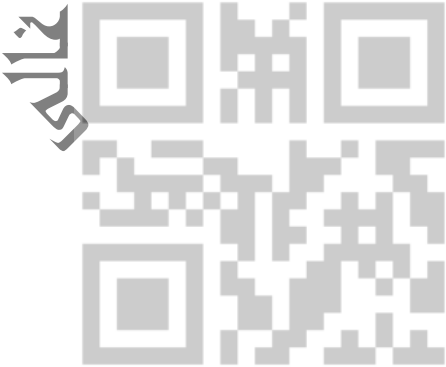


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة عامة

تلجأ الإدارة العامة وهي بصدد ممارسة نشاطها إلى مجموعة من الوسائل المتعددة والمتنوعة، وهي ما تعرف بأعمال الإدارة العامة. هذه الأعمال قد تكون من جانب واحد كالقرارات الإدارية، وقد تكون أعمالاً من جانبين «اتفاقية» كالعقود. ويمثل أسلوب التعاقد أسلوباً مهماً من الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة العامة لممارسة نشاطها، فعن طريقه تتمكن الإدارة من شراء المنقولات أو العقارات أو تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، أو نقل أو بيع أو تأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمنقولات والمشروعات المملوكة لها.

وأطراف العقد الإداري - في الغالب الأعم - شخص من أشخاص القانون العام وشخص خاص «طبيعي أو معنوي»، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يبرم هذا العقد بين أشخاص القانون العام فيما بينهم^(١)، بل أن أسلوب العقد الإداري يمثل الأسلوب الأساسي للتعامل بين الجهات الإدارية المختلفة والمستقلة عن بعضها البعض^(٢).

بيد أن عقود الإدارة ليست كلها من طبيعة واحدة أو بمعنى أدق لا تخضع كلها

2024/2025

لنظام قانوني واحد، ولكنها تنقسم إلى قسمين: 2024/2025

▪ عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص:

« Contrats de droit privé de l'administration »

▪ عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام:

« Contrats administratifs »

ويطلق على القسم الأول من هذه العقود «عقود الإدارة المدنية»، وفيها تقف الإدارة كطرف مساوٍ للمتعاقد معها لا تتميز عنه. فهي لا تختلف عن عقود الأفراد في القانون الخاص، ومن ثم تخضع لمبادئ القانون الخاص وأحكامه ويكون المختص بالفصل فيما يثور من منازعات بشأنها هو القضاء العادي.

(١) انظر:

• A. MOYRAND, L'essentiel sur le droit administratif, Tome2, 1^{ère} édition, L'HERMES, 1993, P.47.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص ٥.

أما القسم الثاني من هذه العقود فيطلق عليه « العقود الإدارية ». وهو موضوع دراستنا . وفيه لا تكون جهة الإدارة المتعاقدة مساوية للأفراد بل تكون في موقع اعلي يعطي لها امتيازات وسلطات خاصة مثل النص في العقد علي حق الإدارة في التنفيذ المباشر علي نفقة المتعاقد حال تقصيره في أداء التزاماته . دون اللجوء إلي القضاء . أو علي حق الإدارة في الرقابة والإشراف علي تنفيذ المتعاقد لالتزامه ، أو علي حقها في توقيع جزاءات علي أو تعديل شروط العقد وطريقة تنفيذه وحقها في إنهاء الرابطة العقدية بإرادتها المنفردة ، ومن ثم تخضع هذه العقود لمبادئ وأحكام القانون العام ويكون المختص بالفصل فيما يثور من منازعات بشأنها هو القضاء الإداري .

وتحظى العقود الإدارية بأهمية كبيرة في مجال الاستثمارات الأجنبية وخصوصا عقود الامتياز التي تجيز للشركات الأجنبية استغلال بعض موارد الثروة الطبيعية . كالبتترول . أو تنفيذ بعض المشروعات العامة الكبيرة التي تتطلب إمكانيات مادية وفنية ضخمة لا تتوفر في الشركات المحلية مثل مشروع حفر مترو الأنفاق . ومما لا شك فيه أن سياسة الخصخصة والاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة في السنوات القليلة الماضية أدت إلى ظهور أنواع جديدة من العقود التي تبرمها الإدارة في مجال مشروعات البنية الأساسية . مثل عقود **B.O.T** ، مما يبرز الحاجة إلى ضرورة تطوير نظرية العقود الإدارية بما يتلاءم مع الاعتبارات الجديدة^(١).

ونظراً للأهمية العملية للعقود الإدارية فأنها تحظى بأهمية تشريعية علي اعتبارها أحد أساليب ممارسة النشاط الإداري . لذلك اصدر المشرع المصري في ٢٠١٨/١٠/٣ قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة^(٢) : لاغيا بذلك القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولاغيا ايضا القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن تنفيذ أعمال الخطة الاقتصادية وكذلك لاغيا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ . ويعد هذا القانون استجابة تشريعية واعية للتطورات الاقتصادية في المجتمع المصري وأيضا للمتغيرات الاقتصادية علي الصعيد الدولي .

(١) انظر : د. عمر حلمي ، معيار تمييز العقد الإداري ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٣ ، ص ٩ .

(٢) راجع المادة ٢ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

ويهدف المشرع المصري من تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الي الاتي^(١):

١. تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود .
٢. تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام .
٣. تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح .
٤. تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات .
٥. تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية .
٦. توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيايل والفساد والاحتكار .
٧. تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبني

2024/2025

2024/2025 سياسات التعاقد المستدام . 2024/2025

٨. تهيئة المناخ للشركات والمشروعات والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.

وقد بلغت من أهمية العقود الإدارية أنها أصبحت تحظى باهتمام دولي فقد صدر عن لجنة القانون التجاري الدولي المنبثقة من الأمم المتحدة قانون نموذجي لشراء السلع والخدمات، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الدولية كان آخرها مؤتمر القاهرة الدولي في الفترة من ٢٩ . ٣١ يناير لسنة ١٩٩٤ لمناقشة إصلاح وتحديث قواعد المناقصات والمزايدات في الدول الآخذة في النمو^(٢).

وفي ضوء ما سبق سوف نقسم دراستنا إلى خمسة أبواب، نبدأها بتعريف العقد الإداري مع استعراض أهم صوره في باب أول، ثم نتعرف علي الأساليب المختلفة لإبرام

(١) لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، ولكن صدرت مسودة غير نهائية لهذه اللائحة، وقد تم الاستعانة بها في هذه الدراسة.

(٢) انظر: د. انس جعفر: العقود الإدارية، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣، ص ٦.

العقود الإدارية في باب ثان، و نتناول القواعد العامة التي تنظم العقود الإدارية في باب ثالث، والباب الرابع لتتعرف علي الجهة المختصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. وأخيراً نخصص الباب الخامس لمعرفة كيفية انتهاء العقد الإداري.

وبناء علي ذلك ستكون خطة الدراسة علي النحو التالي:

الباب الأول: مفهوم العقد الإداري ومعياري تمييزه وصوره.

الباب الثاني: أحكام إبرام العقد الإداري.

الباب الثالث: تنفيذ العقد الإداري.

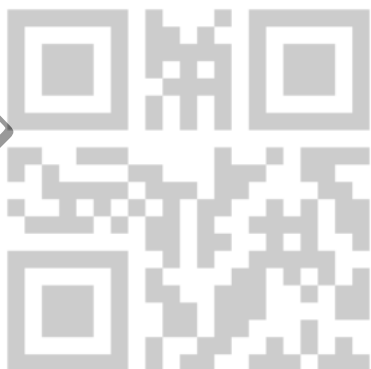
الباب الرابع: تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.

الباب الخامس: نهاية العقد الإداري.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الباب الأول

مفهوم العقد الإداري ومعياري تمييزه وصورة

في إطار هذا الباب المعنون بمفهوم العقد الإداري ومعياري تمييزه وصورة، نتناول ثلاثة موضوعات أساسية، نبدأها بإيضاح مفهوم العقد الإداري، ثم شرح كيفية تمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية، وأخيراً نورد الصور المختلفة للعقود الإدارية، علي أن نسبق ذلك بدراسة الخلفية التاريخية لنشأة نظرية العقد الإداري في كل من مصر وفرنسا، ومن هذا المنطلق نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول متعاقبة علي النحو التالي:

الفصل الأول: الخلفية التاريخية لنظرية العقد الإداري.

الفصل الثاني: مفهوم العقد الإداري.

الفصل الثالث: تمييز العقود الإدارية.

الفصل الرابع: صور العقود الإدارية.

الفصل الأول

الخلفية التاريخية لنظرية العقد الإداري

من خلال دراستنا لهذا الفصل نتعرف علي الخلفية التاريخية لنشأة نظرية العقد

2024/2025

2024/2025

الإداري في كل من فرنسا ومصر:

المبحث الأول

نشأة نظرية العقد الإداري في فرنسا

ترجع نشأة نظرية العقد الإداري في القانون الإداري الفرنسي إلى مطلع القرن العشرين، فلقد كان المعيار المتبع في توزيع الاختصاص بين المحاكم القضائية والقضاء الإداري يرتكز علي فكرة السيادة أو السلطة. وترتب علي ذلك اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات التي تتعلق بأعمال السلطة، واختصاص القضاء العادي بالتصرفات العادية التي تهبط فيها الإدارة إلى مرتبة الأفراد العاديين تتبع لهم أو تشتري أو تستأجر منهم... الخ، أي أن تتعامل الإدارة مع الأفراد بذات الأسلوب الذي يتعاملون به فيما بينهم.

ووفقاً للمعيار السابق صنف القضاء الإداري الفرنسي عقود الإدارة ضمن طائفة أعمال الإدارة العادية التي تختص المحاكم العادية. كأصل عام. بنظر المنازعات التي تنشأ بشأنها ولم يستثن من ذلك سوي عددا يسيرا من العقود أطلق الفقه عليها تسمية «العقود الإدارية بتحديد القانون»، حيث نص المشرع الفرنسي. لأسباب خاصة. علي اختصاص المحاكم الإدارية بشأن ما يدور حولها من منازعات. ومن قبيل ذلك قانون ٢٨ أيلول للسنة

الثامنة الذي جعل من اختصاص مجالس الأقاليم^(١)، النظر في المنازعات المتعلقة بعقود الأشغال العامة وعقود بيع أملاك الدولة. وقانون ١٧ يوليو ١٧٩٠ و ٢٦ سبتمبر ١٧٩٣ المتعلق بعقود القروض العامة، ومرسوم ١١ يونيو ١٨٠٦ المتعلق بعقود التوريد والمرسوم بقانون الصادر في ١٧ يونيو سنة ١٩٣٨ المتعلق بالعقود التي تتضمن شغلا للدومين العام. وتشير التسمية السابقة إلى أن اختصاص القضاء الإداري الفرنسي بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود السابقة لم يكن راجعا إلى خصائصها الذاتية وإنما بسبب إرادة المشرع الصريحة^(٢). وحقيقةً حاول مجلس الدولة الفرنسي عن طريق القياس توسيع دائرة اختصاصه، فمد اختصاصه إلى كثير من العقود الأخرى التي لم يرد بشأنها نصوص خاصة، مثل عقود توزيع المياه والغاز في المدن، والعقود الخاصة بالإضاءة ونظافة الطرق استنادا إلى تضمنها عنصر الأشغال العامة. وأيضا مد اختصاصه إلى طلب المعاونة استنادا إلى ذات الأساس. إلا أن الأمر ظل استثناء من الأصل العام الذي يعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الإدارة للمحاكم العادية.

ولما كان المعيار المحدد لاختصاص القضاء الإداري . وهو معيار السلطة العامة كما ذكرنا . يبعد العقود من نطاق هذا الاختصاص إلا استثناء وينص تشريعي. إلا أن الفقه والقضاء الإداريان قد هجرا المعيار السابق^(٣) لأسباب عديدة^(٤) وتبنى معيار المرفق العام^{2024/2025} كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري. وكان أول تطبيق لهذا المعيار في مجال العقود الإدارية هو حكم « Terrier » الصادر في ٤ فبراير ١٩٠٣ فقد قدم مفوض الدولة « Romieu » في تقريره تعريفا غير مباشر للعقد الإداري بأنه: « ذلك الذي يتعلق بتنظيم أو تسيير المرفق العام » وأوضح أن: « اختصاص القضاء الإداري يتناول كل ما يتعلق بتنظيم وسير المرافق العامة قومية أو محلية سواء أكانت وسيلة الإدارة في ذلك عملا من أعمال السلطة أو تصرفا عاديا. فالعقود التي تبرمها الإدارة بهذا الخصوص هي أعمال إدارية بطبيعتها، وبالتالي يجب أن يختص القضاء الإداري بالفصل في كل ما ينجم عنها من منازعات »^(٥).

(١) المحاكم الإدارية حاليا.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية ، المرجع السابق، ص ٣٣.

(٣) نفس المرجع السابق، ص ٣٣.

(٤) انظر:

• C. E. 4 février 1904, TERRIER, Rec. P. 94 Concl. ROMIEU.

وقد توالى الأحكام التي استخدمت فكرة المرفق العام كمعيار لتمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية^(١). ويتطبيق ذلك المعيار اكتسبت العقود التي تبرمها الإدارة لأول مرة الصفة الإدارية بناء على خصائصها الذاتية التي تحددها معايير الفقه والقضاء، لا بناء على إرادة المشرع. مما أدى إلى اتساع نطاق اختصاص القضاء الإداري الفرنسي بنظر منازعات العقود الإدارية.

المبحث الثاني

نشأة نظرية العقد الإداري في مصر

مما لا شك فيه أن أحكام العقود الإدارية هي من صنع القضاء الإداري الفرنسي، وحيث أن مصر لم تأخذ بنظام القضاء الإداري إلا ابتداء من عام ١٩٤٦ وهو تاريخ نشأة مجلس الدولة المصري، لذا يمكننا أن نقرر بدءاً ارتباط نشأة وتطور نظرية العقد الإداري في النظام القانوني المصري بنشأة هذا المجلس. وهذا ما سوف نوضحه بدراسة الأوضاع القانونية للعقود التي أبرمتها الإدارة المصرية قبل وبعد نشأة مجلس الدولة المصري، وذلك في مطلبين علي النحو التالي:

المطلب الأول: فكرة العقد الإداري في ظل القضاء الموحد.

المطلب الثاني: فكرة العقد الإداري في ظل قضاء مجلس الدولة.

2024/2025

2024/2025

المطلب الأول

فكرة العقد الإداري في ظل القضاء الموحد

في مرحلة الأخذ بالقضاء الموحد ظلت عقود الإدارة تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها العقود المدنية، حيث لم تطبق المحاكم القضائية المصرية المختلفة أهلية كانت أو مختلطة أحكاماً خاصة بها، بل طبقت عليها القواعد الواردة في التشريعات الخاصة بكل عقد منها. وذلك على أساس أن مهمة القاضي هي تطبيق القانون لا خلقه.

لذلك كان أمراً طبيعياً أن يرفض القضاء الأهلي والمختلط تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي اقراها مجلس الدولة الفرنسي على عقود الإدارة والتي تعطي للمتعاقد مع الإدارة الحق في الحصول على تعويض مناسب حال ظهور ظروف غير متوقعة وغير ممكن دفعها تجعل تنفيذ التزاماته مرهقاً. ومثال ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٩٢٤ والذي رفضت فيه لشركة مياه الإسكندرية حقها في طلب

(١) انظر علي سبيل المثال:

• C. E. 4 mars 1910, THEROND, Rec. P. 193, Concl. PICHAT.

زيادة المقابل المالي الذي تتقاضاه من جمهور المنتفعين بسبب ارتفاع التكاليف ارتفاعاً كبيراً، وقررت أن السبيل الوحيد أمام الشركة هو الاتفاق الودي مع الأفراد، وليس للقضاء أن يعتدي علي حق الإدارة في هذا الخصوص لأن اختصاصه يقتصر علي تفسير الاتفاقات المبرمة بقصد العمل علي احترامها دون تعديل لشروطها^(١).

ولم تخالف المحاكم الأهلية مسلك المحاكم المختلطة، وعندما أرادت محكمة الاستئناف تلمس العدالة وتطبيق نظرية الظروف الطارئة اهتداء بما قرره مجلس الدولة الفرنسي وقفت لها محكمة النقض بالمرصاد وألغت قضائها في ذلك. فقد تعلق الأمر بعقد من عقود التوريد التزم بمقتضاه المورد علي توريد كمية كبيرة من الشعير إلي الإدارة . في وقت كانت الحكومة تفرض تسعيرة محددة للشعير. فما أن شرع المورد في توريد ما اتفق عليه حتى ألغت الحكومة التسعيرة فارتفع سعر الشعير بصورة كبيرة فتوقف عن تنفيذ التزامه، قامت الإدارة بشراء كمية الشعير المتبقية علي حسابه، ثم رفعت دعوى أمام محكمة أول درجة لتطالبه بفرق الثمن. دفع المورد بتطبيق نظرية الظروف الطارئة أمام المحكمة ولكنها رفضت دفعه وقررت أنه: «.... من المتفق عليه أن ارتفاع السعر أو تكبد المتعهد خسائر لم تكن في حسابه لا تخليه من الالتزام بالوفاء إذ أن ذلك لا يعد من الحوادث القهرية التي تعفيه من المسؤولية»^(٢).

2024/2025

2024/2025

وعندما استأنف المورد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ألغت الأخير هذا الحكم المستأنف مقرر: «انفساخ الالتزام بالظروف الطارئة التي لم يكن يتوقعها العاقدان والتي تجعل التنفيذ مرهقا للمدين». ولكن عندما اتصلت محكمة النقض بالدعوى أصدرت حجمها بتاريخ ١٤ يناير سنة ١٩٣٢ بإلغاء حكم محكمة الاستئناف لأنه أخطأ في تأويل القانون بتقريره المساواة بين الظرف الطارئ الذي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمتزم وبين الحادث الجبري الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة. وقررت أنه: «....ومن حيث أنه وإن كانت نظرية الظروف الطارئة تقوم علي أساس العدل والعفو والإحسان إلا أنه لا

(١) انظر: مجموعة التشريع والقضاء المختلطة، السنة ٣٦ ص ٢٨١.

وأكدت هذا المعني صراحة محكمة الإسكندرية المختلطة في حكمها الصادر بتاريخ ٦ مايو سنة ١٩٢٦ حين قررت أن: « القانون المصري يجهل نظرية الظروف الطارئة وأن مهمة المحاكم تنحصر في تفسير العقود والعمل علي احترام الاتفاقيات التي تعقد بحرية، وأن هذه المبادئ تسري علي عقود الامتيازات التي تبرمها الإدارة دون شك». راجع: الجازيت، سنة ١٦، ص ٢٥٥.

(٢) انظر: حكم محكمة الإسكندرية الأهلية الابتدائية، الصادر بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٢٣، المجموعة الرسمية سنة ١٩٢٧، رقم ١١٦، ص ٢٢٣.

يصح لهذه المحكمة أن تستبق الشارع إلى ابتداعها فيكون عليها هي وضعها وتبيان الظروف الواجب تطبيقها فيها....»^(١).

وبالرغم من إخضاع المحاكم القضائية في ظل القضاء الموحد العقود الإدارية - بصفة عامة - للقواعد والمبادئ التي تخضع لها العقود المدنية، فإن بعض الأحكام القضائية قد أبرزت الصفات الخاصة بالعقود الإدارية، وعلاقتها بالمرفق العام. ففي حكم لمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ ١٠ يناير سنة ١٩٣٣ تقرر انه في حالة عدم وجود تشريعات خاصة لتنظيم العقود الإدارية، فإنه علي المحاكم عند تصديها للمنازعات الناشئة عن تلك العقود، أن تراعي المبادئ العامة الخاصة بالعقود الإدارية والتي يمكن استمدادها من المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري، ذلك القانون الذي يوجد حتما في كل دولة متحضرة^(٢).

ولكن نظراً لندرة تلك الأحكام فإنها لا يمكن لها بحال من الأحوال أن تمثل اتجاها قضائياً ينبئ عن ظهور نظام قانوني واضح المعالم للعقود الإدارية يميزها عن العقود المدنية.

المطلب الثاني

فكرة العقد الإداري في ظل قضاء مجلس الدولة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أنشأ المشرع المصري مجلس الدولة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦، وقد حدد هذا القانون اختصاص المجلس علي سبيل الحصر، بمعنى ان المشرع قد حدد المسائل التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري علي سبيل التحديد وبنص القانون، ولم يتضمن أية إشارة إلى اختصاصها بنظر المنازعات التي تثار بصدد العقود التي تبرمها الإدارة، وبالتالي في ظل القانون الأول لمجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ احتفظت المحاكم العادية باختصاصها كاملاً في مجال العقود الإدارية.

علي أن الأمر تغير بصدر القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩، حيث نص في المادة الخامسة منه علي أن: « تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد ».

(١) المجموعة سنة ١٩٣٢، حكم رقم ١١٠، ص ٢١٠.

(٢) مجموعة التشريع والقضاء المختلط السنة ٤٥، ص ١١٤.

وقد تعرض القانون السابق لانتقادات شديدة من جانب الفقه^(١) لأنه أورد العديد من القيود علي اختصاص القضاء الإداري في مجال عقود الإدارة:

١. حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري بثلاثة عقود فقط هي عقد الالتزام وعقد الأشغال العامة وعقد التوريد الإداري، ومن ثم أخرج من نطاق اختصاصه سائر العقود الإدارية الأخرى^(٢). وإن لوحظ أن مجلس الدولة المصري قد لجأ إلى القياس ليمد اختصاصه إلى أنواع أخرى من العقود الإدارية علي غرار مسلك القضاء الفرنسي السابق الإشارة إليه^(٣).

٢. اقتصر اختصاص القضاء الإداري علي المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد. أما المنازعات المثارة بين الإدارة والغير أو بين المتعاقد والغير فإنها تخرج عن اختصاص القضاء الإداري وتكون دائماً من اختصاص المحاكم العادية.

٣. جعل الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الثلاثة السابقة شركة بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم العادية بحيث يتخير ذوو الشأن بين أي السبيلين لجأ، ويترتب علي لجوئه لأحدهما منع الجهة الأخرى من النظر في النزاع. وقد

أبدي هذا المسلك إلى ازدواج المبادئ القانونية التي تطبق بصدد العقود الإدارية. 2024/2025

وإزاء الانتقادات التي وجهت إلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩، كان من الطبيعي أن يعمل المشرع علي تقادي هذه العيوب في قوانينه التالية له. حيث نص في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في المادة العاشرة علي أن: « يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر ».

(١) انظر في ذلك: د. سليمان محمد الطماوى ، الأسس العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٩. د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري ، دار النهضة العربية، ١٩٨٢، ص ١١، د. عمر حلمي، مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٨ - ٢٩.

(٢) وقد بررت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب هذا التحديد بقولها: « ...لأنه لا يشترط أن كل عقد تكون الإدارة طرفاً فيه يصدق عليه انه عقد إداري، فكثيراً ما ترتبط الإدارة كأي فرد من الأفراد بعقود عادية، ولأن تكييف العقد بأنه إداري كان ولا يزال موضع خلاف كبير، و لم ينته استقراء الفقهاء إلى ضابط يحدد المقصود من العقد الإداري تحديداً مانعاً، فلاقتصار في هذا الصدد علي تلك العقود المعينة يكفي هذا الخلاف الطويل ».

(٣) من ذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢٦ ديسمبر ١٩٥١ والذي مد فيه المجلس اختصاصه إلى عقد المعاونة استناداً إلى ارتباطه بالأشغال العامة في العقد.

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أسباب التعديل بقولها: «ولقد كان الفصل في طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية، وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وسائر العقود الإدارية مشتركاً بين القضاء الإداري والقضاء العادي. ولا يخفى ما في هذا الاشتراك في الاختصاص من معاييب، أقلها التعارض في تأصيل المبادئ القانونية التي تحكم هذه الروابط القانونية، ولذلك رؤى أن يكون الفصل فيها من اختصاص القضاء الإداري وحده، وهي الجهة الطبيعية باعتبار أن تلك الروابط من مجالات القانون الإداري أو القانون العام».

وهكذا أصبح الوضع بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ طبيعياً، حيث توحدت الجهة المختصة بموضوع العقود الإدارية، وبالتالي توحدت القواعد الموضوعية التي تحكم المنازعات المتعلقة بها، وأصبح اتجاه مجلس الدولة إلي تطبيق القواعد الإدارية في هذا الصدد، اتجاهاً حقيقياً، لا يحد منه، أو ينقص من قيمته، التزامه بتطبيق بعض القواعد المدنية.

وقد التزم المشرع المصري بالمحافظة علي نص المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ رقماً ولفظاً في القانونين التاليين له رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ (١).

2024/2025

2024/2025
الفصل الثاني

2024/2025

مفهوم العقد الإداري

العقد بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانوني معين، فهو ينشئ التزاماً أو يعدله أو يلغيه (٢). فيجب أولاً لكي نكون بصدد عقد أن تتفق إرادتان أو أكثر، فالعقد لا يتم بالإرادة المنفردة، ويجب ثانياً أن يكون توافق الإرادتين بقصد إحداث أثر قانوني، فإذا لم يكن المقصود إحداث هذا الأثر فلا نكون بصدد عقد. فدعوة صديق للغداء وقبول الصديق لهذه الدعوة لا يعتبر عقداً، لأن الطرفين لم يقصدا إنشاء التزام قانوني (٣).

(١) نصت المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ علي أن: « تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر ».

(٢) من الملاحظ أن المشرع المصري لم يأت بتعريف للعقد علي عكس المشرع الفرنسي الذي ينص في المادة ١١٠١ من القانون المدني علي أن العقد: « اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص آخر أو أكثر بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ».

(٣) انظر: د. عبد الودود يحيي، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول "مصادر الالتزام"، دار النهضة العربية، ١٩٩٢، ص ١٧.

وبناء على ذلك فإن مفهوم العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقد يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء التزام أو تعديله^(١). وهذا التعريف إذا كان يجدي في التمييز بين العقد الإداري والقرار الإداري . ظاهريا ، فإنه لا يجدي في التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني.

أولاً: التمييز بين العقد الإداري والقرار الإداري:

القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن إرادة منفردة من جانب الإدارة العامة وهو يعد أنجع وأقوى الوسائل القانونية التي تتسلح بها الإدارة العامة لإمكان قيامها بواجباتها المتعددة^(٢)، نظراً لأنه يقوم على عنصر الجبر والإلزام، فمتمي أصدرت الإدارة قراراً إدارياً وجب على الأفراد احترامه وتنفيذه وإلا قامت الإدارة بتنفيذه جبراً بما تملكه من سلطات.

ولكن من غير المتصور أن تلجأ الإدارة العامة في جميع الأحوال إلى إصدار قرارات إدارية ملزمة للأفراد لإشباع حاجاتها، فثمة حاجات أخرى لا يمكن لها أن تقتضيها من الأفراد . في الأحوال العادية . إلا بالاتفاق والتراضي، لذلك لا تجد مفراً سوى التعاقد معهم. فمن ناحية أولى، قد تحتاج الإدارة إلى الحصول على سلع أو خدمات ذات موصفات معينة أو استشارات أو أعمال فنية مما يستلزم ترغيب الطرف الآخر في تقديم هذه الأعمال أو الخدمات نظير مقابل مادي يحقق له الكسب والربح^(٣)، ومن ناحية ثانية، قد تحتاج الإدارة إلى الحصول على هذه الأعمال أو الخدمات من الخارج و في هذه الحالة لا تستطيع الإدارة الأخذ بأسلوب القرار الإداري لأنها لا تملك إلزام أو إجبار غير مواطنيها، لذلك لا تملك غير أسلوب التعاقد مع الشخص الأجنبي طبعياً كان أو معنوياً « شركة » للحصول على هذه الأعمال أو الخدمات.

وبناء على ذلك يمكننا استخلاص العناصر المميزة للعقد الإداري عن القرار

الإداري:

- ١ . العقد الإداري هو تصرف صادر عن إرادتين أي من جانبين جهة الإدارة والمتعاقد معها، أما القرار الإداري فهو تصرف صادر عن إرادة واحدة أي من طرف واحد ، وهو جهة الإدارة.

(١) انظر:

• L. RICHER, Les contrats administratifs, Dalloz, 1991, P.9.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الرابعة، ١٩٨٤، ص ٢٣.

(٣) انظر في ذلك: د. عبد الله حنفي، العقود الإدارية، الكتاب الأول (ماهية العقد الإداري وأحكام إبرامه)، دار النهضة العربية، ١٩٩٩، ص ١٠.



٢. القرار الإداري لا يلزم عند إصداره رضا من صدر في مواجهته، علي عكس العقد الإداري الذي لا يتم إبرامه إلا بتوافق ارادتين، أي يقوم علي عنصر التراضي. إلا أن الاعتماد علي عنصر الرضا للتمييز بين العقد الإداري والقرار الإداري قد يؤدي إلى إدخال بعض المراكز القانونية في المجال التعاقدية^(١).

لذلك فإن الرأي الراجح في الفقه^(٢) يري إضافة مضمون وأثار التصرف الذي تقوم به الإدارة. بجانب عنصر الرضا. فإذا كان تصرفها يترتب آثارا في مواجهة الغير فقط فأنة يعد بمثابة قرار إداري. وعلي العكس من ذلك إذا كان تصرفها يترتب آثارا متبادلة في مواجهتها ومواجهة الغير فأنة يعد عقدا إداريا.

وبناء علي ما سبق يمكننا أن نعرف العقد الإداري بأنه: « عمل قانوني ملزم لأطرافه، ناتج عن اتفاق إرادة شخصين أو أكثر علي إنشاء حقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين ». في حين أن القرار الإداري يعد « عمل قانوني يصدر عن إرادة منفردة وينتج آثار قانونية في مواجهة أشخاص يعتبرون من الغير ».

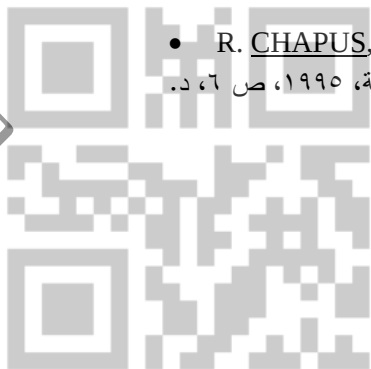
وهذا هو المعيار الذي جري القضاء الإداري المصري علي اتباعه للتمييز بين العقود الإدارية والقرارات الإدارية. فقد قررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١٨ مايو سنة ١٩٦٨ أن: « القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء علي سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانوني يكون جائزا وممكنا قانونا وبباعت من المصلحة العامة التي يبتغيها القانون. أما العقد الإداري فهو الاتفاق الذي تبرمه الإدارة مع أحد الأفراد يتحدد فيه حقوق والتزامات كل من الطرفين ويخضع للقانون العام.... »^(٣).

(١) ليس حتما كل عمل يتضمن توافق ارادتين أو أكثر يعتبر عقدا، فالتعيين في الوظيفة العامة ينطوي علي توافق ارادتين ولكنه مع ذلك ليس عقدا، ولا ينشئ مركزا ذاتيا، إنما هو عمل شرطي (واتفاقي في نفس الوقت) ينشئ مركزا تنظيميا. فإذا كان العقد يشترط توافق ارادتين أو أكثر، فالعكس ليس صحيحا بمعنى أن كل عمل يتضمن توافق ارادتين أو أكثر ليس عقدا حتما، ولكن يعد عملا اتفاقيا. انظر في التمييز بين العمل الاتفاقي والعقد :

- د. توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الأولى، ١٩٥٤ - ١٩٥٥، ص ص ٥٢-٥٣.
- L. DUUIT, Traité de droit constitutionnel, 3^e éd. , 1927, t.I, p. 380 et s.

(٢) انظر في ذلك:

- R. CHAPUS, Droit administratif général, T.1, éd. 1985, p.336.
- د. محمد عبد الواحد الجميلي، ماهية العقد الإداري، دار النهضة العربية، ١٩٩٥، ص ٦، د. عبد الله حنفي، مرجع سبق ذكره، ص ١١.
- (٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن، رقم ١٠٠٤، الصادر بتاريخ ١٨/٥/١٩٦٨.





وكذلك اعتبرت في النزاع بين الشركة العامة لمصانع السكر والتقطير المصرية . وهي شركة اقتصاد مختلط . وبين وزارة التموين « أن القرارات والأحكام المتعلقة بتنظيم تصريف الأصناف المختلفة من هذا السكر وتوزيعها إنما صدرت عن وزارة التموين بإرادتها المنفردة وفرضت علي الشركة دون تفاوض معها كطرف ثان أو قبول صريح أو ضمني من جانبها في الشكل وبالإجراءات والأوضاع التي يتم فيها عادة إبرام العقد الإداري....، ودون أن تتوافر في الوضع الخاص الذي فرض علي الشركة جبرا عناصر التعاقد القائم علي الرضا اللازم كركن لانعقاد العقد والذي أساسه الإرادة الحرة المتبادلة للمتعاقدين..... وبالتالي...فان مساهمتها الإجبارية في هذا المرفق ليس أساسها علاقة تعاقدية..»^(١).

ومن الجدير بالذكر أن اعتبار العمل عقداً إدارياً، من شأنه جعل الاختصاص فيما يتعلق به من منازعات للقضاء الكامل وليس لقضاء الإلغاء، وذلك باستثناء علي نحو ما سنراه لاحقاً . القرارات الإدارية المنفصلة، وطعون المستفيدين من عقود الالتزام. كما أن ذلك من شأنه أيضاً أن تستبعد قواعد المسؤولية غير العقدية في حالة رجوع أحد الطرفين علي الطرف الآخر، حيث لا يمكن له أن يحتج سوي بقواعد المسؤولية العقدية.

ثانياً: التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني^(٢):

تلجأ الأشخاص الإدارية وهي بصيورها ممارسة نشاطها، لتسيير المرافق العامة وإدارة المشروعات العامة التي تتولاها، وكذلك لاستغلال أموالها الخاصة إلى إبرام العديد من العقود بين بعضها البعض أو بينها وبين الأفراد. إلا أن هذه العقود من نوعين متميزين وتخضع أساساً لنظامين قانونيين مختلفين. فبعضها وهي العقود الإدارية يخضع لأحكام القانون العام، والبعض الآخر وهي العقود المدنية تسري عليها أحكام القانون الخاص. فكل عقد تبرمه جهة الإدارة ليس حتماً عقداً إدارياً. ومما لا شك فيه انه لا يعتبر العقد إدارياً يجب أن تكون الإدارة أحد أطرافه، ولكن هذا الشرط وحده غير كاف. إذ أن الإدارة قد تبرم عقوداً مدنية، إلى جانب العقود الإدارية. فإذا باعت إحدى الوزارات أو أجرت قطعة أرض من ممتلكات الدولة الخاصة إلى أحد الأفراد، أو استأجرت مبني لتشغل فيه إدارتها، فان مثل هذه العقود لا تعتبر عقوداً إدارية، بل هي عقود مدنية^(٣).

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٠٥٩، سنة ٧ ق، الصادر بتاريخ ١٩٦٣/٥/٢٥.

(٢) انظر فيما بعد، الفصل الثالث من هذا الباب، حيث يتعرض تفصيلياً لكيفية التمييز بين العقد المدني والعقد الإداري.

(٣) انظر: محكمة القضاء الإداري، حكم رقم ٨٧٠، لسنة ٥ ق، ١٩٥٦/١٢/٩. وانظر كذلك، المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٥٥٩، السنة ١١ ق، ١٩٦٨/٣/٢٤.



ومن الجدير بالذكر أن العقد الإداري يخضع لذات أسس وأركان العقد المدني من حيث ضرورة توافر الرضا والمحل وقيام السبب، غير أنه توجد عدة اختلافات جوهرية تميز العقد الإداري عن نظيره المدني يمكن إجمالها فيما يلي:

١. الاختلاف من حيث نوعية مصلحة وهدف طرفي العقد:

ففي مجال العقود المدنية يهدف كل من طرفيه إلى تحقيق مصلحته الشخصية، ولهذا يحرص كل طرف على تضمين العقد نصوصا تكفل له تحقيق تلك المصلحة. أما في مجال العقود الإدارية فيهدف أطرافه إلى تحقيق مصالح متغيرة، فالإدارة تهدف دائما إلى تحقيق المصلحة العامة، أما المتعاقد معها فيهدف دائما إلى تحقيق مصلحته الخاصة. وبناء على ذلك نجد أن الإدارة ليست حرة كالأفراد. في أن تبرم ما تشاء من العقود أيا كانت الغاية منها، بل يجب أن تهدف دائما من عقودها تحقيق المصلحة العامة، ويعد هذا قيداً عاماً تلتزم به الإدارة في جميع تصرفاتها سواء من جانب واحد أو من جانبيين ولو لم يرد به نص صريح.

ولعل نقطة الاختلاف بين العقود الإدارية والعقود المدنية من حيث مصلحة وهدف طرفي العقد، هو ما يبرر تنحية هدف الربح أو الكسب المادي لجهة الإدارة من وراء إبرام عقودها، وتتمسكها بتنفيذ تلك العقود بالرغم من عدم تحقيقها لأية عائد أو ربح مالي من عقودها، بل قد تتكبد الإدارة في بعض الأحيان لخسائر مالية في سبيل تنفيذها وذلك لتحقيق النفع العام. أما في العقود المدنية الخاصة فالهدف الأساسي من إبرامها هو تحقيق الربح المادي.

٢. الاختلاف من حيث المركز القانوني لأطراف العقد:

إذا كان الأصل أن كلا من العقود الإدارية والمدنية ينبتان من شجرة واحدة أصلها أن العقد شريعة المتعاقدين^(١)، إلا أن النظام القانوني الذي يخضع له العقد الإداري يختلف اختلافاً أساسياً عن النظام القانوني الذي يخضع له العقد المدني، مما يضفي على نظرية العقد الإداري طابعاً قائماً بذاته ويجعلها مستقلة عن نظرية العقد المدني.

(١) هذا ما تقرره الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بقولها: « الأصل بالنسبة للعقود المدنية والإدارية على حد سواء هو أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقرها القانون... ». ملف ٢٥٣٠/٢/٣٢، جلسة ١٩٩٧/٢/٥، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء ٤٩، ١٩٩٩ - ٢٠٠٠، ص ٢٣.

ويرجع هذا الاختلاف إلى عدم المساواة بين طرفي العقد الإداري، فهما يمثلان مصالح غير متعادلة: المصلحة العامة التي تبتغيها الإدارة العامة من جهة، والمصالح الخاصة التي يدافع عنها الأفراد من جهة أخرى. وذلك علي عكس العقد المدني حيث مصالح الأفراد متعادلة. لذلك في العقود الإدارية نجد أن الإدارة دائماً في مركز اعلي من المتعاقد معها، حيث تمنح العديد من السلطات والامتيازات في مواجهته.

وهذا ما تؤكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ١٩٥١/١٢/٢٦ في: « أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة، علي مصلحة الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازنة ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يعلو الصالح العام علي المصلحة الفردية الخاصة... »^(١).

٣. الاختلاف من حيث أسلوب إبرام العقد واختيار المتعاقد:

في مجال عقود القانون الخاص يسيطر مبدأ حرية التعاقد كحق عام يتمتع به أطراف العقد، حيث لهم مطلق الحرية في تحديد محل العقد ما لم يكن ذلك مخالفاً للقانون أو لقواعد النظام العام الآداب، كما يتم إبرام العقود ببساطة أي دون ما إتباع شكليات معينة مل 2024/2025 لم ينص القانون علي خلاف ذلك.

أما في مجال العقود الإدارية، نجد أن الإدارة تخضع لمجموعة من القيود والالتزامات التي تقيد حركتها وتحدد لها كيفية اختيار المتعاقد معها. فالإدارة - بصفة عامة - لا تتمتع بحرية كاملة في اختيار من تتعاقد معه، وإنما يقيد بها المشرع بعدة طرق وأساليب محددة يتعين عليها إتباعها للوصول إلي أفضل المتعاقدين من الناحيتين المالية والفنية.

(١) انظر: حكم محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم ٢١٣، لسنة ٤٤، الصادر في ١٩٥١/١٢/٢٦، وأيضاً حكمها في الدعوى رقم ٨٧٠، لسنة ٥٥، الصادر في ١٩٥٦/١٢/٩، وكذلك حكمها رقم ٦٣١ لسنة ٣٥ ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٣/٢/٢، حيث تقرر أن: «..... أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره، وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازنة ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يعلو الصالح العام علي المصلحة الفردية الخاصة.»

٤. الاختلاف من حيث الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن العقد:

يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بين الأفراد العاديين فيما بين بعضهم البعض، كما يطبق عليها مبادئ وقواعد القانون الخاص. بينما يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية، ويطبق عليها مبادئ وأحكام القانون العام.

الفصل الثالث

معيار تمييز العقود الإدارية

في بعض الأحيان، نجد أن طبيعة العقد يتم تحديدها من جانب المشرع نفسه، سواء بصورة مباشرة. وهو فرض قليل الحدوث عملاً. أو بصورة غير مباشرة. وهو الأمر الغالب. عن طريق جعل المشرع الاختصاص بنظر ما قد ينشأ من منازعات حول عقد معين للقضاء الإداري أو للقضاء العادي^(١). فإذا عهد المشرع مثلاً للقضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد معين فإن ذلك يعد قرينة على اعتبار هذا العقد عقداً إدارياً. ويطلق الفقه على العقود التي يحددها المشرع تسمية العقود الإدارية بتحديد القانون، إلا أن هذا التحديد التشريعي لا يشمل إلا عدداً قليلاً من العقود الإدارية ومن ثم يقع على عاتق القضاء الإداري. الذي يلعب دوراً بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية. وضع المعيار 2024/2025 المميز للعقد الإداري.

وبناءً على ما تقدم يتضح أن العقود الإدارية، إما أن يحددها المشرع، وإما أن يتدخل القضاء الإداري ليميزها عن غيرها من العقود المدنية، وهو ما سنتولى إيضاحه في بحثين متتاليين على النحو التالي:

المبحث الأول: العقود الإدارية بتحديد القانون.

المبحث الثاني: العقود الإدارية بتحديد القضاء.

المبحث الأول

العقود الإدارية بتحديد القانون

توجد بعض العقود التي تبرمها الإدارة تعتبر دائماً عقوداً إدارية نظراً لأن المشرع قد ينص صراحة على إصباح الصفة الإدارية لها، إلا أن نص المشرع لا يعد قرينة حاسمة وقاطعة في تكليف العقد بأنة عقد إداري، بل أن تدخل المشرع يساعد على توضيح الأمر

(١) انظر:

• L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op.cit., p.96.

بصفة مبدئية^(١)، ويظل الأمر متروكا للقضاء الإداري ليقوم بتكييف العقد وإعطائه الوصف القانوني الصحيح، وما إذا كان عقدا إداريا أم مدنيا^(٢).

هناك العديد من العقود التي أضفى عليها المشرع الفرنسي الصفة الإدارية، ولكن ما هو موقف المشرع المصري من هذا التحديد؟ وللإجابة على هذا التساؤل سوف نتناول فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون في فرنسا «المطلب الأول»، ثم نبين مجال هذه الفكرة في مصر «المطلب الثاني».

المطلب الأول

العقود الإدارية بتحديد القانون في فرنسا

قرر المشرع الفرنسي الصفة الإدارية لبعض العقود . بصورة غير مباشرة . وذلك بان نص في القوانين المختلفة علي اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تثور بشأنها، ومن أمثلة هذه العقود:

١. عقود الأشغال العامة: اعتبر قانون ٢٨ بليفور للسنة الثامنة أن عقد الأشغال

العامة من قبيل العقود الإدارية بتحديد القانون، حيث نص في مادته الرابعة علي اختصاص مجالس الأقاليم بالمنازعات التي تنشأ بين مقاول الأشغال العامة والإدارة

والمترتبة بتنفيذ شروط العقد المبرم بينهما^(٣). ونظرا لعدم تحديد القانون السابق 2024/2025

الإشارة إليه المقصود بالأشغال العامة، لذلك تولي القضاء الإداري تحديد نطاق الأشغال العامة^(٤). ولقد كان له دور كبير في توسيع مفهوم فكرة الأشغال العامة

(١) انظر:

- V. D. TRUCHET, Le contrat administratif in le droit contemporain des contrats, Thèse, Rennes, 1987, p.20.

(٢) انظر:

- V. G. VEDEL & P. DELVOLLE, Droit administratif, THEMIS, P.U.F. 9^{éd.}, 1984, p. 341.

(٣) انظر:

- L'article 4, alinéa 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII, dispose que le conseil de préfecture est compétent " sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés".

(٤) انظر:

- L. RICHER, Droit de contrats administratifs, op.cit., p.96.

وإدخال أي عقد له علاقة ولو بسيطة بالأشغال العامة ضمن إطارها، مثل عقد المساهمة في المشروعات العامة وعقود توريد الكهرباء، المياه والغاز.

٢. **عقود بيع أصول الدولة الخاصة:** وفقا لنص المادة الرابعة من قانون ٢٨ بليفوز السنة الثامنة يختص القضاء الإداري أيضا بالمنازعات الخاصة بعقود بيع أصول الدولة الخاصة (١). وعلي الرغم من أن هذه العقود تعد من عقود القانون الخاص، إلا أن المشرع الفرنسي قد منحها الصفة الإدارية لأسباب سياسية (٢).

٣. **عقود التوريد:** نص مرسوم ١١ يونيو الصادر في ١٨٠٦ في مادته الرابعة عشرة علي اختصاص القضاء الإداري بمنازعات عقود التوريد التي تبرمها الدولة (٣). ومن الملاحظ أن هذا النص قد قصر اختصاص القضاء الإداري بالنسبة للعقود الإدارية علي تلك التي تبرمها الدولة دون تلك التي تبرمها الأقاليم.

٤. **عقود القرض العام التي تبرمها الدولة:** بصدر قانون ١٧ يوليو ١٧٩٠ وقانون ٢٦ سبتمبر ١٧٩٣ اختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناجمة عن عقود القرض العام التي تبرمها الدولة. أما تلك العقود التي تبرمها الوحدات المحلية بشأن قرض فإنها كانت تخضع وما ينشأ عنها من منازعات للمحاكم العادية.

٥. **عقود شغل الدومين العام:** وفقا للمرسوم بقانون الصادر في ١٧ يونيو ١٩٣٨ بعد 2024/2025

القضاء الإداري هو جهة الاختصاص بنظر المنازعات الناجمة عن عقود شغل الدومين العام. حيث جاء فيه: « تخضع لاختصاص مجالس الأقاليم دون إحالة إلى مجلس الدولة المنازعات المتعلقة بعقود شغل جزء من الدومين العام أيا كان شكلها وتسميتها، والتي تبرمها الدولة، والأقاليم والمؤسسات العامة أو ملتزمي هذه المؤسسات » (٤). وبذلك أصبحت كافة عقود شغل الدومين العام ذات طبيعة إدارية

(١) انظر:

- " Ainsi, la loi du 28 pluviôse an VIII (art.4) a attribué compétence à la juridiction administrative sur les ventes des biens du domaine privé de l'Etat". V. L. RICHER, Les contrats administratifs, op.cit., p.18.

(٢) المرجع السابق، ص ١٨.

(٣) انظر:

- L'article 14 du décret du 11 juin 1806, prévoit « la compétence administrative en ce qui concerne les marchés de fournitures».

(٤) انظر في ذلك:

- Le décret loi du 17 juin 1938 (art. L. 84 du Code du domaine de l'Etat).

بصرف النظر عن تسميتها أو نوعها ولذلك خضعت هذه العقود جميعها لاختصاص القضاء الإداري الفرنسي.

وعلى العكس مما سبق، فإن هناك بعض العقود التي تبرمها الإدارة وتكون عقود خاصة بنص القانون. لذلك تخرج هذه العقود من مجال القانون العام ويختص بها القضاء العادي ويطبق عليها قواعد القانون الخاص. ومن أمثلة هذه العقود^(١):

١. عقود الإجارة الزراعية ذات الرسوم القروية، وذلك وفقا لنصوص وأحكام المرسوم الصادر في ١٧ مايو ١٨٠٩.

٢. العقود المتعلقة بإطعام الجنود، وذلك وفقا لأحكام المرسوم الصادر في ٢٢ أبريل ١٩٠٥ والمرسوم الصادر في ٦ نوفمبر ١٩٣٠.

٣. الإجراءات الريفية للوحدات العامة، وذلك وفقا للمادة ٨٦١ من القانون الريفي المتعلقة بالإجراءات الريفية للوحدات العامة.

٤. عقود إيجار الصيد المتعلقة بالدومين العام النهري، وذلك وفقا للمادة ٤٢١ من القانون الزراعي الصادر في ٢٩ يونيو ١٩٨٤.

٥. العقود المبرمة بين هيئة البريد و شركة التليفونات الفرنسية العامة وعمالتهما،

وذلك وفقا للمادة ٢٥ من قانون ٢ يوليو ١٩٩٠ التي تنص علي أن: « علاقات 2024/2025

هيئة البريد وشركة France Télécom مع عملاتهما أو مع الموردين المتعاملين معها أو مع الغير يحكمها القانون الخاص والمنازعات الناشئة عنها تختص بها المحاكم القضائية»^(٢).

المطلب الثاني

مجال فكرة العقود الإدارية

بتحديد القانون في مصر

باستعراض القوانين التي نظمت اختصاص مجلس الدولة المصري نستخلص أنه:

(١) انظر في ذلك:

- A. MOYRAND, L'essentiel sur le droit administratif, op. cit., p.48.

(٢) انظر:

- Selon l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 « les relations de La Poste et de France télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires».



أولاً: لم يتضمن القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الصادر بإنشاء مجلس الدولة المصري أي إشارة إلى عقود الإدارة. حيث حدد المسائل الداخلة في اختصاصه، علي سبيل الحصر ولم يجعل من بين هذا الاختصاص النظر في المنازعات الخاصة بأي عقد إداري، لذلك ظلت المنازعات الناشئة عن هذه العقود من اختصاص المحاكم العادية.

ثانياً: القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ تضمن اختصاصاً بنظر بعض المنازعات الناشئة عن بعض العقود الواردة علي سبيل التحديد والحصر، حيث نص مادته الخامسة علي أن: « تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد ويترتب علي رفع الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المذكورة عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية، كما يترتب علي رفعها إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري ».

ثالثاً: القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ورد النص به علي أن: « يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر »^(١). وبناء علي ذلك أصبح مجلس الدولة المصري صاحب الاختصاص الأصيل . دون غيره . بمنازعات العقود الإدارية جميعها بعدما ذيل

2024/2025

المادة ١٠ « أو بأي عقد إداري آخر » 2024/2025

رابعاً: وأخيراً بالنسبة للقانون الحالي لمجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فقد تضمن نفس العبارات الواردة في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥^(٢).

قد يبدو للوهلة الأولى من ظاهر النصوص السابقة أن المشرع المصري حدد الطبيعة الإدارية لبعض العقود . كما فعل المشرع الفرنسي . ولكن فحص النصوص السابقة عن كثب يؤدي إلى عكس ذلك كما يري أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي . فيري سيادته بالنسبة للعقود التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ أن عقود الأشغال العامة وعقود الالتزام هي عقود إدارية دائماً وفقاً لخصائصها الذاتية، ولصلتها الوثيقة بمبادئ القانون العام، أما العقد الثالث وهو عقد التوريد، فهو يحتمل أن يكون إدارياً أو غير إدارياً وفقاً لإرادة الإدارة. ولهذا حرص المشرع أن ينعته صراحة بالصفة

(١) انظر: المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥.

(٢) نصت المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ علي أن : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر".



« الإدارية » مما يعني استبعاد المنازعات الناشئة عن عقود التوريد غير الإدارية . الخاضعة للقانون الخاص . من اختصاص مجلس الدولة . بالإضافة إلى انه قد سمح لذوي الشأن اختيار رفع الدعوى أمام القضاء العادي او القضاء الإداري وهذا دليل أكيد علي انه لم يقرر الصفة الإدارية لهذه العقود بصفة قاطعة.

أما بالنسبة لنصوص قوانين مجلس الدولة التالية للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٩ وهي المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، والفقرة ١١ من المادة ١٠ من القانون الحالي رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، فان صياغتها قاطعة الدلالة علي أن ذكر العقود الإدارية الثلاثة هو علي سبيل التمثيل لا الحصر ، والدليل علي ذلك أن نهاية المادة تقول: « أو بأي عقد إداري آخر » . وينتهي سيادة الأستاذ الدكتور الطماوي . ونؤيده . إلى أن المشرع المصري لا يعرف فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون^(١).

وهذا اتجاه محمود لمشرع المصري لأنه بذلك يضع حدا فاصلا بين القضاء الإداري والقضاء العادي ، فقصر اختصاص القضاء الإداري علي مجالات القانون العام وحدد اختصاص القضاء العادي بمجال القانون الخاص^(٢) . وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٦ حيث تقول: « فلم يعد هذا الاختصاص "أي اختصاص مجلس الدولة في مجال العقود الإدارية " مقصورا علي عدد معين من عقود الإدارة ، المتعلقة بتلك العقود..... فقد أصبحت العقود الإدارية في مصر عقودا إدارية بطبيعتها ، وفقا لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون ولا وفقا لإرادة الشارع..... »^(٣).

المبحث الثاني

العقود الإدارية بتحديد القضاء

يعرف العقد الإداري - وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري المصري^(٤) والفرنسي^(٥) - بأنه « ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ص ٥٠-٥١.

(٢) انظر في ذلك: د. عبد الله حنفي، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٠.

(٣) انظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ٨٧٠ ، حق، الصادر في ١٩٥٦/١٢/٩.

(٤) انظر في ذلك: د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧ وما بعدها. د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٢ ، ص ٢٩ و ما بعدها. د. عمر حلمي، مرجع سبق ذكره، ص ٣١ وما بعدها. د. محمد عبد الواحد الجميلي،

تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام».

وقد استقرت علي هذا التعريف للعقد الإداري العديد من أحكام مجلس الدولة المصري^(١). ففي حكمها الصادر بتاريخ ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٦٠ ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى « أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص »^(٢).

وأيضاً استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي ذات التعريف حيث ذهبت في حكمها الصادر بتاريخ ٢٤ يناير سنة ١٩٩٥ إلى أنه: «... ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب

2024/2025

2024/2025

2024/2025

مرجع سبق ذكره ، ص ٥٧ وما بعدها. د. جرجي شفيق ساري، تطور طريقة ومعياري تمييز وتحديد العقد الإداري "في القانونين الفرنسي والمصري"، دار النهضة العربية، ١٩٩٦، ص ١٥ وما بعدها.

(١) انظر:

- MOYRAND, L'essentiel , op. cit., p. 49 et s.
- P. AMSELEK, " La qualification des contrats de l'administration", A.J.D.A. 1983, p.3.
- J. LAMARQUE, " Les difficultés présentes et les perspectives d'avenir de la distinction entre les contrats administratifs et les contrats privé", A.J.D.A., 1961, p.123.

(٢) انظر علي سبيل المثال:

- أحكام محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم ٦٢٥ ، ٤ق ، الصادر في ١٢/٢/١٩٥٢، الدعوى رقم ٢٢٢ ، ١٠ق، الصادر في ١٣/١٢/١٩٥٦، الدعوى رقم ١٨٩٤ ، ١٠ق، الصادر في ١٠/٣/١٩٥٧، الدعوى رقم ٣٤٨٠ ، ٩ق، الصادر في ٢/٦/١٩٥٧ والدعوى رقم ١١٨٤ ، ١٤ق، الصادر في ٢٥/٦/١٩٦١.
- أحكام المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم ٥٥٩ ، ١١ق، الصادر في ٢٤/٣/١٩٦٨، الطعن رقم ١٨٨٩ ، ٦ق، الصادر في ٣١/٣/١٩٦٢ و الطعن رقم ٨ ، ٥ق، الصادر في ٥/٤/١٩٧٥.
- (٣) محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ٥٦٧ ، ١٣ق، الصادر في ٢٣/١٠/١٩٦٠.

القانون العام. وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص»^(١).

كما أخذت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بهذا التعريف، فقد قررت في فتاها رقم ٦٣٧ « أن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية ذلك لأنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بقصد تحقيق مصالح عامة. ومركز المتعاقدين فيها غير متكافئ إذ يجب أن يراعى فيها تغليب المصالح العام على المصالح الخاص وهذا الهدف يجب أن يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين عند تطبيقه وتفسيره»^(٢).

وقد أخذت بهذا التعريف محكمة النقض، فقد قررت أن: «.....مناطق العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهي انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص»^(٣).

وفي ذات الاتجاه ذهبت المحكمة الدستورية العليا . باعتبارها محكمة تنازع . إلى مسايرة القضاء المستقر في شأن معيار تمييز العقود الإدارية حيث تؤكد انه: «...يتعين»^{2024/2025} لا اعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وان يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام، وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط غير مألوفة في القانون الخاص»^(٤).

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٣١٢٨ ، ٣٥ ق، بتاريخ ١٩٩٥/١/٢٤ ، مجموعة من المبادئ في العقود الإدارية ، إصدار مجلس الدولة ، المكتب الفني بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلس الدولة ص ٩٨ .

(٢) فتوى رقم ٦٣٧ في ١٩٥٦/١٠/٢٣ ، مجموعة أبو شادي، طبعة ١٩٦٤ ، ص ٧٥١ .
(٣) نقض مدني، الصادر بتاريخ ١٩٨٨/١/٢٦ ، الطعن رقم ٧٦٧ ، لسنة ٥٤ ق، مجموعة المكتب الفني، الجزء الأول، قاعدة رقم ١٣٥ . وانظر أيضا، نقض مدني، الصادر بتاريخ ١٩٩٠/٢/٥ ، مجلة القضاء، لسنة ٢٥ ، ص ٤٤٥ .

(٤) انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بتاريخ ١٩٧٤/٦/٢٩ في القضية رقم ١٠ لسنة ٤ ق، المجموعة ص ١١١ . وفي حكم آخر لها، تقرر انه: «.....يتعين لا اعتبار العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة لروابط القانون الخاص » انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٩٨٠/١/١٩ ، في القضية رقم ٧ ، لسنة ١٠ ق، المجموعة الجزء الأول، ص ٢٤٤ . وكذلك حكمها الصادر بتاريخ ١٩٩١/١/٥ ، المجموعة ، الجزء الرابع، رقم ٢٦ ، ص ٥٣٦ .

ويتضح من الأحكام السابقة وما استقر عليه الفقه أن العقد الإداري يقوم على ثلاث

أسس:

١. أن تكون الإدارة طرفاً في العقد (المطلب الأول).
٢. أن يتصل العقد بمرفق عام (المطلب الثاني).
٣. أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص وذلك بإتباع أساليب القانون العام (المطلب الثالث).

المطلب الأول

أن تكون الإدارة طرفاً في العقد

لكي يوجد العقد الإداري، يجب أن يكون أحد أطرافه على الأقل شخص من أشخاص القانون العام. فمن غير المتصور إطلاق وصف العقد الإداري على العقد المبرم بين فردين عاديين أو شخصين من أشخاص القانون الخاص، حتى لو كان أحدهما مكلف بمهمة عامة^(١). وضرورة تواجد الإدارة كطرف في العقد أمر يبرره أن قواعد القانون الإداري إنما وجدت لتحكم نشاط الإدارة، ولذلك فإن العقد الذي يبرم بين الأفراد أو الهيئات الخاصة لا يعد عقداً إدارياً^(٢).

وعلى الرغم من الوضوح الظاهري لهذا الشرط، إلا أنه يواجه بعض الصعوبات

التي تحتاج إلى إيضاحات:

أولاً: ما المقصود باصطلاح الإدارة:

أن مفهوم الإدارة التي يستلزم أن تكون طرفاً في العقد الإداري يشمل أشخاص القانون العام المستقر على أنهم من الأشخاص المعنوية العامة وهي إما أشخاصاً إقليمية أي

(١) انظر:

- MOYRAND, L'essentiel sur le droit administratif, op.cit., p.49.
- L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op.cit., p.103.
- T.C. 3 mars 1969, Soc. Interlait, A.J.D.A., concl. KAHN, note Laubadère, 1969, p.307.
- T.C. 17 janvier 1972, S.N.C.F. c/ Entreprise Solon, Concl. BRAIBANT, R.D.P., 1972, p.465.
- C. E. 21 juillet 1970, LACHAUD, Rec.509; C. E. 24 mai 1974, Soc. P. MILLET, Rec. 310, s.

(٢) انظر: المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١٥٥٨، لسنة ٧ق، الصادر في ١٩٦٤/٣/٧.

تحدد علي أساس إقليمي كالدولة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء^(١)، أو أشخاصا مرفقيه تحدد علي أساس ممارسة نوع معين من النشاط كالمؤسسات والهيئات العامة. وكذلك الأشخاص الاعتبارية التي يعترف لها القانون أو القضاء بالصفة العامة أو ببعض امتيازات السلطة العامة. فقد استقر القضاء الإداري المصري علي اعتبار النقابات المهنية المختلفة كنقابة الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها من النقابات^(٢) من قبيل أشخاص القانون العام وعلي هذا أيضا استقر القضاء الإداري الفرنسي، منذ حكمة في قضيتي **Monpeurt et Bouguen**^(٣) واعترافه بان العقود التي تبرمها النقابات المهنية تعد من قبيل العقود الإدارية. كما منح مجلس الدولة المصري لبعض الجماعات الدينية كبطر كخانة الأقباط الأرثوذكس^(٤)، والمجلس الصوفي الأعلى^(٥)، وكنائس نهضة القداسة^(٦) الشخصية المعنوية العامة. ومن ثم فان العقود التي تبرمها هذه الجماعات تعتبر عقودا إدارية إذا ما استوفت باقي الشروط.

ثانيا: الوقت الذي تتوافر فيه الصفة الإدارية:

الأصل أن العبرة في تحديد صفة الشخص المعنوي هو وقت إبرام العقد، فإذا كان في هذا الوقت يتمتع بالشخصية المعنوية العامة فان العقد الذي يبرمه يظل إداريا - إذا استوفى باقي الشروط - حتى ولو تحول بعد ذلك إلى شخص من أشخاص القانون الخاص 2024/2025

(١) انظر نص المادة ٦١ من الدستور المصري الدائم لسنة ١٩٧١ والتي تنص علي أن: « تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة ذلك ». وبناء علي ذلك استخدم المشرع التفويض المخول له دستوريا، فأضاف وحدتين جديدتين هما المراكز والأحياء بمقتضى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ وهو ما سار عليه قانون نظام الإدارة المحلية الحالي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ إذ نص في مادته الأولى علي أن: « وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية..... ».

(٢) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١٥١٣، لسنة ٢٨ق، الصادر في ١١/٦/١٩٨٣ المجموعة، ص ٧٩٠.

(٣) انظر:

• C.E. 31juillet 1942, Monpeurt, Rec., p. 239.

(٤) انظر:

• C.E. 1 April 1943, Bouguen, Rec., p.18.

(٥) محكمة القضاء الإداري، في حكمها الصادر في ٦/٤/١٩٥٤، لسنة ٨ق، المجموعة ص ١١٧١.

(٦) محكمة القضاء الإداري، في حكمها الصادر في ١٧/١١/١٩٥٤، لسنة ٩ ق، المجموعة ص ٣١.

(٧) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن الصادر في ٢٠/١٢/١٩٨٠، لسنة ٢٦ق، المجموعة، ص ١٧٥.

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا المفهوم في حكمها الصادر في ١٩٦٩/٣/١٦، بمناسبة عقد كانت قد أبرمته مؤسسة الأبنية العامة . وهي شخص من أشخاص القانون العام . ثم تحولت فيما بعد إلى شخص من أشخاص القانون الخاص. فقد اعتبرت المحكمة أن العقد إداري تأسيسا علي صفة المؤسسة وقت إبرام العقد، بصرف النظر عن صفتها وقت النزاع^(١).

إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد خالفت هذا الأصل ورأت أن تحول الجهة الإدارية من شخص من أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص وقت إقامة الدعوى يؤدي إلى فقدان العقد لأحد الشروط التي تسبغ عليه الصفة الإدارية، ويتحول بالتالي إلى عقد مدني. وهذا واضح في حكمها الصادر في ١٩٩٤/١/١٨ حيث تقول: «... من حيث انه وإن كان العقد محل النزاع المائل قد نشأ في الأصل إداريا وتوافرت له مقومات العقود الإدارية باعتبار أن المتعاقد مع الطاعن كان شخصا من أشخاص القانون العام وهي مصلحة المناجم والمحاجر، وأن العقد لذلك تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إلا انه وقد أصبح المتعاقد مع الطاعن وقت إقامة الدعوى هي شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وهي من أشخاص القانون الخاص بلا خلاف فان العقد وقت رفع الدعوى يكون قد غدا مفتقدا لأحد العناصر الأساسية للعقود الإدارية»^(٢).

2024/2025

وأكدت المحكمة الإدارية العليا ذات المبدأ في حكم آخر إذ تقرر: «...وبناء علي ذلك، إذا فقد العقد شرطا من الشروط التي يتحقق بتوافرها منط العقد الإداري، صار العقد من عقود القانون الخاص، وذلك كأن تفقد الإدارة صفتها كشخص معنوي عام أو.....»^(٣).

ولا شك أن اتجاه المحكمة الإدارية العليا هو اتجاه سليم فكما هو معلوم أن إسباغ الصفة الإدارية للعقد يؤدي إلى ميزة هامة لجهة الإدارة وهي خضوع العقد لقواعد القانون العام بما يتضمنه من قواعد تعلق من شأن جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وكذلك اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناجمة عنه. وهذه الميزة إنما أعطيت

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ٢٨٧، لسنة ١٨ق، الصادر في ١٩٦٩/٣/١٦.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٣٨٦، لسنة ٣٣ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١/١٨، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء ٤٩، ص ٤٦.

(٣) لمحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٥٤، لسنة ٣٤ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٧/١/٢، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء ٤٩، ص ٥٤.

لجهة الإدارة لتحقيق الصالح العام باعتبارها " سلطة عامة " أو شخص من أشخاص القانون العام. فإذا فقدت الإدارة هذه الصفة وتحولت إلى شخص من أشخاص القانون الخاص كان من المنطقي والطبيعي أن يعاد التوازن بين أطراف العقد فيطبق عليه أحكام القانون الخاص ويتحول بالتالي لعقد مدني.

ثالثاً: هل يكفي أن تكون الإدارة طرفاً في العقد ليكتسب الصفة الإدارية:

مما لا شك فيه أن العقد المبرم بواسطة الإدارة لا تكون له الصفة الإدارية إلا إذا أبرمته الإدارة بوصفها سلطة عامة. أما إذا تنازلت الإدارة عن سلطتها العامة وأبرمت عقودها كشخص من أشخاص القانون الخاص فإن تلك العقود تكون عقوداً مدنية وتخضع لأحكام القانون الخاص، ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناجمة عنها.

وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري المصري حيث أعلنت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢١ فبراير ١٩٨٧ أن تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاليد مبان ليس بوصفها سلطة عامة إنما باعتبارها ناطرة علي وقف أي كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص، فإن العقد المبرم بينهما لا يعد عقداً إدارياً حيث تخلف شرط أن يكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام^(١). وكذلك حكمها الصادر بتاريخ ١٩٩٥/١/٨ الذي تقرره فيه أن ما يميز العقد الإداري عن العقد المدني المبرمين بواسطة جهة الإدارة أن العقد الإداري تبرمه الإدارة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلاً المتعاقد معها وذلك بقصد تحقيق نفع عام^(٢).

رابعاً: هل يكفي تدخل الإدارة في عقد من العقود بين الأفراد اعتبار هذا العقد عقداً إدارياً:

تدخل جهة الإدارة في عقد مبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص لا يمكن أن يحوله إلى عقد من عقود القانون العام بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانت الإدارة تستهدف من ذلك تحقيق نفع عام. وهذا ما أكدته مجلس الدولة الفرنسي في قضية " Sté. Boulanger " حيث تدخلت جهة الإدارة في النزاع وقامت بالتوقيع علي عقد التصالح بين صاحب المصنع وعمالة، وبالرغم من هذا التوقيع فإن المجلس لم يضيف علي

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن الصادر في ١٩٨٧/٢/٢١، لسنة ٣٢ ق، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، الجزء الأول، ص ٨٥٣.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٣٨٣، لسنة ٣٥ ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٥/١/١٨، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء ٤٩، ص ٦٠.



- C.E.18 décembre 1936, Prade, S.1938.3.59, not Alibert.

والوكالة قد تكون ظاهرة جلية تنص عليها نصوص العقد، وقد تكون ضمنية تستخلص من صياغة بنود العقد وظروف تنفيذه^(١). وقد ينص عليها المشرع صراحة، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من تطبيقها دون هذا النص التشريعي^(٢).

ومن أمثلة النصوص التشريعية في فرنسا والتي تسمح بمثل هذه الوكالة المادة ٣٢١ من القانون الخاص بتنظيم المدن والتي تنص علي أن: « الدولة والوحدات المحلية والمؤسسات العامة يمكن أن تعهد لأجهزة خاصة بالتنظيم والإعداد بالقيام باسمها ولحسابها بمشتريات أو أعمال »^(٣). وكذلك المادة ٤٣٢ من قانون التأمينات التي تعطي لشركة التأمين الخاصة " *La COFACE* " مهمة التأمين - لصالح الدولة وتحت رقابتها - ضد مخاطر التجارة الدولية^(٤).

كما أن الوكالة قد تتم أيضا عن طريق اتفاق بين الدولة والشخص الخاص، وهذا الاتفاق يتم عادة في إطار عقد إداري^(٥). ومن أحكام القضاء الإداري الفرنسي في هذا الصدد، حكم مجلس الدولة الصادر في ١٩٥٧/٥/٢٧ وكانت القضية تتعلق بالتجمع الوطني لمنتجات الألبان، والذي كان مكلفا بواسطة اتفاقية ١٩٤٩ مع المفوضية العليا للتموين بعقد العقود باسم الدولة^(٦). وكذلك حكم المجلس في ١٩٧٦/٦/١٨ والمتعلق

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) انظر: د. مصطفى عبد المقصود سليم، الوكالة في إبرام العقد الإداري، دار النهضة العربية، ١٩٩٥، ص ٣٨.

(٢) انظر:

• L. RICHER, Droits des contrats administratifs, op.cit., p. 106.

(٣) انظر:

• L'article R. 321-20 du Code de l'urbanisme prévoit que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent confier à des organismes aménageurs le soin de procéder " en leur nom et pour leur compte " à des acquisitions et travaux.

(٤) انظر:

• V. L'article R. 432-1 du Code des assurances. Et V. aussi la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage public.

(٥) انظر:

• V. par ex. : C.A.A. Paris 7 juillet 1992, S.A. La Campinoise d'H.L.M., Rec., 562: Le contrat de mandat est administratif dès lors qu'il est lié à l'aménagement d'une zone urbaine et renvoie à un cahier des charges.

(٦) انظر:

• C. E. 27 mai 1957, Artaud, Rec., p. 350 .

بالمصرف العقاري والذي عهدت إليه اتفاقية ٥ مايو لسنة ١٩٥٨ بالموافقة علي القروض للمرحلين إلى بلادهم وذلك لحساب الدولة^(١).

وتوجد تطبيقات كثيرة لفكرة الوكالة في القضاء الإداري المصري التي واستقر من خلالها إلى اعتبار العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص عقدا إداريا إذا كان أحد أطرافه يتعاقد باسم ولحساب شخص من أشخاص القانون العام^(٢). ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ٢١ يونيو سنة ١٩٨٠ حيث قضت بأن الترخيص الصادر من شركة المعمورة للإسكان - وهي من أشخاص القانون الخاص - بالانتفاع بكازينو في منطقة شاطئ المعمورة الذي عد من المنافع العامة والمقصود حق استغلاله علي الشركة يعتبر قد صدر عنها باعتبارها نائبة عن الدولة في إدارة واستغلال مرفق الشاطئ، حيث أكدت: « ومن حيث أن الكازينو محل المنازعة مقام في منطقة الشاطئ المعترية من المنافع العامة والمقصود حق استغلالها علي الشركة الطاعنة، ومن ثم يكون التصريح للمطعون ضده بالانتفاع بالكازينو المذكور قد تم من الشركة الطاعنة بوصفها نائبة تتوافر في هذا التصريح مقومات العقد الإداري باعتباره صادرا من جهة نائبة عن الدولة ولكونه متصلا بنشاط مرفق الشاطئ، ولأنه قد تضمن شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص^(٣) ».

2024/2025

2024/2025

المطلب الثاني

اتصال العقد بنشاط مرفق عام

رأينا فيما سبق أن وجود الشخص المعنوي العام كطرف في العقد يعتبر شرطا أساسيا لإضفاء الصفة الإدارية علي العقد، وقد نظر إلى هذا الشرط باعتباره يمثل معيارا عضويا أو شكليا لأنه يستند إلى صفة أطراف العقد لتمييز العقد الإداري عن العقد المدني. وهذا الشرط وإن كان ضروريا إلا أنه غير كاف، فكما رأينا أن الإدارة لها حرية اختيار أسلوب التعامل مع الأفراد واختيار النظام القانوني الذي يحكم تصرفاتها القانونية. فهي

(١) انظر:

- C. E. Sect. 18 juin 1976, Claude, A.J.D.A. 1976, p. 579.

(٢) انظر علي سبيل المثال: حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢٤/٤/١٩٥٦، لسنة ١٩٥٦، المجموعة، ص ٣٠٧. حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم ١٥٥٨، لسنة ٩٩، الصادر في ٣/٧/١٩٦٤، الموسوعة الإدارية الحديثة ج ١٣، ص ٦٨٦.

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢١/٦/١٩٨٠، مشار إليه لدي د. محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، الإسكندرية، ١٩٨٩، هامش ص ٢٩١.

تستطيع أن تلجأ إلى أسلوب القانون العام أو أسلوب القانون الخاص . بحسب الأحوال . ولهذا لا يجدي مجرد وجود الإدارة كطرف في العقد لمنحة الصفة الإدارية وإخضاعه بالتالي لقواعد القانون العام واختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناجمة عنه . ولهذا لجأ القضاء إلى المعيار الموضوعي . أي الذي يستند إلى موضوع العقد ذاته . ليحدد طبيعة العقد، واستند في ذلك إلى فكرة المرفق العام الذي يدور العقد حوله ويبرم لخدمته، وهذا هو الشرط الثاني لمنح العقد الصفة الإدارية والذي يتعين من خلاله اتصال العقد بنشاط مرفق عام.

وتحتل فكرة المرفق العام مكانة هامة في القانون الإداري، بل إنها كانت الفكرة الأساسية التي قامت عليها أحكام القانون الإداري، فمما لاشك فيه أن مقتضيات سير المرافق العامة هي التي تبرر تلك القواعد المتميزة في القانون الإداري والتي تخرج عن المألوف في قواعد القانون الخاص^(١).

ويرجع الفضل إلى مجلس الدولة الفرنسي وكذلك محكمة التنازع في نشأة نظرية المرفق العام. حيث اخذ مجلس الدولة الفرنسي بفكرة المرفق العام كمعيار لاختصاص القضاء الإداري لأول مرة في حكم روتشيلد « **Routchild** » سنة ١٨٥٥ وديكستير « **Dekeister** » ١٨٦١. وبعد حكم بلانكو « **Blanko** » لمحكمة التنازع الفرنسية هو 2024/2025 الأساس الذي بني عليه الفقه نظرية المرفق العام وأعطوا لها هذا الدور الهام في القانون العام عن طريق ما عرف بمدرسة المرفق العام^(٢).

إلا أن أول تطبيق لنظرية المرفق العام في مجال العقود الإدارية ظهر في حكم مجلس الدولة مع بداية القرن العشرين في قضية تربييه « **Terrier** » سنة ١٩٠٣ فقد أوضح مفوض الدولة « **Romieu** » في تقريره أن: « اختصاص القضاء الإداري يتناول كل ما يتعلق بتنظيم وسير المرافق العامة قومية أو محلية سواء أكانت وسيلة الإدارة في ذلك عملا من أعمال السلطة أو تصرفا عاديا. فالعقود التي تبرمها الإدارة بهذا الخصوص هي أعمال إدارية بطبيعتها، وبالتالي يجب أن يختص القضاء الإداري بالفصل في كل ما ينجم

(١) انظر: د. عزيزة الشريف، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩.

(٢) وضع أساس نظرية المرفق العام العميد **Duguít** واخذ بمذهبه العديد من الفقهاء منهم جيز **Jèze** وبونارد **Bonard** . الدولة في نظر أنصار مدرسة المرفق العام تسعى إلى تحقيق هدف معين هو أداء المرافق العامة وتستخدم سلطتها العامة لتحقيق هذا الهدف.

عنها من منازعات»^(١). وقد توالى الأحكام التي تستخدم فكرة المرفق العام كمعيار لتمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية^(٢).

والمرفق العام وفقا لتعريف محكمة القضاء الإداري هو: « كل مشروع تنشئة الدولة أو تشرف علي إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها لا بقصد الربح، بل بقصد المساهمة في صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة والصفات المميزة للمرفق العام هي أن يكون المشروع من المشرعات ذات النفع العام، أي أن يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة.... كما أن التطور الحديث في الفقه والقضاء يعترف بصفة المرفق العام للمرفق الصناعي والتجاري مع انه يعمل لتحقيق الربح ولكن الواقع من الأمر أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المرافق ليس تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة أسوة بكل المرافق الأخرى، وما الربح الذي يحققه إلا أثرا من الآثار المترتبة علي صفة المرفق باعتباره يقوم بأعمال صناعية أو تجارية»^(٣).

كما أن المحكمة الإدارية العليا قد تبنت ذات الاتجاه بالنسبة للمشروعات الجديدة، والتي قررت إضفاء صفة المرافق العامة عليها. ومن ذلك علي سبيل المثال حكمها الصادر في ١٢ أبريل ١٩٥٨ والذي تقول فيه: « أن تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة هي مرافق عامة، مما يدخل أصلا في صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة علي المصالح^{2024/2025} والمرافق العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم، لانهم اقدر عليه، مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة، يستعينون به علي تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للمصالح العام، فان ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة»^(٤). وأيضا في حكمها الصادر في ١٩٦١/٥/٢٠ الذي تؤكد فيه: « لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذي نفع عام لتنمية الإنتاج الاقتصادي في البلاد، فهي بهذا تعتبر مرفقا عاما، تديره الدولة عن طريق نظام خاص...»^(٥).

(١) انظر:

- C. E. 4 février 1904, TERRIER, Rec. P. 94 Concl. ROMIEU.

(٢) انظر علي سبيل المثال:

- C. E. 4 mars 1910, THEROND, Rec. P. 193, Concl. PICHAT.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم ٣٤٨٠، لسنة ٩ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٥/٦/٢.

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ ١٩٥٨/٤/١٢، المجموعة، س٣، ص١١٠٣.

(٥) حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ ١٩٦١/٥/٢٠، المجموعة، س٦، ص١١٥٤.

ولقد ذهب الأستاذ بيكينو " **Pequignot** " إلى أن عبارة مرفق عام يمكن استعمالها في عدة معان مختلفة فما يتعلق بموضوع العقد^(١):

- فقد يقال أن العقد قد ابرم بين أحد الأفراد ومرفق عام، ومفهوم المرفق العام هنا مرادف لكلمة « إدارة »، وعلي ذلك فالعبارة ذات معنى عضوي.
 - وقد يقال أيضا أن العقد كان له "هدف مرفق عام"، فان مثل هذا العقد يرمي إلى إشباع حاجة عامة إلى درجة أن الهدف الذي ترمي إليه العقود يكيف بأنه مرفق عام، والعبارة هنا ذات معنى غائي أي متعلق بغاية العقد.
 - وأحيانا أخرى، فان العقد يحدد طريقة لسير العمل في المرفق العام، بان موضوعه مساهمة أحد الأفراد في تنفيذ مرفق عام، وذلك بقيامه بتقديم أداءات ووضعها تحت تصرف المنتفعين بخدمات المرفق ومن ثم فالعبارة تتخذ معنى ديناميكية أو وظيفية.
 - وأخيراً يقال أن العقد خاضع لقواعد المرفق العام، وحينئذ فان عبارة المرفق تدل علي نظام قانوني معين. وفي هذا المعنى نتكلم عن المرفق العام بالمعنى المادي.
- وينتهي الأستاذ « بيكينو » **Pequignot** " إلى القول أن حول المعنى العضوي والمادي يدور دائما تعريف المرفق العام.

وقد تعرض معيار المرفق العام للنقد خاصة مع ظهور فكرة البنود غير المألوفة 2024/2025
كمعيار مميز لعقود الإدارة، حتى أن بعض الأحكام كانت لا تكتفي بشرط اتصال العقد بالمرفق العام حتى يمكن اعتباره عقدا إداريا، ومن ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١١ نوفمبر سنة ١٩١٠ والذي قرر فيه: « أن العقد المبرم بين الإدارة وإحدى المطابع والمتصل بمرفق التعليم لا يعتبر عقدا إداريا لأنه ابرم بالشروط المألوفة في العقود المدنية ولم يتضمن شروطا استثنائية تختلف عن الشروط العادية التي ترد في عقود القانون الخاص »^(٢). وأكد المجلس هذا الاتجاه في حكم شركة الجرانيت **Société des granits porphyroïdes des Vosges** الصادر في ٣١ يوليو سنة ١٩١٢ والذي

(١) انظر:

- G. PEQUIGNOT, Les contrats de l'administration, J.C.A., fasc. 500, 1962, p.17.

مشار إليه لدى د. عمرو احمد حسبو، التطور الحديث عقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام ال B.O.T.، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ٢٠٠٢، ص ص ٤٠-٤١.

(٢) انظر:

- C.E, 11 novembre 1910, D. 1912, p.143.

أخذ فيه المجلس باقتراحات المفوض ليون بلوم " Léon Blum " ليس فقط فيما يتعلق بموضوع أو هدف العقد ولكن أيضا بمحتواه والذي قال فيه انه لمعرفة ما إذا كان هناك عقد إداري فانه يجب البحث عما إذا كان العقد يحتوي علي شروط خاصة أو إذا كان من شأنه أن يجعل المتعاقد يشارك إيجابيا بنشاط في مرفق الطرق^(١).

واستمر هذا الوضع حتى صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي الشهير الصادر في ١٩٥٦/٤/٢٠ في قضية الزوجين برتان « Epoux Bertin » وكانت القضية تتعلق بعقد تم إبرامه بين الزوجين برتان والإدارة لاستقبال واستضافة الرعايا السوفييت في الأراضي فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية حتى عودتهم إلى أوطانهم. وقد اعتبر المجلس أن هذا العقد ذو طبيعة إدارية . وذلك طبقا لطلبات المفوض لونغ " Long " . وذلك علي أساس أن العقد المذكور يعهد إلى أصحاب الشأن بالتنفيذ ذاته لمرفق عام وأن هذا الشرط وحدة يعد كافيا لإسباغ الصفة الإدارية علي العقد، دون البحث فيما إذا كان يتضمن شروطا استثنائية^(٢). وبالرغم من ذلك، لحق بهذا الحكم حكم آخر لمجلس الدولة في ١١ مايو سنة ١٩٥٦ في قضية جوندران " Gondrand " أكد فيه الصفة المدنية للعقد المبرم بين الإدارة وبين المتعاقدين والخاص بنقل وتخليص البضائع، حيث ارتكز المجلس لإنكار صفة العقد الإداري علي أن العقد لم يتضمن أي شروط غير مألوفة في القانون الخاص^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويشترط القضاء الفرنسي حتى يمكن تكييف العقد بأنه عقد إداري وفقا لمعيار المرفق العام . أن يكون اتصاله بالمرفق اتصالا وثيقا . واتصال العقد بالمرفق العام قد يكون في شكل أن يعهد للمتعاقد بمهمة تنفيذ أو تسيير المرفق العام منفردا، أو في شكل اشتراك المتعاقد مع جهة الإدارة في تسيير المرفق العام أو في شكل التنفيذ ذاته للمرفق العام^(٤).

(١) انظر:

- C.E. 31 juillet 1912, R.D.P., 1914, p. 145.

(٢) أنظر:

- C.E. 20 avril 1956, Epoux Bertin, D., 1956, Note De laubadère.
- R.D.P., 1956, p.869, concl.,Long, Note Waline.

(٣) انظر:

- C.E. 11 mai 1956, Gandrand, R.D.P.,1957, p.107.

(٤) انظر:

- DE LAUBADERE, Traité de Droit administratif, 11^{éd}, L.G.D.J., 1990.

مشار إليه أيضا لدي د. جو رجي شفيق ساري، تطور طرق ومعيار تمييز مرجع سبق ذكره، ص ٤٧.



أما القضاء الإداري المصري فإنه يشترط اتصال العقد بالمرفق العام بأي صورة من الصور ودون اشتراط شرط الاتصال الوثيق. وذلك يرجع إلى أن القضاء الإداري المصري لا يكتفي بمعيار المرفق العام - كمعيار كافي بذاته لتمييز العقد الإداري مثل القضاء الفرنسي - وإنما يشترط إلى جانبه معيار الشروط غير المألوفة. وفي هذا المعنى تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٩ ديسمبر ١٩٥٦ والذي جاء فيه: «.... غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام . وإن كان شرطاً لازماً . فإنها ليست مع ذلك كافية فلم يعد المرفق العام وحدة هو المعيار القاطع في التمييز الدقيق بين العقود الإدارية بمعناها القانوني الصحيح التي تبرمها جهة الإدارة وبين تلك العقود المدنية التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة..... العبرة إذن بما تأخذ به جهة الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام يأخذ الطابع المميز للعقد الإداري وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى شروط العقود الخاصة بين الأفراد»^(١).

وأكدت ذلك في حكمها الصادر في ٢٣ أكتوبر ١٩٦٠ الذي تقول فيه: « إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص..... المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من العقود الأخرى ليس هو صفة المتعاقد بل هو من جهة الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة وكذلك من ناحية موضوع العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام علي أية صورة من الصور »^(٢).

وهو الأمر الذي أكدته المحكمة الإدارية العليا في قضائها دون انقطاع، ومن ذلك حكمها الصادر في ٣١ مارس ١٩٦٢ وجاء فيه: « أن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري بحسب ولايته المحددة »^(٣). وكذلك حكمها الصادر في ٢٤ يناير ١٩٩٥ والذي

(١) محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٨٧٠، لسنة ٥ق، بتاريخ ١٢/٩/١٩٥٦.

(٢) محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٥٦٧، لسنة ١٣ق، بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٦٠.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٨٨٩، لسنة ٦ق، الصادر في ٣١/٣/١٩٦٢، الطعن رقم ٣٥٦٥،

لسنة ٣٣ق، الصادر بتاريخ ٢/٢/١٩٩٣، الطعن رقم ٣٧٠٣، لسنة ٣٣ق، الصادر في ٩/٢/١٩٩٣

وأيضاً الطعن رقم ٢٣٨١، لسنة ٣٤ق، الصادر في ١٦/٥/١٩٩٣.





تقول فيه: «ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وأنه من المسلم به في فقه القانون الإداري أن اختيار جهة الإدارة لوسائل القانون العام هو الشرط الفاصل في تمييز العقود الإدارية، ذلك أن اتصال العقد الذي تبرمه الإدارة بالمرفق العام إذا كان شرطاً لازماً لكي يصبح العقد إدارياً، فإنه لا يكفي بذاته لكي يضيف علي العقد تلك الصفة.....»^(١).

ويأخذ اتصال العقد الإداري بالمرفق العام صوراً عدة وإن كانت تدور في مجملها حول إنشاء المرفق وتسيير نشاطه، فقد يكون الهدف من إبرام العقد إنشاء مرفق عام كما هو الحال في عقد الأشغال العامة، كما قد يأخذ اتصال العقد الإداري بالمرفق صورة أخرى تتمثل في المساهمة في إدارته كما هو الحال في عقد الالتزام، والتي يشارك فيها المتعاقد مع الإدارة في إدارة المرفق، كما قد يتعلق العقد بتسيير المرفق العام كما هو الحال في عقد التوريد والتي يتعهد فيها المتعاقد مع الإدارة بتوريد أصناف معينة تحتاجها الإدارة في تسيير نشاط المرفق العام^(٢).

وفي حالة انقطاع الصلة فيما بين العقد والمرفق العام، فإن العقد يفقد صفته الإدارية ويتحول إلى عقد من عقود القانون الخاص، حتى ولو كان أحد أطرافه شخصاً عاماً، وتطبيقاً لذلك يخرج عن نطاق العقود الإدارية تأجير الإدارة لقطعة أرض من أملاكها الخاصة لأحد الأفراد لإقامة مصنع خاص عليها^(٣)، وكذلك بيعها لثمار حديقة تملكها حيث أن الصلة منقطعة بين هذه التصرفات والمرفق العام، فالإدارة تتصرف هنا في إطار استغلال الدومين الخاص لها ملكية خاصة شأنها في ذلك شأن تصرف الأفراد في أموالهم^(٤).

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣١٢٨، لسنة ٣٥ق، الصادر في ١٩٩٥/١/٢٤.

(٢) انظر: د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، ٢٠٠٤، منشأة المعارف، ص ٣٠.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٢٢٣، لسنة ١٤ق، الصادر في ١٩٦٠/٣/٢٢.

(٤) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٨٧٠، لسنة ٥ق، الصادر في ١٩٥٦/١٢/٩.



المطلب الثالث تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص

رأينا أن وجود الإدارة كطرف في العقد، واتصال هذا العقد بمرفق عام شرطان ضروريان لتمييز العقد الإداري، إلا انهما غير كافيين لإضفاء الطبيعة الإدارية علي العقد. ولذلك يعتبر الشرط الثالث المتعلق باستخدام الإدارة لوسائل وامتيازات القانون العام هو الشرط الحاسم في تمييز العقود الإدارية. ويظهر هذا الشرط في احتواء العقد لشروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص. وهذا الشرط يكاد يكون مستقرا في أحكام القضاء المصري علي اختلاف أنواعه^(١). وفيما يتعلق بالقضاء الإداري الفرنسي فقد اخذ بمعيار الشروط الاستثنائية غير المألوفة لتمييز العقد الإداري عن عقود القانون الخاص، ومن أوائل الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي وذكر فيها فكرة الشروط غير المألوفة حكمه الصادر في ١١/١١/١٩١٠ والذي قرر فيه: « أن العقد المبرم بين الإدارة وإحدى المطابع والمتصل بمرفق التعليم لا يعتبر عقدا إداريا لأنه ابرم بالشروط المألوفة في العقود المدنية ولم يتضمن شروطا استثنائية تختلف عن الشروط العادية التي ترد في عقود القانون الخاص^(٢)».

2024/2025

2024/2025

كما أكد المجلس هذا الاتجاه في حكم شركة الجرانيت "Société des granits porphyroïdes des Vosges" - السابق الإشارة إليه - والصادر في ٣١/٧/١٩١٢ ويعد هذا الحكم الظهور الحقيقي لهذا المعيار وأن لم يذكر صراحة تعبير الشروط غير

(١) انظر علي سبيل المثال:

- حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٢٢٣، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٦/١٢/١٩٥٦.
- وأيضا حكمها في القضية رقم ١٨٩٤، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٠/٣/١٩٥٧.
- المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦٢، لسنة ٢ ق، الصادر بتاريخ ١٣/٥/١٩٦١. وأيضا في الطعن رقم ١٥٧١، لسنة ٤١ ق عليا، الصادر بتاريخ ٢٥/٢/١٩٩٧، الموسوعة، ج ٤٩، ص ٦٣.
- حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ١١/١١/١٩٦٥، س ١٦ ق، ص ١٠٤٨. وحكمها الصادر بتاريخ ٧/٧/١٩٦٤، س ١٤ ق، ص ٩٥٦.
- المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ٧، لسنة ٧ ق، الصادرة بتاريخ ١٩/١/١٩٨٠، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ص ٢٤٤.

(٢) انظر:

- C.E, 11 novembre 1910, D. 1912, p.143.



المألوفة^(١) فقد اعتبر المفوض ليون بلوم " Léon Blum " أن المعيار المميز للعقد الإداري هو اتصاله بمرفق عام وتضمنه شروطا غير مألوفة حيث قال: « لكي يكون القاضي الإداري مختصا لا يكفي أن يكون التوريد موضوع العقد يستخدم لمرفق عام بل يجب أن يكون العقد بطبيعته الذاتية من العقود التي يستطيع إبرامها شخص عام وحده وأن يكون قد تأثر بالمرفق العام الذي أبرم من أجله وبالقواعد التي تحكم ذلك المرفق »^(٢). وقد اخذ المجلس بالاعتراحات الواردة في تقرير المفوض. ثم توالى الأحكام التي صدرت في هذا الاتجاه^(٣).

وفيما يلي نوضح ماهية الشروط غير المألوفة، صورها، والأثر المترتب علي خلو العقد منها.

أولاً : ماهية الشروط غير المألوفة:

بالرغم من أن الفقه والقضاء - سواء في فرنسا أو في مصر - يجمع علي ضرورة احتواء العقد عي شروط استثنائية وغير مألوفة لكي يكتسب الصفة الإدارية. إلا أنهم لم يجمعوا علي تعريف محدد لهذه الشروط يمكن من خلاله تحديد اعتبار الشروط خارجة علي المألوف في القانون الخاص. ويرجع ذلك أن القضاء الإداري الفرنسي قليلاً ما يضع تعريفاً للشروط غير المألوفة، فهو يكتفي عادةً بأن يعلن مبدأ اشتغال العقد علي شروط غير مألوفة^{2024/2025} دون شرح لهذه الشروط ومن ثم يعتبر العقد إدارياً^(٤).

وعلي الرغم من ذلك فإننا نستطيع أن نجد بعض الأحكام التي تضع تعريف للشروط غير المألوفة. ومن ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية " Stien " ، الصادر في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٠ حيث يعرفها بأنها: « تلك التي تمنح أحد الطرفين المتعاقدين حقاً أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها

(١) انظر:

- L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p.79.

(٢) انظر:

- C.E. 31 juillet 1912, R.D.P., 1914, p. 145.

(٣) انظر علي سبيل المثال:

- C.E. 23,mars 1923, Commission des Chargeurs réunis, Rec., p.307.
- C.E. 7 août 1925, Gouverneur de l'Indochine, Rec., p.823.

(٤) في نفس المعني راجع: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص٧٩.



من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري»^(١). وكذلك حكم محكمة التنازع الفرنسية الصادر في ١٩ يونيو ١٩٥٢ والذي يعرفها بأنها: «الشروط التي تختلف بطبيعتها عن تلك التي يمكن أن ينص عليها في عقد مماثل في القانون الخاص»^(٢).

وعلى العكس من موقف القضاء الإداري الفرنسي نجد القضاء الإداري المصري يأخذ في الغالب من أحكامه بالمسلك المفصل في توضيح قائمة الشروط غير المألوفة التي أنطوي عليها التعاقد. فعلى سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٣١ مارس ١٩٦٢ فبعد أن أبرزت المحكمة أن أحد طرفي العقد شخص معنوي عام وهي الهيئة الدائمة للاستصلاح الأراضي وصله العقد بالمرفق العام، استطردت توضح قائمة الشروط غير المألوفة التي احتواها العقد. ومن هذه الشروط في نظر المحكمة في ذلك الحكم:

- أ- النص على حق الهيئة الدائمة للاستصلاح الأراضي في توقيع غرامه يومييه قدرها جنية عند الإخلال بأي شرط من شروط العقد.
- ب- النص على حق الهيئة المشار إليها المطلق في فسخ العقد إذا أخل المورد بأي شرط من الشروط.

ج- استقلال الإدارة المتعاقدة بوضع شروط العقد^(٣).

وكذلك حكمها الصادر في ٢ يناير ١٩٩٧، فبعد أن أبرزت المحكمة أن مبرم العقد 2024/2025 شخص معنوي عام وهي محافظة البحر الأحمر، وأن هذا العقد يتصل بمرفق عام وهو مرفق السياحة، استطردت توضح قائمة الشروط غير المألوفة التي انطوي عليها التعاقد. ومن هذه الشروط في نظر المحكمة في ذلك الحكم^(٤):

(١) انظر:

- C.E. 20 octobre 1950, Stien, Rec., 505.

(٢) انظر:

- T. C. 19 juin 1952, Ste. Des combustibles et carburants, Rec., p.628.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٨٨٩، لسنة ٦٠ ق، الصادر في ١٣/٣/١٩٦٢.

(٤) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٥٤، لسنة ٣٤ ق، الصادر في ١/٢/١٩٩٧.

* انظر كذلك ما سبق الإشارة إليه من أحكام:

- حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٢٢٣، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٦/١٢/١٩٥٦. وحكمها في القضية رقم ١٨٩٤، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٠/٣/١٩٥٧.
- لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦٢، لسنة ٢٠ ق، الصادر بتاريخ ١٣/٥/١٩٦١. حكمها في الطعن رقم ١٥٧١، لسنة ٤١ ق، الصادر بتاريخ ٢٥/٢/١٩٩٧، الموسوعة، ج ٤٩، ص ٦٣.



- R. Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, Thèse, Paris, 1957, p. 128.

ويري الأستاذ " G. Vedel " أن الشروط الاستثنائية هي: « شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ويكون موضعها منح المتعاقدين أو تحميلهم بالتزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي يستطيع المتعاقدين الاتفاق عليها »^(١). ويرجح من الفقه المصري الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي هذا الاتجاه مؤكداً أن العديد من الشروط التي تدرج في العقود المدنية دون أن تجعلها باطلة ولذلك فإنها شروط غير معتاد النص عليها في عقود القانون الخاص^(٢).

ويعرفها الأستاذ " Charles Debbasch " بأنها: « تلك التي تحمل السمة الإدارية، وتعطي الإدارة حق الرقابة الغير مألوف »^(٣).

كما يري الأستاذ " A. De Laubadère " أن الشروط الاستثنائية: « هي الشروط ذات الصلة القوية بالقانون العام، والتي تحمل طابع هذا القانون ويظهر ذلك من محتواها وهدفها »^(٤). ويرجح هذا الاتجاه من الفقه المصري الدكتور محمد سعيد حسن أمين حيث يري انه اتجاه واقعي يعبر عن حقيقة تلك الشروط التي تتمثل في الصلة الوثيقة بمبادئ القانون العام والتي من شأنها اتساع نطاق تلك الشروط لتشمل الصور التي لا تدخل في طائفة الشروط المتصلة بامتيازات السلطة العامة^(٥).

ويذهب الأستاذ الدكتور ثروت بدوي إلى وجود نوعين من الشروط الاستثنائية: النوع الأول ويتعلق بالشروط التي تحدد الطبيعة الإدارية للعقد بصفة مباشرة. وهي الشروط الاستثنائية التي تنسم بطابع السلطة العامة التي لا يمكن وجودها في عقود القانون الخاص، أما النوع الثاني: الشروط التي تحدد الطبيعة الإدارية للعقد بصفة غير مباشرة. أي التي

(١) راجع:

- G. VEDEL, Remarque sur la notion de clause exorbitante, Mél. Mestre, 1956, p. 527.

(٢) انظر: د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، طبعة ١٩٨٨، ص ٢٧٢.

(٣) راجع:

- Charles DEBBASCH, Institutions et droit administratif, T. II, Paris, P.U.F., 1987, p.163.

(٤) راجع في ذلك:

- De LAUBADERE, F. MODERNE & P. DELOVE, Traité des contrats administratifs, L.G.D.J., 2^{éd}, T.I, 1983.

(٥) راجع: د. محمد سعيد حسن أمين، الأسس العامة للالتزامات وحقوق التعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري، دراسة مقارنة، ١٩٨٤، ص ٩٥.

تكشف عن نية المتعاقدين في اتباع أحد أساليب القانون العام بشرط ألا يوجد ما يدل على عكس ذلك ولذلك فهذه الشروط ليست بمستحيلة الوجود في عقود القانون الخاص^(١). وإزاء اختلاف الفقه - سواء الفرنسي أو المصري - في وضع تعريف محدد لفكرة الشروط غير المألوفة أو الاستثنائية. لأن تعريف أي شيء يجب أن يكون جامعاً مانعاً، ومهما أحكمت التعريفات - سألقة الذكر - فإنها لن تتضمن كافة الشروط الاستثنائية التي يمكن أن يحتويها العقد وبعد بناء عليها عقداً إدارياً ونظراً لانه قد تظهر شروط غير مألوفة أخرى في المستقبل، فإننا نؤيد رأي فقهي في أن تحديد هل يعتبر الشرط استثنائياً أم لا هو مسألة موضوعية تترك لقاضي الموضوع يحددها في كل حالة على حدة مستهدياً في ذلك ببعض القرائن التي تعطي امتيازات للإدارة أو للمتعاقد^(٢).

ثانياً : صور الشروط الاستثنائية أو غير المألوفة:

رأينا أن القضاء الإداري . سواء في فرنسا أو في مصر . لم يهتم بحصر أو تحديد صور الشروط الاستثنائية أو غير المألوفة، وإنما اكتفى بتقرير احتواء العقد لها. إلا أنه من خلال دراسة أحكام مجلس الدولة الفرنسي وكذلك نظيرة المصري يمكننا تبين الملامح العامة للشروط المعتمدة . من وجهة نظر القضاء الإداري . استثنائية وغير مألوفة والتي يمكن أن يتضمنها العقد الإداري، ومن ذلك:

2024/2025

2024/2025

١. شروط لها طابع السلطة العامة:

تعد الشروط التي تحمل طابع السلطة العامة من أهم وأبرز الشروط الاستثنائية أو غير المألوفة. فالعقود الإدارية تتضمن عادة النص على بعض امتيازات السلطة العامة. هذه الامتيازات إما قد تُمنح لمصلحة جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، أو تُمنح للمتعاقد مع الإدارة في مواجهة الغير.

أ - الشروط التي تتضمن امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها:

تتمتع جهة الإدارة بامتيازات كبيرة في مجال العقود الإدارية. إذ بمقتضى هذه الامتيازات تستطيع الإدارة . بإرادتها المنفردة . أن تُحمل المتعاقد معها التزامات . بهدف تنفيذ العقد لصالحها . مما يؤدي إلى جعل موقف المتعاقدين في العقد الإداري غير متكافئ. ففي مرحلة إبرام العقد الإداري يتجلى الإخلال بقاعدة المساواة بين الإدارة والمتعاقد معها. ففي حالة إعلان الإدارة عن إجراء مناقصة أو مزيدة عامة . على سبيل المثال . فإن

(١) انظر : د. ثروت بدوي، النظرية العامة في العقود الإدارية، القاهرة، ١٩٧٦، ص ١٠٣.

(٢) انظر : د. انس جعفر، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧. وفي نفس المعنى أيضاً : د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٨٢.



وفي أثناء تنفيذ العقد تملك الإدارة سلطة تعديل التزامات المتعاقد معها سواء بالزيادة أو بالنقص، وبسلطة التدخل للأشراف على تنفيذ العقد وتملك إعطاء بعض التوجيهات والتعليمات للمتعاقد معها، وتستطيع تغيير طريقة التنفيذ، أو وقفه مؤقتاً، ولها سلطة توقيع جزاء على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزاماته تجاهها أو بشرط من شروط العقد ولها سلطة الحلول محل المتعاقد في حالة امتناعه عن تنفيذ التزامه والتنفيذ على حسابه وأخيراً فسخ العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء المتعاقد معها.

هذه الشروط تمنح للمتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير وتدخل له الحق في ممارسة بعض مظاهر السلطة التي تمارسها الإدارة عادةً وذلك حتى يستطيع تنفيذ

2024/2025

في عقود امتياز المرفق العام، قد يمنح المتعاقد مع الإدارة حق تحصيل الرسوم من المنتفعين بخدمات المرفق العام الذي يتولاه، وقد يمنح بعض سلطات البوليس أو الحق في نزع الملكية.

➤ وفي عقود الأشغال العامة قد يمنح للمقاول المتعاقد مع الإدارة سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات المملوكة ملكية خاصة، أو شغلها مؤقتاً في حالة عدم الاتفاق ودياً مع أصحابها.

هي الشروط التي لا يمكن تفسيرها إلا على ضوء نظريات القانون الإداري وقواعده والتي يقتضى تنفيذها إعمال الأحكام الخاصة بهذا القانون^(١). بمعنى آخر هي تلك الشروط

(١) انظر : احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ١٩٧٣، ص ٨٣.





التي تبدو مستوحاة من القانون العام وتحمل طابعه بناء علي مضمونها أو هدفها^(١). وهذه الشروط وإن كانت لا تتضمن أي مظهر من مظاهر السلطة للإدارة المتعاقدة إلا أنها تمثل وضعاً غير مألوف في العلاقات الفردية^(٢). ومن أمثلة هذه الشروط:

أ- الشروط التي تثير قاعدة من قواعد القانون العام:

وهي الشروط التي تردد قاعدة من قواعد النظرية العامة للعقود الإدارية وكذلك الشروط التي لا يمكن تفسيرها إلا في إطار مبادئ وقواعد القانون الإداري. ومن قبيل الشروط التي تردد قاعدة من قواعد النظرية العامة للعقود الإدارية الشروط التي تعطي حقوقاً للمتعاقد لإعادة التوازن المالي للعقد إذا تم الإخلال به نتيجة تدخل الإدارة. وكذلك الشروط المتعلقة بتعديل الثمن وفقاً لقواعد معينه في حالة تقلب الأسعار نتيجة تغير ظروف اقتصادية غير متوقعة، فهذه الشروط لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع لنظرية الظروف الطارئة.

ب- الشروط المستوحاة من اعتبارات الصالح العام:

وتعد كذلك من الشروط الاستثنائية غير المتوقعة الشروط المستوحاة من اعتبارات الصالح العام والتي تستهدفها الإدارة، ومن أمثلتها النصوص المدرجة بوثائق التأمين البحري - في زمن الحرب - والتي تخضع دفع التعويض لشراء سفينة جديدة، وكذلك الشروط الواردة في عقد تأجير عربات نقل "Camions" لإحدى الشركات والتي تلزم الشركة باستغلال العربات واستغلالها لأقصى حد ممكن، وأيضا الشروط التي تتضمنها عقود النقل المبرمة في زمن الحرب بواسطة الدولة وفقا لأوضاع تقتضيها اعتبارات الدفاع الوطني^(٣).

٣. شروط محل خلاف حول طبيعتها الاستثنائية:

إلى جانب الشروط التي تتسم بطابع السلطة العامة أو قاعدة من قواعد القانون العام وبصفة خاصة ما يرد في العقد وبفيد الإحالة إلى النظرية العامة للعقود الإدارية، فإن العقد وإن لم يحتوي علي شروط من هذا القبيل، قد يتضمن شروط يثير الشك حول طبيعتها الاستثنائية، ومن أمثلة هذه الشروط:

أ- الإحالة إلى نوع معين من العقود:

قد يتضمن العقد شرطاً يحيل إلى نوع معين ومعروف من العقود الإدارية أو المدنية، فما هي قيمة هذا الشرط؟.

(١) راجع: د. محمد عبد الواحد الجميلي، مرجع سابق ذكره، ص ١٣٧.

(٢) نظر: محمد جمال جبريل، العقود الإدارية، إبرام العقد الإداري وصحته وفقاً لقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية، الطبعة الثانية، ١٩٩٩، ص ٥٦.

(٣) انظر: د. احمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص ٨٥ - ٨٦.



الأصل أن هذه الإحالة من شأنها أن تحدد طبيعة العقد الإدارية أو المدنية وذلك وفقاً لنوع العقد المحال إليه. لأن هذه الإحالة تُظهر نية الإدارة التي لها مطلق الحرية في أن تختار بين أسلوب القانون العام أو أسلوب القانون الخاص في مباشرتها لوظائفها. وبناءً على ذلك إذا تضمن العقد شرطاً يفيد الإحالة إلى عقداً من العقود المدنية، فهذا يفيد مبدئياً أن هذا العقد ينتمي إلى طائفة العقود المدنية.

ولكن قاعدة « أن الإحالة إلى نوع معين من العقود من شأنها أن تحدد طبيعة العقد المدنية أو الإدارية وفقاً لنوع العقد المحال إليه » قاعدة ليست مطلقة، ذلك أن الإحالة ليست لها قيمة فعلية إلا إذا كانت متفقة مع المضمون الحقيقي للعقد المبرم بمعنى آخر يجب ألا يوجد من بين شروط العقد نصوص تتعارض مع تلك الإحالة^(١). فإذا تبين من نصوص العقد أو مضمونه، أنه عقد إداري فإنه يأخذ هذا الوصف حتى ولو أحال المتعاقدان أو وصفوه بأنه عقد من عقود القانون الخاص المعروفة^(٢).

ب - الإحالة إلى أحد دفاتر الشروط العامة للإدارة:

قد يخلو العقد من أية شروط استثنائية أو غير مألوفة، ولكنه يتضمن شرط يحيل في الأمور التي ينظمها أو بعضها إلى أحد دفاتر الشروط التي تنظم العقود الإدارية^(٣).
فهل تعد هذه الإحالة بمثابة شرط استثنائي يضيف الطبيعة الإدارية على العقد؟

2024/2025

2024/2025

الأصل أنه إذا أحال العقد إلى أحد دفاتر الشروط، - وكان هذا العقد لا يتضمن شروطاً استثنائية - توقفت طبيعة العقد على نوعية الشروط التي تتضمنها الدفاتر المحالة إليها، فإذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطاً استثنائية اكتسب العقد الطبيعة الإدارية وذلك لأن الشروط الواردة في الدفاتر المحال إليها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد كما لو كانت قد وردت فيه صراحة. أما إذا خلت الدفاتر من الشروط الاستثنائية فإن الإحالة في هذه الحالة لا تؤدي إلى إضفاء الصفة الإدارية للعقد.

(١) انظر: د. محمد عبد الواحد الجميلي، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٠.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في ١٦/١٢/١٩٥٦، المجموعة، س ١١، ص ٥٨٧. وحكمها في ١٠/٣/١٩٥٧، المجموعة، س ١١، ص ٢٥٤.

(٣) « دفاتر الشروط هي عبارة عن شروط موحدة طوائف مختلفة من العقود الإدارية تقوم الإدارة بإعدادها مقدماً قبل التعاقد وتضمنها دفاتر مطبوعة، وتعتبر جزءاً من العقد الإداري بعد إبرامه بجوار الشروط الخاصة التي يتفق عليها بين الإدارة وبين المتعاقد الآخر ». انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٨٤.

وبهذا الرأي يأخذ القضاء الإداري - الفرنسي أو المصري - فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في العديد من الأحكام أن الإحالة إلى أحد دفاتر الشروط العامة أمر غير مفيد في تحديد طبيعة العقد، إلا إذا كانت الشروط الواردة في الدفتر المحال إليه في ذاتها استثنائية^(١).

كما قرر مجلس الدولة المصري نفس الاتجاه، ففي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢٤ مارس ١٩٨٦ تؤكد المحكمة: « أن مناط العقد الإداري أن تكون الإدارة أحد أطرافه وأن يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصة وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقرره بمقتضى القوانين واللوائح »^(٢).

ج- الشروط الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي:

كثيرا ما تلجأ الإدارة إلى أن تضمن عقودها نصا يشير إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري في كل ما يتعلق بالمنازعات الناجمة عن العقد. فهل يكفي هذا الشرط لكشف عن طبيعة العقد الإدارية؟.

2024/2025 حاول مجلس الدولة الفرنسي في 2024/2025 يتعلق بهذا الشرط الاتفاقى أن يوفق بين 2024/2025

أمرين:

الأمر الأول: مبدأ حرية المتعاقدين في الاختيار بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص.

الأمر الثاني: لا تستطيع الإدارة والمتعاقد معها أن تعدل قواعد الاختصاص، لان هذه القواعد تتعلق بالنظام العام.

ويتطبيق هذين المبدأين، ينتهي القضاء الإداري الفرنسي إلى أن هذا الشرط لا يمكن أن يؤثر بذاته على طبيعة العقد. فإذا كانت الطبيعة الإدارية لعقد واضحة لاحتوائه

(١) نظر علي سبيل المثال:

- C. E. 21 janvier 1938, Bureau de L'édition musico-mécanique, Rec., p.78.
- C.E. 23 février 1940, Trhand, R.D.P., 1945, p.225.
- C. E. 2 octobre 1981, Commune e Borce, Rec., p.642 .
- C.E. 13 janvier 1984, Sté. Doubigeon Normandie, Rec., p.653.

(٢) المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم ٥٥٩ ، لسنة ١٣٠٣ ، الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٣/٢٤ ، المجموعة ، ص ٥٥٧.

مثلا علي شروط استثنائية وغير مألوفة، فان شرط الاختصاص يصبح مجرد تأكيد حقيقة ثابتة من قبل. وبالعكس إذا كانت الطبيعة المدنية للعقد واضحة، كما لو كان موضوعه تعلق بالدومين الخاص للدولة مثلا، فان القضاء يهدر الشرط باعتباره مخالفا للنظام العام^(١).

وتبدو أهمية هذا الشرط إذا كانت طبيعة العقد غير واضحة، بمعنى أن العقد الذي ورد به الشرط قد يكون إداريا أو خاصا تبعاً لإرادة المتعاقدين، ففي هذه الحالة إذا ما كانت الشروط غير قاطعة في إضفاء الطبيعة الإدارية للعقد، لكونها مجرد قرائن ترجح الصبغة الإدارية، فحينئذ يكون شرط الاختصاص، بالإضافة إلى القرائن الأخرى، العامل الحاسم في إبراز صفة العقد الإدارية^(٢). وفي هذا الصدد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمة الصادر في ١٩ يونيو ١٩١٨ إلى أن شرط الاختصاص يستخدم في تلك الحالة « كدليل ترجيحي باعتباره كاشفاً عن النية المشتركة للمتعاقدين »^(٣). وأكدت محكمة التنازع الفرنسية هذا المبدأ في حكمها الصادر في ١٩ يونيو ١٩٥٢^(٤).

ثالثاً: الأثر المترتب علي خلو العقد من الشروط الاستثنائية:

الأصل أن خلو العقد من شروط غير مألوفة في العقود الخاصة المماثلة يجعل هذا العقد يندرج في مصاف العقود المدنية، حيث يعد ذلك بمثابة قرينة علي أن نية الإدارة قد اتجهت إلي عدم استعمال أساليب القانون العام في تعاقداتها، الأمر الذي يجعل من هذا التعاقد تعاقدًا مدنيًا.

غير أن هذا المبدأ لا يطبق علي جميع عقود الإدارة، حيث توجد طائفة من العقود التي تبرمها الإدارة تعد إدارية بالرغم من خلوها من أية شروط مألوفة، مثل عقود التزام المرافق العامة والأشغال العامة والتوريد الإدارية، فنظرا للطبيعة الخاصة لهذه العقود فقد نص القانون علي اعتبارها عقودا إدارية في كل أحوال إبرامها. فمثل هذه العقود تكون إدارية بطبيعتها، حيث يشترك بمقتضاها المتعاقد مع الإدارة مباشرة في تسيير المرفق العام، الأمر الذي يضيف عليها الصفة الإدارية بغض النظر عن احتوائها لشروط استثنائية من عدمه^(٥).

(١) انظر:

- C.E. 28 juillet 1916, Sté. gén. Du gaz du Midi, Rec., p330.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٨٦.

(٣) انظر:

- C.E 19 juin 1918, Sté. des voiliers français, Rec., p.597.

(٤) انظر:

- C.E 19 juin 1952, Sté. interprofessionnelle de viande, Rec., p.629.

(٥) انظر: د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ٤١.



الفصل الثالث الصور المختلفة للعقود الإدارية

لا تأخذ العقود الإدارية صورة واحدة، بل تتعدد هذه الصور تبعاً لموضوع العقد، فلم يعد الأمر قاصراً على عقود محددة على سبيل الحصر كما كان الأمر في الماضي. حيث كانت العقود الإدارية تنحصر في ثلاثة عقود هي عقود الأشغال العامة، الالتزام والتوريد. غير أنه نتيجة لانتشار ظاهرة الخصخصة وعجز عن القيام بالمشروعات الكبرى، أصبح بإمكان الإدارة إبرام طائفة أخرى من العقود - والتي تتوافر فيها أركان العقد الإداري - لعل أهمها ذلك العقد المستحدث الذي يستخدم حالياً في أغلب دول العالم وخاصة الدول النامية منها وهو عقد البوت B.O.T.

وسنقوم في هذا الفصل بدراسة أهم صور العقود الإدارية «المبحث الأول»، بالإضافة إلى بعض العقود الإدارية التي أقرها القضاء الإداري المصري «المبحث الثاني»، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول أهم صور العقود الإدارية

وسنقوم في هذا المبحث بدراسة أهم صور العقود الإدارية والتي تتمثل في عقود الالتزام وعقود المقاولات، عقد البوت B.O.T. وذلك في ثلاثة مطالب متتالية، على النحو التالي:

المطلب الأول عقد التزام المرافق العامة

عقد التزام المرافق العامة هو أشهر العقود الإدارية التقليدية^(١). بل إنه يعتبر أهمها على الإطلاق. ويعد عقد الالتزام أسلوباً لإدارة المرافق العامة، ذلك أن الدولة قد تری لأسباب كثيرة إلى أن تتخلى عن إدارة بعض المرافق العامة فتعهد بها إلى الملتزم ليقوم بإدارتها تحت إشرافها ورقابتها.

أولاً : تعريف عقد الالتزام:

١. التعريف الفقهي:

يعرف الفقه التقليدي عقد الالتزام بأنه: « عقد إداري يتولى الملتزم فرداً كان أو شركة بمقتضاه وعلي مسؤوليته، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم تقاضاها

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٩٧.



من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة سير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تُضمنها الإدارة عقد الامتياز^(١).

ووفقاً لتعريف الفقه التقليدي نستطيع أن نحدد خصائص عقد الالتزام في النقاط

الآتية:

أ- التزام المرافق العامة هو اتفاق ينتج عن تقابل برادتين مختلفتين، إحداهما لشخص من أشخاص القانون العام وبصفة خاصة الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية الأخرى { محافظة، مدينة، قرية } والأخرى لشخص من أشخاص القانون الخاص فردا كان أو شركة.

ب- مجال عقد الالتزام هو مرفق عام ذو طبيعة اقتصادية "صناعية أو تجارية، ومن أمثلة هذه المرافق مرافق النقل بالسيارات داخل المدن أو فيما بينها أو بين القرى والمراكز وكذلك مرافق النقل بالترام والنقل النهري. وقد فسر الفقه ذلك لسببين: أولهما يتلخص في أن الإدارة بطبيعتها ليست مهياً لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، فالوسائل الفنية والإنسانية والمالية تقتصها، وذلك بعكس الشركات والهيئات الخاصة. وثانيهما يتصل بالأعباء المالية التي تترتب علي إدارة المرفق العام وبالأرباح الناتجة عن تلك الإدارة، فإدارة المرافق العامة تحتاج إلى الكثير من

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الاستثمارات التي قد لا تستطيع الدولة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، في حين أن عقد الالتزام يقع علي عاتق الملتزم عبئ تمويل المشروع علي أن يحصل علي ما يعوضه عن ذلك من المنتفعين بالمرفق في الفترة التي يقوم فيها استغلاله.

ج- عقد الالتزام يضع علي كاهل الملتزم تحمل النفقات اللازمة لإدارة المرفق العام وحدة أي عدم إمكانية تحمل الإدارة لأية أعباء مالية في عقد الالتزام.

إلا انه نظرا لأهمية عقد الالتزام، خاصة في الدول التي يستند نظامها الاقتصادي علي دعامتي الملكية الفردية وحرية التجارة والصناعة . كفرنسا مثلاً^(٢) . فقد تطور وتوسع

(١) انظر في هذا المعني: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٩٧، د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره ص ٤٩٤، د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، الدار المصرية الحديثة، الطبعة الأولى ١٩٨١، ص ١٠٤. و أيضاً: د. عزيزة الشريف، مرجع سبق ذكره، ص ٧٦.

(٢) انظر في ذلك:

• Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1982, A.J.D.A., 1982, p. 202.

مفهوم عقد الالتزام مما أدى إلى تغير الخصائص السابقة التي كانت تعتبر أساسا لعقد التزام المرافق العامة.

وعلي ذلك يعرف الفقه الحديث عقد التزام المرافق العامة بأنه: « اتفاق يُكلف بمقتضاه شخص عام شخصاً آخر باستغلال مرفق عام تحت رقابته مقابل مكافأة محددة تتحدد بناء علي النتائج المالية لاستغلال المرفق »^(١).

وطبقا لهذا التعريف يتغير المفهوم التقليدي لعقد التزام المرافق العامة بالنسبة لأطراف العقد ومجال تنفيذ العقد والمقابل المالي للعقد وذلك علي الوضع التالي:

أ- أطراف عقد التزام المرافق العامة هم الإدارة مانحة الالتزام والملتزم. بالنسبة

للطرف الأول لم يحدث له أي تغيير، ولكن حدث تطور يتمثل في شخص الملتزم فهو عادة شخص من أشخاص القانون الخاص وبصفة خاصة شركة تجارية، ومع ذلك فهناك العديد من عقود الالتزام التي لا يكون فيها الملتزم شخصاً من أشخاص القانون الخاص، فقد يكون شركة اقتصاد مختلط « التي تمتلك الدولة معظم رأسمالها » أو شركة وطنية « رأسمالها في صورة أسهم مملوكة لأفراد ». مثال ذلك عقود التزام الطرق العامة التي تبرمها الدولة مع شركات اقتصاد مختلط في فرنسا^(٢) وأيضا عقود التزام النقل عن طريق السكك الحديدية أو النقل الجوي والمبرمة مع شركات وطنية^(٣). وكذلك يمكن أن يكون الملتزم شخصا من أشخاص القانون العام مثل هيئة الكهرباء أو الغاز وهيئة الصرف الصحي ومرفق المياه^(٤).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) انظر: من الفقه الفرنسي:

- A. DE LAUBADERE, Traité élémentaire de droit administratif, 1980, L.G.D.J., pp 294 et s.
- G. PEISER, droit administratif, Dalloz, 11^{éd.}, 1983, p. 122.
- G. DUPUIS & (M. J.) GUEDON & P. CHRETIEN; droit administratif , Armand colin, 7^{éd.}, 2000, p.494.
- L. RICHER, Les contrats administratifs, op. cit., p.33 .

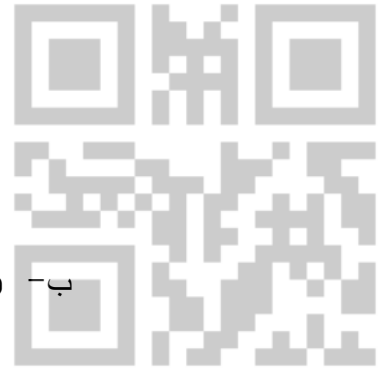
وانظر أيضا من الفقه المصري:

- د. سعاد الشرقاوى، العقود الإدارية، دار النهضة العربية ، ١٩٩٨ - ١٩٩٩، ص ٤٩.
- د. مصطفى محمود عفيفي ، الوسيط في مبادئ القانون الإداري ، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، الكتاب الثاني، ١٩٨٩ - ١٩٩٠، ص ٢٠٣. د. عبد الله حنفي، مرجع سبق ذكره، ص ٧٤.

(٢) انظر: د. عمرو احمد حسبو، مرجع سبق ذكره ، ص ٦٧.

(٣) انظر:

- L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 358.



ب- وفيما يتعلق بمجال عقد الالتزام فلم يعد قاصرا علي إدارة المرافق الاقتصادية «الصناعية والتجارية» فقط، بل امتد ليشمل إدارة بعض المرافق الإدارية، فهناك عقود التزام تنصب علي استغلال الطرق العامة وإدارة المستشفيات وهي . حسب النظرة الفقهية التقليدية . تعتبر مرافق عامة إدارية.

ج- أن قيام الملتزم وحدة بتحمل نفقات إدارة المرفق العام قد ورد عليه بعض الاستثناءات، إذ أصبحت الإدارة تساهم في تحمل بعض هذه النفقات^(١)، بل من الممكن حصول الملتزم علي تمويل من جهة خارجية غير الإدارة أو من غير المنتفعين. وبذلك أصبح ما يتقاضاه الملتزم من رسوم أو مقابل إدارته للمرفق عبارة عن مزيج من الرسوم التي يدفعها المنتفعون أو المبالغ التي يحصل عليها سواء من جهة الإدارة أو من جهة خارجية أو من غير المنتفعين^(٢).

٢. التعريف القضائي:

كان للقضاء سواء الإداري أو العادي منذ وقت طويل دورا في تعريف عقد التزام المرافق العامة، وإن كان . كما سنري . لم يخرج عن تعريف الفقه التقليدي له.

فقير عرفت محكمة القضاء الإداري هذا العقد في حكمها الصادر في ٢٥ مارس ٢٠٢٤/٢٠٢٥
١٩٥٦ بصورة تفصيلية بقولها: «.... التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام علي نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وطبقا للشروط التي تُوضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه علي الأرباح. فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة، وموضوعة إدارة مرفق عام، ولا يكون إلا لمدة محدودة. ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع وأخطاره المالية، ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين.....»^(٣). كما أكدت المحكمة الإدارية العليا نفس التعريف في حكمها الصادر في ٢٠ فبراير ١٩٩٠^(٤).

(١) انظر:

- G. DUPUIS & (M. J.) GUEDON & P. CHRETIEN; *op. cit.*, p.497.

(٢) انظر: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره ، ص ٥٠.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري رقم ١٤٦، سنة ١٠، الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٣/٢٥، المجموعة، ص ٢٥٩.

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣٩٧، لسنة ١٩، الصادر في ١٩٩٠/٢/٢٠.



كما عرفت محكمة النقض المصرية الملتزم في حكمها الصادر في ٨ نوفمبر ١٩٦٢ بقولها أن: « الملتزم بإدارة المرفق العام علي ما يفيد نص المادة ٦٦٨ من القانون المدني . هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن، ومن ثم فلا يعد المجلس البلدي ملتزماً إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة، المجلس البلدي شخص من أشخاص القانون العام وفرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٥ ببعض اختصاصات الدولة في شأن المرافق العامة »^(١).

ثانياً: طبيعة عقد الالتزام:

اختلف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الالتزام، فذهب فريق فقهي أن عقد الالتزام هو عقد مدني، تسوده قاعدة العقد شريعة المتعاقدين^(٢). إلا أنه يؤخذ علي هذا الرأي أنه يحول دون تدخل الإدارة في تعديل شروط الالتزام، وهذا يتنافى مع طبيعة النشاط الذي يقوم المرفق علي تحقيقه وهي الخدمة العامة، كما أنه يغفل ما للملتزم من مزايا لا يتمتع بها غيره من أفراد العقود المدنية كشغل الدومين العام واحتكار تقديم خدمة عامة ... الخ.

لذلك ذهب فريق فقهي آخر إلى تكيف عقد الالتزام بأنه عمل قانوني يصدر من 2024/2025

جانب واحد وهو الإدارة، ويستندون في ذلك إلى أن للسلطة مانحة الالتزام -دائماً- حق التدخل وتعديل قواعد الالتزام بإرادتها المنفردة، دون توقف علي إرادة الملتزم. وهذا الرأي وإن كان يحتفظ للإدارة بحقها في التدخل للتعديل في قواعد الالتزام أو إلغائه دون حاجة لرضاء الطرف الآخر، إلا أنه يغالي في إغفال نصيب الملتزم في إبرام العقد مغالاة قد تؤدي إلى تهديد مركزه بل قد تدفعه إلى الإحجام عن القيام بهذا الدور^(٣).

علي أن الرأي الراجح في تكيف عقد التزام المرافق العامة يذهب إلى اعتباره عمل قانوني مركب، يحتوي علي نوعين من الشروط: شروطاً تعاقدية وأخرى لائحية^(٤).

(١) حكم محكمة النقض، الطعن رقم ٢٩٣ مدني، لسنة ٢٧ق، الصادر بتاريخ ١١/٨/١٩٦٢، المجموعة، ص ١٠٠.

(٢) انظر: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣.

(٣) انظر: د. عمرو احمد حسبو، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٥. وأيضا: د. سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص ٥٣.

(٤) ولقد استقر القضاء الإداري المصري علي الأخذ بتلك التفرقة بين الشروط التعاقدية والشروط اللائحية، انظر علي سبيل المثال:

١. الشروط التعاقدية:

وهي الشروط التي يجري الاتفاق بشأنها بين الإدارة والملتزم. وهي التي تبين حقوق والتزامات طرفي التعاقد، ومدة الالتزام وطريقة استرداد المرفق وهي لا تمتد إلى كيفية أداء الخدمة للمنتفعين. وهذه الشروط كقاعدة عامة تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لذلك ليس للإدارة سلطة تعديلها إلا بموافقة الملتزم.

٢. الشروط اللائحية:

وهي الشروط التي تتعلق بتنظيم المرفق وتسييره، كالشروط التي تحدد قيمة الرسم، ميعاد تقديم الخدمة، كيفية أداء الخدمة للمنتفعين، توفير السلامة للمنتفعين وشروط الانتفاع بالخدمة.... الخ. وهذه الشروط يجوز للإدارة تعديلها - بالحذف أو بالإضافة أو التعديل - بإرادتها المنفردة دون حاجة لموافقة الملتزم، وذلك كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ثالثاً: التنظيم القانوني لعقد التزام المرافق العامة:

نظراً لأن عقد الالتزام يخول فرداً عادياً أو شركة الحلول محل السلطة العامة في إدارة مرفق عام واستغلاله. وعادةً يكون ذلك عن طريق الاحتكار القانوني أو الفعلي، فإنه يجب وجود نوع من الرقابة علي السلطة مانحة الالتزام خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الحالي والذي قد يؤدي إلى أن يكون الملتزم "شركة أجنبية" ولا يخفي علي أحد أن هذا الوضع قد يمثل خطراً حقيقياً علي مصالح الدولة وسيادتها^(١).

وبناء ما سبق، نجد أن الدساتير المصرية السابقة تتضمن نصوصاً تفيد ضرورة أن يكون منح الالتزام بقانون. وعلي سبيل المثال المادة ١٣٧ من دستور سنة ١٩٢٣ تنص علي أن: « كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور وكل احتكار، لا يجوز منحه إلا بقانون ولزمن محدود..... ».

• حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/١/٢٧، لسنة ١١١ق، المجموعة، ص ١٦٠.

• حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١١٠، لسنة ١٣ق، الصادر في ١٩٧٧/١٢/٣٠، مجموعة المكتب الفني، ص ٢٧.

• الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، فتوى رقم ١٤٨٢، لسنة ١٨ق، صادرة في ١٩٦٣/١٢/٢٨، المجموعة، ص ١٠٠.

(١) في ذات المعني راجع: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٠.

وانتقل هذا النص من دستور لآخر^(١)، فالمادة ٣٢ من الدستور الحالي المعدل في سنة ٢٠١٤ تنص علي: " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."

وقد نظم المشرع المصري - بناء على التفويض المخول له دستورياً - عقد الالتزام بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ { المعدل بالقانون رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٥٤، والقانون رقم ٥٣٨ لسنة ١٩٥٥ والقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٨ }، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨.

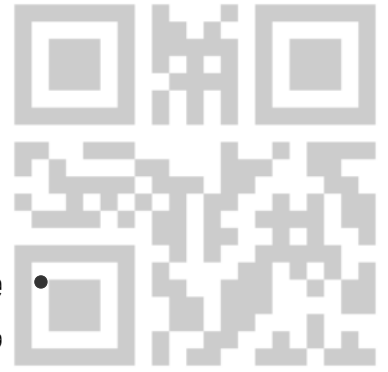
وعلي ذلك يمكننا القول أن المشرع قد نظم عقد الالتزام بالقانون رقم ١٢٩ لسنة

١٩٤٧ والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ ووفقاً لأحكامهما يتحدد النظام القانوني لعقد التزام المرافق العامة كما يلي:

أ. أداة منح التزامات المرافق العامة:

من أهم الأمور التي وردت في القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨، ما يتعلق بالسلطة مانحة الالتزام، فقد حددتها المادة الأولى من ذلك القانون كما يلي:

(١) بالنسبة لدستور ١٩٥٦ تنص المادة ٩٨ منه علي أن: « ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ». كما تنص المادة ٩٩ من نفس الدستور علي انه: « لا يجوز منح احتكار إلا بقانون و إلى زمن محدد ». أما دستور سنة ١٩٥٨ المؤقت فقد نص في المادة ٣٠ علي انه: « لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد ». كما تضمن دستور سنة ١٩٦٤ نص المادة ٧٤ والتي تقول: « ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما بين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة، والنزول عن أموالها المنقولة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ». والمادة ١٢٣ من دستور سنة ١٩٧١ تقضي بأن: « ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة، والنزول عن أموالها المنقولة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ».



• يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وكذلك أي تعديل في شروط الامتياز يتعلق بشخص صاحب الامتياز أو مدة الامتياز أو نطاقه أو الإتاوة (العائدات) بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب.

• بالنسبة لموارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة لوزارة الحربية فيكون منح الامتيازات المتعلقة باستثماراتها وتعديل شروطها بقرار من وزير الدفاع إذا لم تتجاوز مدة الامتياز خمس سنوات.

وبناء على ذلك يمكننا أن نقرر أن - الأصل العام - لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة إنما يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب. ولكن استثناءً من هذا الأصل العام فإنه يجوز منح الامتياز بقرار من وزير الدفاع ولكن لتطبيق هذا الاستثناء يجب أن يتوافر شرطين، أولهما أن تكون محل عقد الالتزام تابعة لوزارة الحربية، وثانيهما ألا تتجاوز مدة الالتزام خمس سنوات. فإذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما فإن منح الالتزام في هذه الحالة يجب أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس النواب.

ب. مدة الالتزام:

2024/2025

2024/2025

نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ على أنه: « لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة ». وتقتضي طبيعة عقد الالتزام أن يمنح لمدة طويلة نسبياً حتى يستطيع الملتزم أن يعوض ما صرفه في إدارة واستغلال المرفق العام مع تحقيق الأرباح المتفق عليها^(١).

وهذا التحديد الذي أوجده المشرع بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ أنهى عرفاً كان يجري بمقتضاه منح الالتزامات في مصر^(٢). فقد كانت عقود الالتزام تمنح في القديم لمدد

(١) انظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠٢. وراجع أيضاً: د. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص ٣٤.

(٢) وتقول المذكرة الإيضاحية لقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ في هذا الشأن أنه: « لم يعد من المقبول إزاء ما نشهده من التطور السريع في المسائل الاقتصادية والاجتماعية أن تمنح الالتزامات لما يقرب من قرن. والحق أنه إذا ما حدد الالتزام مدة ثلاثين عاماً كفل ذلك للملتزم الانتفاع به للمدة الكافية لاستهلاك ما قام به من نفقات الإنشاء ... ». مشار إلى ذلك لدي: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٧.





ج. نهاية عقد الالتزام:

رابعاً: آثار عقد الالتزام:

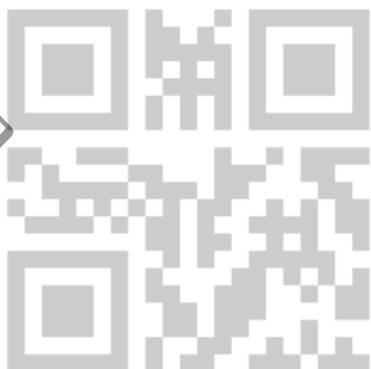
١. حقوق السلطة مانحة الالتزام:

حقوق
2024/2025

أ- حق الرقابة على إنشاء وإدارة المرفق العام:

وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرافق، ويختص هؤلاء المندوبين بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الالتزام.

(١) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٢.



ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزير منح الالتزام أو المشرف على الجهة مانحة الالتزام، أن يعهد إلى ديوان المحاسبة «الجهاز المركزي للمحاسبات الآن» بمراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية أو أن يعهد بالرقابة الفنية والإدارية إلى أية هيئة عامة أو خاصة.

كما يجوز للوزير المختص أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من موظفي وزارته أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولي أمر من أمور الرقابة على التزامات المرفق العامة. وفي هذه الحالة يتولى ديوان المحاسبة أو الهيئة المكلفة بالرقابة دراسة النواح التي ينبط بها رقابتها وتقديم تقرير بذلك إلى كل من الوزير المختص والجهة مانحة الالتزام. وعلى الملزم أن يقدم إلى مندوبي الجهات التي تتولى الرقابة وفقاً للأحكام السابقة، كل ما قد يطلبه من أوراق أو معلومات أو بيانات أو إحصاءات، كل ذلك دون الإخلال بحق مانح الالتزام في فحص الحسابات والتفتيش على إدارة المرفق في أي وقت «.

وعلى ذلك - بمقتضى هذا الحق - يكون للسلطة مانحة الالتزام أن تشرف على الملزم أثناء إعداد المرفق العام أو أثناء استغلاله، وأن تجبره على تنفيذ كافة الشروط الواردة في وثيقة الالتزام إذا أخل بها.

٢-١- حق تعديل النصوص اللائحية بالإرادة المنفردة:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يضاف إلى حق السلطة مانحة الالتزام في الرقابة وكنتيجة حتمية مترتبة عليه حقها في القيام - دون توقف على إرادة الملزم - بتعديل طائفة الشروط اللائحية في عقد الالتزام. وهو ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ حيث تقول: « لمانح الالتزام دائماً متى اقتضت ذلك المصلحة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام أو قواعد استغلاله وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملزم في التعويض إن كان له محل «.

ويستند هذا الحق إلى ضرورات تسيير المرفق العام على النحو الملائم، وتطويره لمقتضيات الظروف المتغيرة والمتطورة بما يكفل أداء خدماته على أحسن وجه. ويجب الإشارة إلى أن الملزم له الحق في الحصول على التعويض المناسب لما يكون قد أصابه من ضرر نتيجة تدخل الإدارة وتعديلها للعقد بإرادتها المنفردة. فحق التعويض مكمل لحق التعديل. وفي ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٧٧ إلى أن: « ومن حيث أن المسلم به فقهاً وقضاً أن شروط عقد التزام المرفق العام تنقسم إلى نوعين: شروط لائحية وشروط تعاقدية، والشروط اللائحية فقط

هي التي يملك مانح الالتزام تعديلها بإرادته المنفردة في أي وقت لمقتضيات المصلحة الهامة دون أن يتوقف ذلك علي قبول الملتزم.... إلا أن إثثار الصالح العام علي الصالح الخاص للملتزم ليس معناه التضحية بهذه المصالح الخاصة بحيث يتحمل الملتزم وحدة جميع الأضرار، فإذا ترتب علي مثل هذا التعديل إضراراً بالملتزم، فعلي مانح الالتزام أن يعرضه بما يجبر هذه الأضرار «(١)».

ج- حق استرداد المرفق قبل نهاية المدة:

للسلطة مانحة الالتزام حق استرداد المرفق قبل نهاية مدة الالتزام. وذلك إذا تبين لها؛ لسبب أو لآخر، أن طريقة الالتزام لم تعد تتفق مع المصلحة العامة التي أنشئ من أجلها. وهو حق أصيل لها حتى ولو لم ينص عليه في عقد الالتزام. وتنص المادة الرابعة من قانون التزامات المرافق العامة رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ علي أن: « يجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل انتهاء مدته».

ويترتب علي استرداد الإدارة للمرفق قبل انتهاء مدته ما يلي:

➤ حق الملتزم في الحصول علي تعويض عادل وكامل يغطي ما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب.

➤ تحل الإدارة مانحة الالتزام محل الملتزم في كل ما يتعلق بالمرفق، كديونه، 2024/2025 2024/2025 والتزاماته قبل عماله (٢).

٢. حقوق الملتزم:

ينتج عن عقد الالتزام حقوقاً للملتزم، يمكن إجمالها فيما يلي:

أ- حق اقتضاء مقابل:

للملتزم حق اقتضاء مقابل مالي من المنفعين بخدمات المرفق. وبذلك يتميز عقد الالتزام عن بقية عقود الإدارة في أن المقابل المالي لا يتمثل في مبلغ مالي معين تدفعه الإدارة للمتعاقد (٣). ومما لا شك فيه أن المقابل المالي الذي يحصل عليه الملتزم لقاء إدارته واستغلاله المرفق يمثل بالنسبة له أهمية كبيرة، بل يعد الدافع الأساسي للتعاقد، إذ عن طريقه يستطيع أن يغطي كل ما أنفقه من مصاريف لإنشاء واستغلال المرفق ومصاريف الإدارة والعمال بالإضافة إلى الربح الذي يأمله من تعاقد.

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١١٠، لسنة ١٣ ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٣٠.

(٢) فتوى الجمعية العمومية في ١٨ نوفمبر ١٩٦٤، س ١٩، ص ١٢٨.

(٣) راجع: محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص ٥١٠.

وللملتزم الحق في تحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه من المنتفعين علي ألا يغالي في ذلك، فان غالي في تحديده أو حدده بطريقة تتعارض مع المصلحة العامة، جاز لمانح الالتزام أن يرد هذا المقابل إلى حدوده المعقولة. ولهذا نصت المادة الخامسة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧، علي أن: « لمانح الالتزام . دائما متي اقتضت ذلك المصلحة العامة . أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام أو قواعد استغلاله وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملتزم في التعويض إن كان له محل ».

كذلك في حالة مخالفة الملتزم في اتفاقاته مع المنتفعين المقابل المالي المحدد في العقد، أو في التعديلات اللاحقة، يمكن لهؤلاء المنتفعون طلب هذه الاتفاقات. حيث أن المادة ٦٧١ من القانون المدني تنص في هذا الصدد علي أن يكون: «لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي ما يخالفها ».

وضماماً لعدم تجاوز الملتزم - في تحديده للمقابل المالي - للحدود المعقولة نصت المادة الثالثة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ علي انه: « لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي أرباح استغلال المرفق العام عشرة في المائة من رأس المال 2024/2025 2024/2025 الموظف والمرخص به من مانح الالتزام وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال. وما زاد علي ذلك من صافي الأرباح يستخدم أولاً في تكون احتياطي خاص للسنوات التي تقل فيها الأرباح عن عشرة في المائة. وتقف زيادة هذا الاحتياطي متي بلغ ما يوازي عشرة في المائة من رأس المال. ويستخدم ما يبقي من هذا الزائد في تحسين وتوزيع المرفق العام أو في خفض الأسعار حسبما يري مانح الالتزام ». كما تنص المادة السادسة من القانون المشار إليه علي حق الإدارة في تعديل قوائم الأسعار وأركان تنظيم واستغلال المرفق " لخفض الأرباح الباهظة أي القدر المقبول". ويذهب رأي فقهي . نؤيده . في أن كل من نص المادة الثالثة والمادة السادسة كان يمكن الاستغناء بأيهما عن الأخرى، إذ بتحديد حد أقصى للربح ١٠% قدر المشرع (القدر المقبول) للربح بحيث يخفضه إذا زاد عن ذلك. وإعمال المادة السادسة بدوره لن يكون بالنسبة إلى الأرباح التي دون الـ ١٠% وإنما تلك التي تتجاوزها بكثير فتخفض إلى نسبة الـ ١٠%. وهذا هو اتجاه محكمة القضاء الإداري كما يوضحه حكمها الصادر في ٢٧ يناير ١٩٥٧ حيث تقول: «أن حق السلطة مانحة الالتزام في محاسبة الشركات الملتزمة . طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون

رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة . لم يكن في حاجة إلى مثل هذا النص ليقرره، إذا كانت قد وجدت في وضع هذه الضوابط لحساب الأرباح ما يحقق المصلحة العامة، لأنها إذ تقرر ذلك إنما تضع في اعتبارها أنه إلى جانب تحقيق أرباح لملتزم يقوم أيضا واجبها في حماية الجمهور وأفراد المنتفعين بالمرفق، وعدم تركهم تحت رحمة الملتزم، ومن ثم فإنه يجب أن يكون للأرباح التي يجنيها الملتزم حدود بحيث لا تتجاوز الأرباح العادية المعقولة، تأسيسا على أن الملتزم . وهو يعاون جهة الإدارة في عمل مقصود منه تحقيق مصلحة المجموع . ليس له أن يبالغ في تحقيق أرباحه أو يجني أرباحا فاحشة غير معقولة، لأن مثل هذا الربح إنما يأخذه على حساب المصلحة العامة، ولذلك يكون من حق الإدارة أن تنزل بهذه الأرباح إلى الحد المعقول، وهذا ما كفلته المادة السادسة من القانون عندما نصت على حق الإدارة في التعديل (خفض الأرباح الباهظة إلى القدر المقبول) «(١)».

ب- حق الحصول على المزايا التي يقررها مانح الالتزام:

كثيرا ما تتعهد السلطة المانحة للالتزام بأن تحقق للملتزم بعض المزايا حتى يتمكن من القيام بمهمته. كأن تتعهد بإعطائه مبلغا من المال في صورة قرض، أو تقدم له قطعة أرض معينة يقيم عليها المرفق، أو تتعهد بالإتاحة لفرد آخر «أو شركة» بأن يزاو ذات النشاط الذي يزاوله.....الخ. والأصل أن تتضمن وثيقة الالتزام هذه الالتزامات التي تقع على عاتق السلطة مانحة الالتزام، وتدخل هذه المزايا في إطار الشروط التعاقدية التي يجب أن يتفق عليها أطراف عقد الالتزام. ولا يجوز للسلطة مانحة الالتزام إلغاء هذه الامتيازات أو تعديلها أو عدم الوفاء بها وإلا ترتب على ذلك مسئوليتها. وإذا تبين أن هذه المزايا كلها أو بعضها جوهرية بحيث يستحيل أو يصعب تشغيل المرفق بدونها، كان للملتزم فسخ العقد والمطالبة بالتعويض(٢).

ج- حق الملتزم في ضمان التوازن المالي للعقد:

رأينا عند استعراضنا لحقوق السلطة مانحة الالتزام، أن لها الحق في أن تعدل بإرادتها المنفردة بنود عقد الالتزام أو أن تعدل قواعد استغلال المرفق، وأن تسترد المرفق قبل انتهاء مدة الالتزام، وهذا بطبيعة الحال قد يلحق ضرراً مالياً بالملتزم الذي لم يكن ليقدم على

(١) انظر: حكم محكمة القضاء الإداري، رقم ٤٨٥ ، لسنة ٧ ق، الصادر بتاريخ ١/٢٧/١٩٥٧.

(٢) انظر: د. سعاد الشرقاوى ، مرجع سبق ذكره ، ص ٧١.

التعاقد مع الإدارة ويوظف أمواله في إدارة وتسيير المرفق إلا سعيًا وراء الربح المالي^(١).
فهنا تلتزم الإدارة بأن تقدم للملتزم التعويض العادل والمناسب بما يعيد التوازن المالي لعقد
الالتزام إلى سيرته الأولى^(٢)، وفي ذلك ضمان للمصلحة العامة لأن به يستطيع الملتزم أن
يفي بالتزاماته في تقديم الخدمة المنتفعين^(٣).

٣. حقوق المنتفعين في عقد الالتزام:

نظرا لتلقي المنتفعين - في عقد التزام المرافق العامة - خدمتهم من مرفق عام يديره
شخص من أشخاص القانون الخاص، تنشأ علاقة ثلاثية تربط بين أطراف العقد، علاقة
الملتزم بالإدارة، وعلاقة المنتفع بالإدارة وعلاقة المنتفع بالملتزم. وإذا كنا قد بينا العلاقة بين
الملتزم والإدارة فيما سبق، فإنه يتبقى لنا دراسة العلاقة الخاصة بين المنتفع وكل من الإدارة
والملتزم.

أ - بالنسبة لعلاقة المنتفع بالإدارة:

تلتزم الإدارة - في عقد التزام المرافق العامة - بأن تراقب حسن سير المرفق وقدرة
الملتزم علي إدارته للمرفق والتزامه بالتقيد بالمبادئ التي تحكم تنظيم وتسيير المرافق العامة
كمبدأ المساواة علي سبيل المثال، فيجب علي الملتزم أن يطبق فما بين المنتفعين قاعدة
المساواة في المعاملة، بحيث لا يتمتع - ^{2024/2025} ~~بغير~~ ^{2024/2025} سبب مشروع - عن تقديم خدماته إلى ^{2024/2025} من
استوفي شروط الحصول علي تلك الخدمات.

لذلك في حالة إخلال الملتزم في احترام شروط العقد أو المبادئ المنظمة لنشاط
المرافق العامة فإن الإدارة تتدخل - سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من المنتفعين
- لإجبار الملتزم لاحترام ما أخل به.

وفي حالة لجوء المنتفعين للإدارة للقيام بواجبها في الرقابة والإشراف علي إدارة
وتسيير المرفق، وإهمالها في أداء هذا الواجب، جاز لهم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري
بالطريقة الآتية: يقدم المنتفع - أو من استوفي شروط الانتفاع - إلى الإدارة طلبا للتدخل.
فإذا ما أجابت بالرفض أو امتنعت عن الإجابة مدة ستين يوما، عد رفضها أو امتناعها قرارا

(١) راجع: محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص ٥١٤.

(٢) انظر: د. سعاد الشرفاوى، مرجع سبق ذكره، ص ٧١.

(٣) راجع: د. جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص ٣٨.

إداريا مخالفا للقانون، وحق لمحكمة القضاء الإداري إلغاؤه، فيتحتم علي الإدارة أن تتدخل. وهذا ما اخذ به مجلس الدولة الفرنسي، وما يتعين الأخذ به في مصر^(١).

ب- بالنسبة لعلاقة المنتفع بالملتزم:

إذا كان هناك عقد يربط الملتزم والمنتفع، ففي هذه الحالة يلتزم الطرفان بالخضوع لهذا العقد كأى ملتزم في عقد عادي. ويجب الإشارة إلى أن العقد القائم بينهما يستند أساسا إلى عقد الالتزام الأصلي والذي يجب أن يحترما حدوده. وهذا ما قرره صراحة المادة ٦٦٩ من القانون المدني إذ تقول: « ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميلة بأن يؤدي هذا العميل علي الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز وملحقاته والشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين ». وعلي ذلك يكون لكل منهما الحق في اللجوء للقضاء لاقتضاء حقوقه، ويختص القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بمنازعات الملتزم مع المنتفعين.

في حالة عدم وجود تعاقد بين الملتزم والمنتفع، جاز لكل من استوفي شروط الانتفاع بالخدمات التي يؤديها الملتزم أن يطالب هذا الأخير، أو يطالب الإدارة قضائيا، بتنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام لصالح المنتفعين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

غير أن تحديد الأساس القانوني لحق المنتفعين في هذه الحالة كان محل خلاف في الفقه: فذهب رأى فقهي إلى إرجاع هذا الحق إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير المقررة في القانون المدني، علي أساس أن السلطة العامة وهي تتعاقد مع الملتزم إنما تشترط لمصلحة المنتفعين. إلا أن هذه الفكرة لأسباب عديدة لم تلق قبولا لدي الفقه أو القضاء^(٢). ولهذا يرجع غالبية الفقه أساس حقوق المنتفعين إلى الطبيعة الإدارية لعقد الالتزام، باعتبار انه يتصل بمرفق عام، فيستمد المنتفعون حقوقهم مباشرة من شروطه اللائحية، ويكون للمنتفعين جميعا الحق في أن يعاملوا علي قدم المساواة في التمتع بالخدمات التي يقدمها المرفق. وفي حالة إخلال الملتزم بهذه القاعدة، وجب عليه تعويض المضرور، وهذا ما تنص عليه المادة ٦٧٠ من القانون المدني إذ تقول:

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوى، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ١٩٨٢، ص ٣٤٧، د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص ٥١٤ - ٥١٥.

(٢) لبيان هذه الأسباب انظر: د. سليمان محمد الطماوى، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٣٤٧.

« ١. إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.

« ٢. ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تتطوي علي تخفيض الأجور أو الإعفاء منها علي أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام. ولكن المساواة تُحرم علي الملتزم أن يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين.

« ٣. وكل تمييز يُمنح علي خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يُوجب علي الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب علي هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة».

المطلب الثاني

عقود المقاولات

تعد عقود المقاولات - بلا منازع - من أهم واكبر العقود الإدارية. وتشتمل عقود المقاولات علي عقود الأشغال العامة وعقود التوريد والخدمات. وهذا واضح من تعريف القانون الفرنسي للمقاولات العامة، الذي من خلاله يبين أن عقود المقاولات هي العقود التي يبرمها شخص من أشخاص القانون العام من أجل تحقيق أو إنجاز الأشغال، التوريدات والخدمات العامة^(١).

وفيما يتعلق بعقود المقاولات في القانون المصري، بداية فقد أوردت المادة ٦٤٦ من القانون المدني تعريفاً لعقد المقابلة علي النحو التالي: « المقابلة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الآخر».

ومن ثم فقد ثار الخلاف حول هذا العقد هل هو عقد مدني أم عقد تجاري. وبالتالي البحث عن كيفية تمييزه عن سائر العقود الأخرى كعقد البيع وعقد الشركة^(٢). إلا انه بعد تحول الدولة إلى النظام الاشتراكي وصيرورة القطاع العام يغطي أكثر من ٨٠% من مجال

(١) انظر المادة الأولى لقانون المقاولات العامة الفرنسي:

- « Les marchés publics sont des contrats passés dans conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services». Art 1^{er}C.M.P.

(٢) انظر: السنهاوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ٧ " العقود الواردة علي العمل " المقابلة والعمل، ط ٢، ١٩٨٩، ص ص ٧ - ٥٦. مشار إليه لدي: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص ٣١ - ٣٥.

النشاط الاقتصادي بحيث ولم يعد للقطاع الخاص إلا مجالا محدوداً^(١). وترتب علي دخول الدولة إلى المجال الاقتصادي إبرامها للعديد من عقود المقاولات، مما أدى إلى اختصاص مجلس الدولة المصري - وحدة دون غيره - النظر في جميع المنازعات المتعلقة بعقود المقاولات العامة^(٢). مما أثار التساؤل: متي يعد عقد المقاولات عقدا إداريا؟. وتولي الفقه والقضاء الإداري الإجابة عن هذا التساؤل - كما سنري فيما يلي - بأن يكون عقد المقاولات عقدا إداريا، إذا توافرت فيه أركان وعناصر العقد الإداري، بمعنى أن يكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام، وكان موضع العقد متعلقا بإدارة مرفق عام، وأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

وعلي ذلك فان عقود المقاولات العامة تعتبر عقودا إدارية، وذلك لسببين أولهما، نص قانون مجلس الدولة علي أن عقود (الأشغال العامة والتوريد) عقود إدارية، وثانيهما احتوائها علي أركان وعناصر العقود الإدارية.

وبعد من ابرز صور عقود المقاولات الإدارية؛ عقود مقاولات الأشغال العامة، عقود التوريد وعقود أداء الخدمات. وهو ما سيتم دراسته في ثلاثة فروع متتالية علي النحو الآتي:

الفصل الأول

2024/2025

2024/2025

عقود الأشغال العامة

أولاً: تعريف عقد الأشغال العامة:

يعرف عقد الأشغال العامة بأنه عبارة عن: « اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد (أو إحدى الشركات) - ويسمى مقاولا - بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، ويقصد تحقيق منفعة عامة، في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد »^(٣).

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٠.
(٢) تنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ علي أن: « يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر ». مع الإشارة إلى أن القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ كان قد نص سابقا في المادة الخامسة علي أن: « تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد ».

(٣) انظر في تعريف عقد الأشغال العامة: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١١٢، د. محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص ١١٠، د. عزيزة الشريف، مرجع سبق ذكره، ص ١١٦.

وقد عرفته محكمة القضاء الإداري تعريفاً مشابهاً في حكمها الصادر في ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦ بقولها: «..... عقد الأشغال العامة هو عقد مقاول بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام، وتحقيقاً لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد»^(١).

وكان قد سبق أن عرفه قسم الرأي بمجلس الدولة - مجتمعاً - في فتواه رقم ٣٧٩ الصادرة بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٤٩ بأنه: «عقد يتعهد بمقتضاه مقاول للحكومة بأن يقوم بتنفيذ عمل معين تحت مسئوليته وإشرافها، مقابل مبلغ نقدي يدفع إليه حسب الأسس الموضحة بالتعاقد. والعنصران الأساسيان في عقد المقاول هما قيام المقاول بإنشاء العمل المتفق عليه، دون أن يكون له حق استغلاله وقيام الإدارة بدفع المبلغ النقدي للمقاول»^(٢). ولعل العنصر الثاني المتعلق بالمقابل المالي الذي تدفعه الإدارة للمقاول هو أهم ما يميز عقد الأشغال العامة عن عقد التزام المرافق العامة. ذلك أن الملتزم في عقد التزام المرافق العامة يحصل على مكافأته أو حقوقه عن طريق فرض رسوم يؤديها المنتفعين بالمرافق العام للملتزم الذي قام بإنشاء المرفق^(٣). وهو ما يسير عليه مجلس الدولة الفرنسي، حيث أكد أن معيار التمييز بين عقد الأشغال العامة وعقد التزام المرافق العامة إنما ينصب أساساً على المقابل المالي الذي يؤديه الشخص المعنوي العام للمقاول^(٤).

2024/2025

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، رقم ٢٨٤، لسنة ١١ق، الصادر بتاريخ ١٢/٢٣/١٩٥٦.
(٢) راجع الفتوى الصادرة عن قسم الرأي مجتمعاً برقم ٣٦٩ بتاريخ ١٦/١٢/١٩٤٩. مجموعة أبو شادي، ص ٩٧. مشار إليها لدى كل من: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، هامش ص ١١٢ والمستشار: حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية في التطبيق العملي "المبادئ والأسس العامة"، منشأة المعارف، ١٩٩٨، ص ٤٠٣.
(٣) انظر: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٣٧.
(٤) انظر:

- C.E. 14 octobre 1988, SA. Socea Balency, Marchés publics 1989, n°240.

ففي هذا الحكم قرر المجلس أن حصول المقاول على المقابل المادي من الإدارة هو شرط أساسي في عقد الأشغال العامة. "Pour qu'il y ait marché public il est nécessaire que le cocontractant soit rémunéré par la collectivité". المادي من المنتفعين، لا يعد العقد عقداً لأشغال عامة وهذا واضح في قضية "SIMA" حيث يقرر أنه إذا كان مصدر المقابل المادي من أي جهة غير جهة الإدارة خاصة المنتفعين - فإن العقد لا يعد عقداً للأشغال العامة.

"Si la rémunération a une autre origine, notamment si elle provient des usager, le contrat n'est pas un marché".

- C. E. 10 avril 1971, Beau et Lagarde, Rec.243.
- C.E. 6 mai 1991, Syndicat intercommunal du Bocage, A.J.D.A. 1991, 717, not Subra.

ثانياً : أركان عقد الأشغال العامة:

ويستفاد من التعريفان الفقهي والقضائي انه يتعين لكي نكون بصدد عقد أشغال عامة توافر الأركان الثلاثة الآتية:

١. أن ينصب موضوع العقد علي عقار:

إن الأعمال التي ترد علي المنقولات المملوكة للدولة لا تعتبر أشغالاً عامة، حتى ولو كانت تدرج في أموال الدومين العام أو مهما بلغت أهمية هذه المنقولات من حيث الحجم أو القيمة^(١). وعلي ذلك لم يعتبر القضاء الإداري الفرنسي الأشغال التي تتعلق ببناء أو ترميم سفينة أو حظيرة متحركة للطائرات من قبيل الأشغال العامة^(٢). وبناء علي ذلك يجب أن ترد أعمال المقاوله علي عقار سواء كان ذلك بشأن إنشاء العقار أو تحسينه بترميمه، ويضاف إلى ذلك أيضاً ما يرد علي العقار من عمليات الهدم^(٣). ويلحق بالعقار في ذلك، العقار بالتخصيص كإقامة خطوط تليفونية، ومد أسلاك تحت الماء^(٤). كما توسع القضاء الإداري الفرنسي في مفهوم الأشغال العامة، وادخل فيها كافة الأعمال المتعلقة بصيانة العقارات العامة^(٥).

٢. يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام:

يجب أن يتم تنفيذ عقد الأشغال العامة لصالح ولحساب شخص معنوي عام. ولكن^{2024/2025}

ليس من الضروري أن يكون العقار محل العقد مملوكاً لهذا الشخص أم لفرد من الأفراد العاديين، بل يكفي أن يتم الشغل العام عليه لحساب ذلك الشخص العام^(٦). ويعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن العمل قد تم لحساب الشخص المعنوي العام إذا ورد علي عقار مملوك للأفراد وذلك إذا كان لهذا الشخص إشراف مباشر علي الأعمال محل العقد. أو كان مصير

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سبق ذكره، ص ١١٣، د. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص ٥١٧.

(٢) انظر:

• C.E. 17 juin 1938, Le Tounir, Ser. 1939, p6.

(٣) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٨.

(٤) انظر:

• C.E.4 juin 1937, Cie. Fr. des câbles, Rec.p557.

• C.E.21 janvier 1927, Cie. Générales des eaux, Dalloz 1928, concl. Blaevoet, p57.

(٥) انظر:

• C.E.9 février 1934, Mobille, Rec.1934, p33.

• C.E. 8 mai 1935, Quignard, Rec., p627.

(٦) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٨.

العقار أن يؤول إلى الشخص المعنوي العام في نهاية مدة معينة، مثل المنشآت التي يقيمها الملتزم والتي تعود إلى الدولة في نهاية الالتزام^(١).

٣. يجب أن يكون الغرض من الأشغال موضوع العقد تحقيق نفع عام:

يجب أن تكون الغاية من الأعمال أو الأشغال العامة هي تحقيق نفع عام أو مصلحة عامة، كإنشاء المستشفيات لعلاج المرضى أو إنشاء المدارس... الخ. أما العقود التي يكون محلها عقار مملوك للدولة أو لأحد الأفراد العاديين والتي تتم باسم ولحساب الشخص العام ولكن لتحقيق مصالح خاصة أو فردية فإنها تخرج عن نطاق عقود الأشغال العامة وتندرج في الوقت نفسه في إطار طائفة عقود الإدارة الخاصة^(٢).

الفرع الثاني

عقود التوريد

يلاحظ أنه عند تحديد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المصري فيما يتعلق بمنازعات عقود الإدارة أن القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ قد حدد هذا الاختصاص بعقود الالتزام وعقود الأشغال العامة وعقود التوريد «الإدارية». أي أن المشرع أضاف كلمة «الإدارية» لعقد التوريد، وهذه الإضافة هي دليل على الطبيعة الأصلية لهذا العقد وهي الطبيعة المدنية. وعلي ذلك قد يكون عقد التوريد مدنياً - وهو الأصل - وبختص القضاء 2024/2025 العادي في الفصل في منازعاته. وقد يكون إدارياً، وذلك إذا توافرت فيه شروط وأركان العقد الإداري السالف الإشارة إليها وفي هذه الحالة يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به^(٣).

(١) انظر:

- C. E. 22 juin 1928, Sigalas, R.D.P., p525.

(٢) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٨.

(٣) وفي ذلك تقرر محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٢٢٧، مدني، لسنة ٢٠١٠، المجموعة، ص ١٦، ص ٨٩٣ ما يلي: « تنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر. ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه وإنما عقد يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته و خصائصه الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا ابرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و احتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وهي الشروط التي يتسم بها العقد الإداري ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة في المادة العاشرة سالف الذكر والتي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها ».

وعقد التوريد وفقاً لتعريف القضاء الإداري هو: « اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة لشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين »^(١). ويتميز عقد التوريد الإداري بالخصائص الآتية:

١. موضوع عقد التوريد دائماً هو توريد منقولات، كالبضائع أو مواد التموين أو الفحم أو السفن أو المواد الحربية المختلفة... الخ، وبالتالي فإن موضوع عقد التوريد لا يمكن أن يكون عقاراً بطبيعته أو عقاراً بالتخصيص وهو ما يختلف فيه عن عقد الأشغال العامة.

٢. يُعتمد في تحديد الطبيعة الإدارية لعقد التوريد على الخصائص الذاتية بهذا العقد وهي . كما سبق أن ذكرنا . أن تكون الإدارة طرفاً في العقد، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص. ومحكمة القضاء الإداري تقوم بتحديد اختصاصها المنازعات المتعلقة بهذا العقد بناء على هذا الأساس وهذا واضح من حكمها في ٨ يونيو ١٩٥٤ حيث أكدت: « أن الاستفادة بما تم من إجراءات في شأن صفقات الصفيح أن عمليات الاستيراد تتمخض في الواقع عن عقد توريد، فعناصر العقد قد توافرت من حيث السلع ومواصفاتها وأسعارها، ولقد كان الأمر معلوم للطرفين بادئ ذي بدء فكانت الشركة تعلم قبل الإذن بالاستيراد إنها ليست حرة التصرف فيما تستورده وإنما هي تستورد لحساب الحكومة، وكانت الحكومة بدورها تعمل على الاستيراد وتشجع عليه لعلها أن مآل الصفقات جميعاً إليها، ولذلك لم تأذن إلا باستيراد ما يتفق و حاجات البلاد »^(٢).

٣. في حالة اختلاط عقد التوريد بعقد آخر ففي هذه الحالة تسري على كل عقد الأحكام الخاصة به وهو ما تقرره المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢٥ يناير ١٩٦٩ حيث تقول: « إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات

(١) محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ٦٢٥، لسنة ٤٤ق، الصادر بتاريخ ١٢/١٢/١٩٥٢، المجموعة، س٧، ص٧٦. وقد فرقت المحكمة في هذا الحكم بين عقد التوريد وبين الاستيلاء المؤقت على المنقولات المملوكة للأفراد بقولها: « ... وهو يختلف عن الاستيلاء في أن المورد في العقد الإداري يسلم المنقولات المتعاقد عليها برضائه دون أن يكون مضطراً إلى ذلك، بينما الاستيلاء إنما يكون بمقتضى قرار إداري بأن يسلم المورد المنقولات المطلوبة جبراً ».

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٨ يونيو سنة ١٩٥٤، المجموعة، لسنة ٣ق، ص ١٥٥١. وكذلك في حكمها الصادر في ٤ مارس سنة ١٩٥٢، المجموعة، س٦، ص ٦٠٢ بصدد عقد توريد بطاطين، وأيضاً حكمها في، القضية رقم ١٦٠٩، لسنة ١٠ق، الصادر في ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٦.

البخارية "الموتوسيكلات" وعلي توريد وتركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة وصاج وأخشاب ومشمع ومقابض وما إلى ذلك واستكمال الفوانيس والإشارات الحمراء. ولما كان التوريد في هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته وأهميته بجانب العمل، فإن العقد بهذه المثابة ينطوي علي مزيج من مقالة الأعمال والتوريد، تقع المقالة علي أعمال الإصلاح وتطبق أحكامه عليه ويقع التوريد علي المواد وتسري أحكامه فيما يتعلق بها «(١)».

٤. تتخذ عقود التوريد في العمل صوراً مختلفة، فقد يتم التوريد علي مرة واحدة، كما قد يتم علي دفعات متعددة، والأصل أن العقد في الحالتين تكون له الطبيعة الإدارية طالما توافرت فيه شروط وأركان العقد الإداري.

٥. يلاحظ أن عقد التوريد امتد ليشمل صوراً جديدة من التوريد مثل عقود التوريد الصناعية، وهي عقود يغلب علي محلها الطابع الصناعي، إلى حد أن توريد وتسليم محل العقد يستلزم الإشراف والرقابة من جانب الإدارة المتعاقدة علي مراحل التصنيع أو الإنتاج (٢). وأهم العقود التي تبرم في هذا الإطار هي العقود التي تبرمها وزارة الدفاع الفرنسية لتصنيع أجهزة بالغة التعقيد، تحتاج إلى إشراف ورقابة في مرحلة الإنتاج والتصنيع مثل: تصنيع الطائرات الحربية والصواريخ والدبابات والمدافع،

في ٢٠٢٥/٤/٢٠ نفس العقود لتصنيع أجهزة معقدة فنياً مثل ٢٠٢٥/٢/٢٠٢٤

الطائرات وأجهزة الإذاعة الصوتية والمرئية (٣). وأيضاً عقود التحويل، فالإدارة تسلم المتعاقدين منقولات «مواد خام مثلاً» مقابل التزامه بتحويلها إلى مادة أخرى يعاد تسليمها للدولة (٤).

الفرع الثالث

عقود الخدمات

المقصود بعقود الخدمات هي العقود التي ترد علي خدمة معينة كخدمة النقل أو النظافة أو المراسلات.... الخ، أو قد يكون الغرض من الخدمة الحصول علي دراسة أو بحث في مجال معين.

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٧٦٣، لسنة ١٢ق، الصادر في ١٩٦٩/١/٢٥.

(٢) انظر:

• L. RICHER, Droit des contrats des administratifs, op.cit, p. 292.

(٣) انظر: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٣.

(٤) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٥.

أولاً : عقد النقل:

وهو العقد الذي يبرم بين شخص من أشخاص القانون العام وبين أحد الأفراد أو الشركات بقصد نقل مواد منقولة لصالح الطرف الأول، كما يمكن أن يكون موضوعه نقل أشخاص أيضاً^(١). ويستوي أن يكون النقل عن طريق البر أو البحر أو الجو، كما يستوي أن يكون موضوع عقد النقل مقصوراً على مرة واحدة بحيث تنتهي التزامات الناقل بمجرد قيامه بالنقل، أو أن يكون موضوع العقد القيام بالنقل لأكثر من مرة أو القيام به بطريقة منتظمة كالنقل شهرياً أو كل ثلاثة أشهر... الخ.

ويتفق عقد النقل مع عقد التوريد - على عكس كل من عقد الالتزام وعقد الأشغال العامة - في أنه لا يعد عقداً إدارياً باستمرار وإنما يتوقف ذلك على ما يتضمنه من أحكام تضيي عليه الصفة الإدارية. وبناءً على ذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قضية " Cie des chargeurs français " عقد النقل المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها عقداً مدنياً نظراً لأنه لا يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص^(٢). وعلى العكس من ذلك في قضية " Ste des voiliers français " فقد اعتبر عقد النقل إدارياً نظراً لأنه يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص^(٣). وأيضاً في قضية " Manon " فقد اعتبرت محكمة التنازع عقد نقل الجنود عقداً إدارياً نظراً لأنه يتضمن التزام صاحب السفينة بأن يتولى^(٤) ويبحارته نقل الجنود، فيعد بذلك مساهمة 2024/2025 بصفة مباشرة في تسيير مرفق عام^(٤).

وقد سار على نفس النهج مجلس الدولة المصري فقد اعتبر أن عقد النقل المبرم بين مصلحة البريد وأحد الأفراد لنقل طرود من مصر إلى السودان عقداً مدنياً وليس عقداً إدارياً حيث يقول: « ولما كان عقد النقل المبرم بين مصلحة البريد والمدعي لنقل طرود من مصر إلى السودان، والذي ينظم أسس المسؤولية في هذه الدعوى لا يندرج تحت المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ إذ لا تتوافر فيه مقومات العقد الإداري بحسب التعريف الذي حدده قضاء المحكمة علي الوجه المتقدم » والذي أورده الحكم في صدره « إذ

(١) انظر: د. صلاح الدين فوزي، قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشاكل والحلول القانونية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٣، ص ٢٠.

(٢) انظر:

• C. E. 18 juin 1919, Cie des chargeurs français, Rec., p.520.

(٣) انظر:

• C. E. 19 juin 1918, Ste des voiliers français, Rec., p.597.

(٤) انظر:

• T. C. 7 novembre 1920, Manon, Rec., p. 795.

ليس المقصود به تسيير مرفق عام وليس في نصوصه شروط غير مألوفة في القانون الخاص، وإنما هو عقد مبرم لتحقيق مصلحة فردية خاصة وهي نقل رسالة من مصر إلى السودان في مقابل اجر أو رسم، فهو عقد من عقود القانون الخاص التي تخرج المنازعة بشأنها عن ولاية هذه المحكمة»^(١).

ثانياً: عقود الأداء الذهني أو الفكري:

تُعرف عقود الأداء الذهني أو الفكري بأنها العقود التي يكون محل الالتزام فيها تقديم عمل ذهني أو فكري لشخص من أشخاص القانون العام. وينظم هذه العقود في فرنسا المرسوم الصادر في ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٧٨، وقد تعرض لها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، فطبقاً للمادة الأولى منه هي العقود التي يكون محلها تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية لجهة الإدارة.

وتتعدد في الوقت الحاضر صور عقود الأداء الذهني أو الفكري فقد تكون عقوداً خاصة بالدراسة فقط، وقد يسبق عقود الدراسة عقوداً أخرى يطلق عليها عقود التعريف، وقد تكون الدراسة خاصة بالناحية الصناعية «عقود الدراسة الصناعية» أو بالناحية الهندسية أو المعمارية «العقود الهندسية أو المعمارية»^(٢).

وتعد - كقاعدة عامة - عقود الأداء الذهني أو الفكري عقوداً إدارية إذا أبرمها شخص من أشخاص القانون العام وكانت شروطها استثنائية وغير مألوفة في القانون^{2024/2025} الخاص. وتتأثر هذه العقود بطبيعة موضوعها، وكونه عملاً ذهنياً أو فكرياً، مما يحتم تنظيم استخدام النتائج والأفكار التي تحصل عليها الإدارة بمقتضى العقد علي نحو لا يتعارض مع حق الملكية الأدبية والفكرية والعلمية للمتعاقد مع الإدارة^(٣).

المطلب الثالث

عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

B.O.T.

تعتبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T. من العقود الحديثة نسبياً في المعاملات الاقتصادية الجديدة سواء المحلية منها أو الدولية. وقد بدأ الاهتمام بهذه العقود في إطار التغير الذي يشهده العالم في دور الدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة، إذ

(١) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٧٧٩، لسنة ١٠، الصادر في ٢٤/٢/١٩٥٧.

(٢) راجع في الصور المتنوعة للأداء الذهني أو الفكري: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٥.

أصبحت الوظيفة الأساسية للحكومات هي الرقابة ووضع الضوابط من خلال النظم الإدارية والتشريعية لحماية المصالح الاقتصادية للمجتمع^(١).

هذا وقد اتجهت معظم الدول النامية الآونة الأخيرة - ومنها مصر^(٢) - إلى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة يصعب علي الحكومات تمويلها من خلال اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

أولاً : مفهوم نظام ال B.O.T :

ان اصطلاح B.O.T هو اختصار لثلاث كلمات إنجليزية هي - **Build** - **Operate** - **Transfer** ، أي البناء أو الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية إلى الدولة، بمعنى ان تعهد الدولة إلى شركة ما (وطنية أو أجنبية أو مشتركة)، بإنشاء مرفق عام لإشباع حاجة عامة يحتاجها الجمهور كالطرق والمواصلات والمطارات... الخ، وذلك علي نفقة تلك الشركة « **Build** » ثم تتولى هذه الشركة إدارته وتشغيله وتؤدي الخدمة للمنتفعين بشروط محددة ولمدة معينة، وتحت رقابة وإشراف الجهة الإدارية المتعاقدة « وهنا تظهر خاصية الإدارة والتشغيل **Operate** »، ثم في نهاية المدة تنقل الشركة المتعاقدة ملكية المرفق أو المشروع إلى الدولة في حالة جيدة قابلة للتشغيل، وذلك حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في تشغيله « وهذا هو نقل الملكية **Transfer** » وبذلك تضمن استمرارية سير المرفق العام بانتظام واطراد، مما يحقق المصلحة العامة.

ويتبين مما سبق ان العناصر الأساسية لنظام ال B.O.T هي ما يلي:

(١) انظر: د. عمرو احمد حسبو ، مرجع سبق ذكره، ص ٩٧.

(٢) لقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بإبرام العديد من العقود وفقاً لنظام ال B.O.T ، حيث تم إسناد تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية إلى القطاع الخاص. ففي مجال النقل الجوي، طرحت الهيئة العامة المصرية للطيران المدني لتنفيذ مطار مرسى علم في مناقصة عامة و تم إسنادها إلى أحد المستثمرين الكويتيين (شركة اماك مرسى علم). و كذلك تم التعاقد بين الهيئة المصرية للطيران المدني و الشركة الدولية للمطارات من أجل إنشاء مطار العلمين. وفي قطاع النقل البحري و النهري، تم إبرام عقد لإنشاء وإدارة واستغلال محطات تداول الحاويات والبضائع العامة والصبب بالحوض الأول لميناء العين السخنة، وأيضاً إنشاء و تشغيل محطة تداول الحاويات لميناء شرق بور سعيد عبر نهر النيل. وفي قطاع الكهرباء، فقد تم التعاقد علي إنشاء مشروع محطة توليد سدي كرير في ٢٢ يوليو ١٩٩٨، و أيضاً مشروع محطة توليد كهرباء خليج السويس ومشروع توليد شرق بور سعيد في ٣ أكتوبر ١٩٩٩. وفي قطاع الطرق تم التعاقد وفق هذا النظام لإنشاء طريق القاهرة - العين السخنة، وطريق حلوان - الكريمات، وطريق إسكندرية - الفيوم. راجع لمزيد من التفاصيل: د. عمرو احمد حسبو، مرجع سبق ذكره، ص ٨٩ و ما بعده.

أ- التشييد والبناء للمشروع أو المرفق العام « **Build** »، وذلك بالتمويل من رأس مال المستثمر الذين يعهد إليه بإنشاء المشروع أو المرفق، ومن ثم لا تشارك الدولة أو أحد مؤسساتها المالية في هذا التمويل.

ب- التشغيل « **Operate** »، ويتولى المستثمر إدارة وتشغيل المشروع عن طريق إبرامه عقد تشغيل مع شركة إدارة وتشغيل من شركات القطاع الخاص.

ج- نقل الملكية « **Transfer** »، وهو التزام قائم على المستثمر بتسليم المشروع أو المرفق في نهاية المدة المحددة في عقد ال **B.O.T.** بدون مقابل وفي حالة جيدة. وعلى ذلك، يقصد بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية منح الدولة لمن يرغب من مستثمري القطاع الخاص (الأفراد أو الشركات الخاصة وطنية كانت أم أجنبية) في الاستثمار في أحد مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة، امتياز إقامة المشروع على الأراضي التي تحددها الدولة له، مع تحميله جميع الأعباء المالية لإقامة هذا المشروع وذلك مقابل حصول المستثمر على إيرادات تشغيل المشروع خلال الفترة التي تحددها الحكومة، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم نقل ملكية المشروع أو المرفق إلى الحكومة التي يحق لها التصرف في مصيره وفقاً لما تراه من اعتبارات قومية واقتصادية. فقد تری الدولة تجديد فترة الامتياز بشروط جديدة، أو منح امتياز تشغيله لمستثمر آخر، أو قد تری الدولة بيع المشروع في إطار عملية الخصخصة أو الاحتفاظ بالملكية وخصخصة الإدارة.... الخ. ولا يحق للمستثمر في نهاية العقد المطالبة بأية مبالغ أو تعويضات أو أي مقابل لإعادة المشروع وتسليمه للدولة^(١).

ثانياً : الطبيعة القانونية لعقود ال **B.O.T.** :

اختلفت آراء الفقه القانوني إزاء تحديد الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية **B.O.T.**، فأدرجها البعض ضمن العقود الخاصة، في حين يري البعض انها ذات طبيعة خاصة، بينما يري اتجاه ثالث ان عقود البوت عبارة عن تنظيم، وأخيراً يري اتجاه رابع إنها ذات طبيعة إدارية، وللوقوف على حقيقة الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية **B.O.T.**، يجب تناول هذه الآراء بالبحث والتحليل، وذلك علي النحو التالي:

(١) أنظر: د. عمرو احمد حسبو، مرجع سبق ذكره، ص ١٠١.

الرأي الأول: عقود ال B.O.T. من قبيل العقود الخاصة:

يرى هذا الرأي^(١) أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T. من قبيل العقود الخاصة، وتخضع لتنظيمها لأحكام القانون المدني أو التجاري بحسب الأحوال، ومن ثم ينعقد الاختصاص القضائي بشأنها إلي القضاء العادي.

وقد استند هذا الرأي إلي أن عقود ال B.O.T. لا تقبل بحسب طبيعتها أن تضمنها الإدارة شروطاً استثنائية، بل تبرم علي أساس مبدأ العقد شريعت المتعاقدين، ويسودها مبدأ «سلطان الإرادة». حيث أن متطلبات التجارة الدولية تفرض علي الدولة أن تتعاقد بذات الأساليب التي يتعاقد بها الأفراد العاديين. فمثل هذه العقود لا تقبل تميز الإدارة بمختلف السلطات التي تملكها في العقود الإدارية.

ويترتب علي ذلك العقود التي تبرمها الدولة مع طرف اجنبي لإنشاء المشروعات بنظام ال B.O.T. يجب أن تتعاقد فيها الدولة بأسلوب القانون الخاص، وبالتالي لا تستطيع الدولة ان تضمنها شروطاً استثنائية وذلك لأنه اذا كان في استطاعة الدولة في النطاق الداخلي ان تضمن عقودها أساليب وامتيازات السلطة العامة، فإنه لا يمكنها تطبيق ذلك علي العقود الإدارية ذات الطابع الدولي أي التي تحتوي علي طرف اجنبي، وذلك نتيجة حتمية لمبدأ سيادة الدولة، حيث ان سيادتها محددة داخل إقليمها الجغرافي وعلي من يحمل جنسيتها فقط. ومن ثم يجب ان تقف الدولة علي قدم المساواة مع المتعاقد معها إذا كان اجنبياً^(٢) ٢٠٢١/٢٠٢٢ القول بغير ذلك سيؤدي إلي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ الشركات دولية النشاط عن إبرام العقود ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنظام ال B.O.T. وذلك بلا ادني شك يمثل خسارة كبيرة للدولة.

غير أن هذا الرأي يجانبه الصواب، حيث أن مبدأ سيادة الدولة ليس له ادني ارتباط بتضمين العقود الإدارية شروطاً استثنائية، فهذه الأخيرة مردها ارتباط العقد بنشاط مرفق عام. فضلاً عن الشروط الاستثنائية غير المألوفة لا تتضمن في كل الأحوال تمييزاً لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وإنما تضمن في ذات الوقت للمتعاقد معها حقوقاً أكثر مما يتضمنها العقد الخاص^(٣).

الرأي الثاني: عقود ال B.O.T. ذات طبيعة خاصة:

ذهب اتجاه فقهي^(٤) إلي انه من الصعوبة بمكان وضع قاعدة عامة مجردة تقضي بأن عقد البوت B.O.T. عقداً مدنياً أو عقداً إدارياً، وذلك لأن عقود ال B.O.T. يتم

(١) انظر د. ماهر محمد حامد احمد، النظام القانوني لعقد البوت B.O.T. الانشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، ٢٠٠٤.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص ٩٧-٩٨.

(٣) انظر: د. خالد بن محمد العطية، النظام القانوني لعقد التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، ١٩٩٩ ص ٧١. د. أحمد رشاد محمود سلام، عقد الانشاء والإدارة وتحويل الملكية B.O.T.، دار النهضة العربية، ٢٠٠٤، ص ١٩٦-١٩٧.

إبرامها من خلال نظم قانونية مختلفة فيكون لكل عقد منها طبيعته الخاصة به. وهذا يؤدي إلى صعوبة وضع تكييف محدد ثابت لها، وإنما يلزم مراجعة كل عقد على حدة للبحث عما إذا كانت عناصر وأركان العقد الإدارية تتوافر فيه من عدمه، فإذا توافرت تلك الأركان كان العقد إدارياً، وعلي العكس يعد مدنياً في حالة عدم اكتمالها.

ويرى هذا الاتجاه أن عقود ال **B.O.T.** يمكن أن تكون عقود التزام إدارية تخضع لقواعد القانون الإداري في فرنسا، وفي ذات الوقت تعد عقوداً مدنية تخضع لقواعد القانون المدني في مصر. ويستند هذا الاتجاه على اختلاف المعيار المميز للعقد الإداري في القضاء الإداري في مصر عنه في فرنسا^(١). ففي حين يشترط القضاء الإداري المصري توافر ثلاثة معايير مجتمعة، وهي: أن تكون الإدارة طرفاً في العقد، وأن يتصل بنشاط مرفق عام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة. نجد أن القضاء الإداري الفرنسي يكتفي بأحد هذه العناصر، لإصباغ الطبيعة الإدارية على العقد. ونظراً لأن العقود المبرمة بنظام ال **B.O.T.** لا تتضمن شروطاً استثنائية، فإن مثل هذا العقد يكون إدارياً في فرنسا وذلك لوجود الجهة الإدارية طرفاً فيه، أو لأتصاله بنشاط مرفق عام. ومندياً في مصر لخلو العقد من الشروط الاستثنائية.

غير أن هذا الرأي يجانبه الصواب أيضاً، وذلك لأن عقد البوت يعد صورة حديثة من عقد الالتزام، وهو عقد إداري بطبيعته، بمعنى أنه عقد إداري بمجرد أن تكون الإدارة طرفاً في العقد^(٢) ويتصل بنشاط مرفق عام. ^{2024/2025} 2024/2025 في 2024/2025 تعهد جهة الادارة لشخص من أشخاص القانون الخاص بإدارة وتشغيل مرفق عام، ومن باب أولي إنشائه يعد أمراً استثنائياً يضيف على العقد الطبيعة الإدارية.

الرأي الثالث: عقود ال **B.O.T.** عبارة عن تنظيم:

يرى أنصار هذا الرأي أن عقود ال **B.O.T.** ليست اتفاقاً أو عقداً بل هي تنظيم اقتصادي يلزم لتنفيذه عقد العديد من الاتفاقيات المتعددة والمتشابكة بين أطراف مختلفة مصالحها متعارضة^(٣).

وهذا الرأي أيضاً محل نقد حيث أنه ينكر الطبيعة الاتفاقية لعقود ال **B.O.T.** ويخرج بها عن الطبيعة التعاقدية إلى الطبيعة التنظيمية بدعوى أن ذلك العقد يتضمن العديد من الاتفاقيات التي تتعارض فيها المصالح بين أطرافها، وهذا غير صحيح حين أن تلك

(١) انظر:

• ABDEL BAKI (S), Les projets internationaux de construction menés selon la formule B.O.T. « Build, Operate, Transfer », Thèse, Paris, 2000, p.262 et s.

(٢) انظر: د. هاني صلاح سري الدين، التنظيم القانوني لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، دار النهضة العربية، ٢٠٠١، ص ٢٤٥.

الاتفاقيات الفرعية إنما ترتبط وجودها بالعقد الأصلي المبرم بين جهة الإدارة وبين شركة المشروع، أما العقود الأخرى التي تبرم تنفيذا لهذا العقد فهي لا تؤثر في طبيعته والتي يمكن أن تكون عقود توريد أو عقود إشغال أو عقود التزام أو عقود تتعلق بالتمويل المالي، وقد تكون عقوداً إدارية أو عقوداً مدنية بحسب الأحوال^(١).

الرأي الرابع: عقود ال B.O.T ذات طبيعة إدارية:

يعرف الفقه^(٢)، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T بأنه: « عقد بمقتضاه تعهد الدولة أو إحدى الوزارات أو الجهات الإدارية إلى أحد شركات القطاع الخاص سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة بإنشاء مرفق عام وإدارته وتقديم خدماته إلى جمهور المنتفعين لمدة معينة، تحت إشراف الجهة الإدارية ورقابتها، مع الحصول على إيرادات المشروع خلال مدة العقد، على أن تنتقل ملكية هذا المشروع أو المرفق إلى الدولة أو الجهة الإدارية المتعاقدة . في حالة جيدة قابلة لاستمرار تشغيله . في نهاية المدة، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز ».

يتضح من هذا التعريف أن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ال B.O.T هو في حقيقته القانونية عقد إداري، فمما لا شك فيه، توافر جميع العناصر المميزة للعقد الإداري فيه، وذلك على النحو التالي:

١. الإدارة طرفاً في هذا العقد، سواء كانت الدولة أو إحدى الوزارات أو الجهات الإدارية.^{2024/2025}

٢. أن عقود البوت وإن كانت في ظاهرها تهدف إلى تحقيق الربح للمستثمر، إلا أنها من وجهة نظر الدولة المتعاقدة تهدف في المقام الأول إلى تسيير مرفق عام، فلا يستطيع أن ينكر أحد أن "مترو الأنفاق" ليس مرفقاً عاماً حيوياً، أو أن قيام أحد المشروعات باستصلاح آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية أو إنشاء مستشفى تخصصي أو إنشاء مطار دولي... الخ من قبيل المرافق العامة. وبالتالي يتوافر العنصر الثاني من عناصر العقد الإداري، ألا وهو أن العقد يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تنظيمه وتسييره.

٣. أن عقود البوت تتضمن مظاهر عديدة متنوعة للشروط الاستثنائية غير المألوفة في مجال عقود القانون الخاص، فعلى سبيل المثال المزايا العينية التي تقرها الإدارة للمستثمر وطنياً أو أجنبياً كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص ٩٦.

(٢) انظر: د. انس جعفر، مرجع سبق ذكره، ص ٧٥. د. عمرو أحمد حسبو، مرجع سبق ذكره، ص ١٠١.

منحه الأرض التي يقيم عليها مشروعه. يضاف الي ذلك ما يتضمنه شروط توضيح كيفية إقامة وتشغيل وإدارة المشروع تحت إشراف ورقابة الجهة الإدارية المتعاقدة.

وبناء علي ذلك فإن لهذا العقد طبيعة إدارية واضحة، ولذلك تحكمه وتنظمه المبادئ العامة للعقود الإدارية، وينعقد الاختصاص للقضاء الإداري بنظر جميع منازعاته.

المبحث الثاني

بعض العقود الإدارية الأخرى

توجد العديد من صور العقود التي أقر القضاء الإداري بطبيعتها الإدارية لتوافر خصائص ومميزات العقود الإدارية فيها، مثل عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة، عقد القرض العام، عقد الصرف، عقد بحث واستغلال البترول، عقد استغلال المحاجر، عقد إيجار ملاحه أو مقصف، عقد الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، وعقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام.

نكتفي في هذا المبحث بدراسة ثلاثة صور فقط نبدأها ببيان عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة، فإيضاح عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام، وأخيراً عقد القرض العام. وذلك من خلال ثلاثة مطالب متتالية علي النحو التالي:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المطلب الأول

عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة

جرت العادة أن ترسل الدولة . ممثلة في المعاهد والجامعات والمراكز البحثية المختلفة . مبعوثين للخارج لاستكمال دراساتهم في مجالات لازمة لخدمتها، ويتعهد المبعوث قبل سفره أن يتم دراسته في المجال الذي حددته الدولة الموفدة، وان يلتزم بالمدة المحددة للبعثة فلا يتجاوزها، وان يعود للبلاد بعد انتهاء بعثته. وأخيراً بالعمل لدي الجهة الموفدة أو الجهة التي تحددها مدة زمنية معينة. وفي حالة إخلال المبعوث بأحد هذه الالتزامات فإنه يتحمل هو أو كفيله المتضامن معه النفقات التي تكبدتها الدولة للإنفاق علي البعثة.

كذلك قد تشترط الجهات الإدارية القائمة علي بعض المعاهد المتخصصة في دراسة علوم معينة علي الملتحقين بها وجوب تعهدهم بالانتظام بالدراسة وخدمة الجهات التي تتبعها هذه العاهد مدة زمنية بعد انتهاء الدراسة وإلا التزموا برد المصروفات التي قامت الجهة الإدارية بصرفها عليهم أثناء الدراسة.

تلك الالتزامات توضع في إطار عقود بين الإدارة المختصة والمبعوثين للخارج، أو بين إدارة المعاهد المتخصصة والمتحقين بها، ولقد استقر القضاء الإداري المصري علي اعتبار تلك العقود من قبيل العقود الإدارية نظراً لتوافر خصائص ومميزات العقود الإدارية فيها، وذلك علي النحو التالي:

١. الإدارة طرفاً في العقد « الجامعة، المعهد، المركز البحثي، الوزارة،

الخ.....».

٢. اتصال العقد بمرفق عام « مرفق التعليم، الدفاع، الشرطة، البريد،

الخ.....».

٣. يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة، «كالتعهد بخدمة المرفق مدة

محددة، أو التعهد بالاستمرار في الدراسة، الخ.....».

وبناء علي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في الأول من

ديسمبر سنة ١٩٩٧ بأن: «...التعهد الذي يوقعه أعضاء البعثات الحكومية قبل إيفادهم

والذي يتعهدون بمقتضاه بالخدمة في الحكومة مدة معينة بعد انتهاء بعثتهم أو برد ما أنفقتة

الحكومة عليهم إذا ما امتنعوا عن الخدمة في الحكومة الفترة المحددة أو استقالوا أو فصلوا

لأسباب تأديبية، إنما هو من قبيل العقود الإدارية، إذ أن الإدارة تبغي من وراء الحصول 2024/2025

علي التعهد ممن يوفدون إلى البعثات أن يكون ذلك التعهد مقابل إنفاقها عليهم لتحصل علي

موظفين يؤدون خدمات أو في المصالح أو المرافق العامة،.... أن العقد موضوع الدعوى

الذي التزم فيه المدعى المدعي عليه الأول بالعمل بخدمة الحكومة لمدة سبع سنوات بعد

عودته من البعثة . وإلا التزم برد ما أنفقتة الحكومة عليه في البعثة . خاصة وان هذا العقد

وإن حوى شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص إلا أن هذه الشروط ليست شروطاً

تعسفية وإنما هي شروط لا تعتبر شروطاً إذعانية بالمعني المفهوم في نطاق القانون الخاص

ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عنه تعتبر منازعات متعلقة بعقد إداري مما يدخل في ولاية

القضاء الإداري «(١)».

وكذلك قضت محكمتنا الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١٣ مارس سنة

١٩٩٠، والذي قررت فيه أن: «...ومن حيث انه من المسلم به وفقاً لما استقر عليه

قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه أن المنازعات التي تثور بين الأفراد وجهة الإدارة بشأن

مطالبتها إياهم بنفقات الدراسة في معاهدها وكلياتها سواء كانت المعاهد والكليات مدنية أو

(١) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ١٢/١/١٩٩٧، في الدعوى رقم ١٣١٣ لسنة ١٠ ق.

عسكرية لا تعدو في حقيقة الأمر أن تكون منازعات ناشئة عن عقود إدارية تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها وهو ما يؤكد صراحة القانون الحالي لمجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، إذ ينص البند الحادي عشر من المادة (١٠) من هذا القانون علي أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: "حادي عشر" المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر «(١).

المطلب الثاني

عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام

عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام برضائه واختياره بأن يشترك في نفقات مشروع مشروعات الأشغال العامة والمرافق العامة سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية. فقد يتقدم إلى الإدارة بعرض المساهمة أحد الأفراد، كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء ورصف طريق عام يؤدي إلى أملاكه أو توسعة هذا الطريق، أو يعرض مساهمته النقدية في نفقات مبني حكومي «مستشفى، مدرسة، جامعة، معهد.... الخ»، ويستوي أن يكون عارض المساهمة ذا مصلحة في تعهده أو غير ذي مصلحة. وقد يأتي العرض من قبل شخص من 2024/2025 أشخاص القانون العام كغرفة تجارية تبدي استعدادها للمساهمة في نفقات إنشاء محطة للسكك الحديدية أو توسيع ميناء من الموانئ العامة. فإذا ما قبلت الإدارة هذا العرض انعقد بين الإدارة وعارض المساهمة عقداً إدارياً هو عقد تقديم المعاونة. والأصل أن يكون التطوع بالمساهمة اختيارياً ولو جاء نتيجة طلب من الإدارة، أو بإغراء من جانبها. وهذا ما يميز عقد المساهمة عن الاستيلاء ونزع الملكية إذ كلاهما يتم جبراً. أو حتى لو كان مثاراً من جانب الحكومة كما لو عرضت إحدى المدن إنشاء مدرسة بشرط مساهمتها في نفقاتها فيها.

ويستطيع عارض المعاونة سحب عرضه قبل موافقة الإدارة، أما إذا قبلت الإدارة العرض انتهى الأمر بالنسبة له وأصبح ملتزماً بعرضه. أما بالنسبة للإدارة فالأصل أن عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام لا يولد التزامات في جانبها، فهي ليست ملزمة بتنفيذ المشروع الذي قدم العرض من أجله حتى ولو كانت قد قبلت هذا العرض صراحة، فهي تملك العدول عن تنفيذه إذ ارتأت في تقديرها ملاءمة عدم تنفيذه، ولا يكون ذلك خطأً تعاقدياً،

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢٢٨٣ لسنة ٣٤ ق، الصادر بتاريخ ١٣/٣/١٩٩٠.

غاية الأمر أن المتعاقد الآخر يتحمل من التزامه بتقديم ما اتفق عليه. وبالعكس إذا قامت الإدارة بتنفيذ العقد، فإنه قد تترتب بعض الالتزامات في جانبها، وذلك في حالة اقتران العقد ببعض الشروط مثل توريد خدمات معينة بالمجان أو تعليم بعض الأفراد بالمجان، فحينئذ تسأل الإدارة إذا قصرت في أداء تلك الخدمة مسئولية تعاقدية^(١).

ومن المستقر في قضاء مجلس الدولة المصري أن عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام هو عقد إداري^(٢)، وتطبيقاً لذلك أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٣١ يناير سنة ١٩٩٣ التكييف القانوني لهذا العقد: «... أن المستقر عليه فقها وقضاء أن العقد المسمى عقد المساهمة في نفقات مشروع ذي نفع عام هو عقد إداري يتعهد بمقتضاه شخص برضائه واختياره بأن يشترك في نفقات مشروع من مشروعات الأشغال العامة والمرافق العامة، وقد يكون المتعهد ذا مصلحة في تعهده أو غير ذي مصلحة فيه، وقد يكون بعوض أو يتمخض تبرعاً، وقد يكون مبتدأ من تلقاء المتعهد أو مثاراً من جانب الحكومة، كما لو عرضت علي إحدى المدن إنشاء مدرسة بها بشرط مساهمتها في نفقاتها فيها، وقد تكون المساهمة بمبلغ من المال أو بشيء عيني كأرض أو غيرها، وقد يكون التعهد منجزاً وقد يكون مشروطاً. ولكن مهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوصافه، فهو يقوم علي المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام. ومن هنا تظهر لهذا العقد خصائصه الأساسية: الأولى أنه بعقد فيتميز بذلك عن الاستيلاء وعن نزع الملكية للمنفعة العامة إذ كلاهما يتم جبراً والعقد يتكون من عرض من جانب المتعهد يصادف قبولا من جانب الإدارة، والي أن يتم هذا القبول يجوز للعارض سحب عرضه فإذا تم بتلاقي القبول بالإيجاب نشأ التزام علي جانب المتعهد بأن ينفذ تعهده بالمساهمة في النفقات بحسب موضوعها، وكان من جانبه وحده وإذا كان العرض لا يتضمن سوي قيام الحكومة بالمشروع ذي النفع العام، إذ هي لا تلتزم بتنفيذ هذا المشروع أن ارتأت في تقديرها ملائمة عدم تنفيذه، ولا يكون ذلك عندئذ خطأ تعاقدياً، وغاية الأمر أن التعهد يسقط لأنه بطبيعته معلق علي شرط هو القيام بالمشروع فإن تخلف هذا الشرط سقط التعهد تبعاً. أما إذا اشترط المتعهد في عرضه اشتراطات ثانوية وقامت الإدارة بتنفيذ المشروع ذاته، فإنها تلتزم بتنفيذ هذه

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة...، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٩.

(٢) انظر حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ ١٢/٢٦/١٩٥١، لسنة ٦٦. حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٣ لسنة ٢٣ ق، الصادر بتاريخ ١٥/٣/١٩٨٠. وكذلك حكمها في الطعن رقم ١٣٦٦ لسنة ٢٥، الصادر بتاريخ ٢٦/١٢/١٩٨١.

الاشتراطات فإن لم تنفذها كان ذلك خطأ تعاقدياً من جانبها، والثانية هي عقد إداري ويترتب علي ذلك أن العرض لا يسقط بوفاء المتعهد قبل قبول الإدارة، وعلة التشدد في العقد الإداري هو اتصاله بالمصلحة العامة، ويترتب علي هذه الخصيصة أيضاً انه يجوز للإدارة أن تتحلل من قبولها للعرض إذا قدرت بعد هذا القبول انه لا يتفق مع الصالح العام كما لو ظهر لها أن تنفيذ المشروع يكلفها نفقات طائلة أو انه عديم النفع أو لا يحقق الصالح العام علي خير الوجوه أو أن المشروع علي وجه آخر أوفي بهذا الغرض»^(١).

المطلب الثالث

عقد القرض العام

عقد القرض العام هو عقد بمقتضاه تقترض الدولة «أو شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام» مبلغاً مالياً من أحد أشخاص القانون الخاص فرداً كان أو بنكاً مقابل التعهد بأداء فائدة سنوية محددة، ويرد قيمة القرض وفقاً للشروط في نهاية الأجل المحدد. ومن الجدير بالذكر أن قروض الدولة في فرنسا هي من العقود التي تدخل المنازعات بشأنها في اختصاص القضاء الإداري بنص القانون، ومن ثم فإنها تعتبر إدارية بتحديد القانون. ولهذا فقد ذهب رأياً فقهيّاً إلى التمييز بين قروض الدولة وقروض غيرها من الأشخاص العامة، وقصر الصفة الإدارية علي الأولى دون الثانية. ولكن الفقه الحديث 2024/2025 2024/2025 يسوي في هذا الصدد بين النوعين، فيعتبر العقد في الحالتين إدارياً أو مدنياً وفقاً لطبيعته الذاتية^(٢).

وفي مصر نظراً لأن القرض العام يؤدي إلى تحمل الدولة بالتزامات مالية لآجال طويلة، وبشروط قد تكون مرهقة وفي غير صالح الدولة، تنص المادة ١٢٧ من دستور المعدل الصادر سنة ٢٠١٤ علي انه: «تنص المادة علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول علي تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٣٤٤٨ لسنة ٣١ ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٣/١/٣١.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة... مرجع سبق ذكره، ص ١٣٣.



الباب الثاني احكام ابرام العقد الاداري

تخضع السلطة الإدارية في إبرام عقودها الإدارية مجموعة من القيود لا يقابلها الأفراد في عقودهم الخاصة، ويرجع ذلك إلى سببين، أولهما أن الإدارة تهدف من وراء هذا التعاقد إلى تحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة فردية أو شخصية علي النحو الذي يبتغيه الأفراد في تعاقداتهم، وثانيهما أن الإدارة لا تتصرف في مال خاص ولكن تتصرف في مال عام يتمثل في حصيلة الخزنة العامة التي تمول عن طريق المواطنين من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعونها^(١).

وتنظم القوانين واللوائح التنفيذية في الدول المختلفة عملية إبرام العقد الإداري بدءاً من الموافقات التي تسبق التعاقد مثل الأذن المالي أو الموافقات السابقة.... الخ، مروراً بكيفية اختيار الإدارة لأسلوب التعاقد المناسب كالمناقصة أو المزايدة بأنواعها وغير ذلك من النظم التي قد ينص عليها القانون وانتهاءً بمرحلة التصديق علي العقد واعتماده من قبل السلطة المختصة بذلك ودخوله في حيز التنفيذ.

وبناء علي ذلك يجب علي الإدارة وهي بصدد إبرامها لعقودها أن تلتزم بالقيود التي فرضها المشرع في القوانين واللوائح المختلفة، وهي قيود عامة يترتب علي مخالفتها بطلان العقد الإداري. 2024/2025 2024/2025

وسوف نعرض فيما يلي بقدر من التفصيل الإجراءات التمهيدية السابقة علي التعاقد وأساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة وذلك في فصلين متتاليين علي النحو التالي:

الفصل الأول: الإجراءات التمهيدية السابقة علي التعاقد.

الفصل الثاني: أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة.

الفصل الأول

الإجراءات التمهيدية السابقة علي التعاقد

من المسلم به أن العقد الإداري كالعقد المدني يتكون بتوافق إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني معين، إلا أن عملية إبرام العقود الإدارية تتميز بالتعقيد بالنظر إلى نظيرتها في العقود المدنية. ويرجع هذا التعقيد أساساً إلى التعبير عن الإرادة، فإذا كان المتعاقد مع الإدارة يعبر عن إرادته بنفس الأسلوب الذي يتم به التعبير عنها في مجال العقود المدنية، فإن تعبير الإدارة عن إرادتها يأخذ شكل عملية معقدة مجزأة علي مراحل متعددة، فالتعاقد

(١) انظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، الدار المصرية الحديثة، ص ١١٩.



يكون مسبقاً بإجراءات تمهيدية سابقة واستشارات وموافقات يتطلبها القانون ومن ثم يجب علي الإدارة أن تراعي ذلك قبل إعلان رغبتها في التعاقد^(١).

وتتمثل أهم صور الموافقات السابقة علي إبرام العقد الإداري في ضرورة توافر الاعتمادات المالية، والحصول علي إذن بالتعاقد، صدور قرار من المجالس الإدارية قبل التعاقد والاستشارات السابقة، هذا بالإضافة الي تحديد الادارة لاحتياجاتها الفعلية، وهذا ما سوف نبينه في أربعة مباحث علي النحو التالي:

المبحث الأول: تحديد الاحتياجات الفعلية للإدارة المتعاقدة.

المبحث الثاني: الإذن المالي.

المبحث الثالث: الإذن بالتعاقد والاستشارات السابقة عليه.

المبحث الرابع: صدور قرار من المجالس الإدارية قبل التعاقد.

المبحث الأول

تحديد الاحتياجات الفعلية للإدارة المتعاقدة

تتمثل اولي الخطوات التمهيدية السابقة علي إبرام العقد الإداري ان تقوم الجهة الادارية الراغبة في التعاقد بتحديد احتياجاتها الفعلية والضرورية. والغرض الاساسي من تحديد الجهة الادارية لاحتياجاتها الفعلية قبل إبراء رغبتها في إبرام العقد هو الحفاظ علي موازنة الجهات الادارية وضمان استخدامها الاستخدام الامثل، فهو يمنع الجهة الادارية في الاندفاع في إبرام العديد من العقود الادارية عديمة النفع وبالتالي استنزاف المال العام^(٢). ولقد استحدث المشرع في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ انشاء إدارة للتعاقدات بالجهة الادارية أيا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، ويتم تشكيلها من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدرية، وتتولى تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها^(٣).

(١) يجب الإشارة إلى أن تعقد عملية التعاقد الناتجة عن تعبير الإرادة عن إرادتها لا يتعلق فقط بالعقود الإدارية: فالإجراءات والمراحل التي يتطلبها القانون بالنسبة للعقود الإدارية واجبة الإلتزام بالنسبة للعقود التي تبرمها الإدارة في إطار القانون المدني. راجع: د. سعاد الشرقاوي، العقود الادارية، دار النهضة العربية، ص ٢١٦.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار: الوجيز في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ص ١٢٦.

(٣) وفقاً للمادة ٣ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨. " تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات أيا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدرية، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية :

١. تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها .

ويجب على الجهات الادارية المتعاقدة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها، وكذلك مراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح، ويجب تضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها^(١).

وتضيف المادة ٩ من القانون المشار الية يجب على الجهة الإدارية وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية، تتضمن العمليات المتوقعة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة وذلك وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض، ويتم اعتمادها من السلطة المختصة دون غيرها، وتنتشر على بوابة التعاقدات العامة بغرض إعلام المتعاملين معها، ودون أن يترتب ذلك أي التزامات على الجهة الإدارية.

وعلى الجهة الإدارية تعديل خطة احتياجاتها في ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية، واعتماد هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها، ويجب نشر الخطة المعدلة على بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية. ويستثنى من النشر الحالات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي^{2024/2025} عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة. ^{2024/2025}

ومن الجدير ذكره انه وفقا للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب علي ادارة التعاقدات في اطار تخطيط الاحتياجات السنوية مراعاة ما يلي:

١. مخاطبة كافة القطاعات والادارات والوحدات وغيرها التابعة للجهة الادارية لحصر احتياجاتها المطلوبة للسنة المالية التالية وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض.

٢. متابعة تنفيذ العقود التي يتم إبرامها، وتلقي وإرسال الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه العقود المبرمة.

٣. التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وإعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير المطلوبة في شأن التعاقدات العمومية.

٤. القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

(١) راجع للمادة ٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

٢. التأكد من ان الاحتياجات المطلوبة فعلية وضرورية لسير العمل والانتاج بناء علي دراسات واقعية وموضوعية.

٣. اتخاذ واستيفاء ما يلزم من دراسات السوق وطلب المعلومات لتحديد احتياجاتها بكل دقة من حيث الكميات والمواصفات والاعتمادات المالية المطلوبة لها دون تزايد او مبالغة.

٤. مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف والقيام بتجميع الاحتياجات وتقسيمها الي مجموعات متجانسة.

٥. يحظر تضمين خطة الاحتياجات اصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تقي بالغرض، فلا يجوز لجهة الادارة المتعاقدة شراء الاصناف الجديدة الا بعد مراجعة المخازن بذات الجهة اولا لمعرفة مدي توافر اصناف مثيلة او بديلة تقي بالغرض . وفي حالة عدم توافر ذلك . تقوم بمراجعة الجهات الاخرى التابعة للوزارة او المحافظة . حسب الاحوال . بغرض استيفاء احتياجاتها مما قد يكون متوفرا لدي أي من تلك الجهات السابق الاشارة اليها^(١)، وفي حالة عدم توافر الاصناف المطلوبة لدي كافة الجهات التابعة للوزارة او المحافظة، تقوم الادارة المتعاقدة

بمراجعة الهيئة العامة للخدمات الحكومية للوقوف علي مدي توافر اصناف مثيلة او بديلة تقي بالغرض بقاعدة البيانات المسجل عليها بيان الاصناف الراكدة او المستغني عنها والواردة للهيئة من جهات الدولة المختلفة^(٢). ويستثنى من هذه الاجراءات . بعد عرض مبررات ذلك علي السلطة المختصة^(٣):

- الاصناف التخصصية التي ترتبط بطبيعة عمل جهة بذاتها ولا توجد لدي جهات اخرى.
- الاصناف غير القابلة للتخزين او التي ترتبط بمواعيد استخدام محدد «كالمواد غذائية . نتائج . اجندات....الخ.
- الاصناف المطلوبة بصفة طارئة ولازمة للتشغيل ولا تحتتمل التأخير كقطع غيار الآلات والاجهزة والسيارات...الخ.

(١) منشور رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤.

(٢) منشور رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥.

(٣) كتاب دوري رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٦.



٦. يجب علي إدارة التعاقدات الانتهاء من اعداد خطة احتياجات الجهة الادارية قبل تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية بوقت كاف ، وعرضها علي السلطة المختصة لاعتمادها، ويتم نشرها علي بوابة التعاقدات العامة، وتخطر وزارة المالية بخطة الاحتياجات المعتمدة لمناقشتها وإدراجها ضمن موازنة الجهة الادارية وذلك في الموعد المحدد لتقديم مشروع الموازنة.

ويرتبط بهذا الاجراء التمهيدي ما يقرره قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ من حق للجهة الادارية في تعديل العقد بزيادة او انقاص التزامات المتعاقد معها في المادة ٤٦ وذلك إذا طرأت مستجدات بعد إبرام العقد مما يوجب تعديل حجم التعاقد فيكون للجهة الإدارية تعديل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (١٥%) من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك .

ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاءه، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا 2024/2025 2024/2025

تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.

المبحث الثاني

الإذن المالي

لا تستطيع الإدارة أن تبرم عقوداً، وأن تصبح ملتزمة بالتزامات مالية إلا إذا كان هناك اعتماد مالي يغطي هذه الالتزامات، وهذه القاعدة هي محض تطبيق للمبدأ العام الذي يقضي بأن أي إنفاق عام يستوجب أن يكون له اعتماد مالي وتتقرر الاعتمادات المالية بواسطة البرلمان الذي يصدر قانوناً يربط الميزانية^(١). وبناء علي ذلك إذا أرادت الإدارة أن تبرم عقوداً إدارية - ترتب التزامات مالية - يجب أن تكون هناك اعتمادات مالية تسمح لها بإبرام هذه العقود.

ووفقاً للمادة ١١ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب على الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر

(١) راجع في ذلك: م. د.: عبد الفتاح صبري أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، رسالة، كلية الحقوق - جامعة طنطا، ص ١٥٨.

الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية . ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .

ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطوة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة . يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية، كما يخطر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة السلطة المختصة.

ويجب الإشارة إلى أن وجود الاعتمادات المالية التي تغطي الالتزامات المالية للإدارة تعتبر - في حد ذاتها - موافقة ضمنية من جانب البرلمان لان تبرم الإدارة العقود التي تراها ضرورية لسير المرفق العام، مع ملاحظة أن دور البرلمان يقتصر علي رصد الاعتمادات المالية فقط دون أن يمتد هذا الدور إلى إبرام العقد الإداري^(١).

وهو الأمر الذي تنص عليه المادة ٢٤ من قانون الموازنة العامة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ علي انه: « لا يجوز استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة مجلس الشعب وصدر القانون الخاص بذلك».

وعلي الرغم من الصلة الوثيقة بين القانون المالي والقانون الإداري، فان من المسلم به في كل من فرنسا ومصر أن القانون المالي مستقل عن القانون الإداري فكل منهما ذاتيته الخاصة ومجاله المستقل، ويترتب علي ذلك نتيجة هامة، وهي أن جزاء مخالفة القواعد المالية مقصور علي نطاق القانون المالي^(٢).

ويرتب القضاء الإداري علي الفصل بين مجالي كل من القانون المالي والقانون الإداري النتيجةين التاليتين:

الأولى: أن مخالفة الإدارة للقواعد الخاصة بالاعتماد المالي لا يترتب عليها بطلان العقد الإداري. ولذلك إذا أبرمت الإدارة عقدا ما رغم عدم وجود الاعتماد المالي المرصود له

(١) المرجع السابق، ص ١٥٨.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، ١٩٨٤، ص ٣٠١. وراجع أيضا في نفس المعني:

• V. A. DE LAUBADERE, Traité des contrats administratifs, op. cité, p.474.

أو إذا تجاوزت هذا الاعتماد، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان العقد بين الإدارة والمتعاقد معها^(١). وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في أكثر من مناسبة أن: « عدم وجود اعتمادات مالية لا يبرر امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها »^(٢).

والواقع أن هذه النتيجة القانونية تجد سبب تبريرها في أن المتعاقد مع الإدارة يصعب عليه - إن لم يكن من المستحيل - أن يتأكد من وجود أو عدم وجود اعتمادات مالية، وذلك لتعلق الأمر بأمر داخلي لدى الإدارة^(٣)، فليس في مقدور الفرد الذي يتعاقد مع الإدارة أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر اعتماد أو لم يصدر، وما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح وما إذا كان العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد أو ليس في حدود هذا الغرض، فكل أولئك يعد من الدقائق التي يتعذر على الفرد العادي بل الحريص التعرف عليها. ولو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة، وادي ذلك الي تعطيل سير المرافق العامة^(٤).

ويترتب - من الناحية العملية - علي تعاقد الإدارة بالرغم من عدم وجود اعتماد مالي أو تجاوزها للاعتماد أن المتعاقد مع الإدارة يتعين عليه الانتظار حتى يتم تدبير الاعتماد المالي اللازم بالطريق المرسوم قانوناً^(٥). وفي تلك الحالة يكون له الحق في طلب إعادة النظر في الاسعار التي تعاقد عليها، وذلك اذا ما تأخرت الادارة في الحصول علي التمويل المالي لمدة طويلة تغيرت خلالها اوضاعه^(٦). كذلك يمكن له تقرير المسؤولية 2024/2025 السياسية والقانونية للإدارة عن هذا الخطأ^(٧)، وبالتالي يستطيع الحصول علي تعويض في حالة اثبات تعرضة لأضرار مادية، وذلك تطبيقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. كما ان تعاقد

(١) انظر:

- G. JEZE, La théorie générale des contrats de l'administration, Paris, 1931, p. 15.

(٢) انظر علي سبيل المثال:

- C. E. 28 mars 1924, Jauron, Rec., p.356.
- C. E. 25 novembre 1931, Dame Baudoin, Rec., p.1029.

(٣) انظر: في هذا المعني: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الرابعة ١٩٨٤، ص ٣٠٢. م. د.: عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٩. د. جمال عثمان جبريل: العقود الإدارية، إبرام العقد الإداري وصحته وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية، الطبعة الثانية، ١٩٩٩، ص ٧٠. د. جابر جاد نصار: مرجع سابق، ص ٥٠.

(٤) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١١/٦/١٩٥٦، المجموعة، السنة الأولى، ص ٦٩٨.

(٥) انظر: م. د.: عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٩.

(٦) فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رقم ٥٤١، الصادرة بتاريخ ٨/٧/١٩٩٣، ملف رقم ٢٥٦/٢/٧٨.

(٧) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١١/٦/١٩٥٦، المجموعة، السنة الأولى، ص ٦٩٨.

الإدارة دون احترام القواعد الخاصة بتوافر الاعتماد المالي يمثل أيضاً خطأً عقدياً مما يثير أيضاً المسؤولية العقدية لها.

الثانية: توافر الاعتماد المالي اللازم لا يعني بأي حال التزام الإدارة بالتعاقد. فوجود الاعتماد المالي يمثل بالنسبة للإدارة التصريح لها بالتعاقد ولكنها ليست ملزمة بذلك^(١)، فليس للأفراد مطلقاً " بحجة وجود اعتمادات مالية طلب إلزام الجهة الإدارية بالتعاقد تحت أي وجه من الوجوه"^(٢). لأن الإدارة قد تجد في عدم التعاقد . بالرغم وجود هذا الاعتماد المخصص . يحقق المصلحة العامة^(٣).

المبحث الثاني

الإذن بالتعاقد والاستشارات السابقة عليه

الاذن بالتعاقد هو عبارة عن إجراء يفرضه القانون على الإدارة قبل إبرامها لعقودها، وهو غالباً يتعلق ببعض العقود التي لها أهمية والتي يترتب عليها اتفاق مبالغ مالية كبيرة من الموازنة العامة أو استغلال الموارد الطبيعية.

كما قد يقيد القانون الإدارة المتعاقدة باستشارة جهة معينة قبل إبرام العقد، والغرض من هذا القيد يختلف من حالة لأخرى فقد يكون لتحقيق اعتبارات فنية أو لتلافي المخاطر القانونية أو لتمكين الجهة الإدارية الرئاسية من ممارسة رقابة سابقة على التصرف.

2024/2025 ونتناول في هذا المبحث كلا من الإذن بالتعاقد والاستشارات السابقة عليه في 2024/2025

مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: الإذن بالتعاقد.

المطلب الثاني: الاستشارات السابقة على التعاقد.

المطلب الأول

الإذن بالتعاقد

قد يستلزم المشرع بالنسبة لبعض العقود ضرورة حصول جهة الإدارة المتعاقدة على تصريح أو إذن بالتعاقد من جهة يحددها. وفي هذه الحالة لا تستطيع الإدارة التعاقد بدون هذا الإذن أو التصريح.

(١) انظر: د. جمال جبريل ، مرجع سبق ذكره ، ص ٧٠ - م. د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٠.

(٢) انظر:

• C. E. 26 juillet 1946, Nalant Falndry, Rec., p. 211.

(٣) انظر: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠.



هذا ويعد الإذن بالتعاقد - علي عكس الإذن المالي - شرطاً من شروط صحة العقد، ولذلك فإن النتيجة التي تترتب علي تعاقد الإدارة دون الحصول علي الإذن الذي يشترطه القانون هي بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. وهو أمر مسلم به في الفقه والقضاء الفرنسي^(١). وهو ما يؤكد مجلس الدولة المصري، فقد قرر قسم الرأي في فتواه الصادرة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٥٤ والمتعلقة بضرورة موافقة البرلمان علي العقود التي تتضمن تبرعا من جانب الدولة إلى انه: «... فإذا كانت السلطة التشريعية وهي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية لم تعبر عن رأيها، فإن إرادة الدولة لا تكون حينئذ معيبة فحسب، وإنما تكون منعدمة إطلاقاً، إذ أن أفراد السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء بالتعبير عن إرادة الدولة في عقد التبرع، يعتبر منها طغياناً علي السلطة التشريعية بعدم إرادة الدولة. ومتي إنعدمت الإرادة التي تعتبر العنصر الأساسي في تكوين العقد كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا وجود له في نظر القانون، وإنما هو واقعة مادية بحتة، وبالتالي يسقط هذا العقد مع ما يترتب علي ذلك من آثار ...»^(٢).

وأيضاً في فتواه الصادرة في ١٨ مايو ١٩٥٠، أكد قسم الرأي أن عدم احترام الإدارة لنص المادة ١٣٧ من دستور ١٩٢٣ الذي يشترط إذناً سابقاً من البرلمان لاستغلال مورد من الموارد الطبيعية يجعل الترخيص باطلاً بطلاناً مطلقاً^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويترتب علي الانعدام القانوني للعقد الذي تبرمه الإدارة دون الحصول علي الإذن بالتعاقد عدم إمكانية المتعاقد مع الإدارة المطالبة بأية حقوق ناشئة عن هذا العقد، ولكنه في حالة تنفيذه للعقد وإصابته بضرر من جراء هذا التنفيذ أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية، وهذا التعويض يستند أساساً علي المسؤولية شبه الخطئية للإدارة باعتبار إنها أخطأت بعدم الحصول علي الإذن بالتعاقد^(٤).

وفي جميع الأحوال يمكن للمتعاقد مع الإدارة أن يرجع بالتعويض علي الإدارة مستنداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب، إذا استطاع أن يثبت استفادة الإدارة من جراء تنفيذه للعقد، أما إذا كان العكس أي أن المتعاقد مع الإدارة هو الذي استفاد من العقد المعدوم، فإن

(١) انظر: د. سلمان محمد الطماوي، الأسس العامة لعقود الإدارة، مرجع سبق ذكره، ص ٣٠٥.

(٢) الفتوى الصادرة في ٢٢/ ٩/ ١٩٥٤، مجموعة فتاوى المجلس، السنة الثامنة.

(٣) الفتوى الصادرة في ٥/ ١٩٥٠، رقم ١٦٢، مجموعة أبو شادي، ص ٨٦.

(٤) انظر: د. سعاد الشراوي، مرجع سبق ذكره، ص - ص ٢٢٦-٢٢٧، د. جمال جبريل، مرجع سبق ذكره، ص - ص ٧٣-٧٤.



آثار هذا العقد التي تمت في الماضي لا يمكن المساس بها تأسيسا علي حسن نية المتعاقد مع الإدارة وعدم مسؤوليته عن خطأ الدولة^(١).

ويثور التساؤل حول مدى التزام الإدارة بإبرام العقد في حالة حصولها علي الإذن السابق بالتعاقد؟.

لا يعتبر حصول الإدارة علي إذن سابق للتعاقد ملزما لها لإبرام العقد، فالإدارة تتمتع في هذه الحالة بسلطة تقديرية في إتمام العقد من عدمه وفق ما تراه محققا للمصلحة العامة. وبهذا المعني أفتي قسم الرأي . مجتمعا . في ٢٥ يناير ١٩٥٣ حيث يقول: «...ويري القسم مجتمعا أن عقد الترخيص بالبحث لا يتم إلا بعد صدور قبول من الوزير المختص للإيجاب الصادر من طالب الترخيص، وأن هذا القبول لا يكون إلا بناء علي الإذن من البرلمان في ذلك. والقانون الصادر من البرلمان متضمنا هذا الإذن، وإن كان شرطا لإبرام العقد، إلا انه غير ملزم للسلطة المختصة بالمنح، فيبقى لهذه السلطة دائما أن تترخص في تقدير ملائمة منح الترخيص من عدمه بما لها من حق الإشراف والرقابة علي حسن استغلال موارد الثروة الطبيعية في البلاد»^(٢).

ويأخذ الإذن بالتعاقد صوراً متعددة : فقد يصدر من البرلمان في صورة قانون، وقد يصدر بقرار جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري أو من جهة إدارية أخرى. 2024/2025 2024/2025 وبناء علي ما تقدم، ثمة عقود إدارية لا يجوز للإدارة أن تبرمها إلا بعد الحصول علي موافقة البرلمان، وثمة عقود أخرى تتطلب موافقة جهة إدارية أخرى. وهذا ما سنبينه:

أولاً: العقود التي يُشترط أن يأذن البرلمان للإدارة بإبرامها:

لا يمكن للسلطة المختصة إبرام بعض العقود الإدارية الهامة للدولة كتلك التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد أو تمس الأمن القومي أو التي يترتب عليها التزامات مالية تستمر لفترة طويلة من الزمن مثل القروض.... الخ، إلا بعد الحصول علي إذن من البرلمان أو صدور قانون بالموافقة علي إبرام هذا العقد. وتتمثل الفلسفة التي تبرر اعطاء هذه السلطة للبرلمان في الصفة التمثيلية للجهاز التشريعي فهو بحسب الاصل يكون منتخباً من الشعب ويعبر عن اغلبيته وبالتالي فهو اصلح الاجهزة القادرة علي مراقبة عمل الادارة فيما يخص تلك العقود الادارية الهامة.

(١) فتوى قسم الرأي بمجلس الدولة المصري الصادرة في ١٩٥٤/٩/٢٢ السابق الإشارة إليها.

(٢) فتوى قسم الرأي بمجلس الدولة المصري الصادرة في ١٩٥٣/١/٢٥، مجموعة سمير أبو شادي، ص ٩٦.

وتوجد أمثلة عديدة لهذه العقود في كل من فرنسا ومصر، وهو ما سنوضحه علي النحو التالي:

١. الوضع في فرنسا^(١):

من أمثلة هذه العقود في فرنسا ما يلي:

أ- **عقود القرض العام**، فالمادة ٨١ من القانون الصادر في ٣١ ديسمبر ١٩٢١ كانت تستلزم صدور قانون من البرلمان بالموافقة علي إبرامها^(٢). وقد أصبح الاختصاص التشريعي لعقود القرض العام ذو أساس دستوري حيث تنص المادة ٣٤ من الدستور الفرنسي علي أن: « القوانين المالية تحدد إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها »^(٣)، كما تنص المادة ١٥ من الأمر الصادر في ٢ يناير ١٩٥٩ في شأن القوانين المالية علي أن: « عقود القرض العام تبرم بناء علي الموافقة البرلمانية التي تصدر سنويا بالقوانين المالية ».

ب- **بعض عقود الامتياز**، إذا كان القانون الصادر في ١٦ أكتوبر ١٩١٩ بشأن استخدام الطاقة الهيدروجينية والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في ١٧ يونيو ١٩٣٧ والمرسوم ٥٩ لسنة ٦٠ الصادر في ٣ يناير ١٩٦٠ والقانون ٥٣١ لسنة ١٩٨٠ الصادر في ١٥ يولييه ١٩٨٠ يستلزم في مادته الثالثة علي « صدور قانون»^{2024/2025}

بالموافقة علي الامتياز في مشروعات الطاقة المتولدة عن سقوط المياه إذا تجاوزت مائة ألف كيلو وات سنويا «، ولكن المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٦٠ الصادر في ٣ يناير ١٩٥٩ عدل المادة الثالثة المشار إليها ونصت علي أن: « يصدر الامتياز بمرسوم من مجلس الدولة »، ومنذ صدور القانون ٥٣١ لسنة ٨٠ في ١٥ يوليو

(١) انظر : م. د. عبد فتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٢ وما بعدها.

(٢) انظر:

- En vertu de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1921, aucun emprunt de l'Etat ne peut être contracté sous quelque forme que ce soit, qu'en vertu d'une loi spéciale .

(٣) انظر:

- L'article 34 de la constitution française du 4 octobre 1958: dispose que: « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique».

١٩٨٠ نصت المادة ٣٥ منه علي خضوع المشروعات التي تتجاوز قدرتها ٤٥٠٠ كيلو وات لنظام عقود الامتياز.

ويري الفقيه جيز « JEZE » أن كافة عقود الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة القومية، تستلزم دائما موافقة البرلمان^(١)، وذلك نظرا للأهمية المالية لهذا النوع من المرافق^(٢). ولكن هذا الاتجاه العام لا يستند إلى نص قانوني محدد، ولذلك فإن تدخل المشرع يجب أن يقتصر علي حالة إنشاء مرفق عام جديد، إذ أن إنشاء المرافق العامة يستلزم صدور قانون، أو إذا كان من شأن الامتياز أن يمنح الملتزم احتكارا إذ يستلزم الاحتكار صدور قانون^(٣).

ج- العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية: تستلزم هذه العقود في بعض الحالات موافقة البرلمان بهدف حماية الملكية العامة. وبناء علي ذلك فإن التصرفات العقارية الوطنية لا يمكن إبرامها إلا بمقتضى قانون إذا كانت قيمة العقار تتجاوز مبلغ عشرة آلاف فرنك وذلك وفقا لقانون ١ يونيو ١٨٦٤، ثم ارتفعت القيمة إلى أن أصبحت مائة ألف فرنك بال القانون الصادر في ٨ أغسطس ١٩٤٧ ثم أصبحت مليون فرنك وفقا للقانون الصادر في ٨ أغسطس ١٩٥٠. ثم تعدل الوضع بمقتضى المرسوم الصادر في ٢٥ نوفمبر ١٩٥٧ المعدل بالمرسوم ٩٧٩ لسنة ٦٠/2024/2025 الصادر في ٩ سبتمبر ١٩٦٠ والمرسوم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٩ الصادر في فبراير ١٩٦٩ وأصبحت التصرفات العقارية للدومين الخاص تتم بقرار إداري يصدر من السلطة المختصة " قرار وزاري - مرسوم يصدر بناء علي تقرير من وزير المالية " وفقا لقيمة التصرف وذلك ما لم يكن هناك نص خاص في قانون أو لائحة يتعلق ببعض التصرفات.

د- التصرفات الخاصة بقطاع الغابات لا تتم إلا بناء علي قانون باستثناء المساحات التي تقل عن ١٥٠ هكتار.

(١) انظر:

• V. G.JEZE, La théorie générale des contrats de l'administration, Paris, 1931, p.31.

(٢) انظر : د. جمال جبريل، مرجع سبق ذكره، ص ٧٧.

(٣) انظر:

• C.E, 4 mars 1910 , Théron, S., T.3, 1911, p.17 .

هـ - فيما يتعلق بتأجير العقارات، وفقا للمرسوم رقم ١٣٧ لسنة ٦٩ الصادر في ٦ فبراير ١٩٦٩ لم تعد تحتاج إلى صدور قانون، بل يكفي موافقة حاكم الإقليم، ولكن إذا تجاوزت مدة الإيجار ١٨ سنة يلزم موافقة وزير المالية.

٢. الوضع في مصر:

يوجد في مصر العديد من العقود التي يُشترط صدور إذن من البرلمان لإبرامها. فقد جرت الدساتير المصرية المتعاقبة علي ضرورة توافر هذا الشرط بالنسبة لعقود القرض العام أو التزام المرافق العامة واستغلال موارد الثروة^(١)، أما الدستور الحالي المعدل في سنة ٢٠١٤ فالمادة ٣٢ تنص علي: " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح

(١) ففي دستور سنة ١٩٢٣ تنص المادة ١٣٧ علي أن: « لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة في سنة أو سنوات سابقة أو لاحقة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال 2024/2025 مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل احتكار لا يجوز إلا بقانون والي زمن محدود. ويشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك كل تصرف مجاني في أملاك الدولة ». وفي دستور سنة ١٩٥٦ نظمت هذه العقود المواد من ٩٦ - ٩٩. فتتص المادة ٩٦ منه علي أن: « لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانه الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة ». وتتص المادة ٩٧ منه علي أن: « يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر علي خزانه الدولة، وينظم حالات الاستثناء والسلطات التي تتولى تطبيقها ». وتتص المادة ٩٨ منه علي أن: « ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة وفي أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ». وأخيرا تنص المادة ٩٩ علي أنه: « لا يجوز منح الاحتكار إلا بقانون وإلى زمن محدد ». وفيما يتعلق بدستور سنة ١٩٦٤ فقد نص في المواد من ٧٢ - ٧٤ علي ذات الأحكام الواردة بالمواد من ٩٦ - ٩٨ من دستور سنة ١٩٥٦. وكذلك دستور سنة ١٩٧١ تبني ذات الاتجاه فنص في المادة ١٢١ علي أنه: « لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانه الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب ». ونص أيضا في مادته ١٢٣ علي أن: « يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ».

حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وكذلك تنص المادة ١٢٧ من نفس الدستور علي ان: " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

ويتضح من ذلك ان المشرع الدستوري المصري قد حرص علي حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب بل يشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلية فنص صراحة علي ان يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وبناء علي ذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تقدم علي إبرام العقود التي تمنح التزام المرافق العامة، استغلال موارد الثروة، عقود القرض وبعض عقود البيع إلا إذا توافرت الموافقة المسبقة من البرلمان، ويعتبر ذلك اجراءا غير مشروع يحتمه الدستور وشرطا اساسيا لنفاذ العمل 2024/2025

ونوعا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية علي أعمال السلطة التنفيذية^(١).

وتطبيقاً لذلك اوقف مجلس الدولة المصري تنفيذ قرار وزير البترول رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤ والمستند لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ ١٨ سبتمبر لسنة ٢٠٠٠، والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول الحق في التفاوض مع شركة غاز شرق البحر الابيض المتوسط من اجل بيع ٧ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل علي مدار ١٥ عاما قابلة للتجديد، وبأسعار رمزية لا تصل الي عُشر السعر العالمي السائد. هذا واضح من حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨ وفيه تقول: «...وبالنظر الي ان الثابت من استعراض قرار وزير لبترول رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤ المطعون فيه انه فوض كل من رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول في انتهاء اجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط، وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعي وموصفاته ومدة التوريد في عقود شركة شرق اتلبحر المتوسط للغاز

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣.



الطبيعي من خلال خط انابيب مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرياء اسرائيل.

« وطبقا لما ورد بهذا القرار فقد حدد مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٠٠ لكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول اسعار بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الابيض المتوسط واشترطات البيع وازامهما بالتعاقد مع الشركة المذكورة في حدود هذه الاسعار وهي خمسة وسبعون سنتا للوحدة الحراية من الغاز ولا تجاوز دولارا وربع الدولار وكذا اشتراطات التوريد ومدته التي بلغت خمسة عشر عاما قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات اخري. وهذا ما فوض وزير البترول كل من الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال احد اهم موارد الثروة الطبيعية في البلاد علي مجلس الشعب - حسبما ينص علي ذلك الدستور في المادة ١٢٣ سالفه الذكر، الامر الذي يعد افتئاتا علي اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستوريا في الموافقة علي منح الالتزام في الحالة المعروضة.

« ومتي كان ذلك فإن القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من تعاقد علي بيع

الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الابيض المتوسط بالاسعار المشار اليها ومدد التوريد الطويلة سالفه البيان يكون قد صدر معدوما لمخالفته احكام الدستور، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني.....»^(١).

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الدولة المصري حرص علي تطبيق هذا المبدأ بالرغم من سقوط دستور سنة ١٩٢٣ بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ وقبل صدور دستور سنة ١٩٥٦، فقد أكد علي مبدأ عدم التبرع بأموال الدولة إلا بموافقة السلطة التشريعية وهذا واضح في الفتوى الصادرة عن قسم الرأي في ٢٢ سبتمبر ١٩٥٤ حيث يقول: «.... ذلك أن سقوط دستور سنة ١٩٢٣ لا يعني سقوط المبادئ الدستورية العامة، ومن هذه المبادئ حق السلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية في التصرف في أموال الدولة واشتراكها في إبرام هذا التصرف إن كان تبرعا»^(٢).

(١) انظر: حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم ٣٣٤١٨ لسنة ٦٢ ق، الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٨.

(٢) الفتوى الصادرة في ٢٢/٩/١٩٥٤، مجموعة فتاوى المجلس، سنة ٨ ق، ص ٢٢٦، السابق الإشارة إليها.



وبذات المبدأ أفتى المجلس فيما يتعلق برقابة منح التزامات المرافق العامة، فقد جاء في فتوى قسم الرأي - مجتمعاً - والصادرة في ٢٨ نوفمبر ١٩٥٤ ما يلي: « باستقراء أحكام الدساتير المقارنة - لا سيما البلجيكي والفرنسي - يبين أن هناك عرفاً دستورياً مستقراً يقضي بقيام نوع من الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في خصوص منح التزامات المرافق العامة أو استغلال موارد الثروة الطبيعية غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة، بل يقتصر على المرافق القومية الرئيسية والموارد الطبيعية الهامة، » (١).

ثانياً: العقود التي يستلزم إبرامها موافقة جهة إدارية:

وفي هذه الحالة يشترط القانون ضرورة حصول الجهة الإدارية على موافقة جهة إدارية أعلى قبل إبرام العقد، ويهدف المشرع من هذا الأمر تحقيق الرقابة الذاتية لجهة الإدارة بحيث تستطيع الجهة الإدارية الأعلى مراقبة الجهات الأدنى منها حينما تلجأ الأخيرة لإبرام عقودها الإدارية (٢).

ومن أمثلة ذلك في فرنسا (٣)، عقود الدولة - التي تتم في بعض المجالات مثل التصرفات العقارية والمقايضات فإنها تستلزم موافقة ممثل الدولة « حاكم الإقليم » وذلك بناء على اقتراح مدير القطاع المالي إذا كانت القيمة تعادل مليون فرنك أو قرار من وزير إذا تجاوزت القيمة مليون فرنك حتى خمسة مليون فرنك أو بمرسوم يصدر بناء على تقرير 2024/2025 2024/2025 من وزير المالية إذا تجاوزت القيمة خمسة مليون فرنك (٤).

وفي مصر يلزم أيضاً لإبرام بعض العقود الإدارية الرجوع لسلطة إدارية أعلى، ويظهر هذا الوضع بوضوح فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطة المركزية بالهيئات اللامركزية الخاضعة لإشرافها ووصايتها ورقابتها (٥).

فوفقاً لقانون نظام الإدارة المحلية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ (المعدل) يتعين موافقة مجلس الوزراء على تصرف المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المركز أو المدينة بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من اجر

(١) الفتوى الصادرة في ٢٨/١١/١٩٥٤، برقم ٤٤٩، مجموعة فتاوى المجلس، سنة ٨، ص ٧.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣.

(٣) انظر: م. د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٦.

(٤) وذلك وفقاً للمرسوم رقم ١٧٦ لسنة ٦٩ الصادر في ٦ فبراير ١٩٦٩.

(٥) انظر فيما يتعلق بالرقابة الإدارية على الوحدات المحلية وبالأخص سلطة رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية عليها، د. أيمن محمد أبو حمزة، نظرات حول نظام الإدارة المحلية في التشريع المصري " نحو إدارة محلية فاعلة"، دار النهضة العربية، ص ص ١٤٥ - ١٥٩.

المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إذا زادت قيمته علي ٥٠٠٠٠ جنية، كما لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار علي ٣٠ سنة إلا بموافقة مجلس الوزراء أيضا^(١).

كما أوجبت المادتان ٤٢ ، ٥٠ من ذات القانون علي ضرورة موافقة رئيس مجلس الوزراء علي قيام المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة بالتصرف بالمجان في مال من أموال المركز أو المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، إذا كان هذا التصرف يزيد علي عشرين ألف جنية ويقل عن خمسين ألف جنية في السنة المالية الواحدة، كما أوجبت المادتان المشار إليهما موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان هذا التصرف في حدود عشرين ألف جنية في السنة المالية الواحدة.

كما أتاح قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة . في حدود الخطة والموازنة المعتمدة . أن يعقد قروضا للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط عدم مجاوزة حد المديونية ٤٠% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات. وفي حالة زيادة حد المديونية علي النسبة المشار إليها، أو في حالة الاقتراض من جهة أجنبية فإنه يجب الحصول علي موافقة سابقة من رئيس مجلس الوزراء^(٢).

المطلب الثاني

الاستشارات السابقة علي التعاقد

أحياناً قد يلزم المشرع السلطة الإدارية الراغبة في التعاقد أن تستشير جهة معينة قبل إبرام العقد. ويهدف المشرع من وراء هذه الاستشارات تحقيق اعتبارات متعددة: فقد يهدف لتحقيق اعتبارات فنية، كاستشارة جهة متخصصة في موضوع العقد، وقد يهدف إلى

(١) راجع: قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في المواد رقم: (١٤ - ٤٢ - ٥٠)، مع ملاحظة أن جميع هذه المواد كان قد تم استبدالها بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ (الجريدة الرسمية، العدد ٢٦، في ٢٥ يونيو ١٩٨١).

(٢) المادة ١٥ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، مستبدلة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ السابق الإشارة إليه.

تحقيق اعتبارات قانونية كاستشارة جهة متخصصة قادرة علي إحكام الصيغة القانونية للعقد، كما قد يهدف من وراءها إلى تحقيق الرقابة علي جهة الإدارة المتعاقدة... الخ^(١). هذا وبعد الأجراء الإداري الاستشاري شرطاً أساسياً لازماً لصحة التصرف أو العمل الإداري، بحيث يترتب علي عدم استيفاءه أو الالتزام به . إذا كان من النوع الإجمالي المفروض بموجب نص قانوني أو لائحي . أن يكون هذا التصرف مشوباً بالبطلان، وذلك وفقاً لما استقرت عليه كل من آراء الفقه وأحكام القضاء الإداريين^(٢). وعلي ذلك سوف نعرض لهذا القيد المفروض علي جهة الإدارة المتعاقدة في كل من فرنسا ومصر علي النحو التالي:

أولاً: الوضع في فرنسا^(٣):

نجد في فرنسا أن هناك طائفة من العقود تلتزم فيها الإدارة باستشارة جهة معينة قبل إبرام العقد وقد يصل الالتزام أحياناً بالتقيد بمضمون هذا الرأي.

١. **الاستشارات السابقة غير الملزمة:** وفي هذا النوع يلزم المشرع الإدارة المتعاقدة أن تطلب هذه الاستشارة دون أن تتقيد بمضمونها. ومن أمثلة ذلك في عقود امتياز المدينة، حيث يتعين لإبرامها استشارة لجنة بلدية المدينة ولكن ليس هناك نص قانوني أو لائحة يلزم الإدارة بالتقيد بمضمون هذا الرأي.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢. **الاستشارات الملزمة:** وهي التي تلتزم بها الإدارة ولا تستطيع أن تخالفها، وتستمد هذه الاستشارات قوتها من نص القانون في معظم الحالات، حيث يترتب المشرع عليها آثاراً قانونية مما يجعلها ملزمة لجهة الإدارة، ويتم ذلك في النظام القانوني الفرنسي بأمرين:

الأمر الأول: يترتب القانون أثراً ملزماً لهذا الرأي.

الأمر الثاني: عدم إمكانية إبرام العقد إذا صدر الرأي بعدم الموافقة.

ثانياً: الوضع في مصر:

ونجد أيضاً في مصر أن المشرع المصري . يسير علي نهج المشرع الفرنسي . فكثيراً ما يلزم السلطة الإدارية المتعاقدة استشارة جهة معينة قبل التعاقد . فوفقاً لأحكام المادة

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٢١.

(٢) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، المبادئ العامة للإجراءات الإدارية غير القضائية، دراسة مقارنة في

كل من التشريع والفقه والقضاء المصري وفي الدول الأجنبية، بدون دار نشر، ١٩٩٠، ص ١٥٢.

(٣) انظر: م. د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٢.

٥٨ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة من مصالح الدولة ان تبرم أو تقبل أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها علي خمسة آلاف جنية بغير استفتاء الإدارة المختصة^(١).

ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ١٣ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بأن : « يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:

١. الإشراف والرقابة علي أعمال ونشاط هذه المجالس.
٢. التصديق أو الاعتراض علي القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقرها اللائحة التنفيذية.
٣. الموافقة علي اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها «.

وقد فصلت المادة ٤٧ من اللائحة التنفيذية هذا النص بقولها: « للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة، وللمجلس الشعبي المحلي للمركز بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة في دائرته، وللمجلس الشعبي المحلي للمدينة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للأحياء، التصديق أو الاعتراض علي القرارات الصادرة من تلك المجالس في المجالات الآتية:

- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية في المشروعات المحلية.
- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها.
- قواعد بتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المختصة مع الجماهير.
- قواعد بتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.
- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
- اقتراح مشروع الخطة والموازنة.

ويجب علي المجلس الشعبي المحلي المختص إبلاغ قراراته - في المجالات المشار إليها - للمجلس الشعبي المحلي الأعلى خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ويتم

(١) يلاحظ أن هذا النص ورد في جميع القوانين الخاصة بمجلس الدولة بل أن هذا النص كان موجودا في القانون رقم ١ لسنة ١٩٣٢ الصادر بنظام " لجنة قضايا الحكومة ".

التصديق أو الاعتراض علي القرارات المشار إليها في مدي خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، وإذا مضت هذه المدة دون اعتراض اعتبر القرار نافذا. ويجب أن يكون القرار الصادر من المجلس الشعبي المختص بالاعتراض علي كل أو بعض القرارات الصادرة من المجالس المحلية الأخرى مسببا وأن يخطر به رئيس المجلس الشعبي المحلي الذي اصدر القرار المعترض عليه، وفي هذه الحالة يوقف القرار «.

المبحث الرابع

صدور قرار من المجالس الإدارية قبل التعاقد

تتمتع الهيئات الإدارية اللامركزية في فرنسا بالشخصية المعنوية، وتدار في فرنسا بواسطة مجلس منتخب وعضو تنفيذي مهمته تنفيذ قرارات المجلس المنتخب. ولذلك فإن المجلس المنتخب للإقليم هو الذي يقرر إبرام عقد معين لمصلحة الإقليم، ثم يتولى العضو التنفيذي (مندوب الجمهورية في الإقليم)^(١) الذي له الصلاحية في إبرام هذا العقد وتقتصر مهمته في تنفيذ قرارات المجلس المنتخب.

وعلي عكس ما هو مقرر في عقود الدولة التي يختص بإبرامها الوزير المختص أو من يفوضه، فإن العضو التنفيذي ملزم بإبرام العقد الذي يقرره المجلس المنتخب، كما انه لا يملك إبرام عقود سوى تلك التي يقررها المجلس المنتخب الذي له سلطة الإدارة، ومن بين 2024/2025 2024/2025 هذه السلطة الموافقة علي إبرام العقود التي تكون الوحدة المحلية في حاجة إليها، أما بالنسبة لبعض عقود الدولة التي تتطلب الإذن أو التصريح فيقتصر طلب الإذن علي هذه الحالات فقط التي يحددها المشرع دون ما عداها من العقود التي لا تتطلب هذا التصريح أو الإذن^(٢).

هذا وتعتبر موافقة المجلس المحلي المنتخب عنصرا أساسيا في إبرام العقد، لذلك يعتبر العقد المبرم دون موافقة المجلس المحلي المنتخب باطلا لا يرتب أي أثر^(٣)، لذلك لا

(١) كان يطلق علي مندوب الجمهورية في الإقليم " Le commissaire de la République " لقب المحافظ " Le préfet " و كان يمثل السلطة المركزية في الإقليم، ولكن بصدر قانون ٢ مارس لسنة ١٩٨٢ وكذلك مرسوم ١٠ مايو ١٩٨٢ الذين نصوا علي أن ممثل الجمهورية في الإقليم هو الممثل الوحيد للدولة داخل الإقليم.

• Voir, en ce qui concerne l'administration d'Etat dans la région; G. PEISER, Droit administratif, Dalloz, 11^{ed}, 1983, p.84.

(٢) راجع: م.د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص ١٧٣.

(٣) انظر:

• C.E, 11 mars 1927, Bureau, R., p.324.

يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يحتج عليها بوجود رابطة عقدية^(١)، ولكن يستطيع أن يرجع علي الإدارة بالتعويض بناء علي المسؤولية التقصيرية تأسيسا علي خطأ العضو التنفيذي في إبرام العقد دون موافقة المجلس المنتخب صاحب السلطة في تقرير الإبرام من عدمه أو تأسيسا المسؤولية شبة العقدية أو الإثراء بلا سبب إذا استطاع إثبات أن الإدارة قد أثرت أو استفادت بسبب إبرامها العقد^(٢).

وفي هذا الصدد أكد مجلس الدولة الفرنسي أن البطلان الذي يشوب العقد بسبب تخلف موافقة المجلس المنتخب لا تصححه الموافقة اللاحقة لسلطة الوصاية^(٣). إلا أن المجلس المنتخب يجوز له الموافقة اللاحقة علي العقد الذي أبرمه العضو التنفيذي دون موافقته وفي هذه الحالة فإن الموافقة اللاحقة كالإجازة السابقة يصحح البطلان^(٤).

ويثور التساؤل حول الآثار المترتبة علي صدور قرار التعاقد من المجلس المنتخب، ومدى التزام العضو التنفيذي به؟

يجب أن نشير إلى أن صدور قرار بالتعاقد من المجلس المنتخب يترتب عليه الآثار التالية:

أولاً: إن صدور هذا القرار لا يعني أن العقد قد أبرم، وبصورة أخرى طالما لم يقرم العضو التنفيذي بتنفيذ هذا القرار فليس هنالك عقد^(٥).

2024/2025

ثانياً: هذا القرار يلزم العضو التنفيذي بإبرام العقد وبهذا يختلف قرار المجلس الإداري بالتعاقد عن الإذن أو التصريح بالتعاقد. حيث أن الأذن أو التصريح لا يلزم المصريح له بل يعطيه فقط إمكانية التعاقد^(٦).

(١) انظر:

- C.E. 17 mai 1963, Commune de monein, p.305.
- C.E. 29 avril 1977, Société d'aménagement de Braydunes, p. 890.

(٢) راجع: د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص ١٧٥.

(٣) انظر:

- C.E. 12 octobre 1960, Centre Hospitalien régional de Nantes, R., p. 528.

(٤) انظر:

- C.E. 20 décembre 1963, Commune de Battigny, p.831.
- C.E. 9 octobre 1986, Pigalle, p. 481.

(٥) انظر:

- C.E. 22 janvier 1930, Vuitton, p. 81.

(٦) راجع: د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص ١٧٥- د. جمال جبريل، مرجع سبق ذكره، ص ٨٧.

ولكن قد يرفض العضو التنفيذي إبرام العقد، ففي هذه الحالة يستطيع ممثل الدولة . بمقتضى فكرة الحلول - إبرام العقد^(١). وليس للقضاء أية سلطة في إجبار العضو التنفيذي لإبرام العقد^(٢). كما انه ليس للشخص صاحب المصلحة أي حق في الرجوع علي الإدارة سوى المطالبة بالتعويض ان كان له محل.

ثالثاً: الالتزام الذي يقع علي عاتق العضو التنفيذي لا يعني فقط التزامه بإبرام العقد في حالة صدور قرار التعاقد من المجلس المنتخب، بل يعني أيضا ان يبرم العقد وفق الشروط التي وافق عليها المجلس الإداري المنتخب، ولكن المجلس المنتخب يستطيع أن يترك قدرا من الاختيار للعضو التنفيذي. فعلي سبيل المثال، حين يقرر المجلس البلدي الترخيص للعمدة في إبرام عقد امتياز مع شركة دون أن يحدد له شروط الامتياز، فإن العمدة له الحرية في تحديد هذه الشروط^(٣).

كذلك تتمتع الهيئات الإدارية اللامركزية في مصر بالشخصية المعنوية، ويمثلها عادة مجلسان: مجلس منتخب أو معين أو يجمع بين الصفتين، وعضو التنفيذ.

ففيما يتعلق باللامركزية الإقليمية أو نظام الإدارة المحلية فقد نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ (المعدل) في مادته الأولى علي أن: «وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.....ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية»^(٤).

ولقد بين المشرع في القانون السابق ذكره، اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات في المواد من ١٢ - ١٨، كما حددت المادتان ٤١ - ٤٢ من ذات القانون

(١) انظر: م. د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٥.

(٢) انظر:

• C.E. 20 décembre 1954, Pithais, R., p. 543.

(٣) انظر:

• C.E. 19 octobre 1973, Partis d'Mckermann, R., p. 5761.

(٤) تتكون أجهزة الإدارة المحلية وفقا لهذا القانون المشار إليه من سلطتين رئيسيتين: السلطة الأولى وتختص بالتقرير (أي اتخاذ القرارات) ويطلق عليها المجالس الشعبية المحلية، وتتكون من أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من بين المواطنين المحليين وتتمثل مهمتها في صنع السياسات العامة المحلية وإصدار الأوامر والقرارات واللوائح التي تنظم تنفيذ هذه السياسات، أما السلطة الثانية وهي سلطة التنفيذ يطلق عليها المجالس التنفيذية وتتولى مباشرة تنفيذ السياسات المحلية تحت إشراف ورقابة المجلس الشعبي المحلي.

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمراكز وبينت المادتان ٤٩ - ٥٠ من ذات القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمدن، وأخيراً فإن المادة ٦٨ أوضحت اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للقرى.

وفيما يتعلق بتمثيل الوحدات الإقليمية، فقد نص قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في مادته الثالثة علي أن: « يمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسة أمام القضاء و في مواجهة الغير ». وبناء علي هذا النص يكون رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو للمركز أو للمدينة أو للقرية أو للحي هو الممثل القانوني للوحدة المحلية. ولكن المشرع في هذا القانون قد أتى بنص مغاير لنص المادة الثالثة، فنجده في المادة الرابعة ينص علي أن: « يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها ». ومما لا شك فيه أن التمثيل المزدوج فيما يتعلق بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قد يثير الكثير من المشاكل في التطبيق^(١).

أما فيما يتعلق باللامركزية المصلحية فإن المشرع سلك ذات النهج السابق، فكل هيئة من الهيئات العامة وفقاً للقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ يتولى إدارتها جهتان:

➤ **مجلس الإدارة:** وهو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الهيئة وتصريف

أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من 2024/2025 2024/2025

القرارات لتحقيق الهدف الذي قامت من أجله طبقاً لأحكام القانون وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة^(٢).

➤ **رئيس مجلس الإدارة:** وهو سلطة التنفيذ، حيث يتولى إدارة الهيئة وتصريف

شئونها وفقاً لأحكام القانون وتحت رقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة. وهو الذي يمثل الهيئة العامة أمام القضاء وأمام الغير، كما انه المسئول عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة العامة^(٣).

ويتضح من العرض السابق انه في حال إبرام الهيئة الإدارية العامة لعقد من العقود، فان هذا العقد يمر بمرحلتين أساسيتين: الأولى مرحلة صدور قرار من مجلس الإدارة بإبرام العقد باعتباره العضو المختص بذلك، والثانية مرحلة توقيع رئيس المجلس للعقد باعتباره العضو التنفيذي لمجلس الإدارة.

(١) انظر : د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٧.

(٢) المادة ٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣.

(٣) انظر : د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٨.

الفصل الثاني

أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارة

يتمتع الأفراد في علاقاتهم الخاصة بالحرية الكاملة في التعاقد، فالقانون الخاص لا يفرض عليهم قيودا في اختيارهم لمن يتعاقدون معهم طالما كان ذلك في حدود النظام العام والآداب. وعلى العكس مما تقدم، فالسلطة الإدارية ليست لها الحرية الكاملة في اختيار المتعاقد معها، فالمشرع يضع العديد من القيود على الإدارة من هذه الناحية أكثر من الأفراد، ذلك لأن المشرع يريد أن يضمن اختيار أفضل المتعاقدين هذا من ناحية، ويهدف أيضا إلى ضمان الحيطة واستبعاد شبهة المحاباة وإيثار بعض المتعاقدين نتيجة للاعتبارات الشخصية التي تتجافى مع المصلحة العامة من ناحية أخرى^(١).

وتتعدد الوسائل التي تلتزم الإدارة بالتعاقد من خلالها، ففي فرنسا - وفقا للمادة ٨٣ من تقنين المقاولات العامة - تتنوع أساليب إبرام العقد الإداري بين المناقصة العامة، والممارسة العامة، والاتفاق المباشر^(٢).

أما في مصر وفقا لنص المادة ٧ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ : " يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون في الحالات وبالطرق

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١. يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| أ. الممارسة العامة. | ب. الممارسة المحدودة . |
| ج. المناقصة المحدودة . | د. المناقصة ذات المرحلتين . |
| هـ. المناقصة المحلية . | و. الاتفاق المباشر . |

(١) انظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٢.

(٢) راجع:

- L'article 83 du Code des marchés publics dispose que: « les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés».

٢. يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزيدة علنية عامة أو مزيدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات اجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

أ. المزيدة المحدودة . ب. المزيدة المحلية . ج. الاتفاق المباشر .

ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها بإتباع أي من طرق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطاري وفقا لحكم المادة (٦٥) من هذا القانون . ولا يجوز بأي حال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر . وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويلحظ أن القانون الحالي قد جعل كل من المناقصات العامة المزيدة العامة طريقان أساسيان للتعاقد مع الجهة الادارية ، فضلا عن ذلك فهناك طرق استثنائية للتعامل تتمثل في الممارسة العامة او المحدودة والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والاتفاق

2024/2025

2024/2025

المباشر والمزيدة المحدودة والمحلية^(١)

وبذلك أصبحت السمة الأساسية التي تنظم أسلوب اختيار المتعاقد مع الإدارة في مصر - كما هو الحال في فرنسا- هي حرية الجهة الإدارية في اختيار المتعاقد معها، فهي تملك اللجوء إلى أسلوب المناقصات العامة أو الممارسة العامة، كما أن لها في أحوال محددة اللجوء إلى أسلوب التعاقد المباشر وطرق أخرى^(٢).

وبناء على ما تقدم فإننا في نطاق هذا الفصل سنتناول بالشرح الأساليب المختلفة للتعاقد الإداري، وذلك في بحثين متتاليين علي النحو التالي:

المبحث الأول: أسلوب التعاقد عن طريق المناقصة العامة.

المبحث الثاني: أسلوب التعاقد عن غير طريق المناقصة العامة.

(١) انظر: د. عبد المنعم درويش، تعليق علي القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قانون تنظيم التعاقدات التي

تبرمها الجهات العامة، بحث غير منشور، ص ٥.

(٢) انظر: د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ٥.



١١٠

المبحث الأول

التعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة العامة

ندرس في هذا المبحث ثلاثة مطالب متتابعة علي النحو التالي:

المطلب الأول: تعريف المناقصة.

المطلب الثاني: أنواع المناقصات.

المطلب الثالث: التنظيم القانوني الإجرائي للمناقصة .

المطلب الأول

تعريف المناقصة

تعتمد فكرة التعاقد عن طريق المناقصة العامة علي إتاحة الفرصة لقيام منافسة حرة بين الراغبين في التعاقد، مما يتيح للإدارة اختيار صاحب أفضل عرض أو أفضل عطاء، سواء من الناحية المالية أو من الناحية الفنية^(١). وعلي ذلك تُعرف المناقصة بأنها مجموعة الإجراءات التي رسمها القانون بقصد الوصول إلى أفضل المتنافسين سعراً وشروطاً تمهيداً للتعاقد معه^(٢). أو بمعنى آخر مجموعة من الإجراءات تهدف الإدارة من ورائها إلى اختيار المتعاقد الذي يتقدم بأرخص الأسعار، فالمناقصة تهدف أساساً إلى تحقيق المصلحة المالية لجهة الإدارة^(٣).

2024/2025

2024/2025

وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٩ مايو سنة ١٩٥٩ انه: «... من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات العامة أو المحلية أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية التي تتمثل في إرساء المناقصة علي صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزنة علي أي اعتبار آخر، وكذا بمصلحته الفنية التي تبدو في اختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية وحسن السمعة.....»^(٤).

(١) انظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٣. د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٢٦٣.

وانظر أيضاً:

• V. Alain MOYRAND, L'essentiel sur le droit administratif, L'HERMES, 1^{ère} édition, 1993, tome 2, p57.

(٢) راجع في ذلك: أ. احمد منصور، المشكلات العملية في المناقصات والمزايدات، دون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، ص ١٩.

(٣) انظر: م. د. محمد كمال أبو العينين، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات، الكتاب الأول: إبرام العقد الإداري، ص ٢٦٩.

(٤) انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٢٨٨، لسنة ٢٠٠٤، الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٥/٩.



ولا تختلف إجراءات المناقصة العامة عن إجراءات المزايدة العامة إلا فيما يتعلق بكيفية تحديد قيمة العطاء، فبينما يتم التعاقد في المناقصة مع الشخص الذي يتقدم بأقل عطاء لتوريد المواد المطلوبة، أو القيام بالعملية المطروحة، نجد أن التعاقد يتم في المزايدة يتم مع الشخص الذي يقدم اعلي عطاء، ويكون ذلك عادةً في العقود التي تباع وتؤجر فيها الإدارة أملاكها^(١).

ويلاحظ انه إذا فرض المشرع علي الإدارة أن تتعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة، فيجب عليها احترام إرادة المشرع وإلا أعتبر هذا التعاقد باطلا. وهذا ما قرره محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٦ يناير سنة ١٩٥٧ حيث تقول: « أن التشريع المصري لا يحتوى نصوصاً عامة تبين في شكل منتظم شروط إبرام العقود الإدارية وإجراءاتها وأوضاعها، ولم يصدر بالنسبة لهذه العقود . فيما عدا عقد التزام المرافق العامة . سوى بعض قواعد وإجراءات خاصة بعقود التوريد تضمنتها لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في ٦ من يونيو سنة ١٩٤٨، ثم المرسوم بقانون لرقم ٥٨ لسنة ١٩٥٣ بتنظيم المناقصات الذي ألغي وحل محله القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ بتنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه علي عقود التوريد ومقاولات الأعمال أي عقود الأشغال ومقاولات النقل. ولا تلتزم الإدارة بإتباع نظام المناقصة أو المزايدة إلا بالنسبة لهذه العقود، وفي الأحوال التي توجب عليها ذلك هذه النصوص التشريعية. ولما كان موضوع النزاع، والخاص بتأجير محل الشاي والمربطات بحدائق القناطر الخيرية، ليس من العقود المنصوص عليها في القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ بتنظيم المناقصات والمزايدات فمن ثم فإنه لا يخضع بطريق اللزوم وفيما يتعلق بإبرامه أو إجراءاته إلي نصوص هذا القانون. فإذا أرادت الإدارة أن تتبع نظام المزايدة بالنسبة له، فإنها إنما تطبق المبادئ الأساسية التي تخضع لها المزايدة العامة من حيث استهدافها الوصول إلى أفضل العروض بشأن العقد المراد إبرامه، وهي الإعلان عن المزايدة عن المزايدة وحرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين ثم استهدافها بما في نصوص القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ من التزام نظام محدد بخصوص تشكيل لجان فتح المظاريف وفحص العطاءات علي ألا يكون من نتيجة إتباع هذه الأنظمة تقييد حرية الإدارة في إلغاء المزايدة إذا بدا لها عدم ملائمتها، وأن يكون

(١) ويلاحظ أن الاصطلاحان معاً " المزايدة والمناقصة " يغطيها في فرنسا اصطلاح واحد وهو « L'adjudication » ومعني هذا الاصطلاح لغويا الإرساء. راجع في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢١١.

لها حق الاعتراض علي تنفيذها طالما أن المزايدة تهدف إلى إتمام عقد يتعلق بخدمات تتصل بمرفق عام وتعاون علي تسييره، مما يستوجب ان يترك للإدارة سلطة تقديرية في إبرام العقد، حتى لا يفرض عليها التعاقد إذا تبين عدم ملائمة ذلك لظروف تتعلق بمصلحة المرافق العامة من الناحية الإدارية أو المالية»^(١).

المطلب الثاني

الأنواع المختلفة للمناقصات

في مصر يميز قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بين أربعة أنواع من المناقصات علي النحو التالي:

أولاً: المناقصة العامة:

تمثل المناقصة العامة القاعدة العامة التي يجب علي الإدارة أن تلجأ إليها عند اختيارها للمتعاقد معها، والمناقصة العامة مفتوحة لكل من يريد التقدم بعطاءه طالما توافرت فيه الشروط المعلن عنها، وتلتزم الإدارة باختيار أفضل المتقدمين إليها من الناحيتين المالية والفنية. والمناقصة العامة قد تكون داخلية فيقتصر الإعلان عنها داخل جمهورية مصر العربية فقط، وقد تكون خارجية يتم الإعلان عنها في مصر والخارج.

ثانياً: المناقصة المحدودة:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة^(٢) وفي احد الحالات الآتية^(٣):

١. العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم، سواء في مصر أو في الخارج .
٢. العمليات التي اتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق في شأنها، وبحيث يتم دعوة من تم تأهيلهم للاشتراك فيها .
٣. التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي .
٤. توفير المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالمحافظة على الحياة والصحة .

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في ١٦/١/١٩٥٧، السنة ١١ ق.

(٢) انظر المادة ٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

(٣) انظر المادة ٥٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٥. إذا كان الوقت أو التكلفة اللذان للترجى بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد .

٦. عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.

ثالثا: المناقصة المحلية:

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة بآء علي عرض إدارة التعاقدات^(١)، فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .

ويجوز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليوني جنيه على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي يقع نشاطها في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد، ويجوز في هذه الحالة فقط وبقرار من السلطة المختصة الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت في العملية محل الطرح مفاده الالتزام بالسير في الإجراءات، كما يجوز للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة وفقا

2024/2025

لما تضمن شروط الطرح^(٢) 2024/2025

وفي حالة عدم تقدم أي منها للمناقصة، يكون للجهة الإدارية حال إعادة الطرح توجيه الدعوة لهم ولغيرهم، ولا يتم في هذه الحالة الاستثناء من شرط التأمين المؤقت .

ويتعين على الجهات الإدارية قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعلام أصحاب تلك المشروعات بالمحافظة التي يتم بدائرتها التنفيذ لحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة.

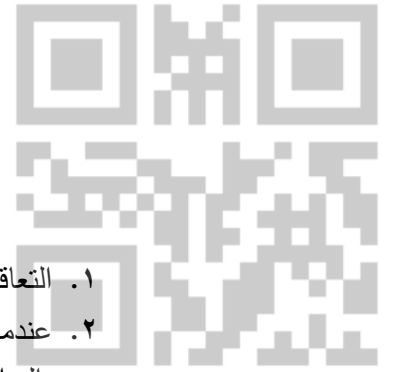
رابعا: المناقصات ذات المرحلتين:

يكون التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين بقرار مسبب من السلطة المختصة ببناء علي عرض إدارة التعاقدات^(٣)، ويجوز التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين بما يمكن الجهة الإدارية من تحديد الجوانب الفنية أو التعاقدية بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسية في أي من الحالات التالية^(٤):

(١) انظر المادة ٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

(٢) انظر المادة ٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

(٣) انظر المادة ٥٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .



١. التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة .
 ٢. عندما ترغب الجهة الإدارية أن تأخذ في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار في شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية .
 ٣. عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح .
- ويتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتين بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات في المرحلة الأولى الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية والميزات والمواصفات التي ترغب الجهة الإدارية في التعاقد عليها، والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ويطلب من مقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار، وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط العقد المقترحة، وأي شروط أخرى .
- المرحلة الأولى:** مخصصة لدخول الجهة الإدارية في مناقشات فنية مع أي من أصحاب العروض المستجيبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك للوصول إلى إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية مدققة تحقق احتياج الجهة الإدارية للوصول إلى أكبر قدر من المنافسة، ويخطر مقدمو العروض 2024/2025
- بنتيجة المرحلة الأولى .

في المرحلة الثانية: تخطر الجهة الإدارية مقدمي العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم، متضمنة العرض الفني والعرض المالي وفقاً للشروط والمواصفات المدققة.

وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسري على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناقصة بحسب الأحوال. ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك.

المطلب الثالث

التنظيم القانوني الإجرائي للمناقصة

يمر تعاقد الإدارة عن طريق المناقصات - أيًا كان نوعها^(١) - بعدد من المراحل هي: التقدم إلى المناقصة، وقيام الإدارة بفحص العطاءات وإرساء المناقصة وإبرام العقد.

(١) وفقاً للمادة ٦٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ : " تسري على كل من المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والممارسة بنوعها، الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية".



وسوف نتناول هذه المراحل في ثلاثة فروع علي النحو التالي:
الفرع الأول: التقدم إلى المناقصات العامة.
الفرع الثاني: فحص العطاءات وتشكيل اللجان وإرساء المناقصة.
الفرع الثالث: إبرام العقد.

الفرع الأول

التقدم إلى المناقصة العامة

تخضع المناقصات بصفة عامة لعدة مبادئ هي: العلانية والمساواة بين المتنافسين وحرية المنافسة وهو ما نص عليه المشرع في المادة السادسة من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ حيث يقرر: «تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص».

وسوف نتناول في هذا المطلب الإعلان عن المناقصة، المساواة بين المتنافسين ثم كيفية التقدم للعطاءات أي القواعد التي تحكم المناقصة العامة. وذلك علي النحو التالي:

الفصل الأول: الإعلان عن المناقصة.

2024/2025
2024/2025
الفصل الثاني: مبدأ المساواة بين المتنافسين.

2024/2025
الفصل الثالث: الاحكام العامة لتقديم العطاءات.

الفصل الأول

الإعلان عن المناقصة

يعتبر الإعلان عن المناقصة إجراءً أساسياً وجوهرياً بالنسبة لنظام المناقصات العامة^(١). تسمى مرحلة النشر والإعلان للمناقصة بمرحلة « طرح العطاء »، وهي إحدى المراحل الأساسية للمناقصة التي تهدف إلى ضمان علم الجميع بها لكي يتمكن اكبر عدد من المتنافسين من التقدم إليها، مما يؤدي إلى تحقيق المساواة بينهم ويؤدي بالتالي إلى اختيار الإدارة لأحسن المتنافسين وأفضل الأسعار وأنسبها لتحقيق المصلحة العامة. ونظراً لأهمية الإعلان عن المناقصة العامة، فإن التشريعات التي تنظمها دائماً ما تحرص علي النص عليه صراحة. ففي فرنسا استوجب المشرع في المادة ٨٤ من تقنين

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة - دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والقانون النموذجي للأمم المتحدة « اليونسترال»، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ٢٠٠٢، ص ٤٢.

العقود العامة بالنسبة لعقود الدولة وفي المادة ٢٨٠ من ذات التقنين بالنسبة لعقود المحليات أن يتم الإعلان عن المناقصات العامة^(١).

وفي مصر أكدت علي مبدأ الإعلان المادة ٦ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ حيث تقرر: « تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص ».

وتوجد بعض النقاط المتعلقة بالإعلان عن المناقصة العامة مثل ماهية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان « موضوع الإعلان »، كيفية الإعلان، مدي إلزامه لجهة الإدارة، والأثر المترتب علي مخالفة شروط وإجراءات الإعلان. وهي ما سوف نتناوله تباعاً:

أولاً: موضوع الإعلان:

يجب أن يتضمن الإعلان موضوع المناقصة والأجزاء الرئيسية المكونة للعقد المزمع إبرامه^(٢). ذلك لان هذا الإعلان السابق عن المناقصة هدفه تمكين المخاطبين بإجراءات المناقصة من العلم بجميع البيانات اللازمة التي تمكنهم من الإلمام بكل تفاصيل وجزئيات التعاقد المزمع إبرامه مع الإدارة.

وينظم القانون الفرنسي بيانات الإعلان بمقتضى القرار الوزاري الذي أصدره وزير 2024/2025

الاقتصاد في ٢١ يناير ١٩٧٦، والذي قرر - تسهيلاً لقراءة الإعلان - أن يتم تنظيم الإعلان وفقاً لنموذج معين. ووفقاً لهذا القرار يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية علي الأقل^(٣):

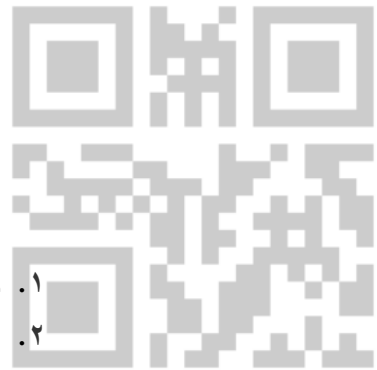
(١) انظر:

- **Art. 84:** « Les marchés par adjudication comportent obligatoirement, la publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ».
- **Art. 280:** « Les marchés par adjudication comportent obligatoirement, 1. La publicité de l'ouverture des soumissions et l'attribution. »

(٢) انظر: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٢.

(٣) انظر:

- **Art. 86- 283:** " Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêt du Ministre chargé de l'économie et des finances et des Ministres intéressés, fait connaître au moins :
1) L'objet du marché.
2) Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation ou bien les modalités d'obtention de ces documents.



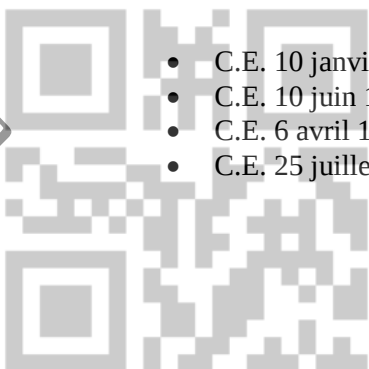
١. موضوع العقد مع الاشتراطات الضرورية.
 ٢. المكان الذي تُسحب منه العطاءات وكراسات الشروط وطريقة الحصول عليها.
 ٣. تاريخ إرسال الإعلان للنشر عنة في الجريدة الرسمية.
 ٤. التاريخ والمكان المحدد لاستلام العطاءات.
 ٥. المكان واليوم والساعة المحددة للبت في المناقصة.
 ٦. المستندات اللازم إرفاقها بالعطاءات.
 ٧. مدة ارتباط أصحاب العطاءات بعطاءاتهم.
- هذا ويترتب علي إغفال أياً من البيانات السابقة بالإعلان المنشور عن المناقصة، تقرير بطلانها وإلغاء التعاقد الذي تم في ظلها، ومبرر ذلك أن تلك البيانات تمثل الحد الأدنى من المعلومات المتعين إلمام المتناقصين به باعتباره مصدر الالتزام الملقي علي عاتقهم عند الإرساء للمناقصة، والذي يتم وفقاً له وفي ضوءه تقديم عطاءاتهم^(١).
- والي جانب تلك البيانات الإلزامية، يوجد بعض البيانات الاختيارية، والتي يمكن لجهة الإدارة أن تتحلل من الالتزام بالإعلان عنها، ومن ثم فإنه لا يترتب علي إغفالها أو عدم علم أحد المتناقصين لها البطلان، ويعد من قبيل هذه البيانات، تلك الخاصة بتحديد السلطة المختصة بإدارة المناقصة^(٢).
- 2024/2025 2024/2025
- أما القانون المصري، فتوجب المادة ١٧ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على إدارة التعاقدات أن تعد مذكرة أو أكثر للعرض

- 3) La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel.
- 4) Le lieu et la date limite de réception des soumissions.
- 5) Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.
- 6) Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
- 7) Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.

(١) انظر: د: السلال سعيد جمعة الهويدي، أسلوب المناقصة في إبرام العقود الإدارية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في الأنظمة الإدارية لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأجنبية، رسالة، جامعة طنطا - كلية الحقوق، ص ٩٣.

(٢) انظر نصوص المواد أرقام: ٨٦ و ٢٨٣ و ٢٨٩ من تقنين العقود العامة الفرنسي. وانظر أيضاً الأحكام القضائية التالية:

- C.E. 10 janvier 1930, Le Cordonner et peton, rec., p. 44.
- C.E. 10 juin 1931, Bigot, rec., p. 275.
- C.E. 6 avril 1935, Marchesini et Simon Giovanni, rec., p. 460.
- C.E. 25 juillet 1939, Gautron, rec., p. 529.



على السلطة المختصة للموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات، ويجب أن تتضمن هذه المذكرة على وجه الخصوص بيان محل الطرح وطريقة التعاقد ومدة سريان العطاءات، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد اوضحت اللائحة التنفيذية في المادة ٤٠ البيانات التي يجب ان يتضمنها الاعلان او الدعوة، وهي:

١. اسم الجهة الادارية الطارحة، وعنوان ادارة التعاقدات بها ورقم التليفون والبريد الالكتروني للادارة.

٢. اسم العملية ورقمها وطريق التعاقد.

٣. وصف موجز وواضح لموضوع التعاقد.

٤. مكان ومواعيد الحصول علي كراسة لشروط وثمنها والاشارة الي امكانية الاطلاع علي بيانات العملية ومستندات الطرح الخاصة بها علي بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

٥. موعد ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات - ان وجدت - وجلسة فتح المظاريف او الممارسة او جلسة المزايدة بحسب الاحوال.

2024/2025

٦. مبلغ التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائي.

2024/2025

ويتعين علي ادارة التعاقدات اذا تقرر طرح اكثر من عملية في تاريخ واحد او تواريخ متقاربة فيراعي الاعلان عنها في اعلان واحد.

ثانياً: كيفية الإعلان عن المناقصة:

يجب أن يتم الإعلان بكيفية معينة ينظمها القانون، الذي يحدد مكان النشر، وعدد مراته، واللغة التي ينشر بها، وميعاده. وقد اهتم قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بكيفية الإعلان عن المناقصات العامة الداخلية والخارجية^(١) وذلك علي النحو التالي:

- كأصل عام يجب نشر جميع العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذا القانون على بوابة التعاقدات العامة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقاً لما تقدره السلطة المختصة، على أن يتضمن النشر طريق التعاقد

(١) راجع المادة ٢٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



- وشروطه والأسباب المبررة لإتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- في حالة التعاقد عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة الداخلية أو المزايدة العلنية العامة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة، فيجب الإعلان مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار .
- يكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وإحدى الصحف الدولية وبالإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات .
- وفي حالة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح .
- وفي حالة إذا ما قررت الجهة الإدارية تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة، فيجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بالطريقة ذاتها .
- وفي جميع حالات الإعلان أو الدعوة للتعاقد المنصوص عليها في هذا القانون يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجوز بموافقتها الإعلان في أكثر من صحيفة مطبوعة أو دولية وفقاً لأهمية وطبيعة العقد في الحالات التي تقتضي ذلك.

2024/2025

ثالثاً: جزاء مخالفة القواعد المتعلقة بالإعلان:

- مما لا شك فيه أن الشروط التي تطلبها المشرع في الإعلان عن المناقصة ملزمة لجهة الإدارة، ومن ثم يتعين عليها احترام القواعد المتعلقة بالإعلان من حيث المدد، كيفية إجرائه، وعدد مراته... الخ، وإلا ترتب على ذلك بطلان المناقصة^(١).
- ويسير مجلس الدولة الفرنسي على هذا الأمر، ففي قضية « Helbing »^(٢)، حكم ببطلان المزاد نظراً لأنه لم يتم الإعلان عنه بالطريقة التي نص عليها القانون، وهي اللصق على اللوحات المعدة لذلك. ونفس الحكم إذا لم تحترم الإدارة المدة المقررة للإعلان^(٣). أو لم تسلم لأحد المتنافسين الشروط الكاملة للمناقصة^(٤).

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٩.
(٢) انظر:

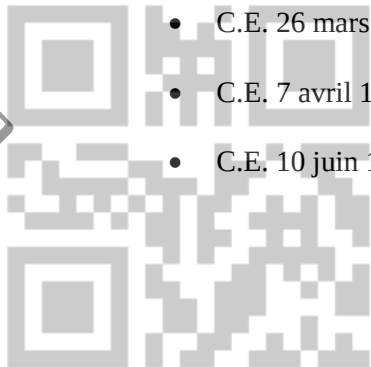
• C.E. 26 mars 1931, Helbing, Rec., p. 377.

(٣) انظر:

• C.E. 7 avril 1922, Imprimerie commerciale, Rec., p.249.

(٤) انظر:

• C.E. 10 juin 1932, Bigot, Rec., p. 572.



ويجب الإشارة إلى أن القضاء الإداري الفرنسي يميز في هذا المجال بين الأشكال الجوهرية ويرتب عليها البطلان والشكليات غير الجوهرية ولا يرتب عليها البطلان. ومن أمثلة الشكليات غير الجوهرية، حكم مجلس الدولة في قضية « **Gantron** » الذي فيه أغفلت الإدارة تضمين الإعلان السلطة المختصة بإجراء المزايدة^(١). وكذلك حكمه في قضية « **Com de Beausoleil** » عندما قرر أن حدوث أخطاء مادية في الأرقام يكتشفها أصحاب الشأن بسهولة يعد من الأشكال غير الجوهرية التي لا يترتب عليها البطلان^(٢).

وعلى نفس هذه المبادئ يسير القضاء الإداري المصري، فقد قررت لجنة الفتوى بمجلس الدولة في فتاها الصادرة بتاريخ ٣١ يناير ١٩٨٨ إلى أن: « أن المشرع قد أوجب في اللائحة التنفيذية للقانون (رقم ٩ سنة ١٩٨٣) نشر الإعلان عنها بالوقائع المصرية محددًا به الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها.....، ويلزم أن يمنح الراغبون في التقدم إلى هذه المناقصة مهلة كافية علي الأقل تبدأ من تاريخ أول إعلان عنها في الوقائع الرسمية ويجوز تقصيرها إلى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً إذا دعت الضرورة إلى ذلك.....ولذلك اشترط المشرع الإعلان عنها بالنشر مرتين في جريدة أو جريدين عربيتين واسعتي الانتشار، متضمنًا ذات البيانات السابقة إلا إذا كانت قيمة المناقصة تزيد عن خمسين ألف جنيه فينشر عنها ثلاث مرات^{2024/2025} وجددير بالتتويه في هذا الصدد أن بعض^{2024/2025} إجراءات وضوابط النشر السالف ذكرها - للإعلان عن المناقصة العامة تعد من الشكليات الجوهرية المقررة لصالح الإدارة والأفراد معا قصد منها كفالة احترام المبادئ الأساسية التي تخضع لها المناقصة العامة وهي العلانية والمساواة وحرية المنافسة بين المتنافسين للوصول إلى انسب العروض والأسعار - وبحيث يترتب علي إغفال جهة الإدارة لهذه الشكليات الجوهرية بطلان الإعلان بدون حاجة إلى نص صريح يقضي بذلك منها قيام الإدارة بتحديد مهلة كافية لتقديم العطاءات قدرها ثلاثون يوماً علي الأقل من تاريخ أول إعلان عن المناقصة بالوقائع المصرية.... ومن ثم يترتب علي إغفال الإدارة لميعاد المهلة المحدد لتقديم العطاءات أو قيامها بتقصير هذا الميعاد في غير حالة الضرورة بطلان الإعلان لمخالفته أحد الشروط الجوهرية المقررة لصحته.....كما إن إهمال جهة الإدارة النشر عن

(١) انظر:

• C. E. 25 juillet 1939, Gantron, Rec., p. 529.

(٢) انظر:

• C.E., 18 janvier 1929, Com de Beausoleil, Rec., p.42.



المناقصة العامة في الجرائد اليومية الواسعة الانتشار وإغفالها لعدد مرات النشر المذكور يؤدي إلى حرمان عدد غير محدد من الأشخاص من الاشتراك في المناقصة العامة... وترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت في الحالة المعروضة أن مديرية الإسكان بمطروح قامت بالإعلان عن مناقصة عامة تزيد قيمتها علي خمسين ألف جنية لنشاء وحدات سكنية بدائرة المحافظة و ذلك بالنشر عنها في الوقائع المصرية لأول مرة بتاريخ ٢٥ يونيو ١٩٨٧ وحددت في الإعلان مواعيد تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ المذكور لجلسات فض مظاريف العطاءات اعتباراً من ١١ يوليو ١٩٨٧ إلى ١٨ يوليو ١٩٨٧ قرين كل نموذج للوحدات السكنية موضوع المناقصة في حين أن المهلة القانونية المحددة لتقديم العطاءات يجب ألا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ أو إعلان بالوقائع المصرية ولم تتوافر حالة الضرورة التي تجيز تقصير هذه المهلة بالشروط المقررة لذلك. كما قامت المديرية بالنشر مرتين فقط عن المناقصة المذكورة في ثلاث صحف يومية علي الرغم من أن قيمتها تزيد علي خمسين ألف جنية، وكان يتعين أن ينشر عنها ثلاث مرات، ومن ثم تكون المديرية قد خالفت إجراءات جوهريين من إجراءات النشر يترتب علي عدم الالتزام بهما بطلان الإعلان عن المناقصة المذكورة»^(١).

ومما لا شك فيه أن ما ذهب إليه قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري يعد تطبيقاً 2024/2025 2024/2025
لما يسير عليه القضاء الإداري الفرنسي والمصري من انه لا يحكم بالبطلان - وإن نص القانون علي ذلك صراحة- إذا ثبت أن الغاية من الأجراء قد تحققت.

رابعاً: مدي إلزامية الإعلان لجهة الإدارة:

يمثل الإعلان عن المناقصة العامة بمثابة دعوة للتعاقد توجهها الإدارة للراغبين في التعاقد معها وذلك لكي يقدموا عطاء اتهم المطابقة للشروط الواردة في الإعلان خلال اجل محدد، ومن ثم فهو لا يمثل إيجاباً تتقدم به الإدارة إلى المتعاقد معها^(٢) وبالتالي لا يوجد أي التزام علي الإدارة لإبرام العقد.

وعلي ذلك استقر القضاء الإداري المصري، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢ ديسمبر ١٩٦٧ إلى أن: « إعلان الإدارة عن إجراء مناقصة أو مزايمة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها ليس هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينتقد

(١) انظر: الفتوى رقم ١٢٢، الصادرة بتاريخ ١/٣١/١٩٨٨، وكذلك الفتوى الصادرة بجلسة ١١/٩/١٩٨٩.

(٢) انظر: م. د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٣.

العقد»^(١). وإلى ذلك أيضا ذهبت محكمة النقض المصرية، ففي حكمها الصادر في ٢٨ مارس سنة ١٩٦٦ قررت: « أن طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد مادة علي أساس الشروط الواردة في قائمة الاشتراطات لا يعتبر قانونا إيجابا منها، وإنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد، أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه »^(٢).

الفصل الثاني

المساواة بين المتنافسين

تقوم فكرة المساواة بين المتنافسين علي أساس مبدأ حرية المنافسة الذي يلزم الإدارة بأن تعامل المتقدمين للمنافسة علي قدم المساواة^(٣). ولذلك إذا فضلت الإدارة أحد المتنافسين علي حساب الآخرين فان ذلك يؤدي إلى بطلان إجراءات المنافسة، إلا إذا كان هذا التفضيل مستندا علي أساس قانوني^(٤).

ولأهمية مبدأ حرية المنافسة في إجراءات المناقصات العامة، حرصت القوانين المنظمة لعمليات المناقصات والمزايدات علي النص عليه صراحة. ففي مصر، وفقاً للمادة ٦ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب أن: « تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص »^(٥) وفي فرنسا تقرر هذا المبدأ المادة ٨٥ من 2024/2025 تقنين العقود العامة، وذلك بالنسبة لعقود الدولة حيث تقرر أحقية كل صاحب عطاء في التقدم بعطائه، وكذلك المادة ٢٨١ من ذات التقنين بالنسبة لعقود المحليات.

إلا أن مبدأ حرية المنافسة ترد عليه العديد من الضوابط والقيود والتي يمكن أن تؤدي إلى حرمان أحد الأشخاص أو المشروعات من الدخول إلى المنافسة العامة، وهذا الحرمان قد يكون حرماناً وقائياً وقد يكون حرماناً جزائياً، وهو ما سنوضحه علي الوضع التالي:

أولاً: الحرمان الوقائي:

نظراً لارتباط العقود الإدارية بالمصلحة العامة، فإن ذلك يحتم علي الإدارة أن تتأكد مقدماً من صلاحية المتنافسين والمزايدين الراغبين في التعاقد معها، ولها أن تستبعد من لا

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٣٣٣، لسنة ١٠ق، الصادر بتاريخ ١٢/٢/١٩٦٧، المجموعة ص ١٦٦.

(٢) نقض مدني، صادر في ١٩٦٦/٣/٢٨، مجموعة أحكام النقض، سنة ١٧ق، رقم ٩٩ - ص ٧٣٠.

(٣) انظر: د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٩.

(٤) انظر: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سبق ذكره، ص ١٤.

يصلح منهم. وهو ما يطلق عليه «الحرمان الوقائي» وفيه تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري، بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، بحرمان المتناقص أو المزايد من التقدم إلى المناقصة أو المزايدة العامة. وهذا الحرمان الوقائي إما أن يكون منصوصا عليه في القانون، أو أن يكون صادرا عن الإدارة لاعتبارات تقدرها تحقيقا للمصلحة العامة.

١. الحرمان الوقائي بنص القانون:

قد يمنع القانون أشخاصا محددين بصفتهن من دخول المناقصات العامة، وذلك لتعارض تلك الصفة مع المصلحة العامة، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يكون لهم تأثير أو نفوذ في عملية إبرام العقد.

ففي فرنسا تحظر المادة ١٧٥ من قانون العقوبات علي الموظف العام الحصول علي منفعة مادية أو معنوية من المزايدات أو المناقصات التي تحدث في نطاق اختصاصهم.

كما تحظر المادة ٨ من المرسوم الصادر في ٤ فبراير ١٩٥٩ (الأمر رقم ٢٤٤ لسنة ٥٩) علي الموظف العام بالذات أو بالواسطة الدخول في مناقصات أو مزايدات في دائرة اختصاصهم.

وفي مصر، تنص المادة ٢٦ من قانون تنظيم التعاقدات المبرمة بين الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي انه: « مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي والمهني، يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال .

ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف، وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة».

كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة».

ويعتبر الحظر الذي يمنع الموظفين من الدخول في المناقصات والمزايدات العامة حظراً مؤقتاً، إذ أنه يزول بزوال سببه وهو انتهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك^(١).

كما أن المادة ٩٢ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ تنص علي انه: « يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص».

وعلي ذلك فالأصل العام هو حظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين العضو المنتخب في المجلس الشعبي المحلي وبين الوحدة المحلية. إلا أنه استثناء من هذا الأصل، يصرح المشرع العضو المجلس الشعبي المحلي أن يبرم هذا التعاقد إذا توافرت شروط معينة هي:

أ. توافر حالة الضرورة أو وجود مصلحة مؤكدة للوحدة المحلية.

ب. موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص علي هذا

2024/2025

2024/2025

التعاقد.

2024/2025

كذلك تنص المادة ١٠٩ من الدستور المصري المعدل سنة ٢٠١٤ علي انه: « لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاوله، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزنة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون». ويسري هذا الحظر أيضاً بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى، وذلك وفقاً للمادة ٢٥٤ من الدستور، والتي تقضي بأن: "سرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١ (فقرة ١، ٢)، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٧. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩.

الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه».

وهذا النص الدستوري الذي يحظر علي أعضاء المجالس النيابية من التقدم بطلباتهم في المناقصات والمزايدات العامة، ويهدف ذلك إلى النأي بهم عن مواضع الشبهات وتمكيناً لهم من ممارسة دورهم الرقابي علي أعمال السلطة التنفيذية^(١).

٢. الحرمان الوقائي بمقتضى السلطة التقديرية لجهة الإدارة:

الحرمان الوقائي قد يكون أيضاً بقرار يصدر عن الإدارة بما تملكه من سلطة تقديرية. فهي تستطيع استبعاد المتناقصين غير المناسبين من التقدم إلى المناقصة العامة. ومن المسلم به، أن قرار الاستبعاد الصادر عن الإدارة هو قرار إداري منفصل، ويخضع للطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء. وبناء علي ذلك فإن الإدارة تمارس هذه السلطة تحت رقابة القضاء الإداري الذي يضمن عدم إساءة استعمال السلطة وانحرافها عن الهدف الأساسي الذي حدده القانون وهو حماية المصلحة العامة.

هذا وقد أكد القضاء الإداري المصري والفرنسي علي هذا المبدأ في العديد من الأحكام.

ففي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢١ أبريل ١٩٥٧ قررت انه: « من 2024/2025 2024/2025

المبادئ الأساسية التي تخضع لها المناقصة العامة الإعلان وحرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والمقصود بحرية المنافسة هو حق الأفراد في التقدم للمناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه بإجراء سواء أكان عاماً أو خاصاً. إلا أن هذا المبدأ الطبيعي يحد من إطلاقه قيدان: أولهما: يتعلق بما تفرضه الإدارة من شروط معينة ترى وجوب توافرها فيمن يتقدم للمناقصة وثانيهما: يتعلق بما تتخذه الإدارة من إجراءات وهي بصدد تنظيم أعمال المناقصة العامة من استبعاد بعض الأفراد الذين يثبت لها عدم قدرتهم الفنية أو المالية لأداء هذه الأعمال مستهدية بذلك ألا يتقدم للمناقصة إلا الصالحين من الأفراد والقادرين منهم، فتوفر بذلك كثيراً من الجهد والوقت علي لجان الفحص والبت....»^(٢).

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، رقم ٢٩٤٦، لسنة ٧ق، الصادر في ١٩٥٧/٤/٢١. وقد أكدت هذه المعاني، المحكمة الإدارية العليا، في حكمها الصادر في ١٩٥٩/٥/٩، لسنة ٤ق، ص ١٢٥٤.

وهذا المبدأ مستقر في أحكام محكمة القضاء الإداري فقد قضت في حكمها الصادر في ٢٩ نوفمبر ١٩٥٥ بصحة استبعاد شخص ثبت للبلدية انه علي صلة بشركة أساءت في تنفيذ بعض العمليات، وأن قدراته المالية والفنية لمواجهة العمليات محل شك كبير^(١). كما تقول أيضا في حكمها الصادر في ٣٠ مارس سنة ١٩٥٦: «..... وأن للوزارة الحق - وهي بصدد تنظيم أعمال المناقصات الخاصة بمشروعاتها - في أن تستبعد المقاولين الذين يثبت لها عدم قدرتهم الفنية أو المالية لأداء هذه الأعمال وقرارها في هذا الشأن يصدر بناء علي سلطتها التقديرية..»^(٢). كما قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ١٠ مارس ١٩٥٤ بصحة استبعاد شخص من الدخول في المزايدات، لأنه كان يتخذها ذريعة للتنقل إلى مركز الشط بقصد تسهيل مهمته في تهريب المخدرات والأسلحة^(٣).

وبذلك يساير قضاء مجلس الدولة المصري ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي منذ وقت طويل، فقد أكد في العديد من أحكامه أن قرارات الإدارة بالحرمان إنما تصدر عن سلطة تقديرية، والتي لا يجوز للقضاء أن يعقب عليها مهما كانت الظروف التي يصدر بمناسبة قرار الحرمان^(٤). وقضي أيضا بأن للإدارة السلطة التقديرية الكاملة في تقرير حرمان شخص ما من دخول المناقصة، ولكنها تخضع في ذلك لرقابة القضاء وذلك حال توافر إنحراف السلطة أو انعدام لأسباب هذا القرار^(٥).

2024/2025

2024/2025

ثانياً: الحرمان الجزائي:

قد يمنع بعض الأشخاص من الاشتراك في المناقصات العامة كعقوبة، وهو ما يطلق عليه « الحرمان الجزائي ». والحرمان الجزائي قد ينص عليه القانون صراحة، أو أن تطبقه الإدارة علي الشخص الراغب في التعاقد معها لسبق ارتكابه أخطاء أو جرائم في تنفيذ عمليات سابقة معها.

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ٢٩/١١/١٩٥٥، السنة ١٠ ق، المجموعة، ص ٥٤.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في ٣٠/٣/١٩٥٦، السنة ١٠ ق، المجموعة، ص ٢٧١.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في ١٠/٣/١٩٥٤، السنة ٨ ق، المجموعة، ص ٩٢٥.

(٤) انظر:

• C. E. 5 juillet 1902, Vautilhe, Rec., p. 500.

(٥) انظر:

• C.E. 25 novembre 1952, rec., p. 941.

• C.E. 28 janvier 1944, Ponos, rec., p. 37.

• C.E. 26 janvier 1966, Société ouest peinture, rec., p.61.

١. الحرمان الجزائي بنص القانون:

قد تستند الإدارة لحرمان الشخص الطبيعي أو المعنوي من دخول المناقصات أو المزايدات العامة إلى نصوص القانون.

ففي فرنسا، تحظر المادة ٥٢ من تقنين العقود العامة علي أن: « الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الذين لم يتقدموا بالإقرارات الضريبية حتي ٣١ ديسمبر من السنة السابقة لتلك التي جري فيها الإعلان عن المناقصة أو الذين لم يؤدوا اشتراكات التأمين الاجتماعي أو الاشتراكات الأخرى المقررة لبعض الصناديق الأخرى أو الذين لم يؤدوا الضرائب والرسوم حق دخولهم وتقديمهم في المناقصات العامة ما لم يقدموا الضمانات العامة التي تتطلبها الجهة الإدارية »^(١). كما تنص المادة ٤٩ من التقنين السابق علي اعتبار الحرمان عقوبة تبعية في الحالات الآتية:

◀ كل شخص حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى المخالفات المنصوص عليها بقانون الضريبة العامة.

◀ كل شخص معنوي يتصرف باسمه أحد الأشخاص المحظور دخول المناقصات العامة.

◀ المشروع الذي يديره شخص محكوم عليه بالتهرب الضريبي، فيمنع المشروع من دخول المناقصات العامة طيلة فترة وجود هذا الشخص به ويزول المنع فور خروجه من المشروع.

وبالنسبة للوضع في مصر فقد نص قانون العقوبات في مادته ٢٥ بأن: «كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: أولاً: القبول في أي خدمات في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد أو ملتزم أيأ كانت أهمية الخدمة».

ويلاحظ أن هذا النص يعتبر نصاً عاماً يطبق علي أي شخص يرتكب مخالفة - أيأ كانت نوعية المخالفة - ولكن المهم أن يحكم عليه بعقوبة جنائية . أيأ كانت مدتها . فيتم حرمانه من مجموعة من الحقوق والمزايا وفي مقدمتها الحرمان من التقدم إلى المناقصات العامة. كما انه وفقاً للمادة ٩٣ من قانون تنظيم التعاقدات التي يتم إبرامها بين الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب علي الجهات المختصة اخطار الهيئة العامة للخدمات

(١) انظر:

• Art. 52: (Décret no. 79-901 du 23 novembre 1979).

الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي.

٢. الحرمان الجزائي الموقع من جهة الإدارة:

وفي هذه الحالة يكون الحرمان جزاء توقعه الإدارة علي المتعاقد نتيجة ارتكابه أخطاء في تنفيذ ارتباطات سابقة معها. وفي هذا الصدد توضح المادة ٥٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي أنه يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :

١. إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في

تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .

٢. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .

٣. إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً، ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (١، ٢) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .

ويعاد قيد المتعاقد الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناء على طلبه إذا انتفى ^{2024/2025} ^{2024/2025}

سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

من الملاحظ ان القانون الحالي يردد نفس الأحكام التي سبق ان أرسنها القوانين التي سبقته .

هذا وقد استقر الرأي في فرنسا علي ان قرار الإدارة بحرمان الشخص من دخول المناقصات العامة لا ينصب إلا علي المناقصات الخاصة بالمرفق أو بالوزارة التي سبق أن أصدرت قرار الحرمان^(١). وبالتالي ليس لهذا القرار أي اثر فيما يتعلق بالمناقصات الخاصة بالمرفق والوزارات الأخرى. علي انه تحقيقاً للمصلحة العامة يتم تبادل القوائم الخاصة بالمحرومين من دخول المناقصات العامة فيما بين المرافق العامة والوزارات المختلفة.

(١) انظر: د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ١٩٧٣، ص ١٥٦- وانظر أيضاً: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥.

الغصن الثالث

الاحكام العامة لتقديم العطاءات

من الطبيعي بعد أن تعلن الإدارة عن المناقصة أو المزايدة العامة، أن تترك مهلة لكي يفكر فيها من يريد التقدم، هذه المهلة يجب أن تكون كافية لكي يتمكن المتناقص أن يزن عطاءه وظروفه جيدا قبل التقدم^(١)، وإذا استقر علي الاشتراك في المناقصة أن تتيح له إعداد عطاءه وفقا للشروط والقيود والمواصفات الفنية التي أعلنتها الإدارة. وقد يتوفي صاحب العطاء، فما هو الاثر المترتب علي ذلك. وهل يجوز لصاحب العطاء ان يعهد ببعض بنود العملية محل العقد الي غيره من الباطن، وما هي محددات واشتراطات التعاقد من الباطن. كما يجب علي صاحب العطاء ان يضمنه ما يفيد سداده التأمين الابتدائي الدال جديته في التعاقد.

أولاً: اعداد وتقديم العطاءات:

تنص المادة ٤٧ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي يتم ابرامها بين الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي انه: « تقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقا للشروط المحددة بمستندات الطرح، ويجب تقديمها علي نموذج العطاء المدرج بكراسة الشروط^{2024/2025}، ويجب ان يثبت علي كل من ^{2024/2025}مظروف في العطاء الفني والمالي ونوعه من الخارج ^{2024/2025} ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضع عليه اسم الجهة الادارية وعنوان ادارة التعاقدات، وما يفيد ان بداخله المظروف الفني والمظروف المالي، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، كما يذكر اسم صاحب العطاء ». وهو ما يتطلبه القانون الفرنسي، حيث « يجب أن يقدم العطاء موقعاً من صاحبة او من الممثل القانوني للمشروع أو الشركة صاحبة العطاء أو من وكيله ولا يجوز ان يكون موكلا عن أكثر من صاحب عطاء عن عملية واحدة^(٢)». ويتحمل صاحب العطاء كافة التكاليف لاعداد وتقديم عطاءه، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الادارية باية حال من الاحوال اية مسؤولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية.

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٩.
(٢) انظر:

- Art. 46: "Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.

ويجب ان يكون صاحب العطاء او المتزايد بحسب الاحوال من المصرح له العمل وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية او يكون ممثلا رسمي لديه كافة الامكانيات وقادر علي تنفيذ كافة التزاماته الواردة بكراسة الشروط والمواصفات فيما لو رست عليه العملية محل الطرح، وكذا العنوان الذي يمكن مخاطبته عليه ويعتبر اعلامه صحيحا^(١).

ووفقا للمادة ٣٣ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء .

ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية، أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد .

ويتم تسليم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ أو الموعد المحددين لفتح المظاريف الفنية اما باليد او عن طريق البريد السريع -الهيئة القومية للبريد او عن طريق الوسائل الإلكترونية - اذا سمحت بذلك شروط العملية^(٢).

2024/2025

ويجب علي صاحب العطاء عدم شطب اي بند من بنود العطاء او من المواصفات الفنية او اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه، وإذا رغب في ابداء اية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الادارية وحتى نهاية مدة سريان العطاءات المحددة.

ثانيا: مدة تقديم العطاءات:

اوضحت اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي انه يجب علي ادارة التعاقدات عند تحديد مدة تقديم العطاءات مراعاة اعطاء الوقت الكافي لاصحاب العطاءات لدراستهم لكراسة الشروط والمواصفات واستيفاء المستندات اللازمة لتقديم عطاءاتهم وفقا

(١) راجع: المادة ٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٢) راجع: المادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



التالى (١):

١. المناقصة العامة والممارسة العامة والمزايدة العلنية والمزايدة بالمظاريف المغلقة خلال مدة لا تقل عن ٢٠ يوما تحتسب من تاريخ الاعلان باحدي الصحف اليومية، ويجوز استثناء بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال المبررة والموثقة تقصير تلك المدة بحيث لا تقل عن ١٤ يوما.
٢. المناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والمزايدة المحدودة والمزايدة العلنية خلال مدة لا تقل عن ١٤ يوما تحتسب من تاريخ توجيه الدعوة، ويجوز استثناء بموافقة السلطة المختصة في حالة الاستعجال المبررة والموثقة تقصير تلك المدة بحيث لا تقل عن ١٠ يوما.
٣. يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او جلسة المزايدة بثلاثة ايام علي الاقل ان يتقدم بطلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات، وتلتزم ادارة التعاقدات بالعرض علي السلطة المختصة بنتيجة دراستها والحصول علي موافقتها حال اقتراح مد المدة وتاجيل موعد فتح المظاريف او المزايدة بحسب الاحوال، او الاسباب التي تراها مناسبة لعدم تاجيل الموعد.
٤. كما يجوز للجهة الادارية اذا ارتأت ضرورة لذلك ان تقوم بتأجيل موعد فتح المظاريف او المزايدة بحسب الاحوال.
٥. في جميع حالات تأجيل فتح المظاريف او المزايدة بحسب الاحوال يتعين الحصول علي موافقة السلطة المختصة واعادة النشر علي بوابة التعاقدات العامة والاعلان او توجيه الدعوات بحسب الاحوال علي الاتقل مدة التأجيل عن نصف المدة المحددة مسبقا لفتح المظاريف الفنية من تاريخ الاعلان او الدعوة.
- ويتضح من النصوص المتقدمة انه علي الراغب في التقدم للمناقصة العامة ان يعطائه خلال المدة التي تقررها ادارة التعاقدات وفقا للشروط السابق ذكرها، وذلك من تاريخ أول إعلان في الصحف اليومية او من تاريخ توجيه الدعوة، فإذا لم يتقدم بعطائه في تلك المدة يسقط حقه في التقدم إلى المناقصة من الناحية القانونية.
- راجع: المادتين ٤٩ - ٥٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

واي عطاء يرد بعد موعده فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط والمواصفات يجب تقديمه فور وصوله الي رئيس اللجنة للتاثير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه، ثم يدرج في كشف العطاءات المتاخرة، ويتم ترقيمه علي هيئة كسر اعتيادي وبسطة رقم العطاء ومقامه العطاءات المتاخرة. وتستبعد لجنة البت العطاءات المتاخرة ويتم ردها الي اصحابها بمعرفة ادارة التعاقدات خلال مدة لا تتجاوز يومين من قرار اللجنة^(١).

وهذه الأحكام التي تنظم ميعاد تقديم العطاء في القانون المصري تتفق مع ما ينص عليه القانون الفرنسي في ذات الشأن، حيث ينص تقنين العقود العامة الفرنسي علي إمكانية تقديم العطاءات حتى ميعاد فتح المظاريف، كما يجب ألا تقل المدة بين أول إعلان وبين الميعاد المحدد لفتح المظاريف عن ٣٦ يوما. وفي حالة الضرورة يمكن تقصير المدة إلى ١٥ يوما فقط^(٢).

وبعد تقديم العطاء في الميعاد الذي حددته ادارة التعاقدات، يظل ساري المفعول خلال المدة المحددة له مسبقا في مذكرة العرض علي السلطة المختصة للموافقة علي البدء في اجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الاجراءات^(٣).

وفيما يتعلق بمدة سريان العطاءات اوضحت المادة ٢٧ من قانون تنظيم التعاقدات التي يتم إبرامها بين الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ انه يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة وأربعين يوما وألا تتجاوز تسعين يوما وفقا لطبيعة العملية.

ويجوز استثناء تجاوز الحد الأقصى في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك، ويتعين في كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وتحسب مدة سريان العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية . وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم البت والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان هذه العطاءات .

فإذا تعذر ذلك، تعين على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة بالأسباب التي أدت إلى التأخير، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان

(١) راجع: المادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار، المناقصات العامة، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٩.

(٣) راجع: المادة ١٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت على أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء.

ثالثا: الاثر المترتب علي وفاة صاحب العطاء:

في حالة وفاة صاحب العطاء اذا كان شخصا طبيعيا، او مالك شركة الشخص الواحد، او الشريك مع الغير بحصة حاکمة تسمح له بالتاثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعد عرض ادارة التعاقدات استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت، او السماح للورثة بالاستمرار في الاجراءات بشرط ان يعينوا عنهم وكيلًا بتوكيل مصدق علي التوقييه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل هو دون غيره مسئولًا امام الجهة الادارية عن تنفيذ الاجراءات^(١).

رابعا: احكام التعاقد من الباطن وشروطه:

تشجيعا للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، اجاز المشرع المصري في قانون تنظيم التعاقدات التي يتم ابرامها بين الجهات العامة لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن، على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم، وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقا للمحددات وأي اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات^(٢)، ومنها علي سبيل المثال ما يلي^(٣):

١. المستندات الدالة علي خبراتهم.
٢. تحديد ما اذا كانوا من المشروعات المتوسطة او الصغيرة او المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك.
٣. الا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في احدي جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، او في جرائم التهرب الضريبي او الجمركي.
٤. ان يكونوا من المصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد.
٥. اقرار ما يفيد الالتزام بالتأمين علي العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة اذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.

(١) راجع: المادة ٥٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٢) راجع: المادة ٢٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٣) راجع: المادة ٦٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



وفي جميع الأحوال، يظل المتعاقد دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد.

ووفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في المادة ٥٩ للجهة الادارية السماح لصاحب العطاء ان يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد الي غيره من الباطن بما لا يجاوز نسبته حد اقصي ٣٠ % من قيمة العقد، عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها زيادة تلك النسبة وبحد اقصي ٦٠ %، وذلك كله بناء علي دراسة موثقة بذلك تعتمدها السلطة المختصة ضمن اجراءات العملية، علي ان تتضمن كراسة الشروط والمواصفات تلك النسبة واية محددات واشترطات ذات صلة.

١. تحديد مبلغ التأمين:

يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدده السلطة المختصة ضمن شروط
الطرح، ويجب تقديره دون مبالغه لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط
للمشاركة في العملية محل طرح. وعلي لجنة اعداد القيمة التقديرية او الثمن الاساسي
بحسب الاحوال اقتراح مبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل من رئيسها وأعضاؤها، ويتم تحديد
مبلغ التأمين المؤقت واعتماده من السلطة المختصة ويخطر به مدير ادارة التعاقدات لاتخاذ
الاجراءات اللازمة.

والسلطة المختصة بتحديد مبلغ التأمين المؤقت ليست مطلقة، حيث لا تستطيع أن تتجاوز الحدود القصوي التي وضعها المشرع في المادة ١٦ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وهي على النحو التالي:

أ. في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية: نسبة (١.٥%) من القيمة التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها، وفي حالة الطرح في مجموعات متجانسة بحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة.

ب. في عمليات شراء أو استئجار العقارات: نسبة (٠.٥%) من القيمة التقديرية للعملية المطروحة .



ج. في عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات: يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة .

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التأمين المؤقت سارياً لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.

٢. الاثر المترتب علي عدم اداء التأمين الابتدائي:

يتم استبعاد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها فيما يتعلق بضرورة وجود التأمين الابتدائي في الحالات التي استلزمه فيها القانون، والأثر الذي يترتب علي تخلفه ما يلي: « ومن حيث ان الثابت في الواقعة المعروضة ان العطاء الذي تم إرساء المناقصة عليه بواسطة لجنة البت كان مقدماً من مؤسسة خاصة غير مصحوب بتأمين مؤقت كما لم يتم تدارك هذه المخالفة بسداد التأمين النهائي كاملاً الذي هو شرط للنظر في هذا العطاء ورغم ذلك فإن لجنة البت نظرت في هذا العطاء ولم تستبعده بل أرست المناقصة عليه، فإنه في هذا الشأن يعد مخالفاً للحكم الصريح الذي أورده المشرع»^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويمكن ان يؤدي التأمين المؤقت - وفقاً للمادة ٣٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ - بطرق متعددة يختار مقدم العطاء ما يناسبه منها، وهي علي النحو التالي:

أ. الدفع الالكتروني:

الأصل أن يؤدي التأمين المؤقت نقداً وذلك بإيداعها بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه، ولكن نظراً لتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً اعتباراً من اول مايو ٢٠١٩، فلا يمكن لمقدم العطاء ان يؤدي التأمين المؤقت نقداً، ولكنه يستطيع ادائه عن طريق وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني^(٢).

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٣١٧٤، الصادر في ٣١/٣/١٩٩٠، لسنة ٢٩ ق، الموسوعة، ج٣٥، ص٣٠٩.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٣١٧٤، الصادر في ٣١/٣/١٩٩٠، لسنة ٢٩ ق، الموسوعة، ج٣٥، ص٣٠٩.

ب. خطاب الضمان^(١):

يمكن لمقدم العطاء اداء التأمين المؤقت من خلال خطاب ضمان، وقد وضع المشرع المصري شروطا في خطاب الضمان الذي يقدم كتأمين دخول المناقصة العامة:

- ضرورة صدور خطاب الضمان من أحد المصارف المحلية المعتمدة. والا يقترن بأي شرط أو قيد. فلا يجوز أن يتضمن شرطا يفيد بعد التزام البنك بقيمة الضمان إلا بعد الرجوع إلى العميل مثلا. فخطاب الضمان ينشئ علاقة مباشرة بين البنك وبين جهة الإدارة، و بالتالي لا يكون لعمل البنك. الذي أصدر خطاب الضمان بناء علي طلبه. أي دور في هذه العلاقة. وعلي ذلك يلتزم المصرف بأمر جهة الإدارة الصادر لمصلحتها خطاب الضمان حتى ولو عارض في ذلك - عميلة - مقدم العطاء.
- تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من احد المصارف المحلية المعتمدة، علي ان يتعهد المصرف المحلي بان يدفع للجهة الادارية مبلغ يوازي التأمين المطلوب وانه ملتزم بادائه باكماله عند اول طلب منها دون الالتفات الي أي معارضة من صاحب العطاء.

ج. اجراء المقاصة:

2025/24/2024 يجوز لصاحب العطاء سداد الضمان المؤقت خصما من مستحقاته الصالحة 2024/2025

للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية.

ثالثا: الأثر القانوني المترتب علي إيداع العطاء:

يظل العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة من السلطة المختصة، وبالتالي يلتزم مقدم العطاء بعطائه من وقت تقديمه إلى نهاية المدة حددتها السلطة المختصة كمدة سريان صلاحية العطاءات، وبالتالي لا يستطيع مقدم العطاء الرجوع فيه خلال تلك الفترة.

وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ١٩٧٩/٦/١٧ بأن: « القاعدة هي أن مقدم العطاء يلتزم بعطائه من وقت تصديره إلى نهاية المدة المحددة في شروط العطاء..... »^(٢).

(١) خطاب الضمان هو خطاب يصدره البنك يتعهد فيه بدفع مبلغ نقدي معين عند أول طلب يقدم إليه من المستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه، بشرط ان يقدم هذا الطلب خلال المدة المحددة لصلاحية الخطاب.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٩٦٥، لسنة ٣١ ق، الصادر في ١٩٧٩/٦/١٧.

وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا بأنه: «... من حيث انه من المقرر أن يظل الموجب مرتبطاً بإيجابه خلال الميعاد المحدد للقبول فلا يصبح الإيجاب ملزماً بعد أن فقد ما توافر له من الإلزام ويسقط سقوطاً تاماً وهذا هو التفسير السليم للنصوص المتقدمة ولنية الموجب فهو يقصد أن يبقي إيجابه قائماً خلال المدة المحددة ما دام لجأ إلى التحديد وهذا ما يتعلق بوجه عام مع أصول الالتزامات بحيث لا يبقي الإيجاب مفتوحاً ومعلقاً طالما حُدد بشروط وبمدة معينة»^(١).

هذا ويرتب القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ جزءاً علي مقدم العطاء إذا رجع في عطائه أو سحب هذا العطاء قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية. وهذا الجزء هو خسارته للتأمين الابتدائي الذي قدمه مع العطاء. وتعد مصادرة التأمين الابتدائي صورة من صور التعويض الذي حدده القانون كجزاء علي إخلال مقدم العطاء بالتزامه المتمثل في ضرورة الإبقاء علي عطاءة خلال المدة التي حددتها السلطة المختصة. وفي هذا الصدد تنص المادة ٢٢ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة علي انه: « وإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استثناءه من أي مبالغ مستحقة 2024/2025 2024/2025 أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور. ».

ولكن قد تستجد بعض الظروف والمتغيرات قبل ميعاد فتح المظاريف الفنية، لذلك يحق لمقدم العطاء تعديل عطائه بما يتفق مع الظروف والمتغيرات الجديدة. علي أن هذا التعديل يتقيد بقيدين:

القيد الأول: أن يكون موضوع التعديل لمصلحة الإدارة. ففيما يتعلق بالمناقصات العامة يجب أن يكون التعديل منصفاً علي خفض سعر العطاء. وعلي العكس من ذلك بالنسبة للمزايدات العامة يجب أن يكون التعديل منصفاً علي زيادة سعر العطاء.

القيد الثاني: أن يصل هذا التعديل إلى الإدارة قبل ميعاد فتح المظاريف الفنية، فإذا وصل بعده فلا يعتد به.

وتؤكد هذا المبدأ المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٢ بقولها: «.... منذ أن يصدر مقدم العطاء عطاءه يظل ملتزماً به ولا يكون له إلا أن

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٦٨٠، لسنة ٢٧ق، الصادر في ١٣/٤/١٩٩٣، الموسوعة، ج٣٥، ص ٢٨٩.

يعدل عنه كلية - سحب العطاء - أو أن يخفض ما ورد به من أسعار علي أن يتم ذلك في الحالتين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد من الأسعار التي تقدم بها...»^(١).

الفرع الثاني

فحص العطاءات و تشكيل اللجان وإرساء المناقصة

تستهدف هذه المرحلة من مراحل عملية إبرام العقود الإدارية عن طريق المناقصات العامة اختيار أفضل المتقدمين للمناقصة العامة من الناحيتين الفنية والمالية. ولقد أوجب القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في مادته ٢٨ ان يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولى إحداها فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة . ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها.

وتتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذا القانون لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يجب وفقا للمادة ٢٩ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه .

وكذلك يشترك في عضوية لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال ممثل لوزارة المالية متى بلغ الثمن الأساسي مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه .

أما في حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التي تتم في الخارج، فيشارك في العضوية ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية ملايين جنيه .

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١٢٥٥، لسنة ٢٥ ق، الصادر في ١٩٨٢/٦/٢٦، الموسوعة، ص ٧٧.

ويجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراء أو استئجار العقارات .

وفي جميع الأحوال، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان في الحالات التي تتطلب ذلك. ويجب علي إدارة التعاقدات إخطارهم بالمواعيد المحددة لعمل تلك اللجان قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام علي الأقل للبدء في أعمال شئونهم، علي أن يرفق بالإخطار صورة من مستندات العملية، وأن يتضمن تاريخ وساعة ومكان انعقاد اللجنة، وبالنسبة للمواعيد الخاصة باستكمال أعمال اللجنة فيراعي تحديدها كتابة بالتنسيق معهم.

وسوف نتولى عرض الأحكام الخاصة بلجنتي فتح المظاريف والبت في المناقصات علي النحو التالي:

الخصين الأول

إجراءات البت الفني

أولاً: فتح المظاريف الفنية^(١):

يكون فتح المظاريف الفنية في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية بحضور ~~من يرغب~~ من أصحاب العطاءات، ويجوز لهم ~~2024/2025~~ تفويض من يرونه لحضور الجلسة، شريطة تقديم التفويض الدال علي ذلك.

يقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليم رئيس لجنة فتح المظاريف الفنية ملف العملية والعطاءات المحفوظة لديه، ويلتزم أعضاء اللجنة بالإطلاع علي محتويات ملف العملية قبل بدء الجلسة للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي سبق اتخاذها من إدارة التعاقدات، وعلي اللجنة اتخاذ ما يلي:

١. يقوم رئيس لجنة بفتح المظاريف في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات، إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها.

٢. القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر المظاريف.

٣. التحقق من وجود مطروفين مقدمين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.

(١) مادة ٦٥ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

٤. ترقيم العطاءات علي هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاءات ومقامه عدد العطاءات الواردة. وإثبات رقم كل عطاء علي المظروف الفني وعلي المظروف المالي الذي يتم التحفظ عليه مغلقاً.

٥. إعادة تسليم المظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها الي مدير ادارة التعاقدات لحفظها لديه.

٦. فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلي كل ورقه بداخله.

٧. ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك الأوراق.

٨. قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت ونوعه وغيرها من محتويات المظروف الفني علي الحاضرين من اصحاب العطاءات او من يفوضونهم.

٩. التوقيع من رئيس اللجنة ومن أعضاء اللجنة علي المظروف الفني وكل ورقة بداخله.

١٠. التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح في البيانات الواردة بالمظروف الفني ويجب إثبات كل كشط او تصحيح وضع حوله دائرة حمراء تفصيلاً

2024/2025

والتوقيع منه وجميع أعضاء اللجنة علي هذه التأشيريات. 2024/2025

١١. التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع الأعضاء علي محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة في السجل المعد لذلك.

١٢. تسلم خطابات الضمان او اشعارات سداد التأمين المؤقت او الاقرارات البديلة الي العضو المالي باللجنة لاعمال شئونه.

١٣. إرفاق المظاريف الفنية وجميع الأوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير إدارة التعاقدات وذلك لحفظها لديه.

١٤. مراجعة العينات السابق تقديمها من مقدمي العطاءات علي الكشف الذي دونت عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع أعضائها كما يوقعون علي العينات التي ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتها في كشف خاص وتسلم جميع العينات إلى مدير ادارة التعاقدات أسوة بأوراق العطاءات.

يجب ان تُتم اللجنة عملها بأكمله في الجلسة ذاتها، ولا يحق لها استبعاد اي عطاء او ان تطلب من اصحاب العطاءات تصحيح الاخطاء او تلافي الملاحظات الواردة

في عطاءاتهم، أو اتخاذ اية قرارات تتعلق بالعطاءات المقدمة وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف واية مخالفات في الاجراءات السابقة علي عملها. وعلي ادارة التعاقدات نشر محضر فتح المظاريف الفنية علي بوابة التعاقدات العامة فور الانتهاء من اعمال اللجنة والتوقيع عليه من رئيس اللجنة واعضاؤها.

ثانياً: التعامل مع العينات^(١):

- تتولى إدارة التعاقدات بالتنسيق مع ادارة المخازن فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب ان يبين بهذا السجل تاريخ العملية ونوعها وعلي مدير إدارة التعاقدات ان يرسل فوراً أو في خلال اليومين التاليين علي الأكثر لتاريخ فتح المظاريف الفنية ما يقتضي إرساله منها إلى الجهة الفنية المختصة حتى يتسنى إجراء الفحص الفني المطلوب علي وجه السرعة، ومراعاة مدة صلاحية العطاءات والوقت المطلوب لاتمام اجراءات البت والاحطار بالترسية، وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمام كل عينة ليعرض علي لجنة البت.
- يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات او العينات النموذجية ومدي ملاءمتها للغرض المطلوبة من اجله وذلك بالفحص النظري او الفني او بالتحليل المعمل ^{2024/2025} او بالتجربة العملية ^{2024/2025} بحسب الأحوال و ذلك بمعرفة الجهة الإدارية ^{2024/2025} بأي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون - وعلي مدير إدارة التعاقدات ان يضع علي العينات أرقاماً سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة) ويرسل معها كشفاً تفصيلياً ببيان مفرداتها والغرض الذي من اجله يراد الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه.
- ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وتوقيعات لتمييزها ولضمان عدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة وذلك لكي تقوم الجهة الفاحصة بفحصها وموافاة ادارة التعاقدات بالنتيجة قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بدراسة العطاءات علي ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنة البت في المناقصة في الميعاد المحدد. وعلي جهة الفحص الفني ان تقوم بفحص العينات واختبارها بالتتابع وان تختتمها وتضع عليها أرقاماً سرية أخرى لتمييزها وترسل عنها تقريراً وافياً بالنتيجة من حيث مطابقتها للمواصفات من عدمه ويبين به نسبة الجودة مئوية لكل عينة تم تحليلها وعلي مدير إدارة التعاقدات ان يتحقق من حفظ تقارير المعمل الفني التي

(١) مادة ٦٧ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

ترد تباعا بملفات المناقصات بعد إثباتها في السجل الخاص بذلك وقبل عرضها علي لجنة البت وكذلك التأشير أمام كل تقرير برقم الملف المحفوظة فيه.

الخصين الثاني

اجراءات البت في العطاءات

وتقوم لجنة البت بفحص ودراسة العطاءات المقدمة وذلك لاختيار العطاء الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية. وتتم اللجنة عملها علي ثلاثة مراحل: **الأولى**، لتحديد العطاءات المقبولة فنيا، **والثانية** لتحديد أفضل العروض من الناحية المالية، **والثالثة** حتي يتسنى لها اختيار العطاء الأفضل من الناحية الفنية والمالية. واخيرا ما هي الطبيعة القانونية لقرارات لجنة البت.

أولاً: العطاءات المقبولة فنيا:

١. الفحص الشكلي وتفرغ العروض الفنية(١):

يقوم مدير ادارة التعاقدات بتسليم رئيس لجنة البت العطاءات المحفوظة لديه ومحضر جلسة فتح المظاريف الفنية، **وعلي اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية:**

- الفحص الشكلي للعطاءات والتأكد من انها قد استوفت الشكل القانوني وفقا

2024/2025

2024/2025

لمتطلبات شروط الطرح. 2024/2025

- استبعاد العطاءات المتأخرة، وغيرها من عطاءات غير صالحة للنظر فيها، ومنها العطاءات الغير موقعة من اصحابها، او الغير مكتملة وفقا للشروط، او العطاءات غير المستوفاة للتأمين المؤقت، او العطاءات التي يتبين ان اصحابها من غير المسجلين علي بوابة التعاقدات العامة، او انهم من المسجلين بسجل قيد اسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، او العطاءات التي تضمن معاملات تغير الاسعار في مقاولات الاعمال طبقا لكراسة الشروط. وتعد لجنة البت محضرا بنتيجة الفحص الشكلي، متضمنا اسباب استبعاد العطاءات، يتم حفظه لدي مدير ادارة التعاقدات بعد توقيعه من رئيس اللجنة واعضاءها لايداعه في ملف العملية.

- يكلف رئيس لجنة البت الامانة الفنية للقيام بتفرغ العروض الفنية للعطاءات المستوفاة للشكل القانوني، وذلك علي الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور علي ان يتم حفظ العروض الفنية محل التفرغ في اخر كل يوم لحين الانتهاء من

(١) مادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

تقريغها وتدون جميع ملاحظات واشترطات اصحاب العطاءات، وتعمل مطابقة للعروض علي كشوف التقريغ من اثنين من اعضاء لجنة البت يحددهما رئيسها وتوقع بما يفيد هذه المطابقة ويجب ان تتم هذه العملية في اقل وقت ممكن حتى يتسنى البت في العملية قبل انقضاء مدة سريان العطاءات ، وتقدم الامانة الفنية تقرير تقريغ العروض الفنية الي رئيس لجنة البت.

٢. دراسة العروض الفنية وفحصها:

أجاز قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وللجنة البت أن تضم لعضوية اللجان الفرعية التي تشكلها من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة. وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت^(١).

كما يجوز لإدارة التعاقدات بناء علي طلب لجنة البت ان تستوفي من مقدمي العروض^{2024/2025} من بيانات ومستندات إضافية^{2024/2025} واستيضاح ما غمض من أمور فنية بما^{2024/2025} يعينها في إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض، وذلك خلال مدة لا تجاوز ٣ ايام من تاريخ اخطارهم، ودون الإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين اصحاب العروض. وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات او المستندات او استيضاح الامور الفنية بعطاءه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها، يتم استبعاد عطاؤه باعتباره غير واضح او غير قابل للمقارنة مع العطاءات الاخرى^(٢). تقوم لجنة البت باعداد محضرا يتضمن ما انتهت اليه توصياتها بناء علي دراستها من قبول او استبعاد للعطاءات مع ذكر اسباب عدم القبول تفصيلا، وترفع محضرها للسلطة المختصة للاعتماد^(٣).

بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة التعاقدات إخطار اصحاء العروض بنتائج قرارات اللجان بالقبول او اسباب الاستبعاد او الالغاء بخطابات

(١) مادة ٣٢ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٢) مادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٣) مادة ٧١ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الاحوال وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعتاء ويكون لهم الحق في التقدف بشطواهم كتابة خلال ٧ ايام تبدأ من اليوم التالي لاختارهم بالقرار. وفور ارسال الاخطارات يتم نشر النتيجة في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض ولمدة ٧ ايام، كما يتم النشر علي بوابة التعاقدات العامة ، وبعد انقضاء هذه المدة يتم اخطار اصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف المالية، ما لم يكن هناك شكاوي محل الدراسة^(١).

ثانيا: تحديد العطاء المقبول ماليا:

١. فتح المظاريف المالية:

تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط. وتتولى اللجنة مباشرة اجراءاتها في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من اصحاب تاعاءات المقبولة عروضهم الفنية، ويجوز لهم تقويض من برونه لحضور الجلسة.

ويقوم مدير التعاقدات بتسليم رئيس اللجنة المظاريف المالية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته علي كل مظروف 2024/2025 2024/2025
بجلسة فتح المظاريف الفنية، وعلي اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية:

- فتح المظاريف المالية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة عدد اوراقه التي بداخله.
- التوقيع من رئيس اللجنة واعضاؤها علي كل ورقة بداخل المظروف المالي.
- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح او تحشير في الارقام او الاجماليات الواردة بالمظروف والتوقيع بجانبه من رئيس اللجنة واعضاها علي هذه التأشير.
- التوقيع من رئيس اللجنة واعضاؤها علي محضر اللجنة بعد اثبات ما تقدم.
- ارفاق المظاريف المالية وجميع الوراق المقدمة بها بمحضر اللجنة وتسليمها لمدير ادارة التعاقدات، وذلك لحفظها لديه.

ويجب ان تُتم اللجنة عملها بأكمله في الجلسة ذاتها، ولا يحق لها استبعاد اي عطاء او ان تطلب من اصحاب العطاءات تصحيح الاخطاء او تلافي الملاحظات

(١) مادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

الواردة في عطاءاتهم، او اتخاذ اية قرارات تتعلق بالعطاءات المقدمة وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف.

وعلى ادارة التعاقدات نشر محضر فتح المظاريف المالية علي بوابة التعاقدات العامة فور الانتهاء من اعمال اللجنة والتوقيع عليه من رئيس اللجنة واعضاءها.

٢. تفريغ ومراجعة العروض المالية:

يكلف رئيس اللجنة اثنين من اعضاء اللجنة لمراجعة العروض المالية - بعد تفريغها- مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة، وتكون هذه المراجعة هي الاساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء، واذا تبين من المراجعة وجود اخطاء حسابية فيجب تصحيحها وفقا لاي من الحالات الاتية:

أ. اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول علي سعر الوحدة.
ب. اختلاف بين السعر المبين بالتفقيط والسعر المبين بالأرقام، يعول علي السعر المبين بالتفقيط.

ج. تقديم اكثر من نسخة للعطاء طبقا للكراسة ، وتبين وجود اختلاف في السعر بين النسخ المقدمة يعول علي ما جاء بالنسخة الاصلية.

2024/2025

دراسة وتقييم العروض المالية: 2024/2025

وفي النهاية تتولى لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض، ويجوز لها ان تعهد الي لجنة مالية فرعية متخصصة من بين اعضائها او غيرهم لدراسة وتحليل وتقييم العروض ماليا، واعداد تقرير بنتيجة اعمالها يقدم الي لجنة البت. وعليها القيام باجراء المقارنة والمفاضلة بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية مع الاخذ بالاعتبار تكاليف دورة المنتج وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات، وكذا اية اشتراطات اخري وردت بها بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد مع مراعاة بعض العناصر مثل:

- شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر المؤثرة في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات.
- تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها الي قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل، القدرات، الكفاءة، الاداء، وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات .
- حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة باضافة فائدة تعادل سعر الفائدة من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية الي قيمة العطاءات

المقترنة بالدفع المقدم اذا اقرت كراسة الشروط والمواصفات الدفع المقدم، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ اداء هذه المبالغ حتي تاريخ استحقاقها الفعلي.

- حساب نسبة الافضلية الممنوحة للمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري.

- حساب نسبة الافضلية الممنوحة للخدمات او الاعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية.

- في حالة تقديم العطاء بعملات اجنبية يتم معادلتها بالعمل بالعملة المصرية بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ فتح المظاريف الفنية.

- إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف، اما في مقاولات الأعمال فللجنة الإدارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته اعلي فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر انه ارتضي

المحاسبة علي أساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن 2024/2025

يكون له حق المنازعة في ذلك.

- لا يعتد بالعطاء المبني علي خفض نسبة مئوية عن قيمة اقل عطاء مقدم في العملية.

- افضلية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند التساوي في الاسعار مع غيرهم.

- في حالة تساوي الاسعار بين عطائين او اكثر من المقبولين ماليا، فيحق للجنة البت ترجيح احدهما وفقا لمبررات تبديها بمحضرها بناء علي ما اشتمل عليه كل عطاء، ويجوز تجزئه المقادير المعلن عنها بين مقدميها اذا كان ذلك في صالح العمل.

٤. التقييم بنظام النقاط:

في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط ، فيتم تضمين شروط الطرح اسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الادني للقبول ومنها هلي سبيل المثال، وبحسب طبيعة بالعملية:



١٤٧

- المواصفات المالية.
 - خدمة ما بعد البيع.
 - مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفيذه.
 - الكوادر الفنية والادارية العاملة لدي صاحب العطاء بشكل دائم.
 - المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح، وقيمة اعلي مشروع.
 - المقدرة المالية لصاحب العطاء من خلال ميزانية مدققة.
 - المعدات والالات والاجهزة المتوفرة لدي صاحب العطاء، والضرورية لانجاز العمل المطلوب.
 - وغيرها من للاسس والعناصر التي تراها الجهة الادارية وفقا لطبيعة كل عقد.
- ويكون البت المالي وفقا لالية التقييم المحددة بشروط الطرح ومنها ترتيب اولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء علي مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، وذلك للحصول علي تكلفة الدرجة الفنية لكل عطاء ويتم النرسية علي العطاء الذي حصل علي اقل قيمة مقارنة.

٥. استيفاء واستيضاح العروض المالية:

يجوز لادارة التعاقدات بناء علي طلب لجنة البت ان تستوفي من مقدمي العروض 2024/2025 ما تراه من بيانات ومستندات إضافية واستيضاح ما غمض من أمور مالية بما يعينها في إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض، وذلك خلال مدة لا تجاوز ٣ ايام من تاريخ اخطارهم، ودون الإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين اصحاب العروض.

وفي حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات او المستندات او استيضاح الامور الفنية بعطاءه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها، يتم استبعاد عطاؤه باعتباره غير واضح او غير قابل للمقارنة مع العطاءات الاخرى^(١).

ثالثا: طريقة وآلية الترسية:

وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات.

(١) مادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



وتتم ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأساسه بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته. ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.

وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرا منخفض انخفاضاً غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية، وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت إلى ذلك، ووفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وترفع اللجنة محضرها متضمناً قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو لتقرير ما تراه. ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية على الأسباب التي بني عليها.

وفي جميع الأحوال، يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب

يرسله بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، كما يخطر باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدمي العطاءات.

رابعاً: الطبيعة القانونية لقرارات لجنة البت:

تعتبر قرارات لجنة البت من قبيل القرارات الإدارية المنفصلة - كما سنرى لاحقاً - إذ تجتمع لها مقومات القرارات الإدارية، ولذلك يجوز الطعن فيها. استقلالاً عن العقد أمام القضاء الإداري.

وهذا ما تؤكد به المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ١٥ إبريل ١٩٧٥ حيث تقول : « ينبغي التمييز في مقام التكيف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهئ لمولده بصرف النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يبتغيها القانون

وهذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً أو إدارياً وتتفصل عنه، ومن ثم يجوز لذي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ... وتختص لجنة البت سواء في المناقصة أو المزايدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعيين أفضل المتنافسين أو المتزايدين وفقاً لما رسمه القانون وذلك حتى يتسنى للسلطة الإدارية المنوط بها لإبرام العقد مباشرة اختصاصها في هذا الشأن، وليس من شك في.. أو المزايدة إنما هو في طبيعته . علي ما سلف البيان . قرار إداري نهائي إذ يجتمع له مقومات القرار الإداري من حيث كونه صادراً من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة، وليس ابلغ الدلالة علي صدق هذا النظر من ان جهة التعاقد إنما تلتزم حال انصراف إرادتها إلى إبرام العقد بالتعاقد مع المنافس أو المزايد الذي عينته لجنة البت، وليس لها ان تستبدل غيره «(١)».

الفصل الثالث

الآثار المترتبة علي مخالفة تشكيل

لجان فتح المظاريف والبت

يثور التساؤل عن مخالفة السلطة المختصة لتشكيل لجنة فتح المظاريف أو لجنة البت علي النحو المحدد في القانون أو اجتماع أعضاء هذه اللجنة علي نحو مخالف لما نص عليه القانون بأن كانت هذه اللجان غير كاملة علي الوجه السابق بيانه، فهل يترتب علي ذلك بطلان اجتماعها وبالتالي بطلان ما يصدر عنها من أعمال؟.

عرض هذا التساؤل علي اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة فقررت بتاريخ ٢٥ مارس ١٩٩١ أن: «المشرع قد أناط بالسلطة المختصة بالجهات الإدارية تشكيل لجان فتح المظاريف والبت، وضماناً لسلامة عمل تلك الجهات وسعياً وراء تحقيق الغرض المرجو منها فقد قرر ضرورة تضمين ذلك التشكيل عناصر فنية ومالية وأخرى قانونية إلا ان المشرع لم يعلق صحة عمل تلك اللجان علي ضرورة حضور كل العناصر لما أعوزه النص علي ذلك ويؤكد ذلك النظر ان المشرع عندما رأي ضرورة وأهمية حضور عناصر معينة كمندوب وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ضمن تشكيل لجنة البت إذا تجاوزت القيمة التقديرية للمناقصة حدوداً معينة. فإنه قرر عدم صحة انعقادها إذا تخلف

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٤٥٦ ، لسنة ١٧ ق، الصادر في ١٩٧٥/٤/٥، الموسوعة، ص ٧٥١.

مندوب وزارة المالية او عضو إدارة الفتوى»^(١). وقد خلصت هذه اللجنة إلى صحة انعقاد لجنة فتح المظاريف بدون حضور العضو القانوني.

ولكن الفقه يكاد يجمع علي وجوب اجتماع اللجنة بالتشكيل المقرر في الأمر الصادر بتشكيلها، وإلا ترتب علي غير ذلك بطلان اجتماعها والقرارات الصادرة عنها بالتبعية^(٢). ذلك لان تشكيل اللجنة علي النحو الوارد في القانون يعد ضمانه جوهرية لمقدمي العطاءات لأنه يضمن سلامة إجراءات إرساء العطاء وشفافيتها^(٣).

الفرع الثالث

إبرام العقد

الأصل أن ينعقد العقد إذا صدر إيجاب من أحد العاقدين، واقترب به قبول من المتعاقد الآخر^(٤). ويعد الإيجاب في المناقصة او المزايدة العامة هو العطاء المقدم من المتناقص او المتزايد، ثم يأتي دور السلطة المختصة بقبول هذا التعاقد وإبرام العقد. ويلاحظ ان دور لجنة البت هو مجرد التوصية بالتعاقد مع اصلح العطاءات وليس قبولاً للإيجاب، فالإيجاب كما رأينا يصدر عن السلطة المختصة بإبرام العقد.

ويترتب علي إرساء المناقصة التزام الإدارة . إذا رأت إبرام العقد . بأن تبرمه مع المتناقص الذي رسا عليه العطاء، واختصاصها في هذا الصدد اختصاص مقيد، إذ تلزم 2024/2025 2024/2025 بالامتناع عن التعاقد مع غير من رسا عليه العطاء^(٥). إلا أن الإدارة يحق لها دائماً أن ترفض إتمام التعاقد، فهي تتمتع في هذا المجال بسلطة تقديرية.

وعلي ذلك سنتناول في هذا المطلب دراسة، كيفية التعاقد مع من رست عليه المناقصة وكذلك سلطة الإدارة في عدم إتمام العقد، وذلك علي النحو التالي:

الفصل الأول: التعاقد مع من رست عليه المناقصة.

الفصل الثاني: سلطة الإدارة في عدم إتمام العقد.

(١) الفتوى رقم ١٨٧/٢/٤٧، الصادرة بتاريخ ١٩٩١/٣/٢٥.

(٢) انظر د. سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٥٦ - د. سعاد الشرقاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص ٤٢١. د. عبد الله حنفي، مرجع سبق ذكره ، ص ٢١٩.

(٣) انظر: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية ، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٤.

(٤) انظر: د. عبد الودود يحيي ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول "مصادر الالتزام" ، دار النهضة العربية، ١٩٩٢، ص ٣٣.

(٥) انظر: احمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٧.

الفصل الأول

التعاقد مع من رست عليه المناقصة

وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر، فإن العقد الإداري لا ينعقد بقرار لجنة البت بإرساء المناقصة علي افضل المتناقصين، إذ لا يعدو هذا القرار كونه إجراء تمهيديا سابقا علي مرحلة التعاقد^(١)، فاختيار لجنة البت للمتناقص هو اختيار مؤقت ولا يصبح هذا الاختيار نهائيا إلا بعد صدور قرار باعتماده من الجهة المختصة بإبرام العقد.

أولاً: السلطة المختصة بالتعاقد:

تنص المادة الاولى من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي انه: « يقصد " بالسلطة المختصة" الوزير - ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات في الجهات المنصوص عليها في المادة الاوليمن مواد اصدار هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه.».

ويتضح من هذا النص أن السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد - وبغض النظر عن قيمة هذا العقد - هي:

- الوزير ومن له سلطاته كرئيس الجامعة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 2024/2025 2024/2025

- المحافظ بالنسبة للتعاقدات التي تبرمها الوحدات المحلية المختلفة {المحافظة، المركز، المدينة، الحي أو القرية}.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.

هذا وقد أجاز المشرع للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها الواردة به لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون^(٢).

ثانياً: آثار اعتماد المناقصة:

يعتبر اعتماد المناقصة من قبل السلطة المختصة بمثابة قبول التعاقد مع الشخص الذي حددته لجنة البت، وعندما يصل هذا القبول إلى المتناقص ينعقد العقد.

(١) وإن كان هذا القرار - كما رأينا - رغم كونه إجراء تمهيديا فإنه تجتمع له مقومات القرار الإداري، ولذلك يجوز الطعن فيه استقلالا عن العقد أمام القضاء الإداري.

(٢) راجع: ٨١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ١٤ نوفمبر ١٩٧٣ هذا المعنى، حيث قالت: «.... ومن حيث ان القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، وبالتالي لا يعتبر التعاقد تاماً إلا إذا علم الموجب بقبوله»^(١).

ووفقاً للمادة ٣٩ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجب على إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقاً لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء، ويكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار .

ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تتجاوز يومين بعد انقضاء السبعة الأيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى كما يخطر باقي مقدمي العطاءات بذلك .

وفور إرسال خطابات الإخطار ينشر عن نتائج قرارات اللجان، وكذا عن نتيجة الترسية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان ظاهر للكافة، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر الآتي :

2024/2025

- نتائج القرارات، وأسبابها بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء أو الترسية للعطاءات أو استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت .
- القيمة النهائية للمشروع، وقيمة المكون الصناعي المصري الذي تم التعاقد عليه إن وجد .
- منشأ الصنع وبلده للمنتجات التي تضمنتها العقود التي أبرمت لشراء منتجات صناعية.

١. اداء التأمين النهائي:

أوجب قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في مادته ٤٠ على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين خلال عشرة أيام عمل بنسبة ٥% من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل، ويتم الإخطار بكتاب يرسل

(١) انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٦٨٨، لسنة ١٤٠١، الصادر في ١٤/١١/١٩٧٣، الموسوعة، ج١٨، ص٧٦.

بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، معه تعديده في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، ويجوز بموافقة السلطة المختصة منح مهلة إضافية للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام عمل .

وفي حالات التعاقد بالاتفاق المباشر والتي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل التعاقد، فيحجز ما يعادل نسبة ٥% من مستحقاته .

ولا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي إذا ورد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان، أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة (٥%) من مستحقاته .

ويكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ما لم تعدل مدة التعاقد، وإلا التزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد قيمة المصاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير في الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك .

وإذا تجاوزت قيمة التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير 2024/2025 2024/2025 طلب . وفي جميع حالات عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

٢. أثر عدم سداد التأمين النهائي

وفقا للمادة ٤١ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .

ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.



ويجب علي ادارة التعاقدات إبلاغ مصلحة الضرائب المصرية بقيمة العقود التي تجربها الجهة الادارية مع المتعاقد على ان يتضمن الاخطار الاتي:

2024/2025

كما يجب إبلاغ كل من المصلحة بأية تعديلات تطرأ على القيمة الإجمالية للعقد أو على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التي تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها. كما يجب على إدارة التعاقدات أيضا إبلاغ مصلحة الجمارك بالبيانات المشار إليها بالنسبة للعقود التي يدخل في مشمولها أصناف أو مهمات مستوردة.

سلطة الإدارة في عدم إتمام العقد

يترتب علي إرساء المناقصة التزام الإدارة . إذا رأت إبرام العقد . بأن تبرمه مع صاحب العطاء الذي اختارته لجنة البت، واختصاصها في هذا المجال اختصاص مقيد، إذ



تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير من رست عليه المناقصة وهذا المبدأ معروف بآلية المناقصة^(١).

إلا أن الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو في مصر يري أن الإدارة يحق لها دائما أن ترفض إتمام العقد، فهي تتمتع بسلطة تقديرية في رفض اعتماد المناقصة^(٢). وذلك حتى لا يفرض عليها التعاقد مع شخص لا تقلبه، أو إذا تبينت ملائمة اتخاذ هذا القرار لظروف تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحتها المالية أو الإدارية^(٣). ويعد حق الإدارة في عدم إتمام العقد مظهرا من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية وما تتضمنه من امتيازات تتمتع بها جهة الإدارة في مواجهة الأفراد^(٤).

إلا أنه إذا كان للإدارة السلطة التقديرية في رفض اعتماد المناقصة وبالتالي عدم إتمام العقد، فإن للأفراد الحق في الطعن بالإلغاء علي قرارات رفض الاعتماد، استنادا إلى الأسباب التي يجوز أن طعن بها علي السلطة التقديرية كإساءة استعمال السلطة^(٥)، أو الانعدام المادي أو القانوني لأسباب التي ذكرتها الإدارة للقرار^(٦). كما يحق لهم أيضا في حالة أصابهم أضرار من جراء هذه القرارات المطالبة بالتعويض أما علي أساس الخطأ، أو علي أساس الإثراء بلا سبب^(٧). وهذا ما يؤكد مجلس الدولة المصري، إذ تقرر محكمة

القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٢٧ مايو ١٩٦٢ سنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ أن مسؤولية الإدارة عن عدم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

(١) انظر: د. سعاد الشرقاوى، مرجع سبق ذكره، ص ٣٢٠.
(٢) انظر:

- C. E. 30 mars 1906, Ballande, Rec., p.278.
- C. E. 16 mars 1884, Lhermette, Rec., p.218.
- C. E. 9 juillet 1924, Anslme, Rec., p.662.
- C.E. 1^{er} août 1928, Schwall, Rec., p.975.

(٣) راجع: حكم محكمة القضاء الإداري رقم ٢٢، لسنة ١١ اق، الصادر في ١٨/١١/١٩٥٦، المجموعة، ص ٣١. وانظر أيضا حكمها، رقم ٢٦٧، لسنة ١١ اق، الصادر في ٢٨/٤/١٩٥٧، المجموعة، ص ٣٨٩.

(٤) انظر: احمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٧.
(٥) انظر:

- C. E. 12 décembre 1913, Commune de Biskra, Rec., p.1285.

(٦) انظر:

- C.E. 9 mars 1931, Société Les Cimentiers et macons d'art, Rec., p.1464.

- C. E. 31 décembre 1935, Société Hospices de Moralaix, Rec., p.1182.

(٧) انظر:

- C.E. 25 juillet 1947, Société d'Alfa, Rec., p.344.
- C.E. 19 mars 1910, Chemins de fer de Châteaubriant à Erba, Rec., p.302.

إتمام العقد ترتب للمتأقاص حقا في التعويض إذا كان هناك خطأ من الإدارة أو انحراف في استعمال السلطة أو علي أساس الإثراء بلا سبب^(١).

ويمكن الغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو في حالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .

ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات .

كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية :

١. إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء

واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من

إعادة الطرح ويشترط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية .

2024/2025

٢. إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات . 2024/2025

٣. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت

أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه .

ويكون الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار

من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة، ويجب أن يشتمل

القرار على الأسباب التي بني عليها، ويخطر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمة

البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني

أو الفاكس، بحسب الأحوال.

وفي جميع حالات الإلغاء، يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين

المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو

ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .

(١) حكم حكمة القضاء الإداري، رقم ٤٤، الصادر في ٢٧/٥/١٩٦٢، المجموعة، ص ٨٩.



المبحث الثاني

التعاقد عن غير طريق المناقصة أو المزايدة العامة

توجد عدة طرق أخرى استثنائية يمكن للإدارة أن تتعاقد من خلالها بخلاف أسلوب المناقصة أو المزايدة العامة. وسوف نتناول في هذا المبحث تلك الأساليب، وذلك في مطلبين علي النحو التالي:

المطلب الأول: الممارسة.

المطلب الثاني: الاتفاق المباشر.

المطلب الأول

الممارسة

الممارسة أسلوب من أساليب التعاقد الإداري تتيح للإدارة بعض الحرية في اختيار المتعاقد معها، فعن طريقه تستطيع الإدارة أن تتفاوض علنا مع عدد من الأفراد أو الشركات. كلما كان ذلك ممكنا. للتعرف علي عروض الاسعار التي يمكن التعاقد علي اساسها وشروطهم، ومن ثم تختار العطاء الأفضل من بينهم دون أن تلتزم بمبدأ آلية الإرساء علي مقدم العطاء الأقل كما هو الحال في أسلوب المناقصة.

ولقد اهتم المشرع المصري بتنظيم الممارسة كأسلوب للتعاقد الإداري في العديد من 2024/2025 2024/2025

المواد في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

التعاقد عن طريق الممارسة هو طريق استثنائي، يتم اللجوء اليه بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء علي عرض ادارة التعاقدات^(١). ويسري علي بنوعيتها الاحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون او لائحته التنفيذية^(٢).

وتأخذ الممارسة في مصر إحدى صورتين: الممارسة العامة، والممارسة المحدودة.

وهو ما سوف نوضحه فيما يلي:

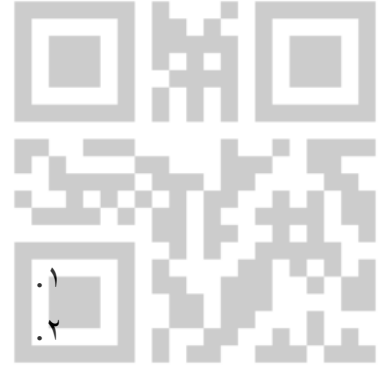
أولاً: الممارسة العامة:

طبقاً للمادة ٥٤ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢

لسنة ٢٠١٨، يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الآتية :

(١) راجع المادة: ٧ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٢) راجع المادة: ٦٠ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



١٥٨

١. أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد .
٢. أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمي والتي على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا .
٣. أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة.

ثانيا: الممارسة المحدودة

- وفقا للمادة ٥٤ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، يقتصر التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
١. الأصناف التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها، أو الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
 ٢. التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي .
 ٣. الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر.

ثالثا: آلية التمارس:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تتم الممارسة بنوعيتها بقيام مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنيا دون غيرهم بالتمارس في الجلسة المحددة لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولا لاختيار العطاء الأفضل شروطا تعاقدية والأقل سعرا، ما لم يكن التقييم فيها بنظام النقاط^(١).
وتستخدم المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات.

المطلب الثاني

الاتفاق المباشر

أجازت المادة ٧ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للإدارة أن تتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر، حيث نصت علي انه: «..... ويجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء علي عرض ادارة التعاقدات اجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

- أ. الممارسة العامة. ب. الممارسة المحدودة. ج. المناقصة المحدودة

(١) راجع المادة: ٥٦ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.





د. المناقصة ذات المرحلتين. هـ. المناقصة المحلية و. الاتفاق المباشر.

وعلي ذلك فالاتفاق المباشر وفقا من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اسلوبا من اساليب التعاقد تلجأ اليه الادارة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، فيتيح لها ان تتعاقد مع من تشاء من المتعاقدين فيما لا تزيد قيمته عن حدود مالية معينة، دون ان تنقيد باجراءات المناقصات والممارسات التي توجب توجيه الدعوة للراغبين في التعاقد مع الادارة لتقديم عروضهم المالية والفنية، ومناقشة المتعاقدين في جلسات علنية تسبق اعتماد السلطة المختصة. ولذلك يتميز الاتفاق المباشر كاسلوب تعاقدى بالاتي:

- اسلوب تعاقد استثنائي، لذلك لا تلجأ اليه الادارة الا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، وبالتالي لا يكون في مقدورها اتباع اجراءات المناقصات والممارسات العامة. فعلي سبيل المثال توريد الادوات الكتابية او المكتبية التي يجب توفيرها قبل بدء العام الدراسي، او في حالة احتكار المتعاقد للمواد التي تحتاجها الادارة او احتكاره لاختراع معين او عندما يكون تنفيذ عقد الاشغال العامة يتطلب خبرات او مهارات معينة او عندما تفرض السرية علي محل العقد كالمهمات المطلوبة امجازها لصيانة امن الدولة وحماية قواتها العسكرية او اتباع سياسة معينة 2024/2025 في نمط التسليح العسكري، او عندما يكون الاعتبار الشخصي امرا متطلبا في المتعاقد مثل عقد التزام المرافق العامة^(١).
- يحذر الادارة من القيود والاجراءات التي تنظم المناقصات والممارسات بكافة انواعها، فعلي سبيل المثال لا تنقيد بمبدأ اليه ارساء المناقصة. فهو يعطي للإدارة حرية واسعة في اختيار المتعاقد معها دون إتباع إجراءات معينة^(٢). فالادارة وفقا لهذا الاسلوب تستطيع ان تتفاوض وان تساوم المتعاقد علي كل شئ دون قيد او شرط بهدف الوصول الي افضل الشروط واقل الاسعار، ولهذا يطلق علي هذه الطريقة التعاقد او الشراء عن طريق الامر المباشر.

(١) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، الاسس العامة العقود الادارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٩. وراجع:

د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٤١.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٢.



- تخضع الإدارة عندما تختار هذا الأسلوب من التعاقد لبعض الضوابط مثل موافقة السلطة الإدارية المختصة علي استخدامه، وكذلك التقيد بحدود مالية محددة.....الخ.

أولاً: حالات الاتفاق المباشر:

وفقا للمادة ٦٢ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في أي من الحالات الآتية :

١. الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في الإمكان توقعها أو التنبؤ بها، أو التي تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فوري، ولا تحتل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما .
٢. وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد .
٣. تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا يوجد له سوى مصدر واحد .
٤. عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم، وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ .

٥ الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما، وذلك لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهات الإدارية، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر في اتخاذ الإجراءات .

٦. في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم .
٧. في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة. ويتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات المبينة قرين البنود (٥)، و (٦)، و (٧) المشار إليها.

ثانياً: سلطة التعاقد بالاتفاق المباشر:

وفقا للمادة ٦٣ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر طبقا لحكم المادة ٦٢ من هذا القانون بناء على ترخيص من :

١. رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار

المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

٢. الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال . ولمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند ٢.

كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقي الخدمات منخفضة القيمة والتي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه في المرة الواحدة، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية، ويتبع في شأنها الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للسلطة المختصة التفويض في اختصاصاتها في هذه الحالة فقط.

٣. الوزير المختص بالصحة بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولا يجوز لأي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .

ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة .

ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات إتباع طريق الاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



١٦٢

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





الباب الثالث

تنفيذ العقد الإداري

تتعترف العقود الإدارية لجهة الإدارة بسلطات متعددة - لا مثيل لها في عقود القانون الخاص - تضمن من خلالها تنفيذ العقد الإداري بطريقة تتماشى مع الصالح العام، وتضمن في نفس الوقت عدم توقف سير المرفق العام عن أداء خدماته. وفي مقابل تلك السلطات توجد حقوقا موازية للمتعاقد مع الإدارة.

ونوضح فيما يلي سلطات الإدارة المتعاقدة، ثم حقوق المتعاقد مع الإدارة، وذلك في فصلين متتاليين على النحو التالي:

الفصل الأول: سلطات الإدارة المتعاقدة.

الفصل الثاني: حقوق المتعاقد مع الإدارة.

الفصل الأول

سلطات الإدارة المتعاقدة

تملك الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري سلطات لا مثيل لها في عقود القانون الخاص، ويبرر ذلك دائماً بمقتضيات تحقيق الصالح العام وضرورة سير المرفق العام بانتظام وإيراد⁽¹⁾.

2024/2025

2024/2025

هذا وقد حدد القضاء الإداري مختلف السلطات التي تمتلكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فعلى سبيل المثال، في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٥٧ بعد أن أبرزت خصائص العقد الإداري، وفقا للمبادئ المقررة في القانون الإداري، قررت أن: «... وهذا القانون... يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته ثم سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت- حسب مقتضيات المصلحة العامة أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري. وهي تتمتع بهذه الحقوق والسلطات حتى ولو لم ينص عليها في العقد لأنها تتعلق بالنظام العام، وهذا كله دون أن يحتاج عليها بقاعدة قوة العقد الملزمة أو بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين بالمعنى المفهوم من ذلك في القانون المدني».

(١) راجع في ذلك: د: جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص ١٩٨. د: سعاد الشرقاوي: العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ص ٤٤٣.

- V. G. PEISER, Droit administratif, Dalloz, 11^{éd}, 1983, p.52.
- V. aussi G. PEQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif, 1945, p.306.



ومن هذا يبدو واضحاً أن كفتي المتعاقدين في العقود الإدارية غير متكافئة علي خلاف الأمر في العقود المدنية حيث يكون التعاقد ثمرة مناقشة حرة بين الطرفين، وحيث تنضبط حقوق الطرفين، والتزاماتها بما تنتهي إليه هذه المناقشة «^(١)).

وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا أيضاً في أحكامها، ومن ذلك حكمها الصادر بتاريخ ٢ مارس ١٩٦٨ الذي تقرر فيه: « إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة ويترتب علي ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه علي تنفيذ العقود الإدارية، ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها انه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا هو ما يقتضيه الصالح العام ، ولا يكون للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه حق، وذلك كله علي خلاف الأصل في العقود المدنية »^(٢).

وعلي ذلك تمارس الإدارة بصدد تنفيذ العقد الإداري السلطات الآتية: سلطة الرقابة، وسلطة تعديل بعض نصوص العقد من جانبها وحدها، وأخيراً سلطة توقيع جزاءات متنوعة علي المتعاقدين معها. وتتميز السلطات الممنوحة للإدارة بالخصائص الآتية:

2024/2025

2024/2025

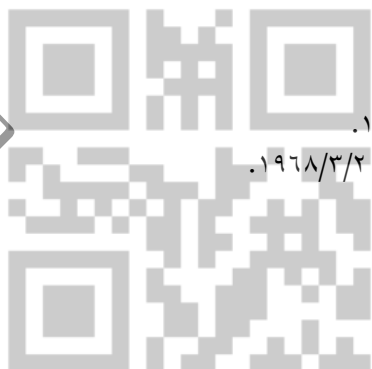
2024/2025

أولاً: تعد من النظام العام، لذلك لا يجوز للإدارة أن تُضمن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معها نص يفيد تنازلها عن استخدام تلك السلطات بعضها أو كلها، أو نص يفيد تقييد حقها في استعمال تلك السلطات. وإذا تضمن العقد مثل هذا النص فلا يعتد به، لان كل اتفاق يمنع الإدارة من استخدام السلطات الممنوحة لها أو يقيد هذا الاستخدام يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ثانياً: تعد حقاً أصيلاً للإدارة تتمتع بها دون حاجة إلى النص عليها في العقد ذاته، وبناء علي ذلك إذا تضمن العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها النص علي بعض تلك السلطات دون البعض الآخر، فإن ذلك لا يعني علي الإطلاق أن الإدارة لا تستطيع ممارسة السلطات الغير منصوص عليها، ذلك لأن الإدارة تستمد حقها في ممارسة تلك السلطات من الطبيعة الإدارية للعقد ذاته لا من اتفاق الطرفين عليها صراحة أو ضمناً.

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، رقم ٩٨٢ ، سنة ٧ ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٨٨٢، لسنة ١٣ ق، الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٣/٢.



وسوف نتناول السلطات الممنوحة للإدارة بمزيد من التفصيل في ثلاثة مباحث متتالية نحل في الأول حقها في الرقابة، وتبرز في الثاني حقها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، وأخيرا ندرس في الثالث مدى إمكانية توقيع الإدارة جزاءات علي المتعاقد معها متى أخل بالتزاماته، وذلك علي النحو التالي:

المبحث الأول: حق الإدارة في الرقابة.

المبحث الثاني: حق الإدارة في تعديل العقد بالإرادة المنفردة.

المبحث الثالث: حق الإدارة في توقيع جزاءات علي المتعاقد.

المبحث الأول

حق الإدارة في الرقابة

من خلال دراستنا لحق الإدارة في الرقابة نتناول بالتحليل أربع نقاط رئيسية. وهي علي النحو التالي: مفهوم حق الرقابة، الأساس القانوني لهذا الحق، ومدى سلطة الرقابة وحدودها، وسوف ندرس كل نقطة منهم في مطلب مستقل كما يلي:

المطلب الأول

مفهوم حق الرقابة

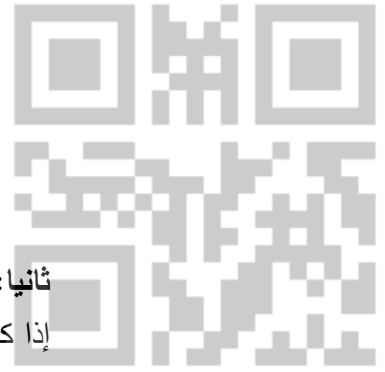
تهدف الإدارة من ممارسة سلطتها الرقابية التأكد من تنفيذ عقودها الإدارية، فهذه السلطة تعد من ضمانات تنفيذ العقد الإداري^(١). ولحق رقابة الإدارة علي المتعاقد معها أثناء تنفيذ التزامه معنيان، أحدهما ضيق والآخر واسع.

أولاً: حق الإدارة بالرقابة بالمعني الضيق «حق الإشراف علي المتعاقد»:

يقصد بحق الإدارة في الرقابة علي المتعاقد بالمعني الضيق أن ينحصر دورها في التحقق من أن المتعاقد يباشر تنفيذ العقد طبقاً للشروط المنظمة له. وحق الإدارة في الرقابة بهذا المعني الضيق ما هو إلا تطبيقاً للقواعد العامة المطبقة في تنفيذ العقود بصفة عامة. وتمارس الإدارة هذا الحق عن طريق إيفاد مهندسين لزيارة مواقع العمل، والتأكد من تطوره وسيره وفقاً للمواعيد، وفحص المواد المستخدمة للاطمئنان إلى صلاحيتها وجودتها، والاطمئنان إلى أن كل شئ يسير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويعد تدخل الإدارة ممهداً لاستلام العمل عند إنجازه، فهو جزء من عملية الفحص اللازمة عند التسليم.

(١) انظر:

- V. L. RICHER, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J., 1995, Les garanties de L'exécution, p.200.



ثانياً: حق الإدارة بالرقابة بالمعنى الواسع «حق توجيه المتعاقد»:

إذا كان حق الإدارة بالرقابة بالمعنى الضيق - أي حقها في الإشراف علي تنفيذ المتعاقد لالتزامه - أمر لا جدال فيه، حيث انه ثابت بمقتضى العقد حتى لو كان عقدا من عقود القانون الخاص، فإن للإدارة الحق في أن تتدخل بدرجة تزيد عن حد التأكد من سلامة تنفيذ العقد بما يتفق والشروط الواردة به، فلها أن تتدخل في توجيه أعمال التنفيذ باختيار انسب الطرق وأصلح الأوضاع التي تراها مناسبة لحسن سير المرفق، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها صراحة في العقد، وإلا تعدي الأمر إلى تعديل في شروط العقد وأصبحنا أمام سلطة أخرى هي سلطة تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة والذي سوف ندرسه فيما بعد.

المطلب الثاني

الأساس القانوني لسلطة الرقابة

يتميز العقد الإداري عن العقد المدني بطابع خاص مناطه سد احتياجات المرفق العام بما يكفل أداءه لوظيفته وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة. ومن مقتضيات هذا الطابع أن يكون للإدارة سلطة الرقابة علي تنفيذ عقودها الإدارية^(١)، ولكن يشترط التساؤل عن الأساس القانوني لهذه السلطة.

2024/2025

وحتى يمكننا الإجابة عن هذا التساؤل، ينبغي أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول عند وجود النص القانوني أو الاتفاقى المبين لحدود هذه السلطة، والأمر الثاني عند غياب هذا النص القانوني أو الاتفاقى^(٢).

أولاً: سلطة الرقابة المنصوص عليها:

قد يرد النص علي سلطة الرقابة في القوانين^(٣) واللوائح المختلفة المنظمة للعقود الإدارية، فعلي سبيل المثال اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تورد صوراً مختلفة لحق الإدارة في مراقبة مقاول الأشغال العامة وإخضاعه لتوجيهاتها طوال مرحلة التنفيذ. فهي تقرر في المادة ١٠٨ في فقرتها

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٨٨٢، لسنة ١٣٠٣، الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٣/٢. وكذلك حكمها في الطعن رقم ٩٧، لسنة ٢٠٠٢، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٤/٢٠.

(٢) انظر: د. احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ١٩٧٣، ص ٢٩١.

(٣) راجع علي سبيل المثال، نص المادة ٧ من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٨، و التي توضح حق منح الالتزام - أي الإدارة - في مراقبة إنشاء المرفق موضوع الالتزام و سيره من النواحي الفنية و الإدارية.



الأولى أن : « يلتزم المقاول بتنفيذ محل العقد - بحسب الاحوال - في الميعاد او المواعيد المحددة بأمر التوريد او الاسناد ، وعليه اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بتنفيذ موضوع العقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط ». وأيضاً تقرر المادة ١٢١ في فقرتها الرابعة أن: « يقوم مهندس الجهة الإدارية بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول أو مهندسة أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين فإذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مهندس الجهة الإدارية ».

كما قد ترد نصوص صريحة في العقد أو في دفاتر الشروط تبين كيفية ممارسة الإدارة لسلطة الرقابة والوسائل التي تتبع في مباشرتها، كما تحدد الضمانات المقررة للمتعاقد في مقابل ذلك.

في هذه الأحوال فإنه يجب تطبيق تلك النصوص، وتقوم السلطة الرقابية للإدارة مرتكزة عليها.

ثانياً: سلطة الرقابة غير المنصوص عليها:

من المسلم به فقهاً وقضاً في مصر وكذلك في فرنسا، أنه إذا لم ينص العقد أو 2024/2025 2024/2025
دفاتر الشروط على حق الجهة الإدارية في مراقبة تنفيذ العقد وإذا لم تقرر القوانين واللوائح هذا الحق وتنظمه، فإن سلطة الإدارة في الرقابة توجد بذاتها دون استناد إلى نص خاص يقرها باعتبارها سلطة أصيلة تقوم مرتكزة على المبادئ العامة في القانون الإداري (١). وإذا تضمن العقد نصوصاً تقرر هذه السلطة، فإنها لا تنشأ ابتداءً، بل يقتصر دورها على تنظيمها وبيان وسائل وشروط مباشرتها، أي أن هذه النصوص لا تعتبر نصوصاً تعاقدية، ولكن تعد نصوص ذات طابع تنظيمي (٢).

وقد أكد القضاء الإداري المصري في العديد من أحكامه وجود هذه السلطة مستقلة عن العقد ودفاتر الشروط، بل واعتبرها من النظام العام. فعلى سبيل المثال في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧ قررت المحكمة فيه: « أن شروط

(١) انظر: د: احمد عثمان عياد ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٩٥. و راجع أيضاً، د: سليمان محمد الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الرابعة ١٩٨٤، ص ٤١٠.

(٢) انظر: د: توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصرية، الطبعة الأولى ١٩٥٤-١٩٥٥، ص ٧٩١.

العقد الإداري هي مظهر لإرادة لها سلطة إلزام ممن يقبل أن يكون خاضعا لقانونها، وأن هذا القانون - وهو دستور العقود الإدارية - يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة علي تنفيذ العقد ، وسلطة توقيع الجزاءات علي المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته ثم سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت - حسب مقتضيات المصلحة العامة أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري. وهي تتمتع بهذه الحقوق والسلطات حتى ولو لم ينص عليها في العقد لأنها تتعلق بالنظام العام»^(١).

أما عن الموقف الفقهي من الأساس القانوني لسلطة الرقابة في حالة سكوت العقد عن إيراد نص ينظم عملية وأسلوب الرقابة، فقد اختلف الفقه بشأنه إلى عدة وجهات نظر: **فيري جانب فقهي أول:** إلى أن الطبيعة القانونية للمرفق العام وحدها هي الأساس القانوني لهذه السلطة. ويستند هذا الجانب الفقهي إلى أن مبدأ وجوب تسيير المرفق العام بانتظام واطراد يعطي للإدارة حتى في حالة سكوت العقد، الحق في مراقبه تنفيذه وتوقيع جزاءات مختلفة القوة علي المتعاقد الذي يقصر في هذا التنفيذ بما يكفل انتظام سير المرفق دون عائق^(٢).

في حين يذهب جانب فقهي ثاني: إلى انه في حالة سكوت العقد فإن الطبيعة القانونية للمرفق العام لا تعد الأساس القانوني الوحيد لسلطة الرقابة، ولكن يوجد إلى جانبها فكرة **الفكرة المشتركة للمتعاقدين** كإرادة ضمنية **مستخلصة من ظروف التعاقد**^(٣).

2024/2025

ويري جانب فقهي ثالث: إلى انه في حالة سكوت العقد فإن سلطات الإدارة في الرقابة تركز علي مقتضيات الصالح العام التي يقع علي عاتق الإدارة تحقيقها في نشاطها التعاقدية كما في سائر أنشطتها الأخرى^(٤).

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، رقم ٩٨٢ ، سنة ٧ ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

(٢) راجع في ذلك: د: توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص ٧٩١.

- G. JEZE, Les contrats administratifs de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, 1932, tome 2, p 336.
- V. aussi, Concl. TARDIEU sur C.E. 6 décembre 1907, Cie. P.L.M., Rec., p. 918.

(٣) انظر:

- G. PEQUIGNOT, Théorie générale des contrats administratifs, Jurisclasseur administratif, 1962, fasc.510, p.9,11,17.
- V. aussi, J. GEORGEL, Les contrats de l'administration, Jurisclasseur administratif, 1968, fasc.510, p. 6.

(٤) انظر:

- V. A. de LAUBADERE, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 1956, tome 2, p.319.

وأخيراً يري جانب فقهي رابع: أن حق الرقابة المقرر للإدارة علي المتعاقد معها في حالة سكوت العقد تركز علي أساس قانوني مزدوج يتكون من فكرة تحقيق الصالح العام (وما تشمله من تحقيق مقتضيات المرافق العامة) كهدف ومبرر لوجود هذه السلطة، و من فكرة امتيازات السلطة العامة والتي تعتبر سلطة الرقابة تطبيقاً من تطبيقاتها^(١).

ونحن نري أن الرقابة تستمد أساسها من فكرة المرفق العام، ذلك أن الإدارة هي المسؤولة عن إدارة المرفق العام وضمان حسن سيره بانتظام واطراد، وإذا لم تتولى بنفسها توفير الحاجات وتقديم الخدمات التي يتطلبها المرفق العام - ذلك في حالة إعطائها هذه المهمة إلى الأفراد- فهي مع ذلك تظل المسؤولة عن إدارة المرفق ، وتقتضي وظيفتها هذه أن تشرف علي النشاط الفردي حين يساهم في تسيير المرفق العام. والدليل علي صواب هذا الاتجاه هو انحياز المشرع المصري لهذا الرأي، إذ تعرض في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٨- بشأن تعديل قانون التزام المرافق العامة رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧- إلى الأساس القانوني لفكرة الرقابة بقوله: « حق الرقابة علي الملتزم حق أساسي مرده إلى فكرة المرفق العام وما يقتضيه سيره وانتظامه. وهو حق ثابت للجهة مانحة الالتزام ولو لم ينص عليه في العقد، بل يظل طالما وجد المرفق العام».

المطلب الثالث

2024/2025

2024/2025

مدي سلطة الرقابة

إذا كان حق الإدارة في الرقابة ثابتاً لها في كل العقود الإدارية بلا استثناء . حيث انه متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق علي استبعاده أو تقييده - إلا أن مدي استعماله يختلف باختلاف العقود الإدارية:

أولاً: عقود الأشغال العامة:

تتمتع الإدارة في عقود الأشغال العامة بقسط وافر من حق الرقابة، فتملك سلطتي الإشراف والتوجيه أثناء تنفيذ عقد الأشغال العامة. فللموظفين الفنيين المنتدبين للإشراف والرقابة الحق في رفض المواد أو لأعمال التي يرون إنها من نوع رديء أو غير مطابق للمواصفات الفنية الثابتة في العقد. ولهم أيضاً سلطة الأمر بإعادة البناء أو إعادة القيام بالأشغال. وعلي المقاول أن يزيل فوراً - في مثل تلك الأحوال - من موقع العمل المواد التي يكون قد رفضها الموظفون الفنيون، أو يهدموا أو يعيدوا تنفيذ الأشغال التي لم يوافق عليها،

(١) انظر: د: احمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٠٠-٣٠١.

والا قامت الإدارة بإزالتها علي نفقته الخاصة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إلى اتخاذ إجراءات قضائية.

ثانياً: عقد التزام المرافق العامة:

تملك الإدارة في عقد التزام المرافق العامة سلطات رقابية كبيرة، ويرجع ذلك إلى أن الملتزم يقوم بنفسه بإدارة المرفق ومن ثم يحق للإدارة أن تتدخل في كل وقت لتغيير أسلوب الملتزم في الإدارة أو طريقته في التعامل مع المنتفعين بخدمات المرفق^(١).

ولأهمية هذا الحق في عقد التزام المرافق العامة، فقد نصت عليه ونظمته المادة ٧ من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ (المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٨)، حيث تقول: « لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية. وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرافق، ويختص هؤلاء المندوبين بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الالتزام. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي اقتراح الوزير مانح الالتزام أو المشرف علي الجهة مانحة الالتزام، أن يعهد إلى ديوان المحاسبة "الجهاز المركزي للمحاسبات الآن" بمراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية أو أن يعهد بالرقابة الفنية والإدارية إلى أية هيئة عامة أو خاصة. كما يجوز للوزير المختص أن يقرر تشكيل لجنة أو 2024/2025 أكثر من موظفي وزارته أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولي أمر من أمور الرقابة علي التزامات المرافق العامة. وفي هذه الحالة يتولى ديوان المحاسبة أو الهيئة المكلفة بالرقابة دراسة النواح التي ينيط بها رقابتها وتقديم تقرير بذلك إلى كل من الوزير المختص والجهة مانحة الالتزام .

وعلي الملتزم أن يقدم إلى مندوبي الجهات التي تتولى الرقابة وفقاً للأحكام السابقة، كل ما قد يطلبوه من أوراق أو معلومات أو بيانات أو إحصاءات، كل ذلك دون الإخلال بحق مانح الالتزام في فحص الحسابات والتفتيش علي إدارة المرفق في أي وقت .»
وعلي ذلك بمقتضى هذا النص يكون للإدارة الحق أن تشرف علي الملتزم أثناء إعداد المرفق العام أو أثناء استغلاله، وأن تجبره علي تنفيذ كافة الشروط الواردة في وثيقة الالتزام إذا أخل بها.

(١) انظر: د: جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠١.

نأالشا: عقود التوريد:

في عقود التوريد تمارس الإدارة سلطتها الرقابية للثثبت من أن المتعهد سلم الأصناف المتعاقد عليها وفقا للمواصفات والعينات المعتمدة والموقع عليها منه. ويجوز لمندوبي الإدارة رفض صنف أو أكثر من الأصناف الموردة في حالة مخالفتها للمواصفات والعينات المعتمدة.

هذا وقد نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ شروط تنفيذ عقود التوريد، فننص المادة ١١٣ علي أن: « يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يتم توريده بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور المورد أو مندوبه ويعطي عنه إيصالا مؤقتا مختوما بخاتم الجهة الإدارية موضحا به اليوم والساعة التي تم فيها التوريد ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المورد بميعاد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص و الاستلام النهائي ويجب أن يتم ذلك الإخطار في خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور الإيصال المؤقت وعلي أمين مخزن الاستقبال فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك 2024/2025 2024/2025 لاتخاذ اللازم ».

كما تنص المادة ١١٧ من اللائحة علي انه: « إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلا عنها و يجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي علي الأكثر ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره فإذا تأخر في سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع ٥% من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد وتخضم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويكون البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة ».

وأیضا تنص المادة ١١٤ من اللائحة في فقرتها الأولى علي ان: « تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف

وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقة من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة ».

المطلب الرابع حدود سلطة الرقابة

مهما اتسعت سلطة الإدارة في الرقابة علي المتعاقد معها، فأنها ليست سلطة مطلقة المدى. إذ تخضع لضوابط تعمل علي توفير بعض الضمانات للمتعاقد مع الإدارة. ويمكن رد هذه الضوابط في إطار ضابطين أساسيين (١):

الضابط الأول: احترام مبدأ المشروعية:

فلا يجوز لجهة الإدارة أن تستعمل سلطتها الرقابية لتحقيق غرض لا يتصل بسير المرفق العام موضوع التعاقد وإلا كان في ذلك إساءة لاستعمال السلطة. فعلي سبيل المثال إذا اصدر مهندس الإدارة المكلف بالرقابة علي تنفيذ عقد أشغال عامة - وفقا لحكم المادة (١٠٨) (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ - أمرا إلى المقاول بفصل بعض العمال بحجة إهمالهم تنفيذ العقد. فيجوز للقضاء أن يفحص أمر الفصل فيما إذا كان متصلا بالمقاولة ومستندا إلى خطأ من جانب العمال المفصولين ومبنيا علي أساس صحيح أو غير 2024/2025 2024/2025 ذلك لبيان إذا كان الفصل نتيجة لإساءة استعمال السلطة.

الضابط الثاني: عدم تعديل موضوع العقد:

يجب علي الإدارة حين ممارسة سلطتها الرقابية أن تستخدمها في إطار نصوص العقد وشروطه ولا تتجاوزها إلى فرض شروط أخرى جديدة أو تعديل شروط قائمة. فسلطة الإدارة في الرقابة لها نطاق معين لا يجوز لها أن تتعدها، وهذا النطاق هو الحد الفاصل بين سلطة الرقابة وبين سلطة تعديل نصوص العقد، بحيث إذا تجاوزت الرقابة هذا النطاق فإننا نصبح أمام سلطة تعديل نصوص وشروط العقد لا سلطة الرقابة علي تنفيذه. ويترتب علي هذا التجاوز استحقاق المتعاقد تعويضا ماليا إذا أضر من جراء ذلك. فمثلا في عقد الأشغال العامة، إذا اتخذت الإدارة إجراءات معينة للتأكد من أن المقاول يستعمل ذات المواد

(١) انظر: د: توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص ٧٩٢-٧٩٣. د: طعيمة الجرف، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤٣. د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٤، ص ٢٤٢. د: احمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص ٣٠٢ وما بعدها. (٢) حيث أنه وفقا لحكم المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية يلتزم المقاول بتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش.

المتفق عليها في العقد أو حددت المواد التي يجب عليه استعمالها في حالة عدم النص في العقد علي تلك المواد، فإنها هنا تباشر سلطتها الرقابية بمعناها الواسع، أي سلطة التوجيه، ولكنها عندما تقرر إحلال مواد مختلفة محل المواد المتفق عليها فإنها تعدل شرطا من شروط العقد.

المبحث الثاني

حق الإدارة في تعديل العقد بالإرادة المنفردة

من المبادئ المستقرة في نطاق القانون الخاص أن العقد شريعة المتعاقدين، فالعقد ملزم لطرفيه، فليس لأي منهما أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة، ولا يجوز له نقض العقد أو تعديله إلا برضاء الطرف الآخر أو وفقا لما يقرره القانون. وتنص علي هذا المبدأ صراحة المادة ١٤٧ من القانون المدني المصري بقولها: «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون». وعلي نفس المبدأ ينص القانون المدني الفرنسي، ففي مادته ١١٣٤ يقول: «الاتفاقات التي تمت علي وجه شرعي تقوم بالنسبة لمن عقدها مقام القانون».

وإذا كان هذا هو الأصل العام في مجال عقود القانون الخاص، فإن الأمر علي خلاف ذلك في مجال عقود القانون العام. ففي العقود الإدارية يجوز للإدارة أثناء تنفيذ العقد 2024/2025 أن تعدل مدى التزامات المتعاقد معها، فتزيد من الأعباء الملقاة علي عاتقه أو تنقصها، ذلك بإجراء صادر من جانبها وحدها. أي بإرادتها المنفردة. بل لها أن تنهي العقد إذا ما رأت أن مقتضيات المرفق العام تستدعي ذلك، كأن تقدر أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري للمصلحة العامة أو انه أصبح غير متفق وحاجات المرفق العام^(١).

ومما لا شك فيه أن حق الإدارة في تعديل نصوص العقد وشروطه تعد اخطر من حقها في الرقابة في أقصى صورها. كما أوضحناه في المبحث السابق. فالإدارة هنا لا تتدخل في مجال غير منصوص عليه في العقد، وإنما تحاول أن تغير في الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد إما بالزيادة أو بالنقص. لذلك يتعين علينا دراسة موقف القضاء والفقهاء من هذه السلطة «المطلب الأول»، تحديد أساسها القانوني «المطلب الثاني»، ومعرفة القيود التي ترد علي حق التعديل «المطلب الثالث» وأخيرا توضيح الأثر المترتب علي ممارسة الإدارة لحقها في التعديل المنفرد «المطلب الرابع».

(١) انظر: د: توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص ٨٠٢.

١٧٤

المطلب الأول

وجود سلطة التعديل الانفرادي في العقود الإدارية

يتعين علينا لمعرفة مدى وجود حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بالإرادة المنفردة أن ندرس الموقف الفقهي والقضائي في كل من فرنسا ومصر فيما يتعلق بهذا الموضوع.

الفرع الأول

موقف القضاء و الفقه بشأن سلطة الإدارة

في تعديل عقودها الإدارية في فرنسا

أولاً: موقف القضاء الفرنسي:

ذكرنا سابقاً أن مجلس الدولة الفرنسي كان يُخضع . في أول الأمر . العقود الإدارية لنفس الأحكام التي تخضع لها العقود المدنية، لذلك لم يكن من الجائز تعديل أي نص من نصوصها، وبصفة خاصة عقود التزام المرافق العامة، إلا باتفاق أطراف العقد^(١). علي أنه عدل عن هذا الأمر وأخذ لأول مرة بشكل صريح بمبدأ سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية، وكان ذلك من خلال حكمة الصادر بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩١٠ بشأن عقد التزام مرفق نقل « **Compagnie générale des tramways** »، والذي قرر فيه انه يجوز 2024/2025 2024/2025 للإدارة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه ضروريا للوفاء بالحاجات العامة ولتحقيق المصلحة العامة، بقطع النظر عما تقرره نصوص العقد. فلها أن تفرض علي الملتزم أداء خدمات تزيد عن تلك التي ينص عليها العقد، مستندة في ذلك لا إلى نصوص العقد التي تمنحها هذا الحق، بل باعتبارها ممثلة للمصلحة العامة^(٢). وقد اخذ القضاء الإداري الفرنسي في أحكامه التالية بهذا المبدأ الجديد^(٣).

(١) انظر:

- C.E 25 janvier 1903, Chemins de fer économiques du Nord, s. 1904.3.49 (Concl. Teissier)note Hauriou.
- C.E. 30juin 1905, Tramways de Paris, Rec. P. 607.

(٢) انظر:

- C.E. 11 mars 1910, Compagnie générale des tramways, Rec. P. 216. (Concl. Blum), R.D.P. 1910, p.270.

(٣) انظر علي سبيل المثال :

- C.E. 9 février 1951, Ville de Nice, Re., p.80.
- C.E. 25 janvier 1952, Ministre de la guerre, R.D.P., p. 521.
- C.E. 2 février 1984, Union des transports publics, R.D.P. 1984, 212, note Auby.



الفرع الثانى

موقف الفقه و القضاء بشأن سلطة الإدارة

في تعديل عقودها الإدارية في مصر

فلقد استقرت أحكام مجلس الدولة المصري على تخويل الإدارة حق تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، بل أن العديد من هذه الأحكام جاءت بطريقة تفصيلية واضحة²⁵ لتبين أحكام وضوابط هذا الحق، ومن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ١٦ ديسمبر، والذي ينص علي: «.... ومقتضى هذه السلطة أن الإدارة تملك من جانبها وحدها وإرادتها المنفردة . على خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم . حق تعديل العقد

(١) انظر:

- V. J.L'HUILLIER, Les contrats administratifs tiennent-ils lieu de loi à l'administration! D. 1953, Chronique xvll, p.87 et s.

(٢) انظر:

- V. G. JEZE, Le régime juridique du contrat administratif, R.D.P., 1945. p. 256 et s.

(٣) انظر:

- V. A. DE LAUBADER, op. cit., p.24.
- V. G. PEQUIGNOT, Théorie générale des contrats administratifs, Jurisclasser administratif, 1962, fasc.510, p.5.
- V. M. ROUSSET, L'idée de puissance publique en droit administratif, thèse, Paris, 1960, p.149.



أنشاء تنفيذه وتعديل مدي التزامات المتعاقد معها علي نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد، فتزيد من الأعباء الملقاة علي عاتق الطرف الآخر أو تنقصها وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو النقص علي خلاف ما ينص عليه العقد. وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل، ومن غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله أو إلا باتفاق الطرفين وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها علي فكرة استمرار المرافق العامة، تفترض مقدما حدوث تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير المرفق. وأن التعاقد معها يتم علي أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن الإدارة و هي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره تملك حق تعديل العقد بما يوائم هذه الضرورة وتحقيق تلك المصلحة. ومن ثم كانت سلطة التعديل مستمدة لا من نصوص العقد فحسب بل من طبيعة المرفق واتصال العقد الإداري به وضرورة الحرص علي انتظام سيره^(١).

كما أن المحكمة الإدارية العليا تؤكد هذا الحق، وتبرزه في العديد من أحكامها، ومن ذلك حكمها الصادر في ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٢، والذي تقرر فيه انه: « من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة ويترتب علي ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه علي تنفيذ العقود الإدارية ولها دائما حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يترأى لها انه اكثر اتفاقا مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يقيد سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوي أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة»^(٢).

(١) محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم، ١٦٠٩ لسنة ١٠ق، الصادر بتاريخ ١٦/١٢/١٩٥٦، ص ٩٠. وراجع أيضا حكمها، في القضية رقم ٩٨٣، لسنة ٧ق، الصادر بتاريخ ٣٠/٦/١٩٥٧. وحكمها، في القضية رقم ٦٨٤٩، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ٤/٦/١٩٦١.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٥٦، لسنة ٣٥ق، الصادر بتاريخ ٢٨/٤/١٩٩٢، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاما، ص ٤٠٠. وراجع أيضا: المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٩٥٤، لسنة ١٢ق، الصادر بتاريخ ١١/٤/١٩٧٠. والطعن رقم ٨٤٥، لسنة ١٩ق، الصادر بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٨٠. و أيضا الطعن رقم ٣٩٨٦، لسنة ٣٥ق، الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٩٩٢، مجموعة المبادئ القانونية....، ص ٤٠٤.



وأيضاً فيما يتعلق بالفقه المصري، فإنه يذهب في مجموعة علي التأكيد علي حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية، سواء وجد نص في العقد أو في دفاتر الشروط يتيح ذلك أو لم يوجد هذا النص^(١).

رأينا أن سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية كانت محل خلاف في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي، وعلي عكس ذلك نجدتها كمبدأ عام مستقر في الفقه والقضاء المصري، ويرجع ذلك إلى المشرع المصري الذي اعترف منذ فترة طويلة بحق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، وبالتالي ساعد هذا الأمر علي صيرورة هذا الحق من الأمور المسلم بها في الفقه والقضاء المصري ويتضح ذلك مما يلي:

▪ **في القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ (المعدل) المنظم لعقد التزام المرافق العامة،** أكدت مادته الخامسة علي أن: « لمانح الالتزام دائماً متي اقتضت ذلك المصلحة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به وذلك مع مراعاة حق الملتزم في التعويض إن كان له محل ».

▪ **في ظل القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٥:** نصت المادة ٨٧ من لائحته التنفيذية علي أن : « تحتفظ الوزارة أو المصلحة بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقصان ^{2024/2025} في حدود ١٥% في عقود التوريد، ٣٠% في عقود توريد الأغذية، ٢٥% في عقود الأعمال دون أن يكون للمتعهد أو المقاول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ». كما أن المادة ٩٣ من ذات اللائحة نصت علي أن: « علي المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكول إليه تنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر من الوزارة أو المصلحة أو السلاح بمقتضى ما يكون مخولاً لها من حقوق في العقد..... ».

▪ **في ظل قانون المناقصات و المزايدات رقم ٩ لسنة ١٩٨٣:** ورد في المادة ٨٠ من لائحته التنفيذية حكم مجمل يقرر مبدأ الزيادة والنقصان في الكميات المتعاقدة علي شرائها أو القيام بها، فالفقرة الأولى من تلك المادة تقرر أن: « المقادير

(١) انظر في ذلك : د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤١٧. د: كامل ليله، نظرية التنفيذ المباشر، رسالة، ١٩٦٢، ص ١١٦. د: احمد عثمان عاد، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٣ و ما بعدها. د: فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، سنة ١٩٦٤/٦٣، ص ١٢١٨.

والأوزان الواردة بجدول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعا لطبيعة العملية. والغرض فيها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة، والأثمان التي تدفع للمقاول تكون علي أساس الكميات التي تنفذ فعلا، سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الوارد بالمقايضة أو الرسومات، وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايضة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد، وبمراعاة ألا يؤثر ذلك علي أولوية المقاول في ترتيب عطائه.»

■ **في ظل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالي رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨:** تقرر المادة ٧٨ من لائحته التنفيذية أنه: « يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود ٢٥% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة. ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك علي أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه..... ».

■ **في ظل قانون تنظيم تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨** 2024/2025 2024/2025

٢٠١٨: تقرر المادة ٤٦ أنه: « إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز (١٥%) من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك . ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص».

المطلب الثاني

الأساس القانوني لحق الإدارة في التعديل

اختلف الفقه في فرنسا ومصر في تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة إلى اتجاهات متعددة، ولكن يمكننا التمييز



في هذا الشأن بين اتجاهين رئيسيين: **أولهما** يؤسس سلطة الإدارة في التعديل علي فكرة السلطة العامة، **وثانيهما** يؤسسها علي فكرة احتياج المرافق العامة

الاتجاه الأول: أساس سلطة التعديل يقوم علي فكرة السلطة العامة:

يرى هذا الاتجاه أن أساس سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بالإرادة المنفردة يُستمد من خارج الرابطة التعاقدية، فوفقاً لهذا الاتجاه تعد القرارات التي تصدرها الإدارة بتعديل عقودها الإدارية من أعمال السلطة العامة، وأن الإدارة لا تمارس بمقتضاها امتيازاً عقدياً، وإنما تستعمل حقاً تملكه كسلطة إدارية، وأن هذا الحق يعد من النظام العام^(١).

الاتجاه الثاني: أساس سلطة التعديل يقوم علي فكرة احتياج المرفق العام.

يرى هذا الاتجاه أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة يقوم علي فكرة احتياج المرفق العام. ويتزعم هذا الاتجاه في فرنسا الأستاذ « اندريه دي لوبادير **A. de Laubadère** » حيث يؤكد أن قيام الإدارة المتعاقدة بتعديل عقودها ، لا يمكن منطقياً أن يؤسس إلا علي فكرة مستلزمات المرافق العامة والتغييرات التي تحدث فيما يتعلق بهذه المستلزمات، في حاجات المرفق أو حاجات الجمهور نفسه. فالفكرة الأساسية أن الإدارة لا يمكن أن تكون مقيدة دائماً بعقود، تصبح عديمة الفائدة، أو بشروط تعاقدية تصير غير متجاوبة، مع احتياجات المرافق العامة^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولهذا **الاتجاه مؤيدون في الفقه المصري**: فيري الدكتور سليمان الطماوي، أن سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية مناطها احتياجات المرافق العامة. كما أن سلطة

(١) انظر:

- V. G. PEQUIGNOT, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, thèse, Montpellier, 1945, p.367 et s.
- V. F. DELMAS, Du pouvoir de l'administration de modifier les prévisions du marché de travail public, thèse, Paris, 1945, p. 44 et 45 et 109.

وراجع أيضاً من الفقه المصري: د: كامل ليله، مرجع سبق ذكره، ص ١١٥ وما بعدها. د: احمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص ٢١٨.

(٢) انظر:

- V. A. de LAUBADERE, op. cit., p.335.
- V. A. FLAMME, Traité théorique et pratique des marchés publics, Tome 2, Bruxelles-Brulant, 1969, p.179 et s.
- V. G. PEQUIGNOT, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, op. it., p. 367.



التعديل لا يمكن اعتبارها مجرد مظهرا للسلطة العامة الممنوحة لجهة الإدارة، وإنما هي نتيجة مباشرة لفكرة المرفق العام، والتي يرجع إليها باستمرار معظم قواعد القانون الإداري^(١). ويرى الدكتور طعيمة الجرف أيضا أن أساس سلطة الإدارة في تعديل عقودها هي فكرة المرفق العام وحتمية مسابرة تغيرات الحاجات العامة. وهو بهذا المعنى ينتهي إلى أن سلطة التعديل تعتبر ملازمة للمرفق العام^(٢).

وكذلك يذهب الدكتور توفيق شحاتة، في أن أساس سلطة التعديل يؤسس علي فكرة المرفق العامة، حيث ينبغي دائما الوفاء بحاجات تلك المرافق لتتمشى مع التطورات الحديثة التي قد يستلزمها مقتضى سير المرافق العامة. ولا شك أن الإدارة، دائما صاحبة الاختصاص الأصيل في تنظيم المرفق العام وفي تحديد قواعد تسييره، وعند الضرورة في تعديل هذه القواعد^(٣).

ونحن نتفق مع الاتجاه الثاني الذي يؤسس سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية علي فكرة احتياجات المرافق العامة، وهو ما يؤيده . علي نحو ما رأينا . الرأي الغالب في فرنسا ومصر. بل واستقرت عليه أحكام مجلس الدولة المصري. ففي حكم محكمة القضاء الإداري علي سبيل المثال الصادر بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٧٠ تقرر أن: «..... أن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها تفترض مقدما جديشا تغير في ظروف العقد وملابساته وطرائق تنفيذها تبعاً لمقتضيات سير المرفق، وأن التعاقد في تلك العقود يتم علي أساس أن نية الطرفين متي انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة. ومن شأن ذلك أن يكون لجهة الإدارة وهي صاحبة الحق في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره، حق تعديل العقد....»^(٤).

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٢١.

(٢) انظر: د: طعيمة الجرف، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، ١٩٦٤، ص ٤٠٩.

(٣) انظر: د: توفيق شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص ٨٠٢ و ما بعدها.

(٤) محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٧٤١، لسنة ٢١ ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٠/٣/٢٢. وانظر بذات المعنى والاتجاه: حكمها في القضية رقم ٩٤٧، لسنة ٢٢ ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٠/٣/١. وحكمها في القضية رقم ٧٣٠، لسنة ٢٣ ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٠/١٢/٦. وتؤكد هذا الاتجاه المحكمة الإدارية العليا، فتقول: «... وهذا الحق لجهة الإدارة في تعديل العقد بما يشمله من إنهائه يترتب علي ما للعقود الإدارية من تميز عن العقود المدنية بطالع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة فلإدارة دائما وفقا لمقتضيات الصالح العام سلطة إنهاء العقد من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب، او بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين،

المطلب الثالث

القيود التي ترد علي حق التعديل

سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية وإن كانت سلطة أصيلة . حيث توجد في حالة سكوت العقد ودفاتر الشروط وتخضع لها جميع العقود الإدارية . إلا إنها ليست مطلقة، إذ ترد عليها العديد من القيود:

أولاً: القيود التشريعية:

تنص المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في فقرتها الثاني علي أن: « ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص. ».

وبناء علي هذا النص، يتعين علي الإدارة حينما ترغب في تعديل عقودها الإداري أن تحصل علي موافقة السلطة المختصة، وأن تتحقق من توافر الاعتماد المالي، وأن تصدر قرار التعديل أثناء تنفيذ العقد، وفيما يلي نشرح ما أجملناه:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١. موافقة السلطة المختصة:

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي أنه: « السلطة المختصة: الوزير، ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات في الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه .

ذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها يحكمها مبدأ سير واستمرار المرافق العامة وهي تفترض مقدما حصول تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات حسن سير المرفق العام وانتظامه ويقوم التعاقد فيها علي أساس أن نية الطرفين قد انصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن جهة الإدارة . هي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره . تملك حق تعديل هذا العقد بما يتواءم مع هذه الظروف المتغيرة مع الضرورة ويحقق تلك المصلحة العامة أو إنهاء العقد إذا ما استلزمت ذلك ضرورة الوفاء بحاجات المرفق العام المحققة للمصلحة العامة « المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٣٩٨٦، لسنة ٣٥ق، الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٩٩٢، مجموعة المبادئ القانونية....، ص ٤٠٤. وانظر بذات المعني والاتجاه، الطعن رقم ٨٨٢، لسنة ١٠ق، الصادر بتاريخ ٢/٣/١٩٦٨، سابق الإشارة إليه. والطعن رقم ٩٥٤، لسنة ١٥ق، الصادر بتاريخ ١١/٤/١٩٧٠.

ووفقاً للمادة ٨١ من ذات القانون تقررمع مراعاة الحالات التي يحظر هذا القانون التفويض فيها، يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها الواردة به لشاغلي الوظائف القيادية دون غيرهم، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتضح من هذا النص أن السلطة الإدارية المختصة التي يتعين موافقتها علي تعديل العقد - بغض النظر عن نوع أو قيمة هذا العقد - هي:

- الوزير ومن له سلطاته كرئيس الجامعة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- المحافظ بالنسبة للتعاقدات التي تبرمها الوحدات المحلية المختلفة { المحافظة، المركز، المدينة ، الحي أو القرية}.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.

هذا وقد أجاز المشرع للسلطات الإدارية المختصة - السابق الإشارة إليها - التفويض في اختصاصاتها ومنها بالطبع الموافقة علي تعديل العقد، علي أن يكون هذا التفويض لشاغلي الوظائف الأدنى منهم مباشرة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن موافقة السلطة المختصة بمفردها كاف علي تعديل العقد بما لا يجاوز ٢٥% من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز ١٥% من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأشعار، على أن تتضمن كراسة الشروط 2024/2023 والمواصفات مضمون ذلك، ولا يتطلب ذلك موافقة المتعاقد.

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا علي هذا القيد، وهذا واضح من حكمها الصادر بتاريخ ٢٢/ يناير سنة ١٩٨٠، حيث تقول انه: «... لا سبيل إلى قيام التعديل والالتزام به قانوناً، ما لم تلتزم الإدارة عند إجرائه بقواعد الاختصاص المقررة فلا يتأتى التعديل إلا من السلطة المختصة بإجرائه، ولا ينتج غير ذلك من التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة أثراً ما في تعديل العقد وتحوير آثاره وتغيير مقتضاه»^(١).

٢. توافر الاعتماد المالي:

الأصل أن الإدارة لا تستطيع أن تمارس نشاطاً يتكلف أعباء مالية إلا إذا وجد الاعتماد المالي المخصص لذلك في الموازنة العامة. ورأينا أن توافر هذا الاعتماد المالي يشكل قيوداً علي الإدارة حال إبرام العقد الإداري، فلا يجوز لها إبرام عقد إداري لا تتوافر له مصادر التمويل.

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٨٤٥ ، لسنة ١٩٩٠ق، الصادر بتاريخ ١/٢٢/١٩٨٠، مجموعة المبادئ... ص ٣٩٢.

ويسرى علي تعديل العقد الإداري - في حالة التعديل بزيادة التزامات المتعاقد - نفس الحكم السابق، حيث أن التعديل بالزيادة يترتب عليه حتما زيادة في النفقات، ومن ثم لابد من توافر اعتماد مالي لمواجهة تلك الزيادة، وذلك حتى لا يكون في هذا التعديل إرهاقاً للخزانة العامة، الأمر الذي قد يؤثر علي أولويات وخطط التنمية^(١).

أما في حالة استعمال الإدارة سلطتها في تعديل العقد، وذلك بإنقاص التزامات المتعاقد معها، فإنه من وجهة نظرنا لا تلتزم الإدارة بهذا القيد، حيث لا يترتب علي هذا التعديل أية زيادة في النفقات بل علي العكس توفير في النفقات، ومن ثم فلا جدوى من هذا القيد في هذه الحالة.

٣. أن يصدر قرار التعديل إنشاء سريان العقد:

في حالة رغبة جهة الإدارة تعديل عقدها الإداري، يجب عليها الإفصاح عن تلك الرغبة وذلك بإصدارها قرارا بالتعديل، ويجب صدور هذا القرار في أثناء سريان العقد. وهذا قيد منطقي لأنه متى انتهى العقد فلا مجال لتعديله، حيث أن تعديل العقد بزيادة التزامات المتعاقد أو إنقاصها لا يرد إلا علي عقد قائم وساري.

أما في حالة عدم إفصاح الإدارة عن رغبتها في تعديل العقد تلتزم بتنفيذه كله وفقاً لشروطه، ويجب عليها تمكين المتعاقد من تنفيذ التزامه معها، وبهذا المعنى قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ٤ يونيو ١٩٦١ بأنه: « ولئن كان لها (الإدارة) أن تعدل العقد بإنقاص الكمية المتعاقد عليها أو زيادتها متى اقتضت ذلك حاجة المرفق أو أن تنهي العقد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، فإن مناط ذلك أن تفصح الإدارة عن إرادتها في استعمال هذه الحقوق بقرار صريح، فإن هي لم تفصح عن ذلك التزمت بتنفيذ العقد كله وفقاً لشروطه ووجب عليها تمكين المتعاقد معها من تنفيذ التزاماته بتمامها وأن تيسر له هذا التنفيذ وألا تحرمه بفعلها من الحقوق التي يربتها له العقد »^(٢).

ثانياً: القيود العامة للتعديل:

١. أن يقتصر قرار التعديل علي شروط العقد المتصلة بالمرفق العام:

أوضحنا فيما سبق أن الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية يرتكز علي فكرة احتياجات المرفق العام، لذلك فإن سلطة الإدارة في التعديل تقتصر علي شروط العقد المتصلة بالمرفق العام، أي الشروط التي تمس تنظيم المرفق العام وتتعلق

(١) انظر: د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٨.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٦٨٤٩، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٩٦١/٦/٤.

باحتياجاته وكيفية إشباع احتياجات الأفراد، ومن أمثلة تلك الشروط أسلوب العمل بالمرفق، طريقة تنفيذ العقد الإداري والجداول الزمنية لمعدلات التنفيذ، والجوانب الفنية والإدارية للتنفيذ، فتلك الشروط تملك الإدارة تعديلها بإرادتها المنفردة دون أن تتوقف علي رضا المتعاقد معها ودون اللجوء للقضاء^(١).

أما الشروط الأخرى المنبئة الصلة بفكرة احتياجات المرفق العام فلا تملك الإدارة تعديلها، وقد استقر الفقه والقضاء الفرنسي^(٢) علي أن هذه الشروط تتمثل في المزايا المتفق عليها للمتعاقد وعلي الأخص العناصر المالية للعقد، مثل أجره المستحق عن عمله، أو ثمن السلع والخدمات التي يقدمها للإدارة، أو الأرباح المالية التي تتحقق له من ممارسة نشاطه.

وقد أقر مجلس الدولة المصري هذا التفسير، فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن جهة الإدارة لا تملك أن تمس بالتعديل المزايا المتفق عليها في العقد والتي يتمتع بها المتعاقد معها، وهذا واضح من حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٥٧، والذي تقول فيه أن: «... وسلطة التعديل هذه، وإن كانت تشمل جميع العقود الإدارية بما فيها عقد الأشغال، وتبدو في أبرز مظاهرها فيما تعلق بالعقد المذكور، اعتباراً بأن جهة الإدارة هي صاحبة الاختصاص الأول والأصيل فيما يتعلق بهذه الأشغال، إلا أن تلك السلطة ليست علي كل حال مطلقة، بل ترد عليها قيود منها أن جهة الإدارة لا تملك أن تمس بالتعديل المزايا المالية المتفق عليها في العقد والتي يتمتع بها المتعاقد معها....»^(٣).

وينفس الأمر قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٧٧، ففيه تقول أنه: «المسلم به فقهاً وقضاءً أن شروط عقد التزام المرفق العام تنقسم

(١) انظر: د: إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ٢٠٠٣، ص ٤٣.
(٢) انظر:

- V. A. de LAUBADERE, op. cit., p.335.
- V. G. PEQUIGNOT, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, op. cit., p. 365.

وانظر أيضاً أحكام مجلس الدولة الفرنسي التالية:

- C.E. 7 août 1891, Morelli, D., 1893,318.
- C.E. 16 novembre 1928,Ravier, Rec., p.1193.
- C.E. 1^{er} mars 1932, Mourier, Rec., p.340.
- C.E. 11 juillet 1941,Hopital-Hospice de Chauny, Rec., p.129.
- C.E. 9 mars 1951, Didonna, Rec., p. 149.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٩٨٣، لسنة ٩٩، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

إلى نوعين: شروط لائحية وشروط تعاقدية، والشروط اللائحية فقط هي التي يملك مانح الالتزام تعديلها بإرادته المنفردة في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة دون يتوقف ذلك على قبول الملتزم، والمسلم به أن التعريف أو خطوط السير وما يتعلق بها من الشروط اللائحية القابلة للتعديل بإرادة مانح الالتزام المنفردة»^(١).

٢. أن يقتصر التعديل على موضوع العقد فلا يخرج عليه:

لا تستطيع جهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد التزامات لا صله لها بالعقد معه، فسلطتها في التعديل تقتصر على موضوع العقد فقط ولا تتعداه. فإذا اتخذت الإدارة قراراً بتعديل شروط العقد وأضافت شروطاً أجنبية لا علاقة لها بموضوعه، فإن قرارها هذا يعد باطلاً ويكون بوسع المتعاقد معها الامتناع عن تنفيذه دون أن تملك الحق في توقيع جزاءات عليه. إضافةً إلى إمكانية لجوء المتعاقد معها إلى القضاء الإداري لإلغاء هذا القرار الباطل^(٢).

غير أن معرفة الالتزامات التي تدخل في نطاق موضوع العقد الأصلي، وتلك التي ليس لها صله بهذا الموضوع مسألة دقيقة للغاية ولا يوجد معيار محدد لها، إلا أنه يمكننا أن نورد بعض الأمثلة الموضحة لهذا الموضوع، فعلى سبيل المثال إذا تعاقدت إدارة الجيش مع المتعهد لتوريد علف للحيوانات (الخيول)، فلا يجوز للإدارة أن تعدل من شروط العقد بأن^{2024/2025} تلزم المتعهد بتوريد الوقود اللازم للسيارات بحجة أن الجيش قد استبدل الخيول بسيارات النقل. وكذلك لا تستطيع الإدارة أن تستبدل بمرفق الإضاءة مرفقاً للنقل أو العكس أي أنه ليس لها أن تطلب من ملتزم الإضاءة أن يقوم بالتزام النقل أو العكس^(٣).

وقد سار مجلس الدولة المصري في هذا الاتجاه، فأعلن في أكثر من حكم أن حدود التعديل التي يجب على الإدارة عدم تجاوزها وأهمها ألا يصل التعديل إلى تغيير موضوع العقد.

فعلى سبيل المثال في حكم محكمة القضاء الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٥٦ تقرر أن: «...سلطة التعديل هذه وإن كانت تتناول وتشمل جميع العقود الإدارية بما فيها عقود التوريد، إلا إنها ليست مطلقة بل ترد عليها قيود...ومن هذه القيود ما يتصل بمقدار الأعباء الجديدة التي تلقي على عاتق المتعاقد مع الإدارة نتيجة لممارستها هذه السلطة إذ

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١١٠، لسنة ١٣١٣، الصادر بتاريخ ١٢/٣١/١٩٧٧.

(٢) انظر: د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص ٢٥١.

(٣) هذه الأمثلة مشار إليها لدى، د: ثروت بدوي، المرجع السابق، ص ٨٤.

يجب أن تكون تلك الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها وأهميتها، لا أن يكون من شأنها فسخ العقد الأصلي أو تبديل موضوعه أو إنشاء محل جديد له غير ما تم الاتفاق عليه....»^(١).

وكذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الأعمال الإضافية يتعين أن تكون من ذات ونوع الأعمال الأصلية المتعاقد عليها، ففي حكمها الصادر بتاريخ ٢٩ أبريل سنة ١٩٨٩ أوضحت المحكمة أن: «...الأعمال الإضافية يتعين أن تكون من ذات ونوع جنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلي عليها عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الإضافية الماثلة للأعمال الأصلية»^(٢).

٣. أن يكون قد حدث تغير في الظروف يبرر تعديل العقد:

من المسلم به أن الإدارة، وهي تتعاقد، لا تبدو كفرد عادي يبرم العقود لتحقيق مصلحته الخاصة، ولكنها تتعاقد لتحقيق المصلحة العامة. ومن المسلم به أيضا أن مستلزمات المصلحة العامة لا تكون دائما ثابتة، فهي تتغير بتغير الوقت والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية للمكان والزمان. ومن هنا يبرز فكرة تغير الظروف، والتي بمقتضاها أن العقود التي أبرمت في زمن معين وفي ظل ظروف معينة، يمكن تحقيقاً للمصلحة العامة . أن يجري تعديل بعض شروطها التي قد تعرقل إمكان مساهمة العقد للحدث الجديد، وبالتالي يمكن أن يحقق العقد ما كان يهدف إليه منذ إبرامه، وهو تحقيق النفع العام لجهة الإدارة والأفراد علي السواء^(٣).

أما في حالة عدم تغير الظروف، لا تستطيع الإدارة تمارس سلطاتها في التعديل، بل يجب عليها أن تلتزم باحترام شروط التعاقد كما هي منصوص عليها في وثيقة العقد عند إبرامه، لان القول بغير ذلك سيؤدي إلى إطلاق الحرية للإدارة في التحلل من التزاماتها التعاقدية التي ارتبطت بها بمقتضى العقود التي سبق لها إبرامها^(٤).

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ١٦٠٩، لسنة ١١ق، الصادر بتاريخ ١٦/١٢/١٩٥٧.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١٩٤٤، لسنة ٣٣ق، الصادر بتاريخ ٢٩/٤/١٩٨٩.

(٣) انظر: د: علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ١٩٧٦، ص ٢٦٩ وما بعدها.

(٤) انظر: د: محمد فؤاد مهنا، مرجع سبق ذكره، ص ١٢١٩، ١٢٢٠.

هذا ويشترط مجلس الدولة الفرنسي، لكي تستطيع جهة الإدارة تعديل عقودها الإدارية، أن تكون الظروف قد تغيرت عما كانت عليه وقت إبرام العقد بحيث تصبح شروط العقد غير متلائمة مع مقتضيات سير المرفق وغير محققة للمصلحة العامة^(١).

كما أن مجلس الدولة المصري كثيراً ما يذكر فكرة تغير الظروف، كشرط من شروط تعديل العقد الإداري. فقد قضت محكمة القضاء الإداري، في حكمها الصادر بتاريخ ٢٢ مارس سنة ١٩٧٠ بأنه: « ليس ثمة نزاع علي أن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها، تقتض مقدماً حدوث تغير في ظروف العقد وملابساته، وطرائق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير المرفق، وأن التعاقد في تلك العقود يتم علي أساس أن نية الطرفين قد انصرفت عند التعاقد، إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق، وتحقيق المصلحة العامة... وسلطة التعديل هذه... ليست مطلقة بل ترد عليها قيود، منها إنها تقتصر علي نصوص العقد المتصلة بسير المرفق وحاجته ومقتضياته... ويشترط لممارسة تلك السلطة أن تكون قد استحدثت ظروف بعد إبرام العقد تبرر التعديل... »^(٢).

وتؤكد نفس الاتجاه المحكمة الإدارية العليا، ففي حكمها الصادر بتاريخ ١٥ نوفمبر ١٩٩٢ تقول: « ومن حيث أن سلطة جهة الإدارة في تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية... »^(٣) ٢٠٢٤/٢٠٢٥
٢٠٢٤/٢٠٢٥
هي الإدارية عن نظام العقود المدنية، ومقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة مستهدفة حسن سير وانتظام المرافق العامة في أداء الخدمات العامة علي النحو الذي يحقق الصالح العام تملك من جانبها وحدها وإبرادتها المنفردة . وعلي خلاف المؤلف في معاملات الأفراد فيما بينهم . حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل التزامات المتعاقد معها علي نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد فتزيد من أعباء الطرف الآخر . أو تنقصها بشرط أن تقضى حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل..... وهذا الحق لجهة الإدارة في تعديل العقد بما يشمل من إنهائه يترتب علي ما للعقود الإدارية من تميز عن العقود المدنية بطالع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة فللإدارة دائماً وفقاً لمقتضيات الصالح العام سلطة إنهاء العقد من

(١) انظر: د: احمد عثمان عياد، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٠.

(٢) محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٧٤١، الصادر بتاريخ ١٩٧٠/٣/٢٢، المجموعة، ص ٢١.
وانظر أيضاً حكمها، في القضية رقم ١٦٠٩، لسنة ١٩٦١، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/١٢/١٦، وفيه تقرر أن: « ذلك لان طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها علي فكرة استمرار المرافق العامة تقتض مقدماً حدوث تغير في ظروف العقد وملابساته..... ».

غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب، أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها يحكمها مبدأ سير واستمرار المرافق العامة وهي تفترض مقدما حصول تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعا لمقتضيات حسن سير المرفق العام وانتظامه ويقوم التعاقد فيها علي أساس أن نية الطرفين قد انصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن جهة الإدارة . هي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره . تملك حق تعديل هذا العقد بما يتواءم مع هذه الظروف المتغيرة مع الضرورة وبحقق تلك المصلحة العامة أو إنهاء العقد إذا ما استلزمت ذلك ضرورة الوفاء بحاجات المرفق العام المحققة للمصلحة العامة»^(١).

٤ . عدم تجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية أو المالية:

لا تستطيع الإدارة أن تفرض علي المتعاقد معها تغييرات مبالغا فيها، أي تغييرات تتجاوز حدود إمكانياته المالية والاقتصادية أو الفنية. فمن المتيقن أن المتعاقد مع الإدارة قبل إبرامه للعقد قام بدراسة متأنية لموضوع التعاقد . في ضوء ما يملكه من إمكانيات مالية وفنية ، ثم انتهى إلى الموافقة علي القيام بتنفيذ هذا العقد. لذلك يتعين علي الإدارة عند إجراء التعديل أن تحرص علي مراعاة تلك الاعتبارات المالية أو الفنية، وألا يصل الأمر إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا علي عقب^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فإذا خرجت الإدارة عن القيد السابق، بأن عدلت العقد تعديلا من شأنه إلقاء التزامات جديدة علي عاتق المتعاقد معها تجاوز إمكانياته المالية أو الفنية مما نتج عنه قلب لاقتصاديات العقد، فإن من حق المتعاقد إما أن يطلب فسخ العقد، أو يطلب تعويضا عن كافة النتائج الضارة التي ترتبت من قيامه بتنفيذ هذه التعديلات^(٣). بل وله أيضا أن يتمتع عن تنفيذ تلك التعديلات التي تجاوز إمكانياته الفنية أو المالية^(٤).

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٣٩٨٦، لسنة ٣٥ق، الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٩٩٢، مجموعة المبادئ القانونية....، ص ٤٠٤.

(٢) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٢٤. وانظر أيضا مجلس الدولة الفرنسي في نفس المعني:

- C.E. 5 juin 1918, Daux, Rec., p.536.
- C.E. 23 juin 1920, Briançon, Rec., p.626.

(٣) انظر:

- V. A. DE LAUBADERE, *op. cit.*, p.390.

(٤) انظر: د: توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص ٨٠٥، ٨٠٦.

وانظر أيضا مجلس الدولة الفرنسي في نفس المعني:

- C.E. 16 novembre 1928, Ravier, Rec., p.1193.
- C.E. 1 mars 1932, Mourier, Rec., p.340.



وباستعراض أحكام مجلس الدولة المصري، نجد تأكيداً على إبراز أن سلطة الإدارة في التعديل المنفرد ليست مطلقة، بل تحدّها ضوابط عديدة، ومنها بالطبع هذا القيد المتمثل في عدم مجاوزة الأعباء الجديدة الحدود المعقولة ولا الإمكانات الفنية والمالية أو الاقتصادية للمتعاقد ولا تؤدي إلى قلب اقتصاد العقد رأساً على عقب، وأجاز . في حالة مخالفة الإدارة لهذا القيد . للمتعاقد الامتناع عن التنفيذ أو فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات إن كان لها وجه. وهذا واضح تماماً من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧، والذي تقرر فيه أن: «..... إلا أن تلك السلطة ليست علي كل حال مطلقة، بل ترد عليها قيود... ومنها كذلك أنه إذا كان من شأن التعديل زيادة أعباء المتعاقد مع الإدارة، إلا أنه لا يصح أن تجاوز الأعباء الجديدة الحدود الطبيعية المعقولة في نوعها وفي أهميتها، أو أن تفوق في قيمتها أو نتائجها ما اتفق عليه أصلاً في العقد، بدرجة كبيرة، أو أن يكون من شأنها أن تقلب اقتصاد العقد رأساً على عقب، بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جديد.... أو أن تؤدي الأعباء الجديدة إلى إرهاقه وتجاوز إمكانياته الفنية أو المالية أو الاقتصادية، وإلا جاز له أن يمتنع عن التنفيذ، بل أن له أن يطلب فسخ العقد...»^(١).

لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ لم تعد مطلقة، بل قيدها المشرع بالآلا تتجاوز في طلبها كميات أو حجم العقد المبرم معها زيادة أو نقصاً عن الحدود الواردة بنص المادة ٤٦، حيث تنص المادة المشار إليها إلى أنه: «إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز ٢٥% من كمية كل بند لعقود المقاولات، وبما لا يجاوز ١٥% من كمية كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك»^(٢).

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٩٨٣، لسنة ١١ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠. وانظر في نفس المعنى حكمها ، في القضية رقم ١٦٠٩، لسنة ١١ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/١٢/١٦. ويؤكد المحكمة الإدارية العليا نفس الأمر في قضائها، ومن ذلك حكمها الصادر في ١١ أبريل ١٩٧٠، الذي توضح فيه أن: «..... كما أن لها "الإدارة" سلطة تعديل العقد بحيث لا يصل التعديل إلى الحد الذي يخل بتوازنه المالي، وإلا كان للطرف الآخر في هذه الحالة التمسك باعتبار العقد مفسوخاً، والمطالبة بالتعويضات إن كان لها وجه». انظر المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٩٥٤، لسنة ١٢ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٠/٤/١١.

(٢) انظر المادة ٤٦ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.



والمستفاد من هذا النص أن المشرع وضع أصلاً عاماً في مجال تنفيذ العقود الإدارية، مقتضاه إلزام المتعاقد مع الجهة الإدارية بقبول طلبها تعديل كميات أو حجم العقد المبرم معها زيادة أو نقصاً في الحدود الواردة به، فإذا باشرت جهة الإدارة حقها هذا فلا خيار أمام المتعاقد معها من الخضوع للطلب والالتزام بتنفيذه سواء أكان بالزيادة أو بالنقص بذات الشروط والأسعار المتفق عليها، ولا يكون له علي أي حال أن يطالب بتعويض عن ذلك.

٥. صدور قرار التعديل مستوفياً لأركان المشروعية الإدارية:

في جميع الحالات التي يجوز للإدارة فيها أن تعدل من شروط العقد الإداري، يجب عليها احترام القواعد العامة للمشروعية عند إجراء هذا التعديل^(١). فقرار التعديل يجب أن يصدر من شخص مختص بإصداره وفي الشكل وبالإجراءات المقررة وفقاً للقواعد القانونية واللائحية التي تحكم هذا الموضوع، وأن تستهدف تحقيق الصالح العام. فإذا خرج قرار التعديل علي مبدأ المشروعية كان قراراً باطلاً، ويكون في استطاعة المتعاقد مع الإدارة الطعن عليه بالإلغاء أمام قاضي العقد^(٢).

المطلب الرابع

أثر استعمال الإدارة لحق التعديل

2024/2025

2024/2025

2024/2025

من المسلم به أن الإدارة في ممارستها لسلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة، إنما تستعمل حقها وهذه السلطة لا تستمدّها الإدارة من نصوص العقد بل من النظام العام لسير المرافق العامة، ومن ثم فحق الإدارة في التعديل مقرر بغير حاجة إلى النص عليه في العقد أو إلى موافقة المتعاقد عليه. وفي حالة إشارة نصوص العقد إلى حق الإدارة في إجراء هذا التعديل، فإن ذلك لا يكون إلا مجرد تنظيم لسلطة التعديل وبيان أوضاع ممارستها وما يترتب علي ذلك دون أن يكون في ذلك أي مساس بالحق الأصيل المقرر للجهة الإدارية في التعديل ولا اتصال هذه السلطة بالنظام العام للمرافق العامة، ومن المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة نفسها أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة لأنها تتعلق بكيان المرافق العامة^(٣).

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٢٣.

(٢) انظر:

• C.E. 18 juillet 1930, Cie P. L.M. et autres, R.D.P., 1930, p.141.

(٣) في نفس المعني انظر: المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٣٩٨٦، لسنة ٣٥ ق، الصادر بتاريخ

١٩٩٢/١١/١٥، مجموعة المبادئ القانونية....، ص ٤٠٤.

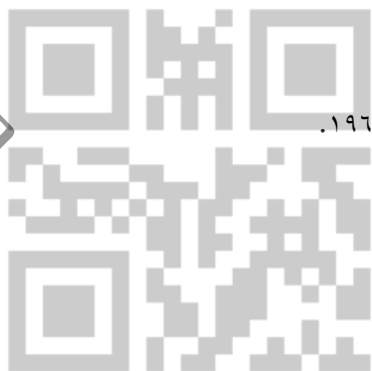


٣. **فسخ العقد:** وذلك في حالة التعديل الذي يجاوز المؤلف، فللمتعاقدين أن يتمتعوا بتنفيذ العقد و يطالبون بفسخ العقد كما أوضحنا سابقاً.

2024/2025

هذا وتختلف الجزاءات في العقود الإدارية عن الجزاءات في العقود المدنية في أمرين: **أولهما:** أن الجزاءات في القانون الإداري متنوعة وتعرف صورا لا نظير لها في القانون المدني^(٢)، **وثانيهما:** انه حتى في حالة وجود جزاء معروف في القانون المدني،

(۲) انظر: د: سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ۴۴۹.



فإن التنظيم القانوني لهذا الجزاء يختلف في نطاق القانون الإداري عنه في نطاق القانون الخاص^(١).

والجزاء التي تملك الإدارة توقيعها علي المتعاقد معها متنوعة ويمكن ردها استناداً إلى موضوعها وإلى هدفها إلى الأنواع التالية:

أولاً: جزاءات مالية: وهذه الجزاءات كما هو واضح من اسمها، عبارة عن مبالغ مالية توقع علي المتعاقد في حالة إخلاله بالتزاماته.

ثانياً: جزاءات ضاغطة: وهي الجزاءات التي تهدف إلى إجبار أو إكراه المتعاقد المقصر أو المتخاذل علي تنفيذ التزامه.

ثالثاً: جزاءات الحل أو الفسخ: وهي الجزاءات التي تهدف إلى إنهاء الرابطة التعاقدية.

رابعاً: جزاءات جنائية: وهذه الجزاءات ذات استخدام محدود في مجال العقود الإدارية، إذ تقتصر علي الحالات التي يوجد فيها نص علي اعتبار الإخلال بالتزام عقدي جريمة وتحديد عقوبة لها في نص قانوني أو لائح.

وقد أوضح القضاء الإداري المصري المبادئ المتعلقة بحق الإدارة في توقيع

الجزاءات علي المتعاقد معها، وبين الأسس القانونية لتطبيقها، **فعلي سبيل المثال، محكمة** 2024/2025 2024/2025

القضاء الإداري تؤكد في حكمها الصادر في ٢٤ نوفمبر ١٩٥٧: « أن كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة لا يقتصر علي أن يكون إخلالاً بالتزام تعاقدي فحسب، وإنما فيه أيضاً مساس بالمرفق العام الذي يتصل بالعقد. واتصال العقد الإداري بالمرفق العام، ضرورة الحرص علي حسن سير هذا المرفق بانتظام واطراد...يوجب أن تكون الجزاءات المترتبة علي هذا الإخلال شديدة، وتتطوي في الواقع علي معني العقوبة، ولا تتفق مع أحكام القانون المدني. ومن هذه الجزاءات سلطة توقيع الغرامة عند التأخير في التنفيذ، ثم سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل الإدارة بنفسها محل المتعاقد معها في تنفيذ الالتزام أو أن تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر. ويتم هذا الإجراء علي حساب وتحت مسؤولية المتعاقد مع الإدارة، فيتحمل نتائجه المالية. وثالث هذه الجزاءات حق الإدارة في الفسخ أي إلغاء العقد بدون الالتجاء إلى القضاء، وذلك في حالة تقصير المتعاقد مع الإدارة تقصيراً جسيماً.....ومن حيث أن هذه الجزاءات هي ضمانات جري العرف الإداري علي ذكرها في العقود الإدارية،

(١) انظر: د: محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، تنظيم الإدارة - نشاط الإدارة - وسائل الإدارة، بدون سنة أو دار نشر، ص ٦٤٣.



وإن كانت لا تستقيم مع قواعد القانون المدني من فسخ أو تنفيذ عيني مع التعويض في الحالتين وإن كان له مقتضى لا تكفي للحيلولة دون عبث المتعاقد مع جهة الإدارة، وإخلاله بالصالح العام، بل لابد لصيانة الصالح العام والأمن العام من وجود جزاءات رادعة يجري توقيعها علي المتعهد المتخلف أو المقصر دون إتباع أي قواعد أو إجراءات ضيقة أو بطيئة كقواعد القانون المدني، لأن قواعد هذا القانون لا تستقيم مع السرعة والليونة التي يستلزمها حسن المرافق العامة. وهذه هي العلة في انطواء مثل هذه الجزاءات في الواقع علي معني العقوبة، بل هي في الواقع عقوبة يجري توقيعها علي المتعهد المتخلف بمجرد قيام سببها، وبصرف النظر عن القواعد التي يقرها القانون الخاص.....»^(١).

هذا وتتميز الجزاءات الإدارية بسمات وخصائص عامة، وفي نفس الوقت يتميز كل جزء من الجزاءات الإدارية بسمات خاصة تميزه عن غيره من الجزاءات ونظام قانوني خاص به، غير أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء علي المتعاقد معها ليست سلطة مطلقة، بل يرد عليها العديد من القيود، والتي تمثل ضمانات للمتعاقد مع الإدارة في نفس الوقت. وهو ما سنعرض له من خلال دراسة الخصائص المشتركة للجزاءات الإدارية، ثم نبين القيود الواردة علي حق الإدارة في توقيع الجزاء، وأخيراً نحلل التنظيم القانوني لكل جزء علي حدة، من خلال دراسة أنواع الجزاءات الإدارية، وذلك علي النحو التالي:

2024/2025

المطلب الأول: الخصائص العامة للجزاءات الإدارية.

المطلب الثاني: القيود الواردة حق الإدارة في توقيع الجزاء.

المطلب الثاني: أنواع الجزاءات الإدارية.

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٤١٨٦، لسنة ١٩٩٠ ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/١١/٤. وتؤكد المحكمة الإدارية العليا تلك المبادئ في العديد من الأحكام الصادرة عنها، فعلي سبيل المثال، في حكمها الصادر بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٦٣، تقول: «أن للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد و مصادرة التأمين وشطب الاسم، وهذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها علي المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معلوماته معها. ولما كان توقيع هذه الجزاءات إنما يهدف أساساً إلى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره وانتظامه تحقيقاً للمصلحة العامة ومن حق جهة الإدارة توقيعها دون انتظار لحكم من القضاء، فإنه لا وجه لاتخاذ أي إجراء يحول دون استعمال الجهة الإدارية لهذا الحق بأية صورة من الصور مهما يكن من أمر ما يدعيه المدعي في هذا الشأن عند نظر أصل الموضوع ذلك أن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازن في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام وإنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض إذا كان لذلك أساس من القانون». راجع المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١١٠٩، لسنة ٨٠ق، الصادر بتاريخ ١٩٦٣/١٢/٢٨.





المطلب الأول

الخصائص العامة للجزاءات الإدارية

تتفرد الجزاءات التي توقعها الإدارة علي المتعاقد معها في إطار تنفيذ العقود الإدارية بعدد من السمات تميزها عن تلك الجزاءات التي توقع في إطار تنفيذ العقود المدنية. فلجهة الإدارة الحق في توقيع الجزاء بنفسها دون اللجوء لجهة القضاء «المطلب الأول»، كما أن لها الحق في اختيار الوقت المناسب لتوقيع هذا الجزاء «المطلب الثاني»، ولا يشترط توافر الضرر لتوقيع الجزاء الإداري «المطلب الثالث»، وأخيراً من الممكن لها أن تجمع بين عدة جزاءات إدارية «المطلب الرابع». وفيما يلي نبين هذه الخصائص:

الفرع الأول

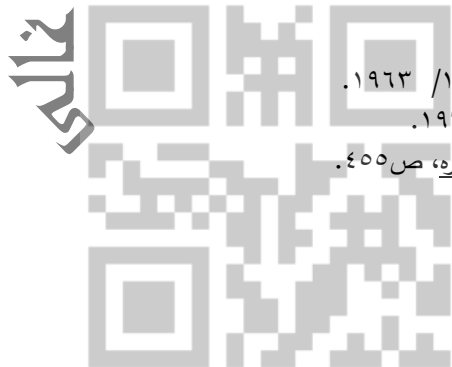
حق الإدارة في توقيع الجزاء بنفسها

تملك الإدارة حق توقيع الجزاءات الإدارية بنفسها، دون انتظار لحكم من القضاء، فهي تملك حق توقيع الجزاء تلقائياً بمجرد ثبوت المخالفة لديها، ففي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٦٣ توضح أن: « للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب الاسم، وهذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها علي المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في 2024/2025 معلوماته عنها. ولما كان توقيع هذه الجزاءات إنما يهدف أساساً إلى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره وانتظامه تحقيقاً للمصلحة العامة ومن حق جهة الإدارة توقيعها دون انتظار لحكم من القضاء، فانه لا وجه لاتخاذ أي إجراء يحول دون استعمال الجهة الإدارية لهذا الحق بأية صورة من الصور «(١). وأيضاً في حكمها الصادر بتاريخ ١٧ يونيو سنة ١٩٧٢ تقول أن: « الإدارة حينما قامت بسحب الالتزام من المدعي ومصادرة التأمين النهائي، إنما كان بسبب إخلال المدعي بشروط العقد، وجزاء السحب من الجزاءات التي تملك الإدارة حق توقيعها علي المتعاقد معها، عند إخلاله بالتزاماته «(٢). وتنتمتع الإدارة بحق توقيع الجزاء بنفسها حتى ولو لم يُنص عليه في العقد، كما انه في حالة نص العقد علي بعض الجزاءات، فإن ذلك لا يمنعها من استعمال الجزاءات الأخرى غير المنصوص عليها(٣)، كما أن الإدارة لا يجوز لها أن تتنازل عن هذا الحق

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ١١٠٩، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٢/٢٨ / ١٩٦٣.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١١٠٩، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٧/٦/ ١٩٧٢.

(٣) انظر: د: محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٥٥.



مقدماً^(١). إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أنه إذا كانت الإدارة لا تملك التنازل عن هذا الحق مقدماً، فإنها تملك وفقاً لظروف الحال أن تقرر إعفاء المتعاقد معها من الجزاءات كلياً أو جزئياً، وهذا واضح من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٦٣ وفيه تقرر أن الجهة الإدارية « باعتبارها القوامة علي حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعاً لذلك علي تنفيذ شروط العقد.....لها مثلاً أن تقدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها »^(٢).

الفرع الثاني

حق الإدارة في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء

إذا قررت الإدارة توقيع جزاء معين علي المتعاقد معها، فإنها تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيعه، حيث إنها تملك سلطة تقديرية في هذا الصدد، وذلك ما لم يحدد العقد ميعاداً محدداً لتوقيع مثل هذا الجزاء.

وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢٠ مايو سنة ١٩٦٧ أنه: « باستثناء حالة النص علي إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء علي المتعاقد معها في وقت معين، فإن الإدارة تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه^{2024/2025} صالحاً لضمان سر المرافق العامة، ومن ثم فإنه لا تثريب في إيقاع الجزاء بالمتعاقد المقصر حتى يفي إلى الحق من حيث النهوض بالتزاماته وقد يكون في هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة إذا كان في أحكام العقد ما يكفل حمل المتعاقد علي المبادرة إلى التنفيذ كان يتضمن العقد النص علي إلزامه بدفع مبلغ معين. ولا يملك المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت في توقيع الجزاء، وأن تراخيها أساء إليه، إذ لا يسوغ للمخطئ أن يستفيد من تقصيره »^(٣).

الفرع الثالث

الضرر ليس شرطاً لتوقيع الجزاء الإداري

تملك الإدارة توقيع الجزاءات علي المتعاقد معها بدون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر معين. ويبرر ذلك أمرين، الأول: هذا الضرر مفترض كنتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته،

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١١٠٩، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٢/٢٨/١٩٦٣.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٦١، لسنة ٢ق، الصادر بتاريخ ٩/٢١/١٩٦٠.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، لسنة ١٢ق، الصادر، بتاريخ ٥/٢٧/١٩٦٧، المجموعة ص ١١٠٠.



والثاني: أن الهدف من هذه الجزاءات ليس عقاب للمتعاقد مع الإدارة علي خطأ ارتكبه، وإنما يكمن هذا الهدف بالدرجة الأولى في تأمين تسير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٦٣ أن: « الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها علي المتعاقد معها في روابط العقد الإداري إذا خالف شروط العقد أو قصر في تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجبه إنما تستهدف أساساً تأمين سير المرافق العامة، فلا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق، إذ أن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب استحقاقها المنصوص عليه في العقد. ذلك أن التراخي في تنفيذ العقود الإدارية ينطوي في ذاته علي إخلال بالتنظيمات التي رتبته الإدارة شؤون المرفق و تأمين سيره علي أساسها، فهي اتفاق ملزم لا يحتمل الترخص في إعمال حكمه أو التقرير في تحديد مداه»^(١).

الفرع الرابع

جواز الجمع بين عدة جزاءات إدارية

ليس هناك ما يمنع من الجمع بين جزاءات متعددة، طالما تحقق السبب الذي يستوجب كلا منها^(٢)، إذ أن كل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى توقيع هذه الجزاءات يتميز ويستقل عن الآخر في الطبيعة والوجهة والغاية.

وفي هذا الصدد تقرر محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤/٢٩٢٥٧ « ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين جزاءات متعددة في العقد الإداري طالما قد تحقق السبب المخول لتوقيع كل منها. فغرامة التأخير ليست مرتبطة بإثبات الضرر الذي ليس مرتبطة بإثبات الضرر الذي يقع من جراء التأخير في التنفيذ بل تعتبر وسيلة للتهديد لمنع التأخير وجزاء يوقع بسبب التأخير في التوريد، أما الشراء علي حساب المتعهد بالتنفيذ المباشر فيكون بعد أن يثبت عجزه عن التوريد (حالة التقصير اليسير)، بينما إلغاء العقد يكون عن تكرار العجز عن التوريد (التقصير الجسيم). فإذا كان الثابت أن نصوص العقد تجيز بعد الأعدار توقيع الغرامة عن التأخير في التوريد، ثم التنفيذ المباشر بالشراء علي الحساب إذا لم يورد المتعهد الأصناف المتعاقد عليها مع اقتضاء فرق الثمن والمصاريف الإدارية، ثم إلغائه عند العجز في توريد أكثر من رسالة . فيكون ما أجراه سلاح خدمة الجيش مع المدعي من توقيع الغرامة لتأخره في التوريد ومن الشراء علي حسابه، ثم إلغاء العقد عندما تكرر التأخير، متفقاً مع نصوص العقد، ويكون ما يثيره المدعي من عدم جواز الجمع بين هذه الجزاءات غير سديد»^(٣).

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٠٨٦، لسنة ٧ق، الصادر بتاريخ ١١/٣٠/١٩٦٣.

(٢) انظر: د: محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص ٦٤٦.

(٣) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٤١٨٦، لسنة ٩ق، صادر بتاريخ ٢٤/١١/١٩٥٧، المجموعة، ص ٢٣.





١٩٧

المطلب الثاني

القيود الواردة علي حق الإدارة في توقيع الجزاءات " ضمانات المتعاقد مع الإدارة "

سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات علي المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته ليست مطلقة، بل يرد عليها بعض القيود التي تمثل ضمانات حقيقية للمتعاقد. فقرارات الإدارة في هذا الصدد تخضع لرقابة القضاء «الفرع الأول»، كما يتعين عليها أن تنبه أو تنذر المتعاقد معها قبل توقيع الجزاء عليه «الفرع الثاني»، وليس لها توقيع الجزاءات الجنائية «الفرع الثالث»، وأخيرا استطاعة المتعاقد معها تقييد سلطتها الجزائية «الفرع الرابع». وهو ما سنوضحه علي النحو التالي:

الفرع الأول

الرقابة القضائية علي الجزاء الإداري

إذا كان للإدارة الحق في أن توقع الجزاء بنفسها، فإنها تفعل ذلك علي مسؤوليتها تحت رقابة القضاء، وعلي هذا المعني تؤكد المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٦١. لتطمئن المتخوفين من سلطة الأداة في هذا الصدد. فتقرر: « والقول انه "هذا الحق" يطلق يد الإدارة في توقيع الغرامة التي تقدرها بلا قيد من حيث مقدار القول مردود بأن استعمال ١٩٦١/٤/١٣ يحققها المخول لها من حيث فرض الغرامة 2024/2025 علي المخالف خاضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من انه غير مشوب بالتعسف »^(١). ومن المسلم به أن رقابة القضاء علي قرارات الجزاءات تعتبر من قبيل القضاء الكامل^(٢)، وهي رقابة شاملة تتناول هذه القرارات من زاوية المشروعية، أي تتناول مشروعية القرارات الصادرة من الإدارة بتوقيع الجزاءات، سواء من حيث الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القانون أو التعسف، وتمتد إلى البواعث التي حدثت بالإدارة لتوقيع هذا الجزاء، وتقيم أسباب صدور القرار. ومن زاوية أخرى، يتناول القضاء الإداري هذه القرارات من حيث الملائمة، فيقدر ما إذا كان المتعاقد قد اخطأ حقيقةً، وما إذا كان الجزاء الموقع من الإدارة يتناسب مع الخطأ المنسوب إليه^(٣).

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ ١٣/٤/١٩٦١.

(٢) انظر: د: محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦٠.

(٣) انظر: د: عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٧٥، ص ١٠٢.



وفيما يتعلق بسلطة قاضي العقد في مواجهة الجزاءات غير المشروعة أو غير الملائمة (القاسية)، فهي تتفاوت من جزء إلى آخر، فهي قد تضيق بالنسبة لبعض الجزاءات، في حين قد تتسع لبعضها الآخر، وذلك علي النحو التالي^(١):

١. بالنسبة للجزاءات المالية: يستطيع القاضي أن يحكم بردها، أو الإغفاء منها أو بتخفيضها إذا كان مبالغاً فيها علي حسب الأحوال.

٢. بالنسبة للجزاءات التهديدية والفاسخة: فيما يتعلق بتلك الجزاءات، يستطيع القاضي دائماً أن يلزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها عما أصابه من أضرار ناتجة عن هذه الجزاءات غير الصحيحة، ولكنه لا يستطيع أن يحكم بإلغائها في جميع الحالات كما سنري لاحقاً.

الفرع الثاني

ضرورة اعدار المتعاقدين^(٢) قبل توقيع العقوبة

يجري القضاء الإداري الفرنسي علي إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تقوم باعدار المتعاقدين بضرورة تنفيذ التزامه قبل توقيع الجزاء^(٣). علي أن مجلس الدولة الفرنسي لا يطبق هذا القيد كقاعدة عامة مطلقة، بل سمح ببعض الاستثناءات عليها، وهذه الاستثناءات هي:

١. إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً بإعفاء الإدارة من الاعذار، أو إذا ورد حكم به في 2024/2025 2024/2025
دفا تر الشروط أو في نص من النصوص^(٤).

٢. يعفي مجلس الدولة الفرنسي الإدارة من قيد الاعذار، إذا كانت الظروف تضفي علي تنفيذ العقد طابع الضرورة الملحة، كما هو شأن تسليم المشتريات المتعلقة

(١) انظر: د: محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦٠. و انظر أيضاً، د: عبد المجيد فياض، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٥.

(٢) يقصد بالاعذار، وفقاً للقواعد العامة إثبات حالة تأخير المدين في تنفيذ التزاماته إثباتاً قانونياً، فهو يعد إجراءً تمهيدياً يجب أن يسبق تطبيق الجزاءات القانونية أو الاتفاقية، فنص المادة ١٥٧ من القانون المدني في فقرتها الأولى، علي انه: « في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ».

(٣) انظر علي سبيل المثال:

- C.E. 3 novembre 1961, Garreau, R.D.P., 1962, p. 377.
- C.E. 9 novembre 1988, Commune de firstroff, R.D.P., 1989, p. 1806.
- C.E. 26 novembre 1993, S. A. Nouveau port Saint-Jeam-Cap-Ferrat, Dr. adm., 1993, N 563.

(٤) انظر:

- C.E. 21janvier 1944, Léont, R.D.P., 1945, p. 245.

بالمجهود الحربي في مواعيدها، فمجرد حلول الموعد، يعد بذاته اعداراً للمتعاقد بالتفويض^(١).

ولا يتطلب الاعذار - وفقاً لقضاء مجلس الدولة الفرنسي - شكل محدد، فجهة الإدارة ليست ملزمة بأن تذكر المتعاقد بكافة تفاصيل التزاماته التي قصر في الوفاء بها^(٢). كما أن الإدارة يمكن لها أن تعدل عنه بعد توجبه، ويجب أن يكون هذا العدول صريحاً، ونتيجة موقف إيجابي منها، فلا يكفي في مجرد التراخي أو مرور وقت طويل بين الاعذار وبين توقيع الجزاء^(٣). وفي حالة عدول الإدارة عن الاعذار، ثم أبدلت رأيها فأرادت التمسك بالخطأ المنسوب للمتعاقد، فيتعين عليها في تلك حالة أن تعيد الاعذار من جديد^(٤).

وفيما يتعلق بمجلس الدولة المصري، فقد سائر في بعض قضائه مجلس الدولة الفرنسي، فأقر مبدأ وجوب اعذار المتعاقد مع جهة الإدارة المقصر في تنفيذ التزاماته قبل توقيع الجزاء عليه، ففي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ٢١ يونيو سنة ١٩٥٣ تقرر أن: « إذا كان العقد المبرم بين المدعي و بين مصلحة المباني صرحاً في إنهاء الأعمال موضوع العقد خلال ستة أشهر من تاريخ الإذن للمدعي بالبدء في هذه الأعمال، أي أنه التزم بتحدد لتنفيذه أجل معين، والأصل فيه أن تخلف أحد المتعاقدين في التنفيذ علي نحو يضار به الطرف الآخر لا ينشئ حقاً في التعويض إلا باعذار الطرف المتخلف وفقاً 2024/2025 2024/2025 لأحكام المادة ١٢٠ من القانون المدني الملغي، والمادة ٢١٨ من القانون المدني الجديد. إذ المسؤولية العقدية الناشئة عن هذا التأخير يجب لاستحقاق التعويض عنها اعذار المدين، كما يجب ان يتم هذا الاعذار فور التأخير وأن يتضمن تكليفاً صريحاً جازماً بالتفويض..... »^(٥).

إلا أن محكمة القضاء الإداري. في قضاء آخر لها. لم تعتد بالاعذار كإجراء لازم، ولكنها رخصت جهة الإدارة إنذار المتعاقد الآخر مقدماً بما تعتزمه من توقيع الجزاء عليه،

(١) انظر:

- C.E. 5 février 1919, Lévy, Rec., p. 119.
- C.E. 27 mars 1920, Chalas, Rec., p. 270.

(٢) انظر:

- C.E. 23 février 1945, Sté. Générale de publicité, Rec., p. 40.

(٣) انظر:

- C.E. 23 février 1945, Sté. Générale de publicité, Rec., p. 40.

(٤) انظر:

- C.E. 11 juillet 1929, Entreprise Delage, Rec., p. 472.

(٥) حكم محكمة القضاء الإداري، لسنة ٧ ق، بتاريخ ١٩٥٣/٦/٢١، المجموعة، ص ١٦٤٣.

إذا قدرت هي ذلك، من باب الملائمة لا من باب الإلزام، إذ قد يترتب علي ذلك عدم الاستمرار في التقصير، ففي حكمها الصادر بتاريخ ١١ يناير سنة ١٩٥٦، بعد أن أوردت مبدأ عدم وجوب الاعذار المسبق، تقرر انه: «مع ذلك حسن إنذاره " المتعاقد المقصر " بما تعترمه جهة الإدارة من توقيع الجزاء عليه، ففي هذا الإجراء ما قد يحول دون الاستمرار في التأخير والإبطاء»^(١).

هذا ويتضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بعض النصوص التي تلزم الإدارة بإنذار وتنبيه المتعاقد معها قبل توقيع جزاء الفسخ أو التنفيذ علي الحساب، منها علي سبيل المثال نص المادة ٥١، والتي تقرر أن: «يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط جوهرى من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة، يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال علي عنوانه المبين في العقد.....».

وفي نفس الوقت تتضمن اللائحة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، العديد من النصوص التي تعفي الإدارة من إنذار أو تنبيه المتعاقد معها قبل توقيع الجزاء عليه، منها علي سبيل المثال نص المادة ١٠٥ والتي تقرر ان: «في حالة إخلال المتعاقد بأي شرط من شروط البيع فيكون للجهة الادارية دون حاجة الي انذاره او اللجوء للقضاء ان تفسخ العقد.....».

الفرع الثالث

توقيع الجزاءات الجنائية ليست من سلطة الإدارة

ليس من سلطة الإدارة توقيع جزاءات جنائية علي المتعاقد معها، حتى ولو كان إخلاله بالتزاماته يشكل جريمة جنائية، إذ لا يملك توقيع الجزاءات الجنائية إلا القضاء فقط^(٢).

كما أن الإدارة لا تستطيع استعمال سلطتها اللائحية، في خارج نطاق سلطتها العامة كسلطة ضبط إداري، لضمان تنفيذ العقود الإدارية عن طريق النص علي عقوبة

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ١٠٦٢، لسنة ٧ ق، بتاريخ ١١/١/١٩٥٦.

(٢) انظر: د: إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص ٧٢.

جنائية^(١). وفي هذا الصدد الغي مجلس الدولة الفرنسي . لعيب الانحراف بالسلطة . لائحة بوليس أصدرتها الجهة الإدارية وضمنتها عقوبة جنائية لضمان تنفيذ عقد إداري^(٢).

الفرع الرابع

استطاعة المتعاقد مع الإدارة تقييد سلطتها الجزائية

في استطاعة المتعاقد مع الإدارة أن يقيد من سلطتها الجزائية، وذلك بان يضمن العقد الجزاءات التي من المتوقع أن يرتكبها ويحدد الجزاء المناسب لكل منها. ففي تلك الحالة إذا ارتكب المتعاقد خطأ منصوص عليه، لا تستطيع الإدارة إلا أن توقع عليه الجزاء المنصوص عليه أيضا.

وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٨ أبريل سنة ١٩٦٧ انه: « إذا ما توقع المتعاقدان في العقد خطأ معين ووضعوا له جزاء بعينه فيجب أن تنقيد جهة الإدارة بما جاء في العقد ولا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق في شأنه نصوص لائحة المناقصات..... لأن الأحكام التي تتضمنها اللائحة كانت ماثلة أمامها عند إبرام العقد »^(٣). كما تقرر في حكم آخر لها صادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة ١٩٧٣ أن: « الأحكام التي تضمنتها اللائحة المذكورة في هذا الشأن هي من الأحكام التكميلية لإرادة الطرفين والتي يجوز الاتفاق على ما يخالفها »^(٤).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المطلب الثالث

أنواع الجزاءات الإدارية

تتنوع الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها إلى عدة صور كما

يلي:

أولاً: الجزاءات المالية.

ثانياً: الجزاءات التهديدية.

ثالثاً: الفسخ الجزائي.

رابعاً: الجزاءات الجنائية.

وسوف نتناول كل منهما في فرع مستقل كما يلي:

(١) انظر: د: محمد فؤاد مهنا، مرجع سبق ذكره، ص ٦٤٨.

(٢) انظر:

• V. A. DE LAUBADERE, *op. cit.*, p. 352.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٠٢٠، لسنة ٩٩، الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٤/٨.

(٤) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٥٩٣، لسنة ٩٥، الصادر بتاريخ ١٩٧٣/١٢/١.

الفرع الأول الجزاءات المالية

وهي عبارة عن مبالغ مالية يحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية. وهي نوعان: منها ما يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالإدارة نتيجة لخطأ المتعاقد، ومنها ما يقصد به توقيع عقاب علي المتعاقد بغض النظر عن أي ضرر يلحق الإدارة. ويطلق علي النوع الأول التعويضات، بينما يطلق علي النوع الثاني الغرامات، وسنبين مفهوم كل منهما تباعاً علي النحو التالي:

أولاً: التعويضات:

من المسلم به، أن كل خطأ . سواء كان إخلالاً بالتزام عقدي أو بالتزام قانوني . سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ويعد التعويض الجزاء الأصلي للإخلال بالتزامات التعاقدية، ذلك في حالة عدم نص العقد ذاته علي جزاء مالي لمواجهة إخلال أحد أطراف العقد. والتعويض يكون جبراً للأضرار التي تصيب الإدارة نتيجة مخالفة المتعاقد معها لالتزاماته العقدية.

والنظام القانوني للتعويضات يقترب كثيراً من النظرية المقابلة لها في عقود القانون المدني، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض، وفي اشتراط ركن الضرر، ولكنهما علي 2024/2025 2024/2025 العكس يختلفان فيما يتعلق بكيفية تحصيل هذه التعويضات^(١).

يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد العامة المتعلقة بتقدير التعويض المنصوص عليها في القانون المدني، ويتضمن قيمة التعويض . وفقاً لهذه القواعد . ما أصاب الإدارة من خسارة وما فاتها من كسب^(٢)، لذلك يجب عند تقدير قيمة التعويض أن يتم تحديد الضرر الفعلي الذي تحملته الإدارة^(٣)، كما يحدد الوقت الذي وقع فيه الضرر^(٤)، وفي حالة حدوث خطأ من الإدارة المتعاقدة، يحدد مدي مساهمة هذا الخطأ في إحداث الضرر، بحيث يخفض التعويض بما يساوي نصيب هذا الخطأ^(٥).

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦١. د: عبد المجيد فياض، مرجع سبق ذكره، ص ١٨١.

(٢) انظر: د: عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص ١٨٣.

(٣) انظر:

• C. E. 17 décembre 1926, Société des chantiers de l'Adour, Rec., p. 1125.

(٤) انظر:

• C. E. 23 mai 1951, Bongert, Rec., p. 283.

(٥) انظر:

• C. E. 10 juillet 1954, Février, Rec., p. 465.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي يسمح للإدارة بأن تحدد بنفسها قيمة التعويض، وتلتزم المتعاقد معها به^(١)، وللمتعاقد أن ينازع في قيمة هذا التعويض أمام القضاء^(٢)، فمما لا شك فيه أن هذه الرقابة القضائية تحمل ضماناً أكيداً للمتعاقد مما قد يشوب تصرف الإدارة بتقدير التعويض بنفسها من أخطاء أو غلو. ولقاضي العقد أن يقرر إعفاء المتعاقد من التعويض، وذلك متى تبين له عدم صحة الأساس الذي بني عليه، كما له أن يخفض هذا التعويض إذا كانت الإدارة قد بالغت فيه^(٣).

غير أن القضاء الإداري الفرنسي يجري على عدم السماح للإدارة بأن تخصم مبلغ التعويض من مبلغ التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد، إلا إذا كان ثمة نص يقضى بذلك في العقد أو في تشريع من التشريعات^(٤). كما أن المشرع الفرنسي يسمح للإدارة في كثير من الحالات بأن تلجأ إلى تحصيل قيمة التعويضات بمقتضى أوامر بالدفع تصدرها بإرادتها المنفردة^(٥).

وعلى خلاف الوضع في فرنسا، نجد أن مجلس الدولة المصري لم يعترف للإدارة بأن تحدد بنفسها قيمة التعويض وتلتزم المتعاقد معها بأدائه، إلا إذا وجد في العقد نص يقضى بذلك. فعلى سبيل المثال تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٦٥ أنه: « لا وجه لالزام الإدارة بان تلجأ إلى القضاء لتحصل منه على حكم بالتعويض، ما دام أن العقد يخولها صراحة الحق في إجراء المقاصة من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعاقد معها مهما كان سبب الاستحقاق لدي المصلحة نفسها أو أية مصلحة حكومية أخرى عن كل خسارة تلحقها من جراء ذلك.

(١) انظر:

- C. E. 31 mai 1907, Déplanque, Rec. 513, concl. Romieu; S. 1907, 3, 113, note Hauriou; D. 1907, 3, 82 concl. Romieu.
- C. E. 11 octobre 1929, Compagnie de navigation sud-Atlantique, Rec., p. 892.

(٢) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦٢. د: عبد المجيد فياض، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٤.

(٣) انظر:

- V. A. DE LAUBDERE, op., cit., t 2, p. 142 et s.

(٤) انظر:

- C.E. 11 octobre 1929, Compagnie de navigation sud-Atlantique, Rec., p. 892.
- C.E. 21 janvier 1944, Sté d'entreprise et de construction, Rec., p. 123.

(٥) انظر:

- C. E. 17 décembre 1926, Monnot, Rec., p.1123.

فإذا كان العقد قد نص أيضا علي أن يكون ذلك بدون الإخلال بحق المصلحة في المطالبة قضائياً بالخسارة التي لا يتيسر لها استردادها فلا يعني هذا بالضرورة إلزام المصلحة بالالتجاء إلى القضاء ما دام أن في حوزتها القدر من المبالغ الكافية لجبر التعويض عن الأضرار، بل النص يعني تخويل الإدارة حق الالتجاء إلى القضاء إذا لم تكف المبالغ التي في حوزتها لجبر الضرر كاملاً»^(١).

وإذا كان القضاء الإداري المصري قد استقر علي عدم السماح لجهة الإدارة أن تقدر قيمة التعويض بنفسها وتلزم المتعاقد معها بأدائه، إلا إذا وجود نص عقدي يسمح بذلك، وهذا يمثل . في نظرنا. خلا في نظرية الجزاءات الإدارية، فهي تتعارض مع أهم خصائص هذه النظرية، ألا وهي حق الإدارة في توقيع الجزاء بنفسها كما أوضحنا فيما سبق.

لذلك تدارك المشرع المصري هذا الخطأ وحاول إصلاحه تشريعياً، فقد أعطى الحق للإدارة في تقدير قيمة التعويض بنفسها وإلزام المتعاقد معها بأدائه، وهذا واضح من نصوص قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، فعلي سبيل المثال:

«وفي جميع حالات الفسخ أو الإلغاء على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي»^{2024/2025}

من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري»^(٢).

٢. «ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١١٨٠، لسنة ٨ق، صادر بتاريخ ٢٧/١١/١٩٦٥، المجموعة س ١١، ص ٥١.

(٢) راجع: المادة ٥١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري»^(١).

٣. «إذا اخل المتعاقد بأي شرط من شروط البيع فيكون للجهة الادارية دون حاجة الي اذاره او اللجوء للقضاء ان تفسخ العقد وتقوم باتخاذ اجراءات البيع من جديد علي حسابه مع حفظ حقها في الحصول علي ما يكون مستحقا لها من مبالغ نظير فروق الاسعار والمصروفات الادارية والتعويضات المستحقة ولا ترد اليه ايه زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع»^(٢).

ثانياً: الغرامات:

[١] مفهوم الغرامة:

الغرامات هي مبالغ إجمالية، تقدرها الإدارة مقدماً، وتنص علي توقيعها في حالة تأخر المتعاقد معها في التنفيذ أو في حالة إخلاله بالتزام معين. وينبغي الإشارة إلى أن اقتضاء الإدارة للغرامة المنصوص عليها في العقد لا يمنع من حصولها علي التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تسببها. هذا ويختلف النظام القانوني للغرامات عن نظيره للتعويضات في أمرين^(٣):

الأمر الأول: انه يجب النص علي الغرامة في العقد حتى تتمكن الإدارة من اللجوء إليها، وذلك بخلاف حق الإدارة في التعويض فهو ثابت دون النص عليه في العقد.

الأمر الثاني: لا تلتزم الإدارة بإثبات ما لحقها من أضرار نتيجة إخلال المتعاقد معها بتنفيذ التزامه، فهي يحق لها أن تلجأ إلى توقيع الغرامة عليه بغض النظر عن أن هذا الأخير سبب للإدارة ضرراً أم لا. وذلك بخلاف حق الإدارة في التعويض فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً، وجوداً وعدماً بوقوع ضرر لجهة الإدارة.

[٢] كيفية تقدير الغرامة:

وفقاً المادة ٤٨ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة

(١) راجع: المادة ٤١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٢) راجع: المادة ١٠٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

(٣) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٦١. د: جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٠.

إعطائه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته .

وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ، لسبب راجع للمتعاقد، يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر وفقا للآتي :

في مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة ١٠% من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة ١٥% إذا جاوزت مدة التأخير ذلك .

ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامي العملية .

ويتم تطبيق معادلة تغير الأسعار للكميات التي نفذت خلال المهلة بشرط أن يكون التأخير راجعا لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، على أن يعدل الجدول الزمني بما يتفق عليه الطرفان إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتناسب مع مدة التأخير .

في باقي العقود بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة ٣% من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة ١٠% من المدة الكلية للعقد، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة ٥% إذا جاوزت مدة التأخير ذلك .

ويحسب مقابل التأخير من قيمة الجزء المتأخر فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الإجمالية للعقد .

ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

[٣] الإعفاء من الغرامة:

تنص ٤٨ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها

الجهات العامة علي أن: « وفي جميع حالات تحصيل مقابل التأخير، يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، وللسلطة المختصة في غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئيا أو

كلية إذا لم ينتج عن التأخير ضرر، ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك.». ووفقاً لهذا النص يكون إعفاء المتعاقد من الغرامة في عقود المقاولات، **مرهون بتوافر شرطين:**

الأول: أن يكون التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، كأن يكون سببه راجعاً إلى فعل الإدارة، أو القوة القاهرة.

الثاني: اخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وفي غير ذلك من العقود، يجوز لجهة لإدارة إعفاء المتعاقد من الغرامة، بشرط أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعدم تسبب التأخير لضرر للإدارة، فإذا حدث ضرراً ولو يسيراً فلا يجوز لها إعفاء المتعاقد من الغرامة.

الفرع الثاني الجزاءات الضاغطة

تستطيع الإدارة إرغام المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، عن طريق حلول الإدارة محل المتعاقد المقصر أو بإحلال غيرها محله، باستعمال ما تملكه من إجراءات جزائية ضاغطة^(١).

2024/2025

2024/2025

ويختلف الجزاء الضاغط باختلاف نوع العقد الإداري، ففي عقد التزام المرافق العامة يمكن للإدارة وضع المرفق تحت الحراسة، وفيما يتعلق بعقد الأشغال العامة تستطيع الإدارة الحلول محل المتعاقد في تنفيذ العقد، أما في عقد التوريد تقوم الإدارة بالشراء على حساب المورد. وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي:

أولاً: وضع المرفق تحت الحراسة في عقد الالتزام:

في عقد التزام المرافق العامة، إذا قصر الملتزم في تسيير المرفق تقصيراً جسيماً، كأن يتوقف المرفق جزئياً أو كلياً عن العمل كنتيجة لعجز الملتزم أو عدم كفايته أو عدم قدرته على الإدارة، كان من حق الإدارة أن تضع هذا المرفق تحت الحراسة^(٢). وقد تضع

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧٦. د: عبد المجيد فياض، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٩.

(٢) انظر:

- C. E. 5 mars 1943, Ville de Nîmes, Rec., p.58.
- C.E. 25 mars 1966, Ville de Royan et suscité anonyme de Royan et sieur Couzinet, Rec., p.237.

الإدارة المرفق تحت الحراسة إذا كان ثمة ما يهدده بالتوقف ولو بدون خطأ من الملتزم، كإضراب لا ذنب له فيه، أو قوة قاهرة يستحيل علي الملتزم معها أن يضمن استمرار المرفق^(١).

ومن المسلم به أن وضع المرفق تحت الحراسة لا يؤدي إلى فسخ عقد الالتزام ولا إلى إسقاط حقوق الملتزم الأصلي، وكل ما يترتب عليه هو رفع يد الملتزم مؤقتا عن إدارة المرفق محل عقد الالتزام^(٢). وحينما تقوم الإدارة بوضع المرفق تحت الحراسة، فإن أمامها اختيارات متعددة لإدارته: إما أن تديره بنفسها إدارة مباشرة، أو أن تعهد بإدارته إلى مقاول تعيينه كحارس مؤقت، إذا تراءى لها أفضلية ذلك، أو أن تعين أحد وكلاء الملتزم نفسه كحارس يكون مسئولاً مباشرة أمامها^(٣).

وللملتزم المنازعة في صحة القرار الصادر من الإدارة بوضع مرفقه تحت الحراسة، ويختص قاضي العقد بنظر هذه المنازعة، ولهذا الأخير إلغاء القرار متى تبين له عدم مشروعية أو عدم وجود مبرر له، وفي هذه الحالة يلزم الإدارة بتعويض الملتزم عما لحقه من ضرر، ويشمل هذا التعويض ما فاتته من كسب وما لحقه من خسارة^(٤).

ثانياً: حلول الإدارة محل المتعاقدين في عقد الأشغال العامة:

بالنسبة لعقد الأشغال العامة، تستطيع الإدارة في حالة تخلف المقاول عن تنفيذ التزامه أو تباطئه في أدائه أن تسحب العملية منه، وتقوم بتنفيذها علي حسابه وتحت مسؤوليته، وذلك ضماناً لحسن سير المرفق بانتظام واطراد، ويعد هذا الجزاء من الجزاءات الاختيارية لجهة الإدارة، فهي تملك بصده سلطة تقديرية، فلها أن تطبقه أو تتغاضى عنه وتفسخ العقد. وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها بتاريخ ٧ يناير سنة ١٩٩١ أن: « لجهة الإدارة الطاعنة سلطة تقديرية في تقرير التنفيذ علي

(١) انظر:

- V. A. DE LAUBDERE, *op. cit.*, t 2, p. 157.
- C. E. 18 juillet 1913, Syndicat national des chemins de fer, Rec., p.875.

(٢) انظر:

- C. E. 29 octobre 1926, Ville de St- Etienne, Rec., p.911.

(٣) انظر. د: عبد المجيد فياض، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٩.

(٤) انظر:

- C. E. 29 octobre 1926, Ville de St- Etienne, Rec., p.911.
- C. E. 23 juin 1944, Ville de Toulon, R.P.D. 1945, conl. Odent, note Jeze, p.101.

حساب المتعاقد المقصر في تنفيذ التزامه تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً، حيث تقوم الإدارة بتنفيذ الالتزام بنفسها وعلي حسابها و تحت مسؤوليته، ودون أن تلجأ في ذلك إلى القضاء، ضماناً لحسن سير المرفق .. «(١).

ومن المسلم به بأن سحب العمل من المقاو حلول الإدارة محله في تنفيذه يعد إجراء مؤقت لا ينهي الرابطة العقدية، ومن ثم يظل العقد قائماً وتستمر مسؤولية المقاو عن تنفيذه، وتعد الإدارة من الناحية القانونية وكيلاً عن المقاو المقصر في كل ما تقوم به من أعمال لتنفيذ ما قصر في تنفيذ أعمالها وتخضع في مسؤوليتها في تنفيذ هذه الأعمال لنص المادة ٧٠٤ من القانون المدني(٢).

هذا ويعد هذا الجزاء من الجزاءات التي لا تلجأ إليها الإدارة إلا في حالة ارتكاب المتعاقد معها لخطأ جسيم. ومن أمثلة الأفعال التي تبرر تطبيق هذا الجزاء في ضوء أحكام مجلس الدولة الفرنسي، تأخر المقاو عن تنفيذ الأعمال متى كان لهذا التأخير أهميته(٣). عدم تنفيذ الأوامر المصلحية، فمجرد عدم استجابة المقاو لهذه الأوامر الموجهة إليه من الإدارة ، يعد مبرراً كافياً لوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة(٤). ارتكاب المقاو بعض المخالفات، وإن كان لا يعد أي منها مبرراً كافياً لهذا الجزاء، ولكنها تظهر في مجموعها إهمالاً شديداً من المقاو في تنفيذ التزاماته(٥). تواجد المقاو في مركز مالي سيئ يمنع 2024/2025 من أداء التزاماته، مثل عدم صرف أجور العاملين لديه بانتظام(٦).

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢٠٧٤، لسنة ٣٠ ق، صادر بتاريخ ١٩٩١/١/٧.

(٢) تنص المادة ٧٠٤ من القانون المدني على أنه:

١. إذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

٢. فإن كانت باجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

(٣) انظر:

• C. E. 13 mars 1912, Quintyn, Rec., p.362.

(٤) انظر:

• C. E. 15 août 1927, Ministre de la guerre, Rec., p.966.

• C. E. 13 février 1942, Les limousins, Rec., p.52.

(٥) انظر:

• C. E. 15 août 1927, Ministre de la guerre, Rec., p.966.

(٦) انظر:

• C. E. 29 janvier 1904, Calmel, Rec., p.75.

وفيما يتعلق بمجلس الدولة المصري، فقد أورد بعض المخالفات التي تستوجب تطبيق هذا الجزاء في العديد من أحكامه^(١)، مثل تأخر المقاول عن البدء في العمل رغم تسلمه الموقع خالياً من الموانع، البطء الشديد في العمل لدرجة يظهر معها . بغير شك . انه لن يستطيع إتمام التنفيذ خلال المدة المحددة لانتهائه، أو إيقافه العمل مدة متواصلة تزيد عن ١٥ يوم بون سبب واضح، أو انسحابه من موقع العمل مع أخذ معداته وأدواته، أو ترك العمل كلية بالموقع، بسبب تنفيذه أعمالاً رديئة مخالفة للمواصفات، وامتناعه عن الاستجابة للملاحظات التي أبديت أثناء التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن جزاء سحب العمل من المقاول المقصر قد ورد النص عليه في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، محدداً الشروط الواجب توافرها لسحب العمل من المقاول المتعاقد وتنفيذه علي حسابه. فوفقاً للمادة ٥١ يكون سحب العمل و التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة، ويتعين علي الإدارة قبل إقدامها علي إصدار قرار سحب العمل من المقاول أن تتيقن من توافر الشرطين التاليين:

١. ثبوت خطأ تعاقدى في جانب المقاول، كقيامه بالإخلال بشرط من شروط

2024/2025

العقد، أو إهماله أو إغفاله عن القيام بأحد التزاماته المقررة.

2024/2025

٢. وجوب اذارها للمقاول، فيتعين علي جهة الإدارة أن تعذر المقاول، وذلك

بإذاره بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد.

وفي حالة توافر الشرطين السابقين، جاز للإدارة أن تصدر قرارها بسحب العمل من المقاول المقصر، دون مسئولية عليها، وينبغي الإشارة إلى أن المشرع يشترط صدور هذا القرار من السلطة المختصة، أي من الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه. ويتم التنفيذ بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد علي أساسها، وذلك باحدي الطرق القانونية المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون.

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٤٣٩٣، لسنة ٣٧ق، صادر بتاريخ ١٩٩٤/٢/٨. وايضا في الطعن رقم ٨٣٢، لسنة ٣٣ق، صادر بتاريخ ١٩٩٢/٧/٢٨.

وفي حالة سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصص ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

وفي النهاية، ينبغي الإشارة إلى أن قرار الإدارة بسحب الأعمال من المقاول و تنفيذها علي نفقته وتحت مسؤوليته خاضع لرقابة القضاء، حيث يكون في استطاعة المقاول في هذه الحالة اللجوء إلى قاضي العقد ليظعن علي هذا القرار، غير انه من المسلم به أن القاضي لا يملك إلغائه أو وقف تنفيذه مهما شابه من عيوب، بل تقتصر سلطته علي تحقيق طلب التعويض عنه^(١)، ويخضع تقدير القاضي للتعويض في هذا الشأن للقواعد القانونية العامة^(٢).

ثالثا: الشراء علي حساب المتعاقد في عقد التوريد:

في عقود التوريد، عندما يتخلف المورد عن تنفيذ التزاماته، تستطيع الإدارة أن تقوم بهذا التنفيذ علي حسابه وتحت مسؤوليته، وذلك لضمان حسن سير المرفق العام واطرادهم 2024/2025 2024/2025 وإعلاء الصالح العام علي المصالح الخاصة^(٣).

والتنفيذ علي حساب المتعاقد في عقد التوريد يعد إجراء مؤقتا لا ينتهي به العقد، ولكن يظل مستمرا منتجا لآثاره ويظل المورد مسئولا عن عملية الشراء أمام الإدارة. وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها في التاسع من يونيو سنة ١٩٦٢ أن: «... الشركة وإن كانت قد توقفت عن التنفيذ بنفسها، إلا أن الإدارة قد قامت بالشراء علي حسابها، ومن مقتضى هذا الشراء علي حسابها عدم إنهاء الرابطة العقدية واستمرار العقد منتجا لآثاره واعتبار الشركة هي المسئولة أمام الوزارة عن عملية الشراء،

(١) انظر:

- C.E. 20 décembre 1961, Soiété Ouest-Peinture, Rec., p.733.
- C.E. 26 novembre 1971, Soiété industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques et de récupération, Rec., p.723.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢٤١، لسنة ١٧ق، صادر بتاريخ ١٩٨١/١٢/٥.

(٣) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى رقم ٣٣٩ في ١٩٩٥/٥/٢ جلسة (١٩٩٥/٣/٢٢) ٤٩.

فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع علي عاتقها غرامة التأخير والمصاريف الإدارية التي تكبدتها الوزارة في عملية الشراء»^(١).

ويرجع أساس مسئولية المورد عن عملية الشراء التي قامت بها الإدارة، إلى أن جهة الإدارة عندما تشتري علي حساب المتعاقد المقصر تكون بمثابة الوكيل عنه في هذا الشأن، وعلي ذلك تلتزم بالقاعدة المنصوص عليها في المادة ٧٠٤ من القانون المدني، والتي توجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في تنفيذ أعماله الخاصة. فإذا كان الهدف من تقرير جزاء الشراء علي حساب المورد هو حصول الإدارة علي ما تريد في أقرب وقت، فإنه إذا تسببت في إطالة مدة وإجراءات التنفيذ بدون مقتضى، مما ترتب عليه حصولها علي ما تريد بعد فترة ارتفعت فيها أسعار المواد المشتراة ارتفاعا كبيرا، فإن المورد لا يجب أن يتحمل كل الفرق بين السعر الذي التزم به أصلا والسعر الذي اشترت به الإدارة والذي يرجع إلى أن الإدارة لم تبذل العناية الواجبة في شرائها علي حسابه^(٢).

ومن المسلم به أن جزاء الشراء علي حساب وتحت مسئولية المورد من الجزاءات التي يجب ألا تلجأ إليها الإدارة إلا في حالة ارتكاب المتعاقد معها لخطأ جسيم. ويختص قاضي العقد بتقدير ذلك^(٣). وبناء علي ذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي أن تقاس المورد عن التسليم^(٢٠٢٤/٢٠٢٥)، أو التأخير الممتد فيه^(٤)، أو ردء الأشياء الموردة^(٥)، تعد أخطاء جسيمة^(٢٠٢٤/٢٠٢٥) تعطي الحق للإدارة بتوقيع مثل هذا الجزاء.

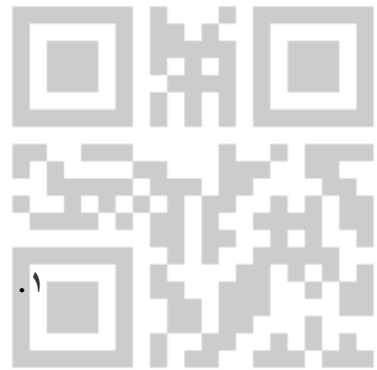
ومن الجدير بالذكر أن الشراء علي حساب المورد المقصر قد ورد النص عليه في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، محددا الشروط الواجب توفرها لسحب العمل من المورد المتعاقد وتنفيذه علي حسابه. فوفقاً للمادة ٥١ يكون سحب العمل و التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة، ويتعين علي الإدارة قبل إقدامها علي إصدار قرار سحب العمل من المورد أن تتيقن من توافر الشرطين التاليين:

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢١٥٠، لسنة ٦٦، الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٦/٩.
(٢) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٢٤٠٢، لسنة ٩٩، الصادر بتاريخ ١٩٥٨/٥/١١.
(٣) انظر: د: عبد المجيد فياض، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٠.
(٤) انظر:

- C.E. 5 décembre 1934, Société Hornes et Buire, Rec., p.1149.
- C.E. 23 mars 1927, Babest, Rec., p.372.
- C.E. 12 janvier 1906, Amsellem, Rec., p.33.

(٥) انظر:

(٦) انظر:



١. ثبوت خطأ تعاقدى في جانب المورد، كقيامه بالإخلال بشرط من شروط العقد، أو إهماله أو إغفاله عن القيام بأحد التزاماته المقررة.

٢. وجوب اعذارها للمورد، فيتعين علي جهة الإدارة أن تعذر المورد، وذلك بإذاره بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد.

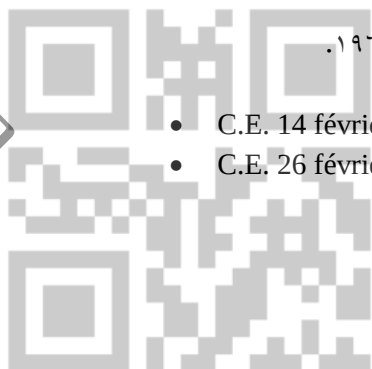
وفي حالة توافر الشرطين السابقين، جاز للإدارة أن تصدر قرارها بالشراء علي حساب المورد المقصر، دون ادني مسئولية عليها، وينبغي الإشارة إلى أن المشرع يشترط صدور هذا القرار من السلطة المختصة، أي من الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه. ويتم التنفيذ بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد علي أساسها، وذلك باحدي الطرق القانونية المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون.

وأخيرا يجب أن تنقيد الإدارة حال مباشرتها الشراء علي حساب المتعهد المقصر بأن تشتري الأصناف التي قصر المتعهد في توريدها، بمعنى ألا تشتري أصنافا مغايرة من حيث طبيعتها للأصناف المتعاقد عليها، كأن تشتري سيارات مثلا في حين أن التعاقد قد كان علي دراجات، إلا إنها تستطيع أن تشتري أصنافا مغايرة من حيث درجة الجودة بالزيادة أو بالنقصان إذا تعذر الحصول علي الصنف الأصلي المتعاقد عليه، كما لو كان مما يصنعه المتعهد فلا يوجد عند غيره أو يكون قد نفذ من السوق مثلا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة قبول هذا الصنف حتى لا يتعطل المرفق^(١).

ونشير في النهاية إلى انه في استطاعة المورد المستبعد ان ينازع في صحة إجراء التنفيذ علي حسابه و علي مسئوليته أمام القضاء، وتدخل هذه المنازعة في اختصاص قاضي العقد. إلا انه لا يجوز للقاضي أن يقرر إلغاء هذا الإجراء مهما شابه من اوجه عدم المشروعية، ولكن تقتصر سلطته فقط علي بحث مدي الحق في التعويض من عدمه^(٢).

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢٠١٣، لسنة ٦٦ق، الصادر بتاريخ ١٦/١٢/١٩٦١.
(٢) انظر:

- C.E. 14 février 1908, Chrétien, Rec., p.155.
- C.E. 26 février 1944, Ploc, Rec., p.69.





٢١٤

الفرع الثالث الفسخ الجزائي

الفسخ هو اخطر الجزاءات التي يمكن أن توقعها الإدارة علي المتعاقد معها، إذ يترتب عليه إنهاء الرابطة التعاقدية، ولذلك يستلزم القضاء الإداري سواء في مصر أو في فرنسا أن يقترن توقيعه بخطأ جسيم يرتكبه المتعاقد في تنفيذ التزاماته. وبذلك يتميز عن حق الإدارة في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وبدون خطأ من المتعاقد معها.

ويعد الفسخ آخر الجزاءات التي يمكن أن توقعها الإدارة علي المتعاقد معها. ومن المسلم به أن الإدارة لا تلجأ إلى توقيع مثل هذا الجزاء إلا إذا أعيتها الحيل في تقويم المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته ولم تُجد الجزاءات الأخرى في ذلك^(١).

أولاً: حالات الفسخ الجزائي:

وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قد يكون الفسخ الجزائي وجوبياً وذلك في حالة تحقق المخالفة التي نص عليها القانون، وقد يكون جوازيًا تقدر الإدارة اللجوء إليه من عدمه.

2024/2025

2024/2025

أ. الفسخ الجزائي الوجوبي:

تنص المادة ٥٠ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي انه يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :

١. إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .

٢. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .

٣. إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

ففي الحالتين الأولى والثانية، يجد الفسخ مبرره في أن المتعاقد بسلوكه المتمثل في استعماله للغش والتلاعب سواء بنفسه أو بواسطة غيره، أو وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار. يعد جرماً يستوجب العقاب وبالتالي يجب فسخ العقد حتى لا يستفيد المتعاقد من جرمه، ولا يخفي أن هذا الفعل يؤدي لفقدان الإدارة للثقة في المتعاقد،

(١) انظر: د: جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الادارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٦.



إضافةً إلى مخالفة المتعاقد لمبدأ تنفيذ العقد بحسن نية وهو الأمر الذي يجب أن يسود تنفيذ كافة العقود سواء المدنية أو الإدارية.

أما في الحالة الثالثة، فيجد الفسخ مبرره في أن المتعاقد لم يعد قادراً علي الاضطلاع بتبعات العقد المالية ولم يعد قادراً علي الاستمرار فيه.

ب. الفسخ الجزائي الجوازي:

الفسخ الجوازي يعني أن الإدارة تلجأ إليه حينما تقدر انه لازم ولا مفر من استخدامه وذلك عندما تتيقن أن استمرار العقد يتعارض مع المصلحة العامة^(١). فالمشرع يترك للإدارة سلطة تقديرية لتوازن بين الإضرار بالمصلحة العامة الذي قد ينتج عن فسخ التعاقد، والأضرار التي قد تصيب هذه المصلحة في حالة استمرار التعاقد في ظل مخالفة المتعاقد لشروطه التعاقدية، وفي ضوء ذلك تتخذ قرارها إما بفسخ العقد أو الإبقاء عليه، علي النحو الذي يجنب المصلحة العامة الضرر الأكبر^(٢).

وقد ورد النص علي حق الإدارة في الفسخ الجوازي في المادة ٥١ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، حيث قررت انه يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد، إذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهري من شروطه، ويكون الفسخ بقرار مسبب من السلطة المختصة، ويتعين علي الإدارة قبل إقدامها علي إصدار قرار الفسخ أن^{2024/2025} تتيقن من توافر الشرطين التاليين:

١. ثبوت خطأ تعاقد في جانب المتعاقد، كقيامه بالإخلال بشرط من شروط العقد، أو إهماله أو إغفاله عن القيام بأحد التزاماته المقررة.
٢. وجوب اعدارها للمتعاقد، فيتعين علي جهة الإدارة أن تعذر المتعاقد، وذلك بإنذاره بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال علي عنوانه المبين في العقد.

وفي حالة توافر الشرطين السابقين، جاز للإدارة أن تصدر قرارها بالفسخ، دون ادني مسئولية عليها، وينبغي الإشارة إلى أن المشرع يشترط صدور هذا القرار من السلطة المختصة، أي من الوزير ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه.

(١) انظر: المرجع السابق، ص ٢٢٦.

(٢) انظر: د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٥.

ثانياً: آثار فسخ العقد:

يرتب قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي توقيع عقوبة الفسخ الآثار القانونية التالية^(١):

١. إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد، أو تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالي أو فساد أو احتكار يتم شطب اسم المتعاقد من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة. ويعاد قيد المتعاقد الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناء على طلبه إذا انتفى سبب الشطب بصور قرار من النيابة العامة بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة.

٢. في جميع حالات فسخ العقد يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية. 2024/2025

٣. لجهة الإدارة أن تخصص ما يستحق لها من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق، دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.

٤. للإدارة أيضاً أن ترجع قضائياً علي المتعاقد بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

٥. انتهاء العقد وانفصام الرابطة العقدية بين طرفيه.

ثالثاً: الرقابة القضائية علي قرار الفسخ الجزائي:

إذا كان الفسخ - كباقي الجزاءات الإدارية - تقوم الإدارة بتوقيعه بإرادتها المنفردة دون حاجة لأن يكون منصوباً عليه في العقد ودون حاجة للجوء إلى القضاء مسبقاً للحصول علي حكم بذلك، فإن الإدارة حين تلجأ إلى استعمال سلطتها في فسخ العقد تخضع لرقابة القضاء.

(١) راجع المادة ٥٠، ٥١ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ففي استطاعة المتعاقد ان ينازع في صحة قرار الفسخ أمام القضاء، وتدخل هذه المنازعة في اختصاص قاضي العقد. إلا انه لا يجوز للقاضي أن يقرر إلغاء هذا القرار مهما شابه من اوجه عدم المشروعية، ولكن تقتصر سلطته فقط علي بحث مدي الحق في التعويض من عدمه^(١).

وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢٦ أبريل سنة ١٩٩٤ أن: «.....ومن حيث أنه وإن كان لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة ودون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي يستهدف تسييره، إلا أن ذلك يجب أن يكون لأسباب تبررها المصلحة العامة وإلا كان للمتعاقد معها أن يطلب الحكم له بالتعويض عما يلحق من أضرار نتيجة لهذا الإجراء غير المشروع والذي يمثل خطأ عقدياً وسواء أكانت هذه الأضرار مادية أو أدبية بشرط أن تكون هذه الأضرار ثابتة ثبوتاً يقينياً وقيم المدعي الدليل علي وقوعها حتى يمكن أن يقضي له بالتعويض عن هذه الأضرار منعا لإثرائه بلا سبب علي حساب الإدارة ومع مراعاة أن التعويض عن الأضرار المادية يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاتته من كسب»^(٢).

2024/2025

الفرع الرابع

2024/2025

الجزاءات الجنائية

ينظم هذا الموضوع - الأصل العام - والذي يقضى بأنه لا جريمة وعقوبة إلا بناء علي نص. فالإدارة كقاعدة عامة لا تستطيع أن توقع علي المتعاقد معها أية عقوبة جنائية مهما كانت جسامة المخالفة التي ارتكبها^(٣). فإذا كانت الإدارة تستطيع أن تضمن عقودها شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص. علي نحو ما فصلنا سابقاً. فإن تلك الشروط لا يمكن أن تصل إلى حد النص علي إعطاء الإدارة الحق في توقيع عقوبات

(١) انظر:

- C.E. 14 février 1908, Chrétien, Rec., p.155.
- C.E. 26 février 1944, PIOC, Rec., p.69.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٤٦٨٢، لسنة ٣٥، الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٤/٢٦.

(٣) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠٦.

جنائية علي المتعاقد معها^(١). وإذا تضمن العقد مثل هذه الشروط التي تتيح للإدارة توقيع جزاءات جنائية، فإنها تعد شروطاً باطلة لمخالفتها للنظام العام^(٢).

ومن المسلم به أن الإدارة قد تمارس سلطة توقيع عقوبات جنائية علي المتعاقد المقصر، ولكن بصفتها سلطة عامة، لا بصفتها طرفاً في العقد. وأهم مجال لهذا الاستعمال هو سلطة البوليس، فالإدارة تملك إصدار لوائح بوليس، وأن تضمنها عقوبات جنائية، فإذا خالف المتعاقد معها . أو أي مواطن آخر . الالتزامات المقررة بمقتضى تلك اللوائح يتعرض الجزاء الجنائي^(٣).

وفي هذا الإطار، تنص المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي أن: « يلتزم المفاوض بتنفيذ محل العقد - بحسب الاحوال - في الميعاد او المواعيد المحددة بامر التوريد او الاسناد ، وعليه اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بتنفيذ موضوع العقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط . ويلتزم المفاوض أيضاً باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئولية في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية. » وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في تنفيذها علي نفقته.

كما قد يرد النص علي اعتبار الإخلال ببعض الالتزامات التعاقدية جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ذلك ما تنص عليه المادة ١١٦ مكرر (ج) من قانون العقوبات، والتي تقرر أن: « كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاول أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩^(٤)، أو مع إحدى شركات المساهمة ويترتب علي ذلك ضرر جسيم أو إذا ارتكب أي

(١) انظر: د: جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٩.

(٢) انظر: د: سعاد الشراقوي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٨٦.

(٣) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠٦.

(٤) تنص المادة ١١٩ المشار إليها علي ما يلي: « يقصد بالأموال العامة في أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لاحدي الجهات الآتية أو الخاضعة لإشرافها أو لإدارتها:

[أ] الدولة و وحدات الإدارة المحلية. [ب] الهيئات (و المؤسسات) العامة ووحدات القطاع العام. [ج] الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. [د] النقابات والاتحادات. [هـ] المؤسسات والجمعيات

غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت في زمن الحرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأي عقد من العقود سألقة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد ويحكم علي الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب علي الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سألقة الذكر علي حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم «.

وفي جميع الحالات التي توقع فيها جزاءات جنائية، يتعين علي الإدارة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز لها أن توقعها بنفسها إلا إذا كان القانون يسمح بذلك، كما أن الجزاء الجنائي مستقل عن سلطة الإدارة المستمدة من العقد^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الخاصة ذات النفع العام. [و] الجمعيات التعاونية. [ز] الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. [ح] أية جهة أخرى ينص علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.

(١) انظر: د: سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٨٨. د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠٩.

الفصل الثاني حقوق المتعاقد مع الإدارة

توجد العديد من الحقوق المقررة للمتعاقد مع الإدارة في مواجهتها، فمن ناحية أولى، المتعاقد مع الإدارة هو إنسان يسعى إلى الحصول على الربح مقابل ما يؤديه من التزامات لصالح الإدارة، ومن ثم يتمثل أولى حقوق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي للعقد. ومن ناحية ثانية، قد يلحق ضررًا للمتعاقد أثناء أو بسبب تنفيذه للعقد الإداري، لذلك يحق له مطالبة الإدارة بالتعويض لجبر هذا الضرر وعلى ذلك يتمثل الحق الثاني للمتعاقد مع الإدارة في الحق في اقتضاء تعويض. ومن ناحية ثالثة، قد تعترض تنفيذ العقد صعوبات خارجية تؤدي إلى تعثر التنفيذ أو إرهاب المتعاقد أو تخل بتوازن العقد المالي، وهنا يبرز ثالث حقوق المتعاقد مع الإدارة وهو حقه في إعادة التوازن المالي للعقد. وعلى ذلك سوف نتناول حقوق المتعاقد مع الإدارة في إطار ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي.

المبحث الثاني: حق المتعاقد في الحصول على تعويض.

المبحث الثالث: حق المتعاقد في ضمان التوازن المالي للعقد.

2024/2025

المبحث الأول

حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي

يعد حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق. صحيح أن بعض العقود الإدارية لا تولد حقًا ماليًا للمتعاقد، بل على العكس تلزمه بأداء نقدي مثل عقود طلب تقديم المعاونة، وشراء شيء أو استئجاره من الإدارة. غير أن أغلب العقود الإدارية الأخرى يستهدف المتعاقد الحصول على مقابل نقدي من الإدارة^(١). ووفقًا لنوع الخدمة التي يلتزم المتعاقد بأدائها للإدارة، يميز الفقه بين نوعين من المقابل المالي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: في حالة أداء المتعاقد للخدمة للإدارة مباشرة: فإن الإدارة تكون هي الملتزمة

بأداء المقابل المالي للمتعاقد. ويتخذ المقابل في هذه الحالة صوراً متعددة وفقاً

لطبيعة العقد: فهو ثمن في حالة عقد التوريد ومقاولات الأشغال العامة و

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٢٧. د: سعاد الشراوي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩٥.

النقل وما جري مجراها. وهو مرتبط في حالة عقود التوظيف وما شابهها. وهو فائدة في حالة عقد القرض....الخ.

ثانياً: في حالة أداء المتعاقد الخدمة للجمهور مباشرة، كما هو الشأن في عقد التزام المرافق العامة، فإنه يحصل على المقابل المالي في صورة رسم يتقاضاه من المنتفعين.

وفي بعض الأحيان قد يصحب المقابل المالي للمتعاقد بعض المزايا المالية الأخرى، كضمان حد أدنى من الربح أو التزام الإدارة بإقراض المتعاقد مبلغ مالي محدد، أو ضمانه لدي البنوك في الحصول على بعض القروض....الخ. وتدخل تلك المزايا في نطاق المقابل المالي للمتعاقد، ولذلك تلتزم الإدارة بالوفاء بها أيضاً^(١).

وكقاعدة عامة، تعد الشروط المتعلقة بتحديد المقابل المالي شروطاً تعاقدية، ومن ثم لا تستطيع الإدارة أن تعدلها بإرادتها المنفردة، بل يتعين موافقة المتعاقد معها على هذا التعديل. وأساس حصانة تلك الشروط من التعديل المنفرد للإدارة يرجع لسببين، **أولهما قانوني**، ذلك أن أساس حق الإدارة في التعديل المنفرد يستند إلى مقتضيات سير المرافق العامة وبالتالي لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق والتي ليس من بينها تلك التي **تحدد المقابل المالي للمتعاقد. والثاني عملي**، إذ لو سمحنا للإدارة بالحق في تعديل الشروط المتعلقة بتحديد المقابل المالي للمتعاقد، فإن ذلك سيؤدي بلا أدنى شك إلى امتناع ونفور الأفراد من التعاقد مع الإدارة. ولكن ترد على هذه القاعدة استثناءان:

الأول: يتعلق بعقد التزام المرافق العامة، وقد رأينا عند دراستنا لعقد التزام المرافق العامة، أن الشروط المتعلقة بتحديد الرسم، هي من قبيل الشروط اللائحية، ومن ثم تستطيع الإدارة أن تعدلها بإرادته المنفردة دون حاجة لرضاء المتعاقد معها.

الثاني: خاص بالعقود التي تؤدي وظيفة الأعمال الشرطية، فهذه العقود لا يتولد عنها مراكز شخصية أو ذاتية فحسب، وإنما تسند إلى المتعاقد مراكز نظامية أيضاً. ومن أوضح الأمثلة لهذه العقود، عقود التوظيف، فالإدارة تستطيع أن تعدل مرتب الموظف بالزيادة أو بالنقص دون أن يحتج عليها بالعقد المبرم بينهما، كما يسري هذا التعديل على جميع الموظفين القدامى والجدد.

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٢٨.

ويعد كلا من الثمن والرسم من أهم صور المقابل المالي في العمل، وبالتالي يتعين علينا أن ندرسهما بشيء من التفصيل في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

الثمن

يتخذ المقابل المالي في أهم العقود الإدارية، كعقود مقاولات الأشغال العامة، التوريد، والنقل... الخ، صورة الثمن. والأصل أن يتم تحديد الثمن في العقد الإداري باتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها. والثمن كما قلنا فيما سبق هو شرط تعاقدى هدف إليه المتعاقد مع الإدارة، فهذا الأخير . في كل حال . يسعى إلى تحقيق الربح، وهو هدف مشروع.

أولاً: ضوابط تحديد الثمن:

أحاط قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية عملية تحديد الثمن في العقد الإداري لضوابط، يتعين على الإدارة ألا تخالفها، وأهم هذه الضوابط:

[أ] حفاظاً على المال العام، يتم إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. (مادة ٣٥ من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

[ب] حددت اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم كتابة وتحديد الأسعار في العروض المقدمة، وهي كما يلي:

- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية و يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
- ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف
- ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء.
- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً وتوقيعه.



- يبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعاً في مصر أو الخارج.

ثانياً: كيفية أداء الثمن:

١. أداء الثمن في عقود الأشغال العامة:

الأصل في عقود الأشغال العامة، أن تسديد الثمن لا يكون إلا بعد أداء المقاول لالتزامه، علي أن الأخذ بهذه القاعدة علي إطلاقها قد يرهق المقاول، نظراً لان تنفيذ العقد قد يستمر مدة طويلة.

ولذلك استثناء من هذا الأصل العام، أجاز قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للإدارة أن تعطي للمقاول بعض الأموال مقدماً لتساعده علي تنفيذ التزامه. والهدف الأساسي من هذا الاستثناء هو تحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال تحقيق المصلحة الخاصة للمقاول، فحين تقوم الإدارة بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ العقد، فإنها تشجع المقاول علي سرعة الوفاء بالتزاماته وبالتالي تضمن عدم توقفه عن التنفيذ الناتج عن عدم وجود السيولة المالية.

وكذلك وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة

٢٠١٨، فإن الإدارة قد تصرف للمقاول دفعات مقدّمة من قيمة التعاقد أو تعطيّه دفعات من 2024/2025 تحت الحساب بعد تمام بعض الأعمال.

وبالنسبة للصورة الأولى نصت عليه المادة ٤٤ من قانون تنظيم التعاقدات التي

تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، محددة للضوابط الواجب توافرها لصرف الدفعات المقدمة من قيمة التعاقد، كما يلي: «يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة بموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدّمة من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعمل ذاتهما، بشرط تضمين كراسة الشروط والمواصفات نسبة الدفعة وطلب تحديد أوجه صرفها، ويتم استئصال قيمة الدفعة المقدّمة مما يتم صرفه للمتعاقد مقابل تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدّمة بالنسبة ذاتها.....».

وفيما يتعلق بالصورة الثانية فقد نصت عليها المادة ٤٥ من قانون تنظيم التعاقدات

التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، يجوز بموافقة الجهة الإدارية المتعاقدة وعلي مسؤوليتها صرف دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وعلي النحو الآتي: "وفي لمقاولات الأعمال تصرف الجهة الإدارية دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل، وذلك خلال ستين يوماً تحسب من تاريخ تقديم المستخلص لها معززاً بالمستندات على النحو الوارد



بشروط التعاقد وقبول هذه المستندات من الجهة الإدارية، وتلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يعتمد".

ووفقا المادة ٩٥ من اللائحة التنفيذية، يكون صرف الدفعات علي النحو التالي:

أ- بواقع ٩٥% من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الوارد من صاحب العطاء. ويتم احتجاز نسبة ال ٥% الباقية لمواجهة اية عيوب او ملاحظات فيوب او ملاحظات في الاعمال يقصر المقاول في اصي الاعمال يقصر المقاول في اصلاحها او تلافيها لحين الاستلام المؤقت. كما يجوز صرف ال ٥% الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

ب- بواقع ٧٥% من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموفقا عليها وان تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي توردها لموقع العمل صالحة للتركيب إلى ان يتم تركيبها.

2024/2025

2024/2025

ج- بعد استلام الأعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالاشراف بتحرير الكشف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها علي الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

د- عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال علي ذلك يسوى الحساب النهائي و يدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقي منه .

ويجوز للمقاول في حالة رفض الجهة الإدارية استلام المستخلص المستوفي لشروط التعاقد إرساله مرفقا به كافة المستندات المبينة بشروط التعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، على أن يكون تاريخ استلام الجهة الإدارية للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء في إجراءات الصرف .

وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدي للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو

المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك.

٢. أداء الثمن في عقد التوريد:

في عقود التوريد يرتبط أداء الثمن بقرار لجنة فحص الأصناف الموردة أو نتيجة الفحص الفني لتلك الأصناف، حيث يتعين أداء الثمن فور صدور قرار لجنة الفحص الفني، وعلي ذلك تنص المادة ٤٥ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ علي ان: " مع مراعاة شروط التعاقد، يصرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد".

وفي الحالات التي يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استلام الأصناف - فيجب علي الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد علي أساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن «.

ومن الجدير بالذكر انه يتم سداد الثمن كاملا للمورد إذا كانت الأصناف الموردة مطابقة للمواصفات، أما إذا كانت تلك الأصناف وفقا لقرار الجهة التي تقوم بالفحص الفني 2024/2025 مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد علي أساسها، فيجب خفض الثمن تبعاً لهذا النقص، ووفقاً للضوابط التي حددتها المادة رقم ١١٦ من اللائحة التنفيذية، وهي كما يلي:

أ. يجوز قبول الاصناف اذا كانت نسبة التباين لا تزيد عن ١٠% عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد علي اساسها، ويتعين لقبول تلك الأصناف توافر الشروط الآتية:

- (١) أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما به من تباين.
- (٢) أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلها وانه لن يترتب علي قبولها ضرر بالجهة الادارية، ولا تون قد سبق رفض عطاءات لنفس السبب.

(٣) أن يقابل ذلك النقص خفضا في السعر يتناسب معه، ويجب أن يكو السعر بعد الخفض مناسباً لنظيره في السوق.

ب. يجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني او اكثر من الجهات الفنية المختصة اذا رأت ضرورة لذلك وبراعي الاتي:

(١) الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها لغاية ٢% يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة.

(٢) الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من ٢% لغاية ٥% يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه مقابل تباين مقداره ٥٠% من هذا المقدار.

(٣) الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من ٥% لغاية ١٠% يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافا إليه مقابل تباين مقداره ١٠٠% من هذا المقدار.

علي أن يكون قبول تلك الأصناف بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام هذه اللائحة. كما ان إذا قررت الجهة التي تقوم بفحص الأصناف إنها غير مطابقة بنسبة تزيد عن ١٠% بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد عليها، تعين علي الجهة الإدارية أن ترفضها.

المطلب الثاني

الرسم

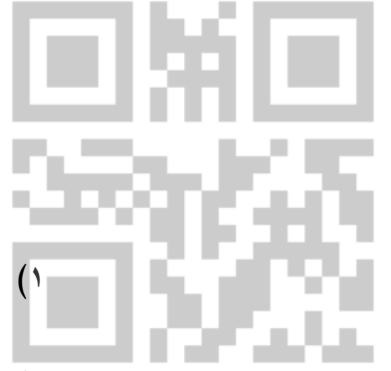
الرسم هو المقابل المالي الرئيسي الذي يحصل عليه الملتزم في عقد التام المرافق 2024/2025

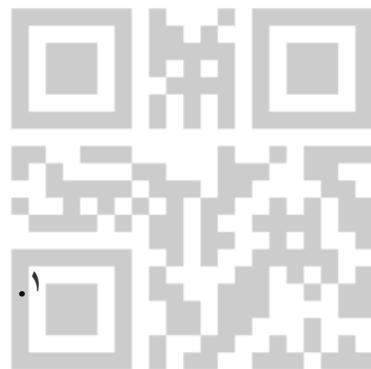
العامة. ويلتزم بأدائه جمهور المنتفعين بخدمات المرفق محل عقد الالتزام.

هذا ويعد الرسم في عقد التزام المرافق العامة من الشروط اللائحية، ومن ثم يمكن للإدارة أن تغيره بإرادتها المنفردة حسب ما تقتضيه مصلحة المرفق، وفي هذا الصدد تنص المادة الخامسة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ المتعلق بالالتزام المرافق العامة، علي انه: « لمانح الالتزام دائما متي اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام وقواعد استغلاله، وبوجه خاص قوائم الأسعار الخاصة به، وذلك مع مراعاة حق الملتزم في التعويض إن كان له محل ».

أولاً: أساليب تحديد الرسم:

يتم النص في عقد الالتزام علي قيمة الرسوم التي يجوز للملتزم تقاضيها من المنتفعين. كما قد تتولى الإدارة بنفسها تحديد هذه الرسوم، وتلجأ الإدارة في تحديدها للرسم اتباع إحدى الوسائل التالية:





٢. أن تتولى الإدارة بنفسها تحديد الرسم دون استشارة الملتزم.

٤. أن تترك للملتزم الحرية في تحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه من جمهور المنتفعين، وذلك بشرط عدم المغالاة في تحديده، فإن غالي في تحديده أو حدده بطريقة تتعارض مع المصلحة العامة، جاز لمانح الالتزام أن يرد هذا المقابل إلى حدوده المعقولة^(٣)، فكما ذكرنا يعد الرسم من الشروط اللائحية.

ترد علي حرية الإدارة والملتزم قيود فيما يتعلق بتحديد الرسم أيا كانت الطريقة المتبعة في تحديده. ويمكن رد هذه القيود إلى الاعتبارات الآتية:

١ مبدأ المساواة بين المنتفعين: 2024/2025

فالمرافق العامة تخضع لقاعدة المساواة بين المنتفعين، وتجد هذه القاعدة صداها فيما يتعلق بضرورة التسوية بين المنتفعين في الرسوم التي يقررها عقد الالتزام، إذ يتعين على الإدارة حين تحدد الرسم بمفردها، وعلى الملتزم حين يترك له الحرية في تحديد الرسوم، احترام القاعدة السابقة. وقد قننت هذه القاعدة تشريعيا في مصر، فقد نصت المادة ٦٧٠ من القانون المدني على ما يلي:

« ١. إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، يجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.

« ٢. ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تتطوّر علي تخفيض الأجور أو الإعفاء منها علي أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافر فيه شروط

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٤٨.

(۲) انظر: د: إبراهيم محمد علي: مرجع سبق ذكره، ص ۱۹۲.

(٢) نظر: المادة الخامسة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ المتعلق بالتزام المرافق العامة.





يعينها الملزم بوجه عام. ولكن المساواة تُحرم علي الملزم أن يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين.

« ٣. وكل تمييز يُمنح علي خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يُوجب علي الملزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب علي هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة ».

وإذا كان النص السابق قد تحدث عن الالتزام إلى يتضمن احتكارا فعلياً أو قانوناً، وهي الحالة الغالبة في عقود الالتزام، فمما لا شك فيه . وفقاً لقواعد القانون الإداري . أن قاعدة المساواة تشمل جميع أنواع المرافق العامة.

ومن المسلم به أن المساواة بين المنتفعين لا تعني بطبيعة الحال المساواة الحسابية أو المطلقة، ولكن يقصد بها توحيد المعاملة متى تماثلت الظروف. ومن ثم يجوز التمييز في حالة اختلاف الظروف. أما ما يحرمه مبدأ المساواة بين المنتفعين، هو خلق امتيازات خاصة غير مبررة لبعض المنتفعين. وبناء علي ذلك من الممكن تغير قيمة الرسم وفقاً لبعد المكان الذي تؤدي فيه الخدمة، أو لنوع الخدمة المطلوبة، أو زمانها...الخ^(١).

٢. القيود التشريعية علي تحديد قيمة الرسم:

قد يحدد المشرع صراحة السعر الذي يتعين أن تقدم به الخدمة كما لو حدد سعر 2024/2025 2024/2025 الكهرباء أو الغاز أو البنزين أو النقل.....الخ. وفي هذه الحالة لا تستطيع كلا من الإدارة أو الملزم أن يخرج عن تلك النصوص التشريعية.

وفي هذا الصدد تنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٩، علي أن: « لا يجوز أن تتجاوز حصة الملزم السنوية في صافي أرباح استغلال المرفق العام عشرة في المائة من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح الالتزام وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال. وما زاد علي ذلك من صافي الأرباح يستخدم أولاً في تكوين احتياطي خاص للسنوات التي تقل فيها الأرباح عن عشرة في المائة. وتقف زيادة هذا الاحتياطي متى بلغ ما يوازي عشرة في المائة من رأس المال. ويستخدم ما يبقى من هذا الزائد في تحسين وتوزيع المرفق العام أو في خفض الأسعار حسبما يري مانح الالتزام ». وبالتالي يلزم هذا النص جهة الإدارة أن تعيد النظر في تعريف الأسعار في ضوء ما يسفر عنه تشغيل المرفق من أرباح طبقاً للأسس التي توضحها تلك المادة.

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٥١.





المبحث الثاني حق التعاقد في الحصول علي تعويض

يحق للمتعاقد مع الإدارة أن يطالبها بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه أثناء تنفيذ العقد الإداري أو بسببه. ويمكن تأسيس هذا التعويض إما علي خطأ الإدارة «المطلب الأول»، أو علي نظرية الإثراء بلا سبب «المطلب الثاني».

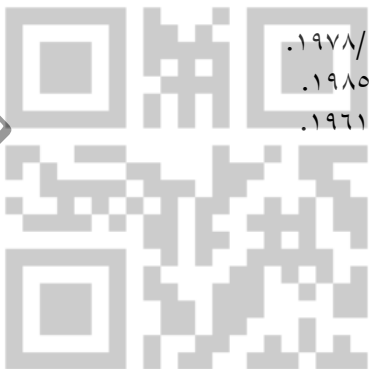
المطلب الأول

التعويض علي أساس خطأ الإدارة

استقر قضاء مجلس الدولة المصري علي أن إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها قبل التعاقد معها علي نحو من شأنه إلحاق ضرر به، يعد سبباً مبرراً لاستحقاقه التعويض عما أصابه من أضرار ناتجة عن ذلك التقصير العمدي أو غير العمدي علي حد سواء^(١). وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٣ يونيو سنة ١٩٦٧ أنه «متي كان الثابت انه قد حيل بين المتعاقد والبدء في تنفيذ العملية بسبب تعرض رجال الإصلاح له، الأمر الذي ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور أمر التشغيل دون أن تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها بتسليم الطاعن مواقع العمل وتمكينه من البدء في التنفيذ، فمن ثم فإنه إذا لوحظ أن المدة التي حددت لتنفيذ العملية هي 2024/2025 2024/2025 شهران فقط، فإن عدم قيام الهيئة المذكورة بتسليم مواقع العمل إلى الطاعن طيلة عام بأكمله مما يحق معه القول بأنها قد أخلت إخلالاً جسيماً بواجباتها نحو الطاعن بعد تمكينه من العمل، وإنها تأخرت في تنفيذ التزامها هذا مدة كبيرة تجاوز القدر المعقول مما يقوم سبباً مبرراً لفسخ العقد المبرم بينهما وتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب ذلك»^(٢). ومن الأمثلة الشائعة لأخطاء الإدارة والتي توجب مسئوليتها، ومن ثم تحملها عبئ التعويض في مواجهة المتعاقد معها، ففي عقود الأشغال العامة: تأخر الإدارة أو عدم تسليمها موقع العمل وتمكينه من البدء في التنفيذ، عدم تمكين المقاول من تشوين المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد، قيام الإدارة بتغيير موقع العمل بعد البدء في التنفيذ.... الخ. وفي عقود التزام المرافق العامة: عدم احترام الإدارة لشرط عدم المنافسة بغير مقتضى

(١) انظر:

- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٠٢٧، لسنة ١٥ق، الصادر بتاريخ ١/٢٨/١٩٧٨.
- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٥٠٣، لسنة ٢٧ق، الصادر بتاريخ ٤/٢/١٩٨٥.
- محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ١٣٠٥، لسنة ١٣ق، صادر بتاريخ ١/١/١٩٦١.
- (٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٨٦٢، لسنة ٩ق، الصادر بتاريخ ٦/٣/١٩٦٧.



الصالح العام. وكذلك في عقود التوريد: امتناع الإدارة عن قبول الأصناف المقدمة من المورد والمطابقة للمواصفات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما بحجة عدم صدور الموافقات الإدارية اللازمة لقبولها، تأخر الإدارة في استلام الرسائل الموردة لها، ويتعدى تأخيرها هذا المدة المعقولة.

غير انه في بعض الحالات يكون الضرر الذي أصاب المتعاقد مع الإدارة أساسه خطأ مشترك، أي الخطأ الذي يرجع إلى المتعاقد نفسه والإدارة في ذات الوقت، وفي هذه الحالة يحدد القاضي الإداري نصيب كل من الإدارة والمتعاقد معها في الخطأ، ثم يقدر علي أساس ذلك قيمة التعويض (١).

هذا ويطبق القضاء الإداري، فيما يتعلق بمسئولية الإدارة المتعاقدة القواعد العامة في المسئولية المطبقة في نطق القانون الخاص، لذلك يتعين لقيام المسئولية الإدارية توافر أركانها الثلاث (٢):

١. الخطأ متمثلاً امتناع الإدارة عن القيام بواجباتها التعاقدية أو تأخيرها في ذلك.
٢. الضرر الذي يصيب المتعاقد مع الإدارة.
٣. علاقة السببية بين الخطأ المنسوب للإدارة والضرر الذي يصيب المتعاقد معها.

المطلب الثاني

التعويض علي أساس الإثراء بلا سبب

2024/2025

2024/2025

تقضي القواعد العامة المطبقة في نطاق القانون الخاص بتعويض من أثري الغير علي حسابه في حدود هذا الإثراء ويقدر ما لحق بذمة المتسبب في هذا الإثراء من نقص أو خسارة مالية، وينظم نظرية الإثراء بلا سبب المادة ١٧٩ من القانون المدني، والتي تنص علي أن: « كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر لتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً و لو زال الإثراء فيما بعد ».

ومن المسلم به فقهيًا (٣) وقضائياً سريان تلك القاعدة في شأن العقود الإدارية، فيحق للمتعاقد مع الإدارة مطالبتها بالتعويض استناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في الحالات التي

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٣٠٣، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٢/٣١/١٩٦٦.

(٢) انظر المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقم ١٦٧٥، لسنة ١٩٥٦، لسنة ٣٠ق، الصادرين بتاريخ ١٣/٣/١٩٩٠. وايضا الطعن رقم ٢٠١٣، لسنة ٣٣ق، الصادر بتاريخ ٧/٢١/١٩٩٢.

(٣) انظر: إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٧. د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ١٩١. د: عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقاتها في مصر، ١٩٩١، ص ٥٦٣.

يقوم فيها تلقائيا وبدون تكليف منها بأداء أعمال أو خدمات إضافية غير منصوص عليها بالعقد، وذلك بشرط أن تكون تلك الأعمال أو الخدمات ذات فائدة ولازمة للمرفق العام^(١). وعلي العكس من ذلك، إذا كانت الأعمال أو الخدمات التي قام بها المتعاقد لا تستفيد منها الإدارة، فلا تلتزم الأخيرة في تلك الحالة بتعويض المتعاقد، هذا فضلا عن التزام المتعاقد نفسه ماليا في مواجهة الإدارة عما تكون قد تكبدته هي نفسها من نفقات أو مصروفات مالية بسبب أدائه لتلك الأعمال أو الخدمات غير المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما.

المبحث الثالث

حق المتعاقد في ضمان التوازن المالي للعقد

إذا كان الأصل العام في عقود القانون الخاص تقضي بأن «العقد شريعة المتعاقدين» بمعنى أن أطراف العقد يلتزمان بالتزامات محددة لا تتغير أثناء تنفيذ العقد، فإن هذا الأصل يعد الاستثناء في إطار تنفيذ العقود الإدارية، حيث أن القاعدة العامة في تنفيذ هذه العقود هو مرونة التزامات المتعاقد مع الإدارة وتحركها أما بالزيادة أو بالنقصان. علي أن هذه القاعدة إذا اقتضت علي التزامات المتعاقد فقط، يصبح العقد الإداري مغرمة لهذا المتعاقد، إضافة إلى ما يشكله ذلك من إرهاب مالي له وغبن في حقوقه. ومن ثم كان لابد من أن تشمل هذه القاعدة حقوق المتعاقد مع الإدارة. ويترتب علي ذلك انه في حالة زيادة التزامات المتعاقد مع الإدارة، زادت حقوقه أيضا، وتلك هي فكرة التوازن المالي في العقود الإدارية.

لقد ظهرت فكرة التوازن المالي في العقود الإدارية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ففي حكمة المتعلقة بقضية « Cie française des tramways » الصادر بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩١٠، وقد تولي المفوض ليون بلوم صياغتها في تقريره الذي قدمه للمجلس، ويقول المفوض بلوم في هذا التقرير أن: « من الأمور الجوهرية في عقود الالتزام، ضرورة أن يتحقق بقدر الإمكان التساوي بين المزايا التي تقررت للملتزم وبين للأعباء التي تفرض عليه.... فالمزايا والأعباء يجب أن تتوازي بما يحقق التوافق بين الفوائد المحتملة والالتزامات المفروضة. ففي كل عقد التزام يتضمن . كما لو كان حسابا . التوازن الشريف بين ما يمنح

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم ٥٦٢، لسنة ٢٣ق، الصادر بتاريخ ١٥/٤/١٩٧٨. وراجع أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي أقرت التعويض علي أساس نظرية الإثراء بلا سبب:

- C.E. 14 avril 1961, Min. de la Construction, Rec., p. 236.
- C.E. 2 décembre 1966, Sté France-Reconstruction , Rec., 635.

للملتزم وبين ما يتطلب منه... وهذا هو ما يطلق عليه التوازن المالي والتجاري، التساوي المالي لعقد الامتياز»^(١).

ثم استقرت هذه الفكرة في الفقه والقضاء كمبدأ أساسي حكم التزامات المتعاقد مع الإدارة. وفي هذا الصدد تقرر محكمة القضاء في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧: « إن من طبيعة العقود الإدارية إنها تحقق بقدر الإمكان توازناً بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة، وبين المزايا التي ينتفع بها، علي اعتبار بان نصوص العقد تؤلف في مجموعها كلا من مقتضاه وجوب التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين، فإذا ترتب علي تعديل التزامات المتعاقد مع الإدارة زيادة في أعبائه المالية، فإنه ليس من العدل ولا من المصلحة العامة نفسها أن يتحمل المتعاقد وحده تلك الأعباء، بل يكون له في مقابل ذلك أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد تأسيساً علي أن هذا العقد ينظر إليه كوحدة من حيث تحديد الحقوق المالية للمتعاقد، فإذا ما انتهى تدخل الأداة في العقد بالتعديل إلى الإخلال بهذه الحقوق كما حددت عند إبرام العقد، فيجب إعادة التوازن المالي للعقد إلى ما كان عليه،»^(٢).

ومن الجدير بالذكر، أن فكرة التوازن المالي للعقود الإدارية لا تطبق في حالة استحقال المتعاقد مع الإدارة التعويض في حالة وجود خطأ منسوب لجهة الإدارة. وإنمى 2024/2025 2024/2025
2024/2025
مجال تطبيقها علي حالات التعويض التي يستحقها المتعاقد مع الإدارة دون وجود خطأ منسوب للإدارة.

ونظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما يؤدي الي عدم استقرار الاسعار، ما بين صعود وهبوط، مما يؤثر تأثيراً كبير علي فكرة التوازن المالي للعقد، وقد يؤدي توقف المتعاقد عن العمل في حالة ارتفاع الاسعار، مما يضر بالمصلحة العامة، ولذلك استحدثت المشرع المصري في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تمكين الادارة من تعديل قيمة عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الأحوال، بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت

(١) انظر:

• C.E. 11 mars 1910, Cie Française des Tramways, Concl. Blum, Rec., p.218.

(٢) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٩٨٣، لسنة ٩٩، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.



بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراجعة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزماً لطرفي التعاقد، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك .

وبناء على ذلك توجد ثلاث حالات يستحق فيها المتعاقد التعويض دون أن ينسب إلى جهة الإدارة أي خطأ، هذه الحالات هي: عمل الأمير، والظروف الطارئة، والصعوبات المالية غير المتوقعة، ويضاف إليها حالة امكانية تعديل عقود المقاولات. وسوف نتناول دراسة كل حالة من هذه الحالات في مطلب مستقل علي النحو التالي:

المطلب الأول نظرية عمل الأمير

أولاً: تعريف فعل الأمير:

يعرف الفقه والقضاء في مصر فعل الأمير بتعريفات عديدة متفقة في المضمون، علي الرغم من اختلافها في العبارات والألفاظ.

فيعرف رأي فقهي فعل الأمير بأنه: «كل إجراء تتخذه السلطة العامة من شأنه أن يزيد ف الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو في الالتزامات التي ينص عليها العقد مما يطلق عليه بصفة عامة (المخاطر الإدارية)»^(١).

ويعرفه رأي فقهي آخر بأنه: «الأعمال الإدارية المشروعة التي تصدر عن السلطة العامة التي أبرمت العقد، ويكون لها علي تنفيذ العقد اثر يضر بمصالح المتعاقد»^(٢).

ويعرفه رأي فقهي ثالث بأنه: «كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه تسوئ مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيدوازن المالي للعقد»^(٣).

وفيما يتعلق بمجلس الدولة المصري، تقرر محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧: «...أن المقصود بعبارة فعل الأمير هو كل إجراء

(١) انظر: د: توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص ٨١٥.

(٢) انظر: د: فؤاد مهنا، مرجع سبق ذكره، ص ٧٢٧.

(٣) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٦٧.

تتخذ السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو في الالتزامات التي ينص عليها العقد مما يطلق عليه بصفة عامة " المخاطر الإدارية " وهذه الإجراءات التي تصدر من السلطات العامة قد تكون من الجهة الإدارية التي أبرمت العقد وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص أو تكون بقواعد تنظيمية عامة «^(١)».

وفي هذا الصدد تقرر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتاها الصادرة بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩٦٥ أن: « عمل الأمير هو إجراء خاصاً أو عاماً من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة لم يكن متوقفاً وقت التعاقد يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقدين لا يشاركه فيه سائر من يسهم في الإجراء » «^(٢)». وكذلك في فتاها الصادرة بتاريخ ١٣ يوليو سنة ١٩٧١ تقول أنه: «... يمكن تعريف هذا الفعل (عمل الأمير) بأنه كل إجراء تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو الالتزامات التي ينص عليها العقد » «^(٣)».

ثانياً: شروط تطبيق نظرية عمل الأمير:

- استقر الفقه والقضاء الإداريين في كل من مصر وفرنسا علي ضرورة توافر مجموعة من شروط حتى يتثني تطبيق نظرية عمل الأمير. هذا وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا هذه الشروط في حكمها الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٩٧، بقولها: «^{2024/2025} فإن قضاء هذه المحكمة مستقر علي أن القضاء بأحقية المتعاقد مع الإدارة بالتعويض بناء علي نظرية عمل الأمير مرهون بتوافر شروط انطباق تلك النظرية، وهي:
١. أن يكون ثمة عقد من العقود الإدارية.
 ٢. أن يكون الفعل الضار صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة.
 ٣. أن ينشأ عند ضرر المتعاقد.
 ٤. افتراض أن الإدارة المتعاقدة لم تخطئ حين اتخذت عملها الضار فمسئوليتها عقدية بلا خطأ.
 ٥. أن يكون الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع.

(١) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٩٨٣، لسنة ٩٩، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

(٢) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى رقم ٢٩٧ في ١١/٣/١٩٦٥، جلسة (١٩٦٥/٢/٢٤) ٣٠٩/٨٨/١٩.

(٣) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى رقم ٧٥٤ في ١٣/٧/١٩٧١، جلسة (١٩٧١/٧/١١) ٤٥٠/١٤٤/٢٥.

٦. أن يلحق المتعاقد ضرر خاص لا يشاركه فيه من يمسه الإجراء العام «(١)». وسوف نتناول هذه الشروط بالدراسة والتحليل تباعاً علي النحو التالي:

١. وجود عقد إداري:

يشترط لتطبيق نظرية فعل الأمير وجود عقد اداري بالمعني المتفق عليه فقهاً وقضاءً، ويعد هذا الشرط أمراً طبيعياً لأننا بصدد نظرية تتعلق بعقود القانون العام وتتميز بطابع خاص يميزها عن عقود القانون الخاص(٢).

وعلي ذلك لا تطبق تلك النظرية علي عقود الإدارة المدنية، والإجراءات الإدارية التي تصدرها بعض السلطات الإدارية والتي قد تؤثر علي ميزانية أحد الأفراد دون وجود أية رابطة عقدية بينه وبين الجهة الإدارية مصدرة هذه الإجراءات. وتؤكد محكمة القضاء الإداري علي أهمية هذا الشرط، ففي حكمها الصادر بتاريخ ٣ مارس سنة ١٩٥٧، تقول انه: «...متي كان الأمر بين الشركة وبين الحكومة خارجاً عن نطاق الرابطة العقدية فإن طلب التعويض عن الأضرار التي تترتب علي التشريع الجديد استناداً إلي نظرية عمل الأمير يكون علي غير أساس سليم من القانون إذ من المقرر أن المسؤولية التي ترتب التعويض في نطاق نظرية أعمال الأمير لا تقوم إلا في حالة ما إذا كان المضرور بسبب التشريعات الجديدة تربطه بالدولة رابطة تعاقدية أثر فيها التشريع الجديد، بأن زاد في الأعباء التي يتحملها في تنفيذ التزاماته بمقتضى العقد وأن تؤدي هذه الزيادة في الأعباء المالية إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد»(٣).

٢. أن يكون الإجراء الضار صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة:

يشترط لتطبيق نظرية عمل الأمير أن يكون الفعل أو الإجراء الضار صادراً من الجهة المتعاقدة. وقديماً كان مجلس الدولة الفرنسي يجيز التعويض علي أساس تلك النظرية دون أن يفرق بين الفعل أو الإجراء الصادر من جهة الإدارة المتعاقدة ذاتها أو من جهة أخرى غير متعاقدة. وتستقر حالياً أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومنذ حكمه في قضية « Ville de Roulon » علي قصر تطبيق نظرية فعل الأمير علي الأعمال الصادرة من جهة الإدارة المتعاقدة فقط. أما الأفعال الضارة الصادرة عن سلطات الدولة الأخرى - كما

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٧٤٩، لسنة ٣٧ق، الصادر بتاريخ ١٦/١٢/١٩٩٧. وكذلك راجع حكمها في الطعن رقم ٦٥، لسنة ١٢ق، الصادر بتاريخ ١٩٦١/٥/٢٠.

(٢) انظر: عبد العظيم عبد السلام، أثر فعل الأمر علي تنفيذ العقد الإداري، الولاء للطبع والتوزيع، ١٩٨٩، ص ٤٤. و راجع أيضاً: د: إبراهيم محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص ٢٣١.

(٣) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ١٥٢٥، لسنة ٦ق، الصادر بتاريخ ٣/٣/١٩٥٧.



سنري فيما بعد - نتيج أيضا التعويض للمتعاقد مع الإدارة ولكن في إطار نظرية الظروف الطارئة إذا توافرت باقي شروطها.

ويتجه مجلس الدولة المصري إلى اشتراط صدور الإجراء الضار من جهة الإدارة المتعاقدة، ففي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٦٩ تقرر أن: « ومن حيث أنه يشترط لتعويض المدعين إعمالاً لنظرية عمل الأمير أن يترتب الضرر الذي يكون قد أصابهما، إن كان ثمة ضرر قد لحقهما نتيجة تنفيذ عقد التوريد محل المنازعة علي إجراء تكون جهة الإدارة المتعاقدة قد اتخذته من جانبها سواء كان ذلك في نطاق العقد، وعلي سبيل استعمالها حقها في التعديل بهدف حسن سير المرفق وتنظيمه أو كان خارج نطاق العقد»^(١).

وفي ذات الإطار تقول المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٦٨: « أن تدخل القضاء الإداري لتحقيق التوازن المالي للعقد الإداري تطبيقاً لنظرية فعل الأمير مناطه توافر شروط هذه النظرية، ومن بينها شرط أن يكون الفعل الضار صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة، فإذا صدر هذا الفعل عن شخص معنوي آخر غير الذي أبرم العقد تخلف أحد شروط نظرية فعل الأمير وامتنع بذلك تطبيقها، ولكن ذلك الامتناع لا يحول دون تطبيق نظرية الحوادث الطارئة إذا ما توافرت شروطها»^(٢).

2024/2025

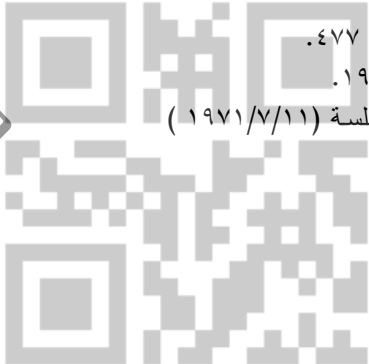
وأيضاً في هذا الصدد تقرر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتاها الصادرة بتاريخ ١٣ يولييه سنة ١٩٧١ أنه: « و يشترط لإعمال تلك النظرية " نظرية عمل الأمير " عدة شروط من بينها أن يكون الفعل الذي أدى إلى زيادة أعباء المتعاقد والتزاماته صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة، فإذا صدر هذا الفعل عن جهة أخرى غير التي أبرمت العقد تخلف أحد شروط نظرية فعل الأمير وامتنع بذلك تطبيقها»^(٣).

هذا ويفترض شرط صدور الفعل أو الإجراء الضار من الإدارة المتعاقدة وجود أشخاص معنوية عامة بجوار الدولة. والأشخاص المعنوية العامة قد تكون أشخاصاً معنوية إقليمية كالمحافظات، المراكز، المدن، القرى والأحياء، وقد تكون أشخاصاً معنوية مرفقية أو مصلحة كالهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى النقابات المهنية وغيرها المؤسسات أو

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ ١٩٦٩/٥/٥، مجموعة المبادئ، ص ٤٧٧.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٥٦٢، لسنة ١٠، الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٥/١١.

(٣) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى رقم ٧٥٤ في ١٣/٧/١٩٧١، جلسة (١٩٧١/٧/١١) ٤٥٠/١٤٤/٢٥.



الهيئات التي تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات السلطة العامة^(١). فإذا أبرم أحد الأشخاص المعنوية العامة - السابق الإشارة إليهم - عقدا إداريا، فيشترط صدور الفعل أو الإجراء الضار عنه حتى تطبق نظرية عمل الأمير.

ويجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يطبق على الوزارات المختلفة في الدولة، كوزارة التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو التربية أو التعليم.... الخ، فإذا أبرمت إحدى هذه الوزارات عقدا إداريا، فما يصدر عنها أو عن أية وزارة أخرى أو عن مجلس الوزراء يعتبر صادرا عن نفس الجهة المتعاقدة، ويرجع ذلك إلى فكرة وحدة شخصية الدولة، فلا عبره بتعدد الأجهزة داخل الدولة واستقلال كل منها عن الآخر، ذلك لأن تلك الأجهزة هي مجرد أوجه لشخص قانوني واحد هو الدولة^(٢).

والفعل أو الإجراء الصادر عن الجهة المتعاقدة والذي يستوجب تطبيق نظرية عمل الأمير، قد يصدر في صورة إجراء خاص يؤدي إلى تعديل مباشر في العقد، وقد يكون في صورة إجراء عام يؤدي إلى تعديل شروط العقد:

أ- صدور عمل الأمير في صورة إجراء خاص:

قد تتدخل جهة الإدارة - وفقا لسلطتها في تعديل العقد - وتصدر قرارات بإرادتها المنفردة لتعديل شروط العقد إما زيادة أو نقصا^{2024/2025}، ويترتب على ذلك بالضرورة تعديل التزامات المتعاقد معها زيادة أو نقصا. وهذا بالطبع يستوجب تعويض هذا المتعاقد ضمانا لوجود توازن بين التزاماته وحقوقه حتى لا يفقد مبرر استمراره في علاقته التعاقدية مع الإدارة^(٣). وعلي ذلك في حالة تدخل الإدارة المتعاقدة بموجب حقها في تعديل العقد الإداري، وأدى تدخلها هذا إلى تعديل وتغيير في التزامات المتعاقد معها، استوجب ذلك تطبيق نظرية عمل الأمير - وذلك متي توافرت باقي شروطها - وتعويض هذا المتعاقد.

ب- صدور عمل الأمير في صورة إجراء عام:

ويقصد هنا بالإجراء العام التشريع أو اللائحة التي تؤدي إلى تعديل شروط العقد الإداري. فعلي سبيل المثال صدور قانون أو لائحة يقرر تخفيض نفقات الدولة، زيادة قيمة

(١) راجع مؤلفنا، الأسس العامة للتنظيم الإداري، مكتبة جامعة طنطا، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥، الأشخاص المعنوية العامة، ص ٥٦ و ما بعدها.

(٢) المرجع السابق، ص ٦٢-٦٣.

(٣) انظر: د: جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٥.

الضرائب، فرض ضرائب جديدة، رفع الحد الأدنى للأجور، فرض تأمينات اجتماعية، أو خفض العملة المحلية.....الخ.

فإذا أدى صدور القانون أو اللائحة زيادة أعباء المتعاقد أو الانتقاص منها، فإنه يتم تطبيق نظرية عمل الأمير، بشرط توافر باقي شروطها، ويتم تعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملا.

وفي هذا الصدد تقرر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتاها الصادرة بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩٦٥: « أنه وأن ترتب علي تنفيذ القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ زيادة في أعباء شركات المقاولات عن عمال المقاولات وعمال الترحيل والعمال الموسميين الذين تستخدمهم، وذلك كاشتراكات في التأمينات الاجتماعية المقررة بذلك القانون، إلا أن ذلك لا يبرر وحدة نشوء حق لهذه الشركات في المطالبة بتعويض عن هذه الأعباء الجديدة، أو في زيادة قيمة ما أبرمته من عقود قبل تقرير تلك الأعباء لمواجهتها، وإنما يجب أن يرد هذا الحق إلى أساس في القانون، ويستمد من قواعده الصادرة عن التشريع أو القضاء الإداري المستقر. ذلك أن صدور تشريع يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة قد يكون سببا في نشوء حق لهذا المتعاقد في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه

نتيجة هذا التشريع، والاساس القانوني لهذا الحق) 2024/2025 حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري 2024/2025. يرجع أما إلى نظرية عمل الأمير أو إلى نظرية الظروف الطارئة «(١).

٣. أن ينشأ عنه ضرر خاص للمتعاقد:

يجب ان يترتب علي فعل الأمير ضرراً فعلياً للمتعاقد مع الإدارة. ولا يشترط هنا درجة معينة لجسامة هذا الضرر، فقد يكون الضرر جسيماً او يسيراً، وقد يتمثل في ضرر فعلي يصيب المتعاقد، وقد يكون مجرد إنقاص في الربح الذي ارتضي علي أساسها المتعاقد إبرام العقد(٢).

هذا ويعد الضرر هو المبرر لتعويض المتعاقد مع الإدارة، فإذا انتفي هذا الضرر فلا يحق له طلب التعويض. ويجب أن يكون هذا الضرر خاصاً، بمعنى أن يصيب المتعاقد مع الإدارة وحدة، أما إذا كان الضرر عاماً أي يصيب العموم، فلا وجه لانطباق نظرية عمل الأمير، وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر

(١) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى رقم ٢٩٧ في ١١/٣/١٩٦٥، جلسة (١٩٦٥/٢/٢٤)

٣٠٩/٨٨/١٩

(٢) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٧١.

سنة ١٩٩٧ أن: «...الضرر الذي تدعيه الشركة بسبب زيادة أسعار مواد البناء ليس ضرراً خاصاً بتلك الشركة بحسبان أن تلك الزيادة قد تم سريانها علي جميع التعاقدات سواء في النطاق الإداري أو نطاق تعاملات الأفراد وبالتالي فلا تكون شروط انطباق نظرية فعل الأمير متحققة بالنسبة للنزاع المائل، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب»^(١).

٤. عدم وقوع خطأ من الإدارة:

يشترط لتطبيق نظرية عمل الأمير عدم وقوع خطأ من الإدارة عند إصدارها لإجراء الضرر الذي ترتب عليه إضرار بالمتعاقد معها. فالإجراء الذي يتيح المطالبة بالتعويض، إجراء مشروع في حد ذاته، سواء كان صادراً عن الإدارة المتعاقدة نفسها حين تمارس سلطتها في تعديل نص من نصوص العقد، أو كان صادراً عن أي سلطة أخرى تتخذ إجراء عام. فإذا ثبت أن هذا الإجراء ينطوي علي خطأ وقعت فيه الإدارة المتعاقدة فلا تطبق نظرية عمل الأمير لاستحقاق المتعاقد لتعويض استناداً إلى المسؤولية العقدية، حيث أن مسؤولية الإدارة وفقاً لنظرية عمل الأمير، وإن كانت مسؤولية عقدية، إلا إنها مسؤولية عقدية بلا خطأ.

ولقد أشارت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠ مايو سنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ١٩٦١ لهذا الشرط بقولها: «...من شروط نظرية عمل الأمير.....افتراض أن الإدارة المتعاقدة لم تخطئ حين اتخذت عملها الضار، فمسئوليتها بلا خطأ....»^(٢).

٥. أن يكون الإجراء الضار غير متوقع:

يشترط لتطبيق نظرية عمل الأمير أن يكون الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع، فإذا توقع المتعاقد مع الإدارة هذا الإجراء الضار وقدره أثناء التعاقد فلا يحق له طلب التعويض وفقاً لنظرية فعل الأمير وذلك بسبب انتفاء أحد شروط تطبيقها. ويعد هذا الشرط شرطاً عاماً في جميع النظريات التي تسعى إلى إقامة التوازن المالي في العقد الإداري والمعروفة بنظرية فعل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، ولذلك إذا توقعت نصوص العقد مثل هذا الإجراء، كان المتعاقد مع الإدارة قد أبرم العقد وهو مقدر لهذه الظروف، ومن ثم تستبعد أحكام نظرية عمل الأمير من التطبيق وتطبق النصوص التعاقدية.

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٧٤٩، لسنة ٣٧ق، الصادر بتاريخ ١٦/١٢/١٩٩٧.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٦٥، لسنة ٢ق، الصادر بتاريخ ٢٠/٥/١٩٦١.

وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو ١٩٥٧ هذا الشرط، حيث تقول: «...ومن شروط تطبيق نظرية عمل الأمير أن يكون الإجراء أو التشريع الجديد غير متوقع الصدور وقت التعاقد، فإذا ما توقعته نصوص العقد، فإن المتعاقد مع الإدارة يكون قد أبرم العقد وهو مقدر لهذه الظروف الأمر الذي يترتب عليه تعذر الاستناد إلى نظرية فعل الأمير»^(١).

وقد أكدت المحكمة الإدارية علي ذلك في حكمها الصادر بتاريخ ١١ يناير سنة ١٩٦٩، بقولها: «...إذا كان الثابت أن المتعاقدين قد توقعوا عند إبرام العقد زيادة الرسوم الجمركية والضرائب واجر النقل أو نقصها ووضعاً نصاً في العقد ليحكم هذه الحالة، فلا محل لتطبيق نظرية فعل الأمير»^(٢).

وإذا كان توقع الإجراء أو عدم توقعه قد يتحقق بالنسبة للإجراءات العامة، فإن الأمر يدق أحياناً بالنسبة للإجراءات الخاصة، حيث أنه من الأمور المستقرة فقهاً وقضاءً . كما سبق أن ذكرنا . أن الإدارة تملك حق تعديل شروط عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، دون التوقف علي رضا المتعاقد معها، ومن ثم يفترض علم المتعاقد مع الإدارة بهذا الحق، فلا يترتب علي استخدام الإدارة له توافر شرط عدم التوقع، و إنما يتوافر هذا الشرط بالنسبة لحدود التعديل ومداه ومدي تأثيره علي اقتصادات العقد باعتباره النطاق الذي ينصب عليه 2024/2025 2024/2025 محل عدم التوقع»^(٣).

ثالثاً: آثار تطبيق نظرية فعل الأمير:

يترتب علي تطبيق نظرية عمل الأمير نتيجة رئيسية تتمثل في تعويض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي لحقت به، إضافة إلى تلك النتيجة الرئيسية، فإنه يتولد عن تطبيقها أيضاً بعض النتائج الفرعية منها:

أ- تحلل المتعاقد من التزامه بتنفيذ العقد، إذا ترتب علي عمل الأمير استحالة التنفيذ، كأن يصدر قانون أو قرار يحرم استيراد سلعة لا يمكن الحصول عليها إلا من الخارج.

(١) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٩٨٣، لسنة ٧ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٤٧، لسنة ١١ق، الصادر بتاريخ ١٩٦٩/١/١١.

(٣) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٧٢. د: عبد

العظيم عبد السلام، أثر فعل الأمير علي تنفيذ العقد الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٦٢.

- ب- حق المتعاقد في المطالبة بعدم توقيع الغرامات المالية عن تأخيرها في التنفيذ، إذا أثبت المتعاقد أن عمل الأمير قد جعل تنفيذه للالتزام عسيراً
- ج- حق المتعاقد في فسخ العقد، وذلك إذا ما ترتب على عمل الأمير أن زادت أعباؤه بدرجة كبيرة لا تحتلها إمكانياته المالية أو الفنية.
- وفيما يلي ندرس بالتفصيل النتيجة الرئيسية المترتبة على عمل الأمير وهي التعويض الكامل، فننتاول أساس هذا التعويض، ثم نوضح كيفية تقديره ومداه:
١. أساس التعويض:

حرص الفقه الإداري في مصر و في فرنسا علي إيجاد أساس قانوني يبرر التعويض الذي يحصل عليه المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي تصيبه من جراء فعل الأمير. ويتردد الفقه في هذا الصدد بين أساسيين لتدبير التعويض الناتج عن تطبيق نظرية عمل الأمير، ففريق يسنده إلى فكره التوازن المالي للعقد، وفريق آخر يري إسناده إلى المسؤولية التعاقدية للإدارة.

ولكن الرأي الراجح يري أن مسؤولية الإدارة في تلك الحالة، هي مسؤولية تعاقدية ، أي ناتجة عن العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها، ولكنها مسؤولية تعاقدية بلا خطأ ، لأن تطبيق نظرية عمل الأمير . كما رأينا . تقضي أن الإدارة لم تخطئ حين تصرفت، وإلا قامت المسؤولية علي أساس هذا الخطأ. وهي تهدف إلى تحقيق التوازن المختل بين التزامات المتعاقد مع الإدارة و حقوقه حتى يستمر في تنفيذ التزاماته. وعلي ذلك تصبح مسؤولية الإدارة في تلك الحالة شبيهة بالمسؤولية علي أساس المخاطر: فأساس مسؤولية المخاطر مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة، وأساس المسؤولية عن عمل الأمير هو التوازن المالي للعقد^(١).

٢. كيفية تحديد التعويض و مداه:

في حالة توافر شروط تطبيق نظرية عمل الأمير، فإن المتعاقد مع الإدارة يستحق تعويضاً كاملاً. والتعويض الكامل يشمل ما لحق بالمتعاقد من خسارة بسبب هذا الإجراء الصادر من الإدارة، كالنفقات الإضافية نتيجة فرق السعر أو الرسوم الجديدة... الخ. كما يشمل ما فات المتعاقد من كسب كالأرباح التي كان من المتوقع أن يجنيها المتعاقد مع الإدارة لو لم يختل توازن العقد نتيجة إصدار الإدارة لهذا الإجراء. وفي هذا الصدد تقرر محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧ أن: «...»

(١) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٩٥ و ما بعدها.

والمحكمة إنما تقدر هذا التعويض طبقاً للقواعد المقررة في القانون الإداري في هذا الشأن، وهو يشمل عنصرين:

الأول: ما لحق المتعاقد من خسارة. ويضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي أنفقها المتعاقد. وهذه المصروفات تختلف باختلاف الأحوال وطبيعة الأعمال، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المتعاقد بدفع أثمان مرتفعة أو زيادة في أجور الأيدي العاملة. كما أنه من الجائز أن يترتب على تعديل العقد أثناء تنفيذه خسائر متنوعة، وفي هذه الحالة يجب تقدير هذه الخسارة ما دامت علاقة السببية قائمة بينها وبين الإجراء الذي طلبت جهة الإدارة من المتعاقد معها اتخاذه.

الثاني: ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب اعتباراً بأن من حقه أن يعرض عن ربحه الحلال عن عمله ورأس ماله «(١)».

ويثور تساؤل هام، هل من الممكن للإدارة أن تضمن عقودها الإدارية شرطاً يعفيها من المسؤولية قبل المتعاقد؟ وللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن نميز بين حالتين:

الحالة الأولى: شرط الإعفاء المطلق من المسؤولية: ويعد مثل هذا الشرط باطلاً

بإجماع الفقه والقضاء الإداري (٢). وهذا ما تقرره محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر 2024/2025

بتاريخ ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧. السابق الإشارة إليه. بقولها أنه: «من المقرر في العقود الإدارية أن جهة الإدارة لا تملك أن تضع فيها نصاً عاماً بعدم مسؤوليتها يعفيها من الالتزام بتعويض الضرر الحادث للمتعاقد معها، لأن ذلك يتعارض مع المبادئ المقررة في القانون الإداري من ثبوت حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض طبقاً للنظريات السائدة في نظام العقود الإدارية ومنها حقه في التوازن المالي للعقد».

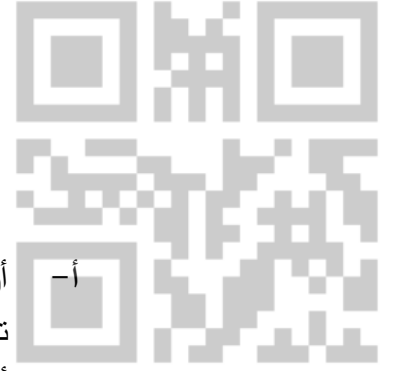
الحالة الثانية: شرط الإعفاء الذي ينصب على إجراء معين: وهذا الشرط

مشروع، فإذا توقع المتعاقدان إجراء معين من الإجراءات السابقة، كخفض العملة المحلية، أو فرض تأمينات اجتماعية جديدة... الخ. ففي تلك الحالة يبرم المتعاقد مع الإدارة العقد وهو مقدر لهذه الظروف، ومن ثم يتحمل ما يترتب عليها من آثار.

ويتم تحدي قيمة التعويض الذي يحصل المتعاقد مع الإدارة، بإحدى الطرق التالية:

(١) محكمة القضاء الإداري، قضية رقم ٩٨٣، لسنة ١١ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

(٢) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٩٩.



- أ- أن يتم الاتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها . حال إبرام العقد . علي مبلغ معين تدفعه الإدارة عن الأضرار التي قد تلحقه من تصرفاتها.
- ب- أن يتم تحديد قيمة التعويض بمقتضى نص تشريعي، وذلك عندما يكون الإجراء المكون لعمل الأمير، إجراء عاماً.
- ج- أن يلجأ المتعاقد إلى القضاء، وفي تلك الحالة، بعد أن يتيقن القاضي من توافر شروط النظرية، يحدد قيمة التعويض. وهو تعويض شامل يتضمن جميع ما لحق بالمتعاقد من خسارة وما فاتته من كسب.

المطلب الثاني

نظرية الظروف الطارئة

أولاً: مفهوم نظرية الظروف الطارئة:

قد تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف استثنائية خارجية عامة لم يكن في وسع المتعاقد توقعها وقت إبرام العقد، وترتب علي حدوثها أن اختل التوازن المالي للعقد اختلالاً خطيراً، بحيث أصبح تنفيذ الالتزام أشد إرهاقاً وأكثر تكاليفاً للمتعاقد. في تلك الأحوال يحق للمتعاقد مع الإدارة مطالبتها بالمساهمة معه في تحمل النتائج المترتبة علي ازدياد الأعباء الناشئة عن تلك الظروف الطارئة، وذلك بتعويضه جزئياً ولمدة مؤقتة عن الخسائر التي لحقت به.

وتعد نظرية الظروف الطارئة في القانون الإداري من صنع مجلس الدولة الفرنسي، فقد أخذ بها لأول مرة في حكمه الصادر بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩١٦ في قضية « Gaz de Bordeaux »^(١) وتتلخص وقائع هذه القضية في أن إحدى الشركات كانت ملتزمة بتوريد الغاز لمدينة بوردو، وترتب علي نشوء الحرب العالمية الأولى ارتفاع أسعار الفحم . وهو المادة الرئيسية لاستخراج الغاز . لأكثر من ثلاثة أمثالها، حيث كان سعر طن الفحم في سنة ١٩٠٤ تاريخ إبرام العقد ٢٣ فرنك، وفي سنة ١٩١٦ ارتفع لأكثر من ٧٣ فرنك، وبالتالي أصبح تنفيذ الشركة لالتزامها مرهقاً لدرجة لم يكن في الوسع توقعها. ولهذا تقدمت الشركة للسلطة مانحة الالتزام طالبة رفع تلك الأسعار، ولكن تلك السلطة رفضت وتمسكت بتنفيذ الالتزام بناء علي أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن تنفيذه لم يصبح مستحيلاً، حيث أن

(١) نظر:

• C.E. 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, Rec., p. 125, concl. Chardent.
D.1916,3. 25. S. 1916. 3. 17. note Hauriou.





الفحم ولو أن أسعاره قد ارتفعت، إلا أنه موجود. لذلك لجأت الشركة إلى مجلس الدولة، والذي قرر مبدأً جديداً مستمداً من قاعدة دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد: مقتضاه، أنه إذا جدت ظروف لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، وكان من شأنها أن تزيد الأعباء الملقاة علي عاتق الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالاً جسيماً، فللملتزم الحق في أن يطلب من الإدارة . ولو مؤقتاً . المساهمة بقدر ما في الخسائر التي تلحق به.

أما في مصر فنجد لهذه النظرية أساس تشريعي، فتنص المادة السادسة من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ علي أنه: « إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد لمانح الالتزام أو الملتزم فيها، وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للالتزام أو إلى تعديل كيانه الاقتصادي كما كان مقدراً وقت منح الالتزام، جاز لمانح الالتزام أن يعدل قوائم الأسعار وإذا اقتضى الحال، أن يعدل أركان تنظيم المرفق العام و قواعد استغلاله، وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر في استغلاله أو لخفض الأرباح الباهظة إلى القدر المعقول ». وعلي ذلك وفقاً لهذا النص يسلم المشرع المصري بتطبيق نظرية الظروف الطارئة بالنسبة إلى عقد الالتزام. وإذا كانت تلك النظرية قد وضعت أصلاً لتمكين الملتزم من مطالبة الإدارة بمساعدته في حالة وقوع الظرف الطارئ، فإنه وفقاً للنص السابق، يجوز للإدارة أن تطالب بتطبيق أحكام تلك النظرية لصالحها، وذلك في الحالة العكسية، أي في حالة ما إذا كانت أرباح المتعاقد معها قد تجاوزت الحد المعقول. فلها أن تطلب خفض تلك الأرباح الباهظة إلى القدر المعقول.

هذا وقد انتقل تطبيق نظرية الظروف الطارئة من مجال القانون العام إلى مجال القانون الخاص، فقد نص القانون المدني الحالي عليها في مادته ١٤٧، والتي تقرر أن: « ١ . العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله، إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

٢ . و مع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها، وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، جاء مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسائر فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف، بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ».



ثانياً: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:

يشترط القضاء الإداري^(١) لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية لم تكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا وأن يكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما وأن تكون من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة. تلك هي الشروط التي تتطلبها القضاء لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وفيما يلي شرحها تفصيلاً:

١. حدوث ظرف أو حادث استثنائي:

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وقوع ظروف أو حوادث استثنائية تصيب المتعاقد مع الإدارة بأضرار جسيمة أثناء تنفيذه لالتزامه. هذا وقد ذهب الرأي التقليدي في الفقه إلى وجوب أن يكون هذا الظرف اقتصادياً، وذلك أن الهدف الأساسي لهذه النظرية هو حماية المتعاقد ضد المخاطر الاقتصادية وكذلك حتى يمكن التمييز بين هذه النظرية وبين نظرية عمل الأمير والتي تحمي المتعاقد في مواجهة المخاطر الإدارية، وبين نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة والتي يلجأ إليها المتعاقد لمواجهة المخاطر الطبيعية كما

2024/2025

2024/2025

سنري لا حقاً
2024/2025

علي أن الفقه الحديث لم يقصر نطاق الظرف الموجب لتطبيق هذه النظرية على الظرف أو الحادث الطارئ ذو الطبيعة الاقتصادية، بل وسع من نطاق هذا الظرف ليشمل كل الأسباب التي تؤدي إلى الخلل في العلاقة الاقتصادية في العقد ويؤدي إلى أن يصبح الإصرار على تنفيذ الالتزام مرهقاً للمتعاقد مع الإدارة. ولذلك يمكننا القول بأن كل حادث طارئ يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد واختلالها اختلالاً جسيماً يمكن أن يؤدي إلى تطبيق هذه النظرية.

وبناء على ذلك قد يكون هذا الظرف اقتصادياً، كارتفاع الأجور والأسعار، الهبوط الحاد في الإيرادات بسبب الكساد.... الخ، وقد يكون طبيعياً، كالفيضانات والزلازل والجفاف... الخ، وأخيراً قد يكون من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة. وهذا واضح في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٩٧، والتي تقرر فيه أن:

(١) انظر: المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٥٦٢، ١٠، ٦٧، لسنة ١١، الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٥/١١. وانظر أيضاً: حكمها في الطعن رقم ٨٧٧، لسنة ٢٧، الصادر بتاريخ ١٩٨٤/١/٢١. وكذلك حكمها في الطعن رقم ١٧٤٩، لسنة ٣٧، الصادر بتاريخ ١٩٩٧/١٢/١٦.

« نظرية الظروف الطارئة رهينة بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد »^(١).

هذا وقد توسع مجلس الدولة الفرنسي فاعتبر الإجراءات العامة التي تصدر من سلطات الدولة المختلفة كالتشريعات واللوائح التي تفرض ضرائب جديدة أو تزيد في الضرائب القائمة وتخفض سعر العملة أو تحظر التعامل بعملة معينة... الخ، من قبيل الظروف الطارئة^(٢). وفي هذا الصدد ذهب قسم الرأي بمجلس الدولة المصري في فتواه الصادرة بتاريخ ١٧ يوليو سنة ١٩٥٤ إلى أنه: « يعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر بتخفيض قيمة الجنيه المصري بالنسبة إلى الدولار حادثاً استثنائياً عاماً في حكم المادة ٢/١٤٧ من القانون المدني »^(٣).

٢. عدم توقع المتعاقد للظرف وعدم استطاعته دفعه:

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أن تكون هذه الظروف غير متوقعة للمتعاقدين وقت إبرام العقد، أي تكون مفاجئة لهم، أما إذا كانت هذه الظروف متوقعة وفقاً لمعيار الرجل المعتاد، فإن النظرية لا تطبق^(٤). وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٤ أبريل سنة ١٩٩٣ أنه: «... ولا تنطبق هذه النظرية »^(٥) 2024/2025 2024/2025 نظرية الظروف الطارئة " إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع في أمور متوقعة قبل التنفيذ وفقاً للسير الطبيعي للأمر وللنظام المعتاد للعمل في الإدارة العامة »^(٦).

وترجع العلة في استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة في حالة توقع المتعاقد لحدوث الظرف الطارئ، إلى أن المتعاقد قد وضع احتمال هذا الظرف المتوقع في اعتباره عند تحديده لأسعار التعاقد، الأمر الذي لا يولد له الحق في التعويض عند حدوث هذا الظرف، هذا من ناحية، وكما أن المتعاقد الذي لم يتوقع حدوث الظرف الطارئ في حين أنه

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١٧٤٩، لسنة ٣٧ق، الصادر بتاريخ ١٦/١٢/١٩٩٧.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٦٢١. وانظر أيضاً: د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٦٥.

(٣) فتوى قسم الرأي رقم ٣٦٠، الصادرة بتاريخ ١٧/٧/١٩٥٤.

(٤) انظر: د. انس جعفر، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة ٢٠٠٣، ص ١٨٨.

(٥) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٥٤٩، لسنة ٨٠١، لسنة ٣٥ق، الصادر بتاريخ ٤/٤/١٩٩٣.

كان في وسعه ذلك . وفقا لمعيار الرجل العادي . لا يكون هناك مجالا لتعويضه أيضا حتى لا يكافأ عن تقصيره وفساد تقديره للأمور من ناحية أخرى^(١).

وعلى الرغم من أن عدم توقع الظرف الطارئ هو الشرط الجوهرى لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، إلا أن تلك النظرية يمكن تطبيقها في حالة إذا ما توقع المتعاقد لحدوث الظرف الطارئ، ولكنه لم يستطيع أن يحدد بدقة كافية المدى الذي يمكن أن يصل إليه آثاره والتي أخلت بالتوازن المالي للعقد إخلالا جسيما. وفي هذا المعنى تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٩ يونيو سنة ١٩٦٢ أن: « .. الارتفاع الباهظ في أسعار الزئبق، إن صح أنه كان متوقعا بالنسبة إلى العقد الثاني، فإن مدي هذا الارتفاع لم كن متوقعا في الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة إلى العقد الأول جنيه و ٦٠٠ ملجم بالنسبة للكيلو، فأصبح وقت التعاقد بالنسبة إلى العقد الثاني ٢ جنيه و ٨٨٠ ملجما ثم اصبح وقت الشراء ٤ جنيه و ٥٠ ملجما، ومن ثم فإن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على هذه الحالة »^(٢).

ومن الجدير بالذكر انه لا يكفي عدم توقع المتعاقد لوقوع الظرف الطارئ لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، بل يشترط أيضا ألا يكون في استطاعة المتعاقد دفع هذا الظرف أو مواجهته بالطرق العادية المألوفة لوقف آثاره الضارة أو لمنع تفاقمها، فإذا كان في إمكانه^{2024/2025} المتعاقد القيام بذلك ولكنه تقاعس فلا يستحق تعويضا عما يخلفه الظرف الطارئ من أضرار. وعلة ذلك أن المتعاقد . في تلك الحالة . يكون قد أخل بالتزامه في تنفيذ العقد الإداري وفقا لما تفرضه عليه مقتضيات حسن النية والتي توجب عليه تنفيذ التزامه بما يجنب الإدارة التحمل بأعباء مالية إضافية في صورة تعويضات تؤدي إليه ما دام في إمكانه تجنب ذلك^(٣).

٣. ضرورة أن يكون الظرف الطارئ أجنبيا عن طرفي العقد:

من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة كون الظرف أو الحادث الطارئ أجنبيا عن طرفي العقد، فإذا كان اختلال التوازن المالي ناتجا عن عمل أو تقصير صادر من المتعاقد مع الإدارة، فإنه يتحمل وحده نتيجة عمله أو تقصيره. وإذا كان نتيجة لعمل الإدارة

(١) انظر: د: عبد العزيز خليفة ، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٤.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٣١٥٠، لسنة ٦٦ق، الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٦/٩.

(٣) انظر: د: عبد العزيز خليفة ، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٥.



المتعاقدة أو لتقصيرها فتطبق إما نظرية عمل الأمير أو نظرية المسؤولية التقصيرية علي حسب الأحوال.

٤. ضرورة وقوع الظرف الطارئ خلال تنفيذ العقد الإداري:

من المسلم به أن وقت وقوع الظرف الطارئ الموجب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ينحصر في الفترة ما بين إبرام العقد الإداري والتاريخ المحدد لإتمام تنفيذه. وتطبيق هذا الشرط لا خلاف عليه، وإن كان يقتضي بعض التحديد من النواحي التالية:

أ - الظروف التي تطرأ قبل إبرام العقد:

الظروف التي تحدث قبل إبرام العقد لا يمكن أن تؤدي إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وهذا أمر طبيعي، لأنه لو وقع الظرف الطارئ قبل إبرام العقد فإن الطرف الذي يريد التعاقد مع الإدارة يستطيع أن يتراجع عن ذلك. فإذا ما قبل التعاقد . في ظل وجود هذا الظرف . فلا يكون طارئاً ومن ثم لا تطبق نظرية الظروف الطارئة.

ب - الظروف التي تطرأ عقب المدة المحددة للتنفيذ:

يثور التساؤل عن مدى تأثير الظروف التي تقع في خلال تنفيذ العقد، ولكن بعد فوات المواعيد المحددة في العقد لتمام هذا التنفيذ، أو بمعنى آخر أوضح ما مدي انطباق نظرية الظروف الطارئة إذا ما حدث الظرف الطارئ بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري:

للإجابة عن هذا التساؤل يجب التفرقة في هذا الصدد بين فرضين:

الفرض الأول: أن يكون التأخير راجعاً للمتعاقد مع الإدارة:

إذا امتد تنفيذ العقد لمدة تزيد عن الأجل المنصوص عليه في العقد للتنفيذ، وكان المتسبب في هذا الامتداد هو المتعاقد نفسه لتأخره في التنفيذ، فإذا وقع الظرف الطارئ في تلك المدة، فلا تطبق حينئذ نظرية الظروف الطارئة، ويتحمل المتعاقد كافة النتائج الضارة المترتبة علي وقوعه. إضافة الي تحمله للمسؤولية العقدية عن تاخره في التنفيذ.

وفي هذا الصدد قررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٨٢، أن: « المدعي عليه أخذ في تنفيذ العملية المقرر لها ثلاثة اشهر ونصف شهر حوالي سنة و تسعة اشهر ولم يكن قد أنجز من العملية حتى يوم سحب الأعمال منه في ١٩٧٥/٩/٢٢ إلا حوالي ٩٠% من الأعمال التي تتألف منها المقولة و لأن كان تنفيذ الأعمال المتبقية علي حسابه قد أسفر عن زيادة في الأسعار بلغت ١٩٥% للأعمال العادية، ٢٦٠% للأعمال الصحية، ٢٨% الأعمال الكهربائية . إلا أن هذه

الزيادات لا تنسب إلى ظروف حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ إذ يتعين في المقام الأول أن تطرأ الحوادث الاستثنائية العامة خلال مدة تنفيذ العقد الإداري وأن تكون خلال تلك المدة وليس بعدها . مؤثرة في التزامات المتعاقد مع الإدارة ولم يثبت من الأوراق أن الأسعار ارتفعت فيما بين إبرام العقد مع المدعي عليه ونهاية مدة التنفيذ المتفق فيه في يوم ١٩٧٣/١٢/٣٠ وكان من المعروف للكافة أن الأسعار لم ترتفع من جراء حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ إلا بعد مضي أكثر من سنة كاملة علي انتهائها....لذلك يتعين الحكم بأن ظروف حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ لا تشكل بالنسبة للعقد محل المنازعة حوادث استثنائية «(١)».

الفرض الثاني: إذا كان سبب التأخير في التنفيذ راجعاً إلى جهة الإدارة:

إذا كان التأخير في التنفيذ راجعاً إلى الإدارة ذاتها أو بسببها، فإنها تتحمل نتيجة ذلك، فهو خطئها. وفي تلك الحالة لا تطبق نظرية الظروف الطارئة، بل تطبق نظرية عمل الأمير، فهي تضمن للمتعاقد الحصول علي التعويض الكامل كما أوضحنا سابقاً.

٥. أن يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد:

يشترط لتعويض المتعاقد مع الإدارة عن الظرف الطارئ، أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأساً علي عقب. فلا يكفي أن يترتب علي الظرف الطارئ أن يفقد أرباحه كلها أو بعضها، ولكن ينبغي أن تلحق به خسارة. علي أن الخسارة البسيطة 2024/2025 2024/2025 تعد غير كافية لتطبيق تلك النظرية، وإنما يجب أن تكون من الجسامة والاستمرار بحيث يخشى ألا يتمكن المتعاقد من القيام بتنفيذ التزاماته بشأن المرفق العام(٢). وقد أفصحت المحكمة الإدارية العليا عن هذا الشرط في أحكام عديدة، فعلي سبيل المثال، في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٥ تقول أنه: «.... يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط..... وأن يكون من شأن هذه الظروف إصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التي يمكن احتمالها علي نحو تختل معه اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً...»(٣).

ومن الجدير بالذكر أن قلب اقتصاديات العقد تعد مسألة نسبية، تختلف من متعاقد لآخر حسب قدرات كل متعاقد علي مواجهة الظرف الطارئ، فقد ينتج عن هذا الظرف

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٨٤٣، ٩٢٢، لسنة ٢٦ق، الصادر بتاريخ ١٩٨٢/١١/٢٠.

(٢) انظر: د: توفيق شحاته: مرجع سبق ذكره، ص ٨٣٤.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢٥٤١، لسنة ٢٩ق، الصادر بتاريخ ١٩٨٥/١١/٣٠. وانظر كذلك حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٧٤، لسنة ١٢ق، الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٧/١٤.

إرهاق مالي شديد لمتعاقد ما، ومن ثم تطبق عليه نظرية الظروف الطارئة، في حين أن نفس الظرف الطارئ قد لا يؤثر علي متعاقد آخر أو يكون تأثيره عليه خفيفا، ومن ثم لا تطبق عليه نظرية الظروف الطارئة، فالمعيار هنا شخصي يتصل بالمتعاقد و مدي تأثير الظرف الطارئ علي تنفيذه لالتزامه التعاقدية^(١). وعلي ذلك يتم تقدير مدي الاختلال المالي الناتج عن الظرف الطارئ وفقا لظروف كل عقد علي حدة. ويخضع هذا التقدير وفقا لاعتبارات متعددة، أقرها القضاء الإداري الفرنسي والمصري، مثل حجم اقتصاديات المتعاقد، وحجم احتياطي الشركة المتعاقدة والسيولة المتوفرة لديها، والمقارنة بين النفقات التي يدعيها المتعاقد مع الإدارة وعناصر العقد في مجموعة...الخ^(٢). كما يدخل في التقدير أيضاً جميع العناصر المؤثرة في اقتصاديات العقد، ومنها كامل قيمته ومدته فيفحص في مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف علي أحد عناصره، فقد يكون في العناصر الأخرى ما يجزي ويعوض المتعاقد عن العنصر الخاسر^(٣).

ثالثا: آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة:

يترتب علي تطبيق نظرية الظروف الطارئة الأثرين التاليين:

١. استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد.

٢. حق المتعاقد في الحصول علي تعويض.

2024/2025

2024/2025

الأثر الأول: استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته:

ذكرنا سابقا أن الظروف الطارئة من شأنها أن تجعل تنفيذ المتعاقد لالتزامه التعاقدية مرهقا بحيث يهدده بخسارة تعرض المرفق العام للتوقف، وهو ما يميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية القوة القاهرة التزام التعاقدية مستحيلا. استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد يعد من أهم الاعتبارات التي تتأسس عليها نظرية الظروف الطارئة، فالهدف الرئيسي لهذه النظرية هو مساعدة المتعاقد مع الإدارة علي مواصلة تنفيذ التزامه التعاقدية حتى لا يتعطل سير المرفق العام، ويتضح ذلك من حكم المحكمة الإدارية، الصادر بتاريخ ٤ أبريل سنة ١٩٩٣، وفيه تقول أن: «... فنظرية الظروف الطارئة تقوم علي فكرة العدالة المجردة التي هي من قوام القانون الإداري، كما أن هدفها تحقيق المصلحة

(١) انظر: د: عبد العزيز خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٢.

(٢) انظر: د: سعاد الشرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص ٥٢٤. د: عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، أثر

الظروف الطارئة والصعوبات المادية على تنفيذ العقد الإداري، الولاء للطبع والتوزيع، ١٩٩٠، ص ٦٨.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣٥٦٢، لسنة ٢٩ق، الصادر بتاريخ ١٦/٥/١٩٨٧.

العامة، فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها....»^(١).

ولذلك يترتب علي توقف المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ التزامه . بالرغم من توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة . تعرضه للجزاءات الإدارية بأنواعها المختلفة: المالية، والضاغطة، والجنائية إن وجدت، ولا يجديهِ نفعاً الاحتجاج بتوافر الظروف الطارئة^(٢). إضافةً إلى أن هذا التوقف يحرمه من حق المطالبة بالتعويض أو المعاونة التي تقرها نظرية الظروف الطارئة^(٣).

وفي هذا الصدد تقرر فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الصادرة بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩٨٠: «... إن تطبيق الظروف الطارئة رهينة بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف لم تكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دعواً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، ومؤدى تطبيق هذه النظرية . إن توافرت شروطها . إلزام الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة بحيث ترد إلى الحد المعقول وذلك ضماناً لتنفيذ العقد.

ولما كانت الهيئة العامة للإنتاج الزراعي قد توقفت عن تنفيذ العقد المبرم بينها وبين وزارة الدفاع بعد أن نفذت الجانب الأكبر منه، فإن دواعي تطبيق نظرية الظروف الطارئة 2024/2025 تتخلف بالنسبة لها، إذ كان يتعين عليها أن تستمر في التنفيذ حتى تحتفظ بحقها في المطالبة بتطبيق تلك النظرية إن توافرت شروط إعمالها،»^(٤).

ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٥ وفيه تقول أنه: «... ليس مؤدي تطبيق نظرية الظروف الطارئة . بعد توافر شروطها، أن يتمتع المتعاقد فوراً عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد وللمتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به نتيجة تنفيذ العقد في ظل الظروف الطارئة، فإذا رفضت جهة الإدارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء.... ومن حيث أن الثابت من سياق الوقائع أن الطاعن قد أخل بالتزامه التعاقدى مع الهيئة

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٥٤٩-٨٠١، لسنة ٣٥ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٣/٤/٤.
(٢) انظر:

• C.E. 10 avril 1923, Sté. d'éclairage d'Oloron, Rec., p. 682.

(٣) انظر:

• C.E. 27 juillet 1951, Commune de Montagnac, Rec., p. 439.

(٤) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رقم ٢١١، الصادرة بتاريخ ١٩٨٠/٢/٦.

المطعون ضدها بامتناعه عن تنفيذ العقد خلال المدة المحددة به بغير سند يبرر امتناعه عن التنفيذ....»^(١).

ومن الجدير بالذكر، انه يحدث عملياً أن تتحول الظروف الطارئة إلى قوة قاهرة في خلال فترة قصير من الزمن^(٢). ففي مرحلة أولى تؤدي الظروف الطارئة إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد دون أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وفي مرحلة ثانية تتحول الظروف الطارئة إلى قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد. فإذا استمر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد خلال المرحلة الأولى، ثم توقف عن التنفيذ في خلال المرحلة الثانية، فإن حقه في المطالبة بالتعويض عن المرحلة الأولى يظل محفوظاً^(٣).

الأثر الثاني: حق المتعاقد في الحصول علي تعويض:

إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، واستمر المتعاقد مع الإدارة في أداء التزامه، فإنه يحق له أن يطالب جهة الإدارة بمشاركته في تحمل جزء من الخسارة التي لحقت به من جراء الحادث الطارئ. وفي هذه الحالة يتعين علي جهة الإدارة والمتعاقد معها إعادة النظر في نصوص العقد ومن ثم تعديلها في ضوء الظروف الجديدة.

ولكن قد ترفض جهة الإدارة التعاون مع المتعاقد معها في مشاركته في تحمل جزء من الخسارة^{2024/2025}، في هذه الحالة يجب علي المتعاقد اللجوء إلى القضاء، ولكن نظراً لأن^{2024/2025} القاضي الإداري لا يستطيع تعديل نصوص العقود الإدارية ورد الالتزام المهرق إلى الحد المعقول - علي عكس حكم القانون المدني، حيث أن للقاضي الحق في رد الالتزام المهرق في العقود الخاصة إلى الحد المعقول^(٤) - فإنه يدعو الطرفين مرة أخرى إلى أن يتوليا ذلك بنفسهما.

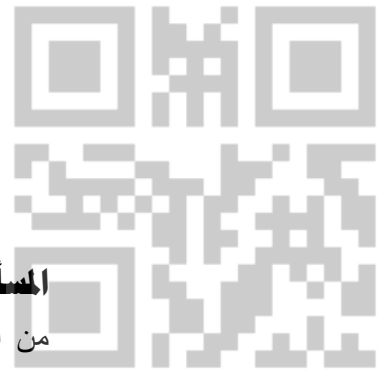
وأخيراً في حالة فشل الطرفين في الاتفاق، يتدخل القاضي الإداري حينئذٍ للحكم بالتعويض المالي الذي ترتبه نظرية الظروف الطارئة. وحق المتعاقد مع الإدارة في التعويض يثير مسألتين هامتين: الأولى تناقش بيان الأساس القانوني الذي يبني عليه التعويض. والثانية تتعلق بحدود هذا التعويض.

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٢٥٤١، لسنة ٢٩ ق، الصادر بتاريخ ١١/٣/١٩٨٥.

(٢) انظر: د: سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٦٢٩.

(٣) انظر: د: سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٥٢٦.

(٤) تنص الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من القانون المدني المصري علي انه: «...جاز للقاضي، تبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المهرق إلى الحد المعقول....».



المسألة الأولى: أساس التعويض في ظل نظرية الظروف الطارئة:

من الممكن إرجاع أساس التعويض في حالة الظروف الطارئة إلى مجموعة من الأفكار والآراء^(١):

١. مبدأ حسن النية: فمن المسلم به أن أطراف العقد الإداري، أي جهة الإدارة والمتعاقد معها، يجب أن يلتزموا بالتعاون الصادق لتنفيذ هذا العقد، وذلك علي أساس مبدأ حسن النية.

٢. التوازن المالي للعقد: ولا يقصد هنا بالتوازن الحسابي، لان المتعاقد في حالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة . كما سنري لاحقاً . يعوض تعويضاً جزئياً، يهدف إلى رد الانقلاب في اقتصاديات العقد إلى الحدود المعقولة، مما يؤدي إلى تمكن المتعاقد من الاستمرار في التنفيذ.

٣. استمرار سير المرفق العام: فالأصل ان المرافق العامة يجب أن تؤدي خدماتها بانتظام واستمرار، وعلي الإدارة ان تعمل علي تحقيق هذه القاعدة. فإذا طرأت ظروف طارئة وترتب عليها إرهاق المتعاقد، فإن علي الإدارة أن تسرع إلى مساعدته للتغلب علي تلك الظروف، حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته، وبالتالي

2024/2025

يستطيع المرفق أن يؤدي خدماته المعتادة دون توقف. 2024/2025

المسألة الثانية: حدود التعويض:

تقوم نظرية الظروف الطارئة علي مبدأ معاونة المتعاقد مع الإدارة للخروج من أزمته وتخفيف خسارته، لكي يستطيع الاستمرار في تنفيذ التزاماته، ومن ثم يتعين توزيع الخسارة الكبيرة المترتبة علي الطرف الطارئ بين جهة الإدارة والمتعاقد معها. علي أن هذا التوزيع لا تحكمه قاعدة ثابتة، وإنما يراعي فيها القاضي مقتضى الحال وظروف العقد وسلوك المتعاقد، والقدر اللازم من التعويض حتى لا يتوقف تنفيذ العقد^(٢).

ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد، حكمها الصادر بتاريخ ١٧ يونيو سنة ١٩٧٢، وفيه تقرر أنه: «...إذا طرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته، وإذا كان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، بل أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان

(١) انظر: د: سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٥٢٩.

(٢) انظر: د: جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الادارية، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٧٨.



التقدير المعقول وقت التعاقد وكانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية، فإن من حق المتعاقد المضار ان يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها فيعوضه عنها جزئياً.....ولما كان التعويض الذي يدفع طبقاً لهذه النظرية لا يشمل الخسارة كلها، ولا يغطي سوى جزء من الأضرار التي تصيب المتعاقد، فإن المدين ليس له أن يطالب بتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع عليه، كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة «(١)».

ومن هذا الحكم يتضح انه لا يجوز أن يكون من شأن التعويض تحقيق ربح للمتعاقد مع الإدارة، فلا يحق له أن يطالب بتعويض ما فاته من كسب، بل يقتصر التعويض على الخسارة التي لحقته، كما لا يشمل الخسارة كلها، فإن جزءاً منها يقع على عاتق المتعاقد نفسه وتتحمل الإدارة الجزء الآخر. وهذا بالطبع ما يميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية عمل الأمير، حيث يعوض المتعاقد مع الإدارة تعويض كامل يشمل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.

المطلب الثالث

نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أولاً: مفهوم النظرية:

إذا صادف المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفيذه لالتزاماته صعوبات مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة ولا يمكن توقعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد، وتؤدي إلى جعل تنفيذ العقد أكثر تكلفه، فإن هذه الصعوبات تعطي الحق للمتعاقد في المطالبة بالتعويض عما تسببه هذه الصعوبات من أضرار.

وتعد عقود الأشغال العامة هي المجال الخصب لتطبيق هذه النظرية، نظراً لما يكتنف تنفيذ تلك العقود من صعوبات مادية.

وقد أجملت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠ يناير سنة ١٩٥٧ أحكام وضوابط هذه النظرية، كما يلي: « الصعوبات غير المتوقعة من النظريات التي ابتكرها الفقه والقضاء الإداري ومقتضاها انه عند تنفيذ العقود الإدارية، وبخاصة عقود الأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات عند التعاقد وتجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة، فيجب . من باب العدالة . تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها

(١) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ٤٦ لسنة ١٤، الصادر بتاريخ ١٧/٦/١٩٧٢.

في العقد زيادة تغطي جميع الأعباء والتكاليف التي تحملها اعتباراً بأن الأسعار المتفق عليها لا تسرى إلا على الأعمال العادية المتوقعة فقط، وأن هذه نية الطرفين المشتركة. والتعويض هنا لا يتمثل في معونة مالية جزئية تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد معها بل يكون تعويضاً كاملاً عن جميع الأضرار التي يتحملها المقاول بدفع مبلغ إضافي له على الأسعار المتفق عليها. وبذلك تختلف هذه النظرية من حيث سببها والنتائج المترتبة عليها عن نظرية الظروف الطارئة التي تطبق بسبب ظروف سياسية أو اجتماعية ينشأ عنها قلب اقتصاديات العقد أو اختلال توازنه المالي ويقتصر التعويض فيها على قدر محدود تساهم فيه جهة الإدارة. كما تختلف أيضاً عن القوة القاهرة في أنه يكفي في حالة الصعوبات غير المتوقعة أن يصبح التنفيذ أشد عسراً وأكثر تكلفة في حين أنه في حالة القوة القاهرة يجب أن يصبح التنفيذ مستحيلاً. كما أنه يترتب على القوة القاهرة أما وقف التنفيذ أو فسخ العقد. أما في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة فإنه يفترض على العكس الاستمرار في التنفيذ بسبب هذا الوضع الخاص للنظرية ويشترط لاستحقاق التعويض المترتب عليها توافر شروط خاصة يمكن أياها بصفة عامة فيما يلي:

أولاً: أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية أو استثنائية.

ثانياً: أن تكون الصعوبات طارئة أي غير متوقعة أو يمكن توقعه أو لم يكن في 2024/2025 2024/2025
الوسع توقعها عند التعاقد.

ثالثاً: أن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد وتزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة.

وفي هذه الحدود والضوابط يكون من حق المتعاقد مع الإدارة الرجوع عليها بالتعويض. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن النظرية لا تطبق، ولا يستحق المتعاقد مع الإدارة أي تعويض «^(١)».

ثانياً: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:

لكي يتم تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، يجب أن يتوافر في الصعوبات التي يصادفها المتعاقد أثناء التنفيذ شروطاً معينة، أشار إليها القضاء الإداري كثيراً في أحكامه، فعلى سبيل المثال تقرر المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٩٧ أن: «... يلتزم للقضاء بأحقية المقاول للتعويض طبقاً لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة توافر الشروط الآتية:

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٧٨٩٢، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/١/٢٠.



أولاً: أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية أو استثنائية.
ثانياً: أن تكون الصعوبات طارئة غير متوقعة أو بما لا يمكن توقعه أو لم يكن في
الوسع توقعها عند التعاقد.

ثالثاً: أن يترتب علي التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد وتزيد في
أعباء المتعاقد مع الإدارة»^(١).

١. أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية وغير عادية أو استثنائية:

إن الصعوبات المادية ترجع في أغلب الأحيان إلى الظواهر الطبيعية وبالتالي فإن
أكثر التطبيقات تتعلق بصعوبات مادية مرجعها إلى طبيعة الأراضي التي تنفذ فيها الأشغال
العامة، كأن يفاجأ الماول أثناء الحفر أن طبيعة الأرض صخرية بينما كان التنفيذ الطبيعي
للعقد يفترض أن تكون الأرض سهلة، ومن ثم يؤدي ذلك بالضرورة استخدام الماول لأجهزة
حديثه في الحفر قد لا تكون في متناوله، أو بوجود طبقات غزيرة من المياه الجوفية والتي
تحتاج لنفقات غير عادية لسحبها وتجفيفها، أو انهيارات في التربة بكميات ضخمة تستلزم
نفقات وجهود ضخمة لرفعها... الخ.

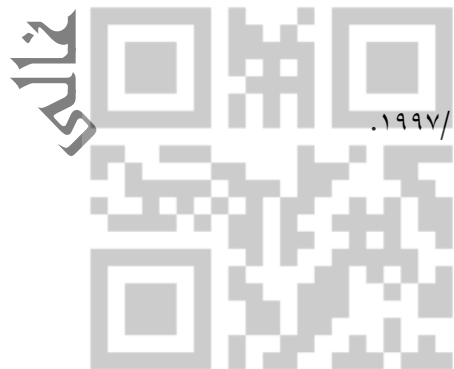
وقد ترجع تلك الصعوبات إلى فعل الغير، مثل وجود قناة مائية بجوار موقع العمل،
أو وجود قواعد وأساسات خرسانية تحت الأرض، ولم تكن في الحسبان وقت إبرام العقد،
ومن ثم تحتاج إلى نفقات و جهود إضافية للتخلص منها.

ولكي يستحق المتعاقد مع الإدارة التعويض وفقاً لتلك النظرية ينبغي أن تكون
الصعوبات من غير أحد الطرفين المتعاقدين، فضلاً عن ضرورة أن تكون ذات طبيعة غير
عادية أو استثنائية :

فمن ناحية أولى: يجب ان تكون الصعوبات خارجة عن إرادة طرفي العقد:

* فالصعوبات المادية يفترض فيها ألا تكون من عمل الإدارة. فإذا كان
مرجع تلك الصعوبات عمل الإدارة، فإن ذلك لا يعني استبعاد حق المتعاقد في
التعويض، ولكنه في تلك الحالة لا يعوض علي أساس نظرية الصعوبات المادية غير
المتوقعة، وإنما علي أساس نظرية عمل الأمير، والتي سبق شرحها.

(١) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٥٦٧، لسنة ٢٩ق، الصادر بتاريخ ١٢/٣٠/١٩٩٧.



* ويشترط أيضا أن تكون الصعوبات المادية خارجة عن إرادة المتعاقد. فإذا كانت راجعة إلى فعله أو ترتب علي فعله زيادتها، فإنه وحدة يتحمل مسئوليتها ولا يكون ثمة ضرورة لتطبيق هذه النظرية أو غيرها.

ومن ناحية ثانية: يجب أن تكون الصعوبات المادية غير عادية أي ذات طابع استثنائي: فالصعوبات العادية التي تواجه المتعاقد مع الإدارة لا تستدعي أن يعوض عنها، حيث أن كل علاقة تعاقدية يمكن أن تواجه بمثل هذه الصعوبات المادية البسيطة أو العادية. وعلي ذلك يشترط أن تكون تلك الصعوبات ذات طبيعة غير عادية أو استثنائية تجاوز كل ما كان متوقعا من المتعاقد وقت إبرام العقد. وتأكيداً لذلك تقرر محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠ يناير سنة ١٩٥٧ أن: « شرط الصعوبة المادية الاستثنائية لا يتوافر لمجرد أن الطبقة التي صادفها المدعي وهو يتولى تطهير ترعة كانت ذات صلابة غير عادية، بل يجب أن تكون لهذه الطبقة امتداد غير عادي أيضا بأن تكون لمساحات واسعة، أو بنسبة كبيرة من مجموع المنطقة محل العقد، وبهذا وحدة يتحقق المراد من اعتبار الصعوبة غير عادية أو استثنائية »^(١).

٢. أن تكون هذه الصعوبات غير متوقعة لحظة إبرام العقد:

يتعين لتطبيق هذه النظرية، ومن ثم تعويض المتعاقد مع الإدارة عن الصعوبات التي تصادفه أثناء تنفيذ التزامه، أن تكون تلك الصعوبات غير متوقعة للمتعاقدين لحظة إبرام العقد. ولذلك يجب علي المتعاقد مع الإدارة أن يبذل جهدا معقولاً للإحاطة بكل ظروف التنفيذ وما قد يحيطه من صعوبات مادية، وأن تكون الصعوبات قد فاقت كل توقعاته بعد بذل هذا الجهد^(٢). ولقد أشارت إلى هذا الالتزام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ في المادة ٨٠ منها، والتي تنص علي أن: « يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات و التصميمات المعتمدة وعليه إخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظته عليها و يكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه ».

ووفقاً للمادة السابقة إخطار المتعاقد لجهة الإدارة بمعانيته للأرض محل العقد . مع عدم إبداءه لأية ملاحظات بوجود صعوبات مادية . هو بمثابة الإقرار الصادر منه بعدم

(١) حكم محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم ٧٨٩٢، لسنة ٨ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/١/٢٠.

(٢) انظر: د: سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٥٤٨.

وجود أية صعوبات مادية، ومن ثم يعد ذلك حائلا بينه وبين المطالبة بتعويضه عن تلك الصعوبات المادية الموجودة فعلا.

أما إذا كانت الصعوبات المادية من النوع الذي لا يمكن توقعه عند التعاقد . وفقا للظروف التي ابرم فيها العقد . فحينئذ يمكن للمتعاقد أن يطلب التعويض عنها . ولقاضي العقد سلطة تقدير ما إذا كانت الصعوبة التي واجهت تنفيذ العقد غير متوقعة أو كان من الممكن توقعها ليطبق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة من عدمه، وذلك وفقا لمعيار موضوعي ينظر فيه إلى الرجل المعتاد الذي يوجد في نفس ظروف المتعاقد وقت إبرام العقد^(١).

وفي هذا الصدد تؤكد المحكمة الإدارية العليا، في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٩٧ أنه: «.....وكانت الإدارة حسبما سلف لم تتف وجود اختلاف في طبيعة الأرض والتربة بالنسبة للأعمال الإضافية عن طبيعة الأرض والتربة بالنسبة للأعمال الأصلية والتي كانت محلا للعقد الأصلي، كما أن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة القضاء الإداري أن الأتربة المتولدة عن الحفر بالنسبة للأعمال الإضافية تختلف اختلافا جوهريا عن الأعمال الأصلية . وأن حجم الأتربة التي قام المطعون ضده بنقلها بمناسبة تنفيذ الأعمال الإضافية يجاوز نسبة ٢٥% من قيمة الأعمال الأصلية.....ومن ثم 2024/2025 فإنه لذلك ونظراً لأن الإدارة لم تقدم ما يفيد أن المطعون ضده قام بمعاينة الأرض محل الأعمال الإضافية أو أن الإدارة بنفسها كانت تعلم باختلاف طبيعة الأرض بالنسبة للأعمال الإضافية عن الأعمال الأصلية. كما وأنه حسبما سلف لا يمكن القول بامتداد الإقرار الصادر من المطعون ضده بمعاينة الأرض والتربة بالنسبة للأعمال الأصلية إلى الأعمال الإضافية . وبالتالي يكون الثابت من الأوراق أن هناك صعوبات مادية لم تكن متوقعة لدي طرفي العقد»^(٢).

٣. أن يترتب علي تلك الصعوبات ضرراً بالمتعاقد:

إضافة إلى الشرطين السابقين يشترط القضاء لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، شرطا ثالثا يتمثل في وجوب أن يترتب علي الصعوبات المادية التي يواجهها المتعاقد مع الإدارة خلال تنفيذه لالتزامه ضررا. ومثل هذا الضرر هو الذي يبرر التزام الإدارة بدفع التعويض للمتعاقد معها. حيث أن تطبيق هذه النظرية يدور وجودا وعدما مع

(١) انظر: د: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٥.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٥٦٧، لسنة ٢٩ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٣٠.

هذا الضرر، فتطبق إذا وجد الضرر، ولا مجال لتطبيقها إذا تخلف. فلو فرضنا أن المفاوض عندما شرع في تنفيذ العقد وحفر الأرض فوجئ بوجود طبقة صخرية، إلا أن هذا المفاوض يملك معدات متطورة تستطيع حفر المناطق الصخرية، في تلك الحالة لا يوجد ضرر للمفاوض، ومن ثم لا تطبق هذه النظرية.

والضرر المتصور وجوده في إطار تواجد الصعوبات المادية غير المتوقعة يتمثل في زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة، مما يجعل تنفيذ العقد مرهقا ماليا له.

وينبغي الإشارة إلى أنه في ظل نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يستوي أن يكون الضرر الذي أصاب المتعاقد يسيرا أو جسيما، حيث لا يشترط لتطبيق هذه النظرية حدوث ضرر جسيم للمتعاقد مع الإدارة أي أن تؤدي الصعوبات المادية التي يواجهها المتعاقد إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا علي عقب كما هو مقرر لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وذلك باستثناء العقود الجزافية التي تتضمن تحديد الثمن الإجمالي الذي تدفعه الإدارة للمتعاقد معها مقابل كمية الأعمال التي يلتزم بها، حيث يشترط الفقه والقضاء في فرنسا ومصر بصدها أن تؤدي الصعوبات التي تصادف المتعاقد إلى قلب اقتصاديات العقد حتى يستطيع الاستفادة من تطبيق نظرية الصعوبات المادية^(١). وفي ذلك ذهبت الجمعية

العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى الصادرة بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٦٤ أنه: 2024/2025 2024/2025

« ومما يجب التنبيه إليه بالنسبة إلى العقود الجزافية وهي التي تتضمن تحديد اجر لكمية الأعمال المطلوبة وتحديد إجماليا لما تلتزم الجهة الإدارية بدفعه من ثمن يقابلها فإن هذا الطابع الجزافي في تحديد الثمن لا يحول دون تطبيق نظرية الصعوبات غير المتوقعة علي انه يجب عندئذ أن يكون من شأنه الصعوبات المادية . في هذه الأحوال . أن تخل باقتصاديات العقد تبعا لانهايار الأسس التي قام عليها تقدير الثمن المتفق عليه..... »^(٢).

ثالثا: آثار نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:

إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، فإنه يترتب علي ذلي ذلك الأثرين التاليين:

(١) انظر: د: عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، اثر الظروف الطارئة و الصعوبات المادية علي تنفيذ

العقد الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٨.

(٢) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، رقم ٩٥، الصادرة بتاريخ ١٩٦٤/٢/٤.

الأثر الأول: استمرار المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته:

علي الرغم من مواجهة المتعاقد خلال التنفيذ من الصعوبات المادية غير المتوقعة، فإن ذلك لا يؤدي إلى تحلل المتعاقد من التزاماته، إلا إذا أدت إلى استحالة التنفيذ، فحينئذ نكون أمام فكرة القوة القاهرة.

فإذا توقف المتعاقد مع الإدارة عن التنفيذ، فإنه يتعرض لمختلف الجزاءات الإدارية. التي سبق ذكرها. كما انه قد يفقد حقه في المطالبة بالتعويض علي أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.

الأثر الثاني: حق المتعاقد في الحصول علي تعويض:

يترتب أيضا علي نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ضرورة تعويض المتعاقد عما تحمله من نفقات لمواجهة تلك الصعوبات. والتعويض الذي يترتب علي وجود الصعوبات المادية غير المتوقعة هو تعويض كامل، بمعنى انه يتعين علي الإدارة أن ترد إلى المتعاقد كافة النفقات الإضافية التي تحملها لمواجهة الصعوبات التي صادفته أثناء التنفيذ. ومن أحكام مجلس الدولة المصري في هذا الصدد، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٩٧ و الذي تقرر فيه ما يلي: « وبالتالي يكون الثابت من الأوراق أن هناك صعوبات مادية لم تكن متوقعة لدي طرفي العقد قد صادفت 2024/2025 تنفيذ الأعمال الإضافية التي قامت الإدارة بإسنادها إلى المطعون ضده خارج نطاق العقد، و أن تلك الصعوبات غير عادية وترجع إلى طبيعة الأرض والأثرية وأنه ما كان بإمكان طرفي العقد توقعها وهو ما يفيد توافر شروط انطباق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة بما يتعين معه تعويض المقاول والتكاليف التي تحملها باعتبار الأسعار المتفق عليها في العقد لا تسري إلا علي الأعمال العادية المتوقعة وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب حيث قضى بإلزام الإدارة بجميع الأعباء والتكاليف التي تحملها المطعون ضده عند تنفيذ الأعمال الإضافية بما يجاوز نسبة ٢٥% من الأعمال الأصلية، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون جديراً بالتأييد «(١).

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٥٦٧، لسنة ٢٩ق، الصادر بتاريخ ١٢/٣٠/١٩٩٧.

جدول يوضح شروط وآثار نظريات التوازن المالي للعقد

الآثار	الشروط	
• حق المتعاقد في فسخ العقد. • حقه في التحلل من التزامه إن ترتب عليها استحالة تنفيذ العقد. • حقه في الحصول علي تعويض كامل.	١. وجود عقد إداري. ٢. صدور الإجراء الضار من جهة الإدارة المتعاقدة. ٣. إصابة التعاقد بضرر خاص. ٤. عدم وقوع خطأ من الإدارة. ٥. عدم توقع الإجراء الضار.	نظرية عمل الأمير
• استحقاق المتعاقد تعويض جزئي. • استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد.	١. حدوث ظرف أو حادث استثنائي. ٢. عدم توقع المتعاقد للظرف وعد استطاعته دفعه. ٣. الظرف الطارئ أجنبيا عن طرفي العقد. ٤. وقوع الظرف الطارئ خلال تنفيذ العقد. وأن يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد.	نظرية الظروف الطارئة
• حق المتعاقد في الحصول علي تعويض كامل. • استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد.	١. أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية وغير عادية أو استثنائية. ٢. أن تكون الصعوبات غير متوقعة لحظة إبرام العقد. ٣. أن يترتب علي الصعوبات ضرراً بالمعقد.	نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

2024/2025

المطلب الرابع تعديل قيمة عقود المقاولات

ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد، وقيام الحكومة بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وقيامها بتحرير سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل الدولار، مما ادي الي عدم استقرار الاسعار، ما بين صعود وهبوط، واثّر ذلك تأثيرا كبيرا علي فكرة التوازن المالي للعقد، وقد ادي لتوقف العديد من المتعاقدين عن العمل اثر ارتفاع الاسعار، مما اضر بالمصلحة العامة، ولذلك استحدث المشرع المصري في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في المادة ٤٧ طريقة تمكن الادارة من تعديل قيمة عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، حيث تلتزم الجهة الإدارية في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الأحوال، بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزما لطرفي التعاقد، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك .

وعلى الجهة الإدارية تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقا للقائمة التي تصدرها وزارة الإسكان، على أن يضع المقاول معاملاتها في المظروف الفني، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

وقد اوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وكيفية معادلة تغير الأسعار في عقود المقاولات واشترطات تطبيقها، وذلك في المادة ٩٩ حيث قررت انه في عقود مقاولات الأعمال التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم ادارة التعاقدات في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة او الخفض في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ويقع باطلا يخالف ذلك .

ويكون حساب التغير في الاسعار ومحاسبة المقاول علي فروق الاسعار رفعا وخفضا وفقا للتعريفات والمعادلة والقواعد الاتية:

أولاً: التعريفات:

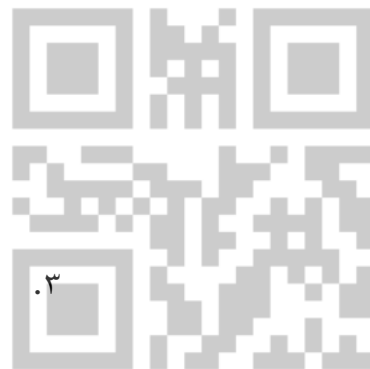
- **مدة التنفيذ:** المدة المحددة لانجاز الاعمال محسوبة من تاريخ تسليم الموقع خالياً من الموانع او استلام المقاول الدفعة المقدمة او الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ ايهما ابعد.
- **البنود المتغيرة:** البنود او مكوناتها الخاضعة للتعديل التي تحددها ادارة التعاقدات بمستندات الطرح (عمالة - مواد خام....الخ) من واقع القائمة التي تعدها وزارة الاسكان.
- **المعامل:** النسبة التي يحددها المقاول بعطائه لكل بند او مكوناته من البنود المتغيرة، بمراعاة الا تساوي صفرا ويقل مجموعا عن ١٠٠% او الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند او مشتملاته.
- **قيمة التعويض او الخصم:** المبلغ المستحق للمقاول او المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة احتساب التغير في اسعار البنود المتغيرة ارتفاعا او انخفاضاً.
- **نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار:** الرقم القياسي لسعر البند او مكوناته عند المحاسبة مطروحا منه الرقم القياسي للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية او الإسناد المباشر، بحسب الاحوال، مقبوما علي الرقم القياسي للسعر عند فتح 2024/2025 2024/2025 المظاريف الفنية او الاسناد المباشر، بحسب الاحوال، وذلك من واقع نشرة الارقام القياسية الصادر رقم الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء.

ثانياً: المعادلة:

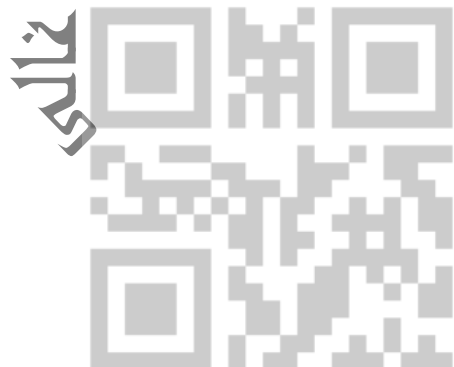
- $\text{قيمة التعويض او الخصم} = \text{قيمة الاعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد} \times \text{معاملاتها} \times \text{نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار}.$

ثالثاً: قواعد المحاسبة في الاسعار:

١. تقوم ادارة التعاقدات بتحديد البنود المتغيرة او مكوناتها ضمن شروط الطرح من واقع القائمة التي تصدرها وزارة الاسكان، وفي حالة عدم تحديدها تلغي المناقصة او الممارسة او امر الاسناد المباشر قبل البت فيها.
٢. يجب ان يتضمن عطاء المقاول (المظروف الفني) معاملات تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة او مكوناتها والتي حددتها ادارة التعاقدات ضمن شروط الطرح، ويتم علي اساسها، وفي حالة عدم تضمين المقاول عطاءه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء.



٣. تصرف قيمة المستخلص المعتمد في المواعيد المحددة وفقا لاسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الاسعار ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر، بحسب الاحوال، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته الذي يتفق عليه الطرفان.
٤. يحاسب المقاول علي التعديل في الاسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل
٥. يحاسب المقاول علي فروق الاسعار رفعا او خفضا خلال ٦٠ يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة، ويتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق، ويجب احتساب اولوية المتعاقد في ترتيب عطائه، وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات الاخر .
٦. لا تسري معادلة تغيير الاسعار وقواعد تطبيقها في أي من الحالات التالية:
- أ- العقود التي تكون مدة تنفيذها اقل من ٦ اشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع الي المقاول.
- ب- العقود التي تكون مدة تنفيذها اقل من ٦ اشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع الي الجهة الادارية، وفي هذه الحالة تتم محاسبة المقاول علي 2024/2025
- الكميات التي تم تنفيذها بعد الستة اشهر وفقاً لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 2024/2025



الباب الرابع

تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية

الأصل في العقود الإدارية أن الخلافات الناشئة عن تنفيذها أو تفسيرها تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري (١)، غير أن المادة ٩١ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تنص على أنه: «يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد».

كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤».

ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز لأطراف العقد الإداري اللجوء إلى القضاء،^{2024/2025} والتحكيم بالإضافة إلى التوفيق والوساطة للفصل في منازعات العقود الإدارية. وعلي ذلك فإن دراستنا لموضوع تسوية منازعات العقود الإدارية ستكون على النحو التالي:

الفصل الأول: الاختصاص القضائي بتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.

الفصل الثاني: الاختصاص غير القضائي بتسوية المنازعات الناشئة عن العقود

الإدارية.

الفصل الأول

الاختصاص القضائي بتسوية المنازعات

الناشئة عن العقود الإدارية

من المسلم به . كما ذكرنا سابقا . أن عقود الإدارة ليست كلها من طبيعة واحدة أو بمعنى أدق لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، فمنها ما يخضع للقانون العام وهو ما يطلق

(١) انظر: المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٦.

عليه العقود الإدارية، ومنها ما يخضع للقانون الخاص وهو ما يطلق عليه عقود الإدارة الخاصة، بالتالي فإن المنازعات المتعلقة بتلك العقود لا تدخل في اختصاص جهة قضائية واحدة.

ولذلك يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناجمة عن العقود الإدارية، بينما يختص القضاء العادي بما ينشأ عن عقود الإدارة الخاصة من منازعات. وتعد القواعد المنظمة للاختصاص القضائي من النظام العام، ومن ثم لا يجوز اتفاق الأطراف على مخالفتها^(١).

والأصل أن اختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري هو اختصاص عام وشامل بحيث يتناول أصل النزاع وكل ما يتفرع عنه. ومع ذلك فإن هناك استثناءين هامين في هذا الصدد هما:

١. **المسائل الأولية:** إذا ما أثر أمام إحدى جهتي القضاء - العادي والإداري - عند تصديها للفصل في نزاع يدخل أصلاً في اختصاصها، نزاع يتعلق بمسألة أولية، لا يمكن القضاء في موضوع النزاع إلا بعد حسمها، فإنه يجب على هذه الجهة أن توقف الفصل في الموضوع، وأن تحيل الدعوى إلى الجهة الأخرى للحصول على حكم في المسألة الأولية. فعلي سبيل المثال، ^{2024/2025} ^{2024/2025} أمام إحدى المحاكم القضائية العادية نزاع يتعلق بمدي صحة عقد إداري، أو بتفسير نص من نصوصه، أو بمجال تطبيقه...الخ. فإذا ما قدرت المحكمة القضائية أن النزاع المثار له علاقة وثيقة بموضوع الدعوى، اعتبرت تصفيته مسألة أولية وأحالت في شأنها إلى جهة القضاء الإداري المختصة^(٢). وعلى العكس من ذلك قد يثار أمام المحاكم الإدارية - عند التصدي لموضوع يتعلق بعقد إداري - نزاع ينصب على عقد من عقود القانون الخاص، أو يتصل بموضوع مما يدخل في اختصاص المحاكم القضائية العادية، كالفصل في ملكية أو تفسير عقد من عقود القانون الخاص...الخ. وهنا أيضا يجري

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٠ - م. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية - العقود الادارة في التطبيق العملي المبادئ والأسس العامة، منشأ المعارف ١٩٩٨، ص ٩٥.

• L. RICHER, Les contrats administratifs, op. cit., p.90.

(٢) انظر:

• T. C. 24 juin 1954, Sire, Rec., p. 714.

القضاء الإداري علي الإحالة إلى القضاء العادي للفصل في هذه المسألة قبل الفصل في الموضوع^(١).

٢. **القرارات الإدارية المنفصلة:** إن العقود التي تبرمها الإدارة - سواء أكانت من عقود القانون العام أو الخاص - تبرم بطريقة خاصة تقتضي في كثير من مراحلها صدور قرارات إدارية هي التي يطلق عليها القرارات الإدارية المنفصلة. و هذه القرارات سواء أسهمت في تكوين عقد خاص من عقود الإدارة أو عقد إداري، فهي قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، باعتباره جهة الاختصاص العام فيما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية^(٢).

كما انه من المسلم به أيضا، ان كل جهة من جهتي القضاء مستقلة في تقديرها عن الجهة الأخرى، بمعنى انه إذا رأت جهة القضاء الإداري أن عقدا ما له الصفة الإدارية، فإن هذا النظر لا يلزم جهة القضاء العادي إذا ما عرض عليها الأمر، والعكس أيضا صحيح. ونظرا لما ترتب علي هذا الخلاف من نتائج بالغة الخطورة، فإن المشرع قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا بمهمة التحكيم بين الجهتين وتحديد الجهة المختصة^(٣)، وفي فرنسا أنشئت بمقتضى قانون ٢٤ مايو لسنة ١٨٧٢ محكمة الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية أطلق عليها اسم محكمة التنازع^(٤).
٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥

وبناء علي ذلك فإنه في حاله حدوث النزاع بين أطراف العقد الإداري -
في أي مرحلة من مراحل تكوينه - فإن القضاء الإداري - وفقا لقواعد الاختصاص القضائي - هو القضاء المختص لتسوية هذا النزاع.

ولما كان الدستور المصري المعدل سنة ٢٠١٤ ينص في مادته ١٩٠ علي أن:
« مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٨.

(٢) المرجع السابق، ص ١٧٠.

(٣) كانت تتولى هذه المهمة محكمو النقض منذ سنة ١٩٦٥ حتى سنة ١٩٦٩، ثم عهد بها المشرع إلى المحكمة العليا بمقتضى قانون إنشائها رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩، والذي حل محله القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

(٤) انظر: د. محمد كامل ليلة، الرقابة علي أعمال الإدارة - الرقابة القضائية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ص ٢١٩.

الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».

كما تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ سنة ١٩٧٢ علي أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولاً)..... (حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.....(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية.

وبذلك وفقا لهذا النص الدستوري وكذلك نص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فإن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في منازعات العقود الإدارية. ولما كان النظام القضائي لمجلس الدولة المصري^(١) يتخذ مظهرين أساسيين هما قضاء الإلغاء والقضاء الكامل «التعويض»^(٢)، لذلك يجب ان نحدد نوع ولاية القضاء الإداري تجاه منازعات العقود الإدارية وما إذا كانت تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض.

ومما لا شك فيه ما لهذا التحديد من أهمية كبيرة نظرا للاختلاف الجوهرى بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض من حيث سلطة القاضي في الدعويين، شروط تحريك الدعوى، مواعيدها وصاحب المصلحة فيها^(٣)

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١. فمن حيث سلطة القاضي، فقاضي الإلغاء تقف سلطته عند الحكم اما بإلغاء القرار المعيب او رفض الدعوى إذا ثبت له عدم صحة الادعاء وسلامة القرار المطعون فيه، دون أن يملك توجيه أوامر او نواهي إلى الإدارة بعمل او امتناع عن عمل. اما القضاء الكامل (التعويض) فيخول للقاضي سلطات واسعة تمكنه من تصفية النزاع كلية، فيلغى القرارات المخالفة للقانون - ان وجدت - ثم يرتب علي ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية او السلبية.

(١) يلاحظ انه بالإضافة إلى قضاء إلغاء وقضاء التعويض يوجد مظهرين آخرين في فرنسا، وهما: قضاء التفسير " Les contentieux déclaratifs "، وقضاء الزجر والعقاب " Le contentieux de la répression. انظر في ذلك:

- G. PEISER, *Contentieux administratifs*, Dalloz, 1990, p. 157 et S.
- (٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٤.
- (٣) انظر في ذلك: د. عمر حلمي، طبيعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ١٩٩٣، ص ٧ وما بعدها. د. جمال عثمان جبريل، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٣ و ما بعدها.

٢. أما من حيث شروط قبول الدعوى ، فنعلم أن أول شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون محل الطعن قرار إداري يوصمه الطاعن بأحد عيوب المشروعية التي حددها القانون، في حين ان دعوى القضاء الكامل من الممكن أن توجه إلى القرارات الإدارية، العقود الإدارية و أعمال الإدارة المادية. وفيما يتعلق بشرط المصلحة، فبينما يكتفي المشرع لرفع دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مجرد مصلحة لا ترقى إلى مستوي الحق، يشترط لقبول دعوى القضاء الكامل أن يستند رافعها إلى حق شخصي اعتدت عليه الإدارة أو مهدد بالاعتداء عليه.

٣. وأخيرا من حيث ميعاد رفع الدعوى، فلا تنقيد دعوى التعويض (القضاء الكامل)

بمواعيد الإلغاء القصيرة (ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو العلم اليقيني به)، وإنما تخضع دعوى التعويض للقواعد العامة لتقادم الدعوى أو الحق.

وبناء على العرض السابق لاختلاف قضاء الإلغاء عن قضاء التعويض (القضاء

الكامل) يتضح لنا ان العقود الإدارية لا تصلح ان تكون محلا لدعوى الإلغاء، فمحل هذه الدعوى هو القرار الإداري وليس العقد الإداري. ولذلك فإن قضاء العقود الإدارية ينتمي إلى القضاء الكامل، ولكنه يثير بعض النواحي التي تتعلق بقضاء الإلغاء^(١). وعلي ذلك فإننا

سنعرض من خلال هذا الفصل دور كل من القضاء الكامل وقضاء الإلغاء في مجال 2024/2025

منازعات العقود الإدارية في مبحثين متتاليين علي النحو التالي:

المبحث الأول: ولاية القضاء الكامل في منازعات العقود الإدارية.

المبحث الثاني: ولاية قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإدارية.

المبحث الأول

ولاية القضاء الكامل في منازعات العقود الإدارية

قضاء التعويض أو القضاء الكامل هو الأصل فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية. وقد ورد اختصاص القضاء الإداري المصري في هذا الصدد مطلقاً، فلم تقيد المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بأي قيد إذ تقول: «.....» (حادي عشر): المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.»

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٤ م.

حمدي ياسين عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص ٩٨.

هذا وقد جرت محكمة القضاء الإداري علي تفسير هذا النص تفسيراً واسعاً^(١)، فأرست مبدأ مقتضاه أن اختصاص المحكمة يمتد ليشمل كل ما يتعلق بعملية التعاقد وبجميع العقود الإدارية وأنه اختصاص عام وشامل ومطلق لأصل المنازعة وما يتفرع عنها، ومن أوضح أحكامها في هذا الصدد، حكمها الصادر في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٦ إذ تقول فيه: «... لم يعد اختصاص محكمة القضاء الإداري مقصوراً علي صحة أو بطلان القرارات الإدارية التي تصدر في شأن هذه العملية المركبة، بل امتد الاختصاص لكل ما يتعلق بالعملية (عملية التعاقد) ابتداء من أول إجراء في تكوينها إلى آخر نتيجة في تصفية كلفة العلاقات والحقوق والالتزامات التي نشأت عنها. وأصبح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بجميع العقود الإدارية اختصاصاً مطلقاً وشاملاً لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، وبهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من إجراءات أو قرارات وذلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات طالما لم يسقط أصل الحق بمضي المدة، ذلك أن واضع التشريع أراد أن يجعل لمحكمة القضاء الإداري ولاية القضاء الكامل في عناصرها العملية بأسرها، يستوي في ذلك ما يتخذ صور قرار إداري وما لا يتخذ هذه الصورة، طالما توافرت فيه حقيقة التعاقد الإداري». وعلي هذا النحو يكون لمحكمة القضاء الإداري في هذه المنازعات أن تفصل في القرارات الإدارية التي تتصل بعملية إبرام العقد بمقتضى ولايتها الكاملة دون حاجة إلى أن تقتصر في شأنها علي الإلغاء، ويكون لها تفريعاً علي ذلك أن تراقب مطابقة القرار للقانون وأن تجاوز هذا الحد إلى رقابة الواقع. ومن حيث أنه علي مقتضى ما تقدم، فإنه متي توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري، سواء أكانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه، فإنها كلها تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء.....»^(٢).

وهذا وتؤكد المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها^(٣) علي انتماء العقود الإدارية ومنازعاتها إلى القضاء الكامل وأن للمحكمة التصدي لكافة المنازعات الناشئة عن العقد وما يتفرع عنها، ففي حكمها الصادر في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٩٤ تقول: «... فإنه من

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٥.

(٢) محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ١١٨٠، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٨/١١/١٩٥٦.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٨٦٤، لسنة ١٩ ق، الصادر في ٣٠/٦/١٩٧٩. وكذلك الطعن رقم ٦٠٥، لسنة ٢٣ ق، الصادر في ٢٦/١/١٩٨٠.

المسلم به في فقه القانون الإداري أن سلطة قاضي الإلغاء تقف عند الحكم بإلغاء قرار معيب، وأما القضاء الكامل فيخول للقاضي تصفية النزاع كلية، فيلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يرتب علي ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية، ومن المسلم به أيضا أن قضاء العقود الإدارية ينتمي أساسا إلى القضاء الكامل، إذ يكون للمحكمة التصدي للمنازعة الناشئة عن العقد الإداري بجميع ما يتفرع عنها، وبهذه المثابة لا يقتصر اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه علي التصدي لبحث حقوق الطاعن المطالب بها، بل يمتد إلى بحث مستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها، للوصول إلى استجلاء وجه الحق في دعوى الطعن»^(١).

وهو ما أكدته أيضا المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها في ٢٤ يناير سنة ١٩٩٥ بقولها أن: «.. ومن حيث انه لما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن قضاء العقود الإدارية ينتمي أساسا إلى القضاء الكامل، فإنه يكون للمحكمة ان تنظر ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات، وذلك باعتبارها من عناصر المنازعة طالما لم يسقط الحق بمضي المدة، كما يكون للمحكمة الاختصاص الشامل لجميع ما يتفرع عن المنازعة الأصلية من أمور مستعجلة»^(٢).

2024/2025 المنازعة حول العقد الإداري في مجال القضاء الكامل تتعدد صورها حسبما 2024/2025

تستهدف، ومن ثم فقد تتخذ الدعوى إحدى الصور الآتية: دعوى بطلان العقد، دعوى الحصول علي مبالغ مالية من المتعاقد الآخر، دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن الإدارة علي خلاف التزاماتها التعاقدية أو دعوى فسخ العقد. وسنتولى بيان كل صورة من هذه الصور علي النحو التالي:

١. **دعوى بطلان العقد:** فقد تستهدف الدعوى بطلان العقد وذلك لعيب في تكوينه او في شروط صحته^(١). ففي هذه الحالة - وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي وهو ما يتعين ان يأخذ به مجلس الدولة المصري^(٢) - ليس للمتعاقد الذي يريد ان توصل إلى إلغاء العقد إلا سبيل القضاء الكامل - فكما رأينا فيما سبق أن دعوى الإلغاء لا يمكن ان توجه إلى العقود الإدارية، فمحل هذه الدعوى الدائم هي القرارات الإدارية. كما ان هذه الدعوى مقرره فقط لأطراف العقد الإداري، وبالتالي لا يمكن لغير المتعاقد ان يرفعها، لان الأجنبي عن العقد - كما نقول محكمة القضاء الإداري في

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣٦٨٣، لسنة ٣٦ ق، الصادر في ١١/٢٩/١٩٩٤.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٣٢٦، لسنة ٣٢ ق، الصادر في ١/٢٤/١٩٩٥.

حكمها الصادر في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٦ انه: «..... لا يجوز له إلا ان يطعن بالإلغاء لأنه أجنبي ليس للعقد في مواجهته أية قوة في الإلزام»^(٣).

٢. **دعوى الحصول علي مبالغ مالية:** وقد تستهدف الدعوى أمام القضاء الكامل الحصول علي مبالغ مالية، وذلك إما في صورة ثمن او اجر متفق عليه في العقد او تعويض عن أضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد او لأي سبب آخر من الأسباب إلى الحكم بمبلغ من المال^(٤).

٣. **دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة من الإدارة:** إذا صدر عن الإدارة تصرف مخالف لالتزامها التعاقدية، فإن للمتعاقد معها لن يحصل علي حكم بإبطال هذا التصرف عن طريق القضاء الكامل. وتحتفظ دعواه في هذه الحالة بصفتها تلك . من حيث إنها تنتمي إلى القضاء الكامل . حتى لو اقتضت علي طلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة بصفتها متعاقدة. ولهذا أثره الخطير فيما تعلق بإجراءات التقاضي ومدده لاختلاف كل من قضائي الإلغاء والتعويض عن الآخر في هذا الخصوص^(٥). ولقد أكدت علي ذلك محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٦ حيث تقول: «.... أما ما يصدر من القرارات تنفيذاً

للعقد، كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات التعاقدية او بفسخ العقد او إنهائه

فهذه كلها تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، فهي منازعات حقوقية، وتكون محلاً للطعن علي أساس استعداء ولاية القضاء الكامل، فيفصل فيها علي نحو لا يختلف عن ولاية القضاء المدني او العادي عندما كان يفصل - في حدود اختصاصه - في منازعات العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد باعتبارها من أعمال الإدارة الصرف وتخضع فيها لسلطة المحاكم العادية أسوة بالارتباطات القانونية بين الأفراد وبعضهم. وأضافت المحكمة: «... كما ان القرار الصادر بفسخ العقد وبمصادرة التأمين ... هذا القرار صادر تنفيذاً للعقد واستناداً إلى نصوصه، فهو كما سبق البيان من القرارات التي لا تدخل في نطاق قضاء الإلغاء، بل في نطاق ولاية

(١) وذلك في حالة تخلف أحد أركان العقد الرئيسية، كالرضا، المحل أو السبب، او وجود عيب يشوب صحة العقد، كتلك التي تصيب الرضا ، كالغط ، التدليس، الغبن او الإكراه.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٦.

(٣) محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ١١٨٠، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٨/١١/١٩٥٦.

(٤) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٦.

(٥) انظر: المرجع السابق، ص ١٧٧.

القضاء الكامل»^(١). ويترتب علي انتماء دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن جهة الإدارة بالمخالفة لأحكام العقد إلى القضاء الكامل ألا تنقيد هذه الدعوى بمدد دعوى الإلغاء. وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٦، حيث تقول: «... هذا القرار صدر تنفيذا للعقد واستنادا إلى نصوصه، فهو كما سبق البيان من القرارات التي لا يدخل المنازعة في شأنه في نطاق قضاء الإلغاء، بل في نطاق القضاء الكامل. ومن ثم كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله...»^(٢).

٤. **دعوى فسخ العقد:** قد تستهدف الدعوى فسخ العقد، ذلك أن المتعاقد له أن يطالب بفسخ عقده عند ثبوت ارتكاب الإدارة المتعاقدة لخطأ أو لاخلال جسيم بتنفيذ التزاماتها العقدية. أو في حالة قيامها بإحداث تغيير في العقد وشروطه يتجاوز المسموح لها بها وفقا لسلطتها في التعديل بالإرادة المنفردة، أو أخيرا عند حدوث القوة القاهرة المؤدية لاستحالة تنفيذ العقد ويعد الفسخ في كافة هذه الحالات بمثابة تعويض للمتعاقد الآخر^(٣).

المبحث الثاني

ولاية قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإدارية

2024/2025

2024/2025

ذكرنا أن المجال الأصيل لقضاء العقود الإدارية هو القضاء الكامل. وبالتالي فإن مجال قضاء الإلغاء في نطاق العقود الإدارية محدود. ويرجع ذلك - كما ذكرنا سابقا - إلى أن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه إلى العقود الإدارية، ذلك أن من شروط قبولها أن توجه الدعوى إلى قرار إداري، فمحل هذه الدعوى دائما قرار إداري. ومن ناحية أخرى فإن دعوى

(١) محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ١١٨٠، لسنة ١٠ ق، الصادر في ١٨/١١/١٩٥٦، سبقت الإشارة إليه. وقد قضت أيضا في حكمها الصادر في ٢٧ يناير سنة ١٩٥٧ بأنه: «.....ومن حيث انه يبين من مساق الوقائع..... أن الحكومة استندت في إلغاء العقد المبرم بينها وبين المدعي إلى المادة ٦١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣. الخاص بالمناجم و المحاجر و إلى البند الثالث عشر من العقد نفسه، فإذا كان الإلغاء مستندا إلى نص القانون فقط وبالتطبيق لأحكامه، كان القرار الصادر قرارا إداريا وطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بدعوى الإلغاء ويدخل في نطاقها، ويرد عليه وقف التنفيذ الخاص بالقرارات الإدارية. أما إذا كان إلغاء العقد مستندا إلى نصوص العقد نفسه وتنفيذا له، فإن المنازعة بشأنه تكون محلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي أساس استعداء الولاية الكاملة لهذا القضاء». محكمة القضاء الإداري ، الدعوى رقم ١٩٨، لسنة ١١ ق ، الصادر في ٢٧/١/١٩٥٧.

(٢) محكمة القضاء الإداري ، الدعوى رقم ٢٨٤، لسنة ٨ ق ، الصادر في ٢٣/١٢/١٩٥٦.

(٣) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٦.

الإلغاء هي دعوى مشروعية، فهي جزاء مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية، في حين ان منازعات العقود الإدارية ترتبط بالتزامات شخصية، وذلك فإنها ليست مجالا لدعوى الإلغاء. وعلي الرغم من ذلك فإن هناك استثناء يرد علي هذه القاعدة، حيث ان بعض المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية قد تدخل ضمن ولاية قضاء الإلغاء، وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي وسابره في ذلك مجلس الدولة المصري.

وعلي ذلك فإن اختصاص قضاء الإلغاء في مجال العقود الإدارية محدود في حالتين، **الأولى:** هي القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية التعاقد، **والثانية:** فهي طعون المستفيدين في حالة عقود الالتزام. وهو ما سنعرض له في المطلبين التاليين.

المطلب الأول

القرارات الإدارية المنفصلة

سنتعرف من خلال دراستنا للقرارات الإدارية المنفصلة علي ماهيتها (**أولاً**)، ثم نتطرق للحديث عن إمكانية التعاقد مع الإدارة في ان يقدم طعنا بإلغاء هذه القرارات وذلك من خلال مناقشة، من له الحق في تقديم الطعن بالإلغاء للقرارات الإدارية المنفصلة (**ثانياً**)، وأخيراً، نشير إلى الآثار المترتبة علي إلغاء القرارات المنفصلة (**ثالثاً**).

2024/2025

أولاً: ماهية القرارات الإدارية المنفصلة: 2024/2025

رأينا أن العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة تمر بعدة مراحل وخطوات، ويتبع فيها العديد من الإجراءات، وتتخذ في خلالها الكثير من القرارات الإدارية، منها ما يسبق عملية التعاقد ومنها ما يتعلق بإجراءات إبرام العقد ذاته، ومنها إجراءات معاصرة لإبرام العقد، ومنها إجراءات وأخرى تتصل بتنفيذ العقد والإشراف علي التنفيذ، ومنها أيضاً ما يتعلق بمرحلة ما بعد التنفيذ وإنهاء العقد^(١).

وفي فرنسا يعرف الفقه والقضاء هذه القرارات بالقرارات الإدارية المنفصلة^(٢). ويطلق عليها نفس الاسم في الفقه والقضاء الإداري المصري، وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها في ٥ أبريل ١٩٧٥ القرار المنفصل بأنه: « قرار يسهم في

(١) انظر: د. جو رجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، " التعريف - النظام القانوني لها"، دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الفرنسي و المصري، دار النهضة العربية، ٢٠٠٢، ص ٦٣.

(٢) انظر:

• L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p.266.



تكوين العقد ويستهدف إتمامه إلا أنه ينفصل عن العقد، وينفرد بطبيعته فيجوز الطعن فيه استقلاً^(١).

هذا وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي فكرة القرارات المنفصلة في بداية القرن العشرين، وبالتحديد في الحكم الصادر في عام ١٩٠٣، ففي هذا الحكم قبل الطعن علي أفراد في بعض القرارات المتعلقة بعملية التعاقد، استقلاً عن عملية التعاقد ذاتها^(٢). وساير مجلس الدولة المصري نظيره الفرنسي في قبول الطعن في مثل هذه القرارات، فأجاز لكل صاحب مصلحة «كطرف من أطراف العقد أو من الغير»، أن يطعن بالإلغاء فيها، بشرط أن يبنى طعنه علي أن القرار المنفصل قد خالف القانون وذلك بأن يوصمه الطاعن بأحد عيوب المشروعية التي حددها القانون، وليس علي الإخلال ببنود العقد وبذلك لا يستطيع أن يستند علي حقوقه الشخصية المتولدة عن العقد ذاته، لأن مجال المنازعة المتعلقة بهذه الحقوق يكون أمام قاضي العقد و بالتالي أمام القضاء الكامل.

ولقد اعتبرت محكمة القضاء الإداري، القرارات الإدارية السابقة علي إبرام العقد او اللاحقة له، كقرارات وضع شروط المناقصة او المزايدة، او قرارات لجنة فحص العطاءات ولجنة البت، او قرارات إرساء المناقصة او المزايدة، قرارات إدارية منفصلة عن العقد، وبالتالي يمكن الطعن فيها بالإلغاء. ففي حكمها الصادر في ٨ يناير ١٩٥٦ أوضحت ان : « القرار 2024/2025 الذي يصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح الإدارة بقصد إحداث اثر قانوني. وتحليل العملية القانونية التي تنتهي بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونة له، يتضح ان القرارات السابقة او اللاحقة علي العقد، كوضع الإدارة لشروط المناقصة او المزايدة، وقرارات لجنة فحص العطاءات وقرارات لجنة البت، والقرار بإرساء المناقصة او المزايدة، هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء، ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ويمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها ان كان لهذا التعويض محل. أما العقد ذاته فإن المنازعة بشأنه تدخل او لا تدخل في اختصاص هذه المحكمة بحسب طبيعة العقد واختصاص المعقود للقضاء الإداري. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه - الصادر من مصلحة الإذاعة بإرساء مزاد توزيع مجلة الإذاعة المصرية علي شركة معينة- إنما هو قرار إداري صادر من جانب واحد هو جهة الإدارة بناء علي سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار منصفاً

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣٢٠، سنة ١٧ق، الصادر في ١٩٧٥/٤/٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٨٧.



علي قرار إداري، فتختص هذه المحكمة بنظره، ويتعين بالتالي رفض الدفع بعدم الاختصاص^(١).

إلا أنه يجب التمييز بين القرارات المنفصلة والتي تصدرها الجهة الإدارية أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد، والقرارات التنفيذية أي التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذ لعقد من العقود الإدارية واستنادا إلى نص من نصوصه، حيث يكون النظر في شأن المنازعات التي تثار بشأن هذه الأخيرة من اختصاص القضاء الكامل^(٢).

هذا وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القرار الصادر بفسخ العقد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد وبالتالي لا يجوز مخصصتها بدعوى الإلغاء. وهذا طبيعي لأن فسخ العقد لا يعدو إلا أن يكون إجراء تتخذه الإدارة كطرف متعاقد وليس كسلطة عامة^(٣).

ثانيا: من له حق طلب إلغاء القرار الإداري المنفصل:

سبق أن ذكرنا أن القضاء الإداري يجيز لكل صاحب مصلحة أن يطعن بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة، سواء كان طرف من أطراف العقد، أو من الغير.

١. طلب إلغاء القرار المنفصل المقدم من المتعاقد:

إنما أبرمت الإدارة عقدا إداريا مع أحد الأفراد، ثم تبين للمتعاقد أن بعض القرارات التي ساهمت في تكوين عقده، كانت غير مشروعة، فهل يجوز له أن يطلب إلغائها؟
يجيب غالبية الفقه الفرنسي علي هذا التساؤل بالنفي، أي أن المتعاقد ليس أمامه سوى قاضى العقد، ليحسم بمقتضى سلطة القضاء الكامل (قضاء التعويض) جميع المنازعات المتعلقة بالعقد، وبالتالي فإن المتعاقد -إذا حاول أن يطرق باب قضاء الإلغاء - فسيواجه بالدفع المبني علي فكرة "الدعوى الموازية"^(٤). ولكن يري رأيا فقهيا، أن اتجاه غالبية الفقه - لا يقوم علي أساس سليم، ويتضح ذلك من سماح مجلس الدولة للمتعاقد بالطعن في القرار المنفصل بدعوى الإلغاء^(٥).

(١) محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم ٣٤، لسنة ٧ ق، الصادر في ١٩٥٦/١/٨.

(٢) لمحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٦٦٦، لسنة ٢٤ ق، الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/١٤.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٦٥٤، لسنة ٣٦ ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٣/٢٢.

(٤) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٣.

(٥) راجع:

• وقد DE LAUBADÈRE, Traité des contrats administratifs, op. cit., p.329.

أورد بعض الأحكام في هذا الخصوص: مثل حكم المجلس الصادر في ٦ فبراير ١٩٣٦ في

هذا ويرى أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي - ونؤيده - في أن التجاء المتعاقد مع الإدارة إلى قضاء الإلغاء محل نظر، ذلك أن التجاء هذا المتعاقد إلى القضاء لا يكون - بطبيعة الحال - إلا بعد إبرام العقد، وبالتالي فإن المتعاقد ليس له مصلحة في الالتجاء إلى قضاء الإلغاء، لأن القضاء الكامل أجدى بالنسبة إليه من قضاء الإلغاء، لأنه لو حصل علي حكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل فإنه يتعين عليه بعد ذلك أن يعود مرة أخرى إلى قاضي العقد لكي يرتب له النتيجة التي ترتبت علي الحكم بالإلغاء، ومن ثم فإنه يكون من الأفضل له ان يلجأ إلى قاضي العقد مباشرة^(١).

ولكن المتعاقد مع الإدارة يسترد حقه في الالتجاء إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت من الإدارة قرارات غير مشروعة بصفة أخرى غير صفتها كمعاقدة معه، فحينئذ يكون للمتعاقد - كسائر المواطنين - ان يطلب إلغاء تلك القرارات إذا ما استوفى شرط المصلحة، وكان القرار المطلوب إلغاؤه غير مشروع. كما يجب ان تكون هذه القرارات ذات علاقة غير مباشرة بالعقد، أما إذا كانت علاقتها مباشرة بالعقد فإن المنازعات التي تثور بشأنها يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الكامل وليس قضاء الإلغاء. وبناء علي ذلك إذا أصدرت الإدارة المتعاقدة تلك القرارات استنادا إلى دفاتر الشروط ، فإن المنازعات التي تثور بشأنها يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الكامل^(٢) (قضاء التعويض)، أما إذا أصدرت الإدارة هذه القرارات استنادا إلى القوانين واللوائح فإن الطعن في هذه القرارات يكون عن طريق دعوى الإلغاء^(٣). وهو ما أعلنته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٢٧ يناير سنة ١٩٥٧ حيث تقول: « فإذا كان الإلغاء (إلغاء العقد) مستندا إلى نص القانون فقط وبالتطبيق لأحكامه كان القرار الصادر بالإلغاء قرارا إداريا و يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بدعوى الإلغاء و دخل في نطاقها، و يرد عليه طلب وقف التنفيذ الخاص بالقرارات الإدارية، أما إذا كان إلغاؤه مستندا إلى نصوص العقد نفسه و تنفيذا له، فإن المنازعة بشأنه تكون محلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي أساس استعداء الولاية الكاملة لهذا القضاء ... »^(٤).

، وكذلك حكمه الصادر في ٤ فبراير ١٩٥٤ في " Département de la Greuse " قضية " Ville de Saverne " قضية.

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٣ - ١٩٤.

(٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٩٤.

(٣) محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم ١٦٧، لسنة ١١ ق، الصادر في ٢٧/١/١٩٥٧.

٢. طلب إلغاء القرار الإداري المنفصل المقدم من الغير:

يقصد بالغير هو غير المتعاقد، الذي لا يستطيع اللجوء إلى القضاء الكامل لأبطال العقد أو الحصول على نتائج هذا الأبطال^(١). ولقد استقر القضاء الإداري المصري والفرنسي على السماح للغير بالطعن في القرارات الإدارية المنفصلة وهي تلك التي تستهدف العمل على إتمام التعاقد أو الحيلولة دون إتمامه^(٢).

ويعد من أقدم أحكام مجلس الدولة المصري في هذا الخصوص، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢٥ نوفمبر ١٩٤٧ والذي تقول فيه: « إذا طلب المدعي إلغاء قرار صدر من مصلحة الأملاك باعتماد رسو المزاد على المدعي عليهما الأخيرين بناء على أن هذا القرار خالف القاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر في ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٣ بمقولة أن من مقتضاها وجوب أن يكون البيع في مثل هذه الحالة بالممارسة مع المدعي، فإن طلبه يكون والحالة هذه متعلقا بإلغاء قرار إداري صادر من جانب واحد هو جهة الإدارة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح محدثا أثره القانوني في الجانب الإداري من تلك العملية المركبة وبهذه المثابة تختص محكمة القضاء الإداري بنظره.

ومن حيث أنه لا يقدح فيما تقدم ما قد يخیل بادئ الرأي من أن الطعن بالإلغاء 2024/2025 2024/2025

يكون في مثل هذه الحالة غير مجد ما دام لا ينتهي إلى إلغاء العقد ذاته، وذلك لأن مناط الاختصاص هو ما إذا كان ثمة قرار إداري يجوز أن يكون محلا للطعن بالإلغاء أم لا. فحيثما يمكن فصل مثل هذا القرار من العملية المركبة، فإن طلب إلغائه يكون والحالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الإداري. على أن وجه المصلحة في الطعن ظاهرة، إذا لوحظ أن قرار الإلغاء قد يكون محل تقدير المحكمة المدنية (أو الإدارية) كما أن الأغيار الذين لا يستطيعون الطعن في العقد مدنيا لفقدان الحق الذي يخولهم ذلك على اعتبار أنهم ليسوا أطرافا في العقد، يمكنهم الطعن بالإلغاء في القرار الإداري المتصل به، متى كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الطعن. وقد يؤدي إلغاء القرار الإداري إلى تسوية الأمر على نحو يحقق مصلحتهم....»^(٣).

(١) راجع: د. جمال عثمان جبريل، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٧.

(٢) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٥ - د.

جمال عثمان جبريل، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٧.

(٣) محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم ١٤٣، لسنة ١ ق، الصادر بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٥.

ثالثاً: اثر إلغاء القرار الإداري المنفصل علي العقد الإداري:

مما لا شك فيه أن إلغاء القرار الإداري المنفصل يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليها من نتائج، لأن ما يبني علي باطل فهو باطل. ولكن مجلس الدولة المصري أو الفرنسي يجري باستمرار - ومنذ أمد بعيد - علي أن إلغاء القرارات المنفصلة في مجال العقود الإدارية لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد، بل يبقى سليماً وناظراً حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء، وحينئذ يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإلغائه استناداً إلى سبق إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة والتي ساهمت في إتمام عملية التعاقد^(١).

لكن الأمر في فرنسا قد تغير في عقد التسعينات، وذلك بصور حكيم هامين: أولهما الحكم في قضية " Les Mimosas " والذي صدر في ١ أكتوبر سنة ١٩٩٣^(٢) والثاني في قضية " Ep. Lopez " والذي صدر في ٧ أكتوبر ١٩٩٤^(٣). واكمل التغيير بصور قانون ٨ فبراير لسنة ١٩٩٥، والذي أعطى لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية سواء كمحاكم استئناف أو كمحاكم أول درجة سلطة إصدار أوامر للإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، كما يعطيها الحق في أن تحكم علي الإدارة بغرامة تهديديه إذا ما تأخرت أو تقاعست عن تنفيذ ما يقتضيه الحكم، وذلك لحث جهة الإدارة علي ضرورة احترام أحكام القضاء واحترام حجيتها وقوة الشيء المقضي به فيها.

2024/2025

2024/2025

ويمكننا أن نبين المبادئ التي تضمنها هذا التغيير أو التطور في فرنسا في

الآتي^(٤):

١. النظر للسبب الذي استند إليه الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل:

وفي هذه الحالة يجب ان نميز بين أمرين: أولهما، ان يكون سبب إلغاء القرار المنفصل هو عدم مشروعية شروط العقد ذاته، وفي هذه الحالة فإن إلغاء القرار المنفصل يؤدي إلى بطلان العقد، وثانيهما، هو ان يكون سبب إلغاء القرار المنفصل هو عيب في القرار ذاته وليس في شروط العقد، وفي هذه الحالة يتعين - في كل قضية علي حدة -

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٦.

(٢) راجع:

• C.E. 1^{er} octobre 1993, Les Mimosas, Rec., p.971.

(٣) راجع:

• C.E. 7 octobre 1994, Ep. Lopez, Rec., p.480.

(٤) انظر: د. جو رجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٥ و ما بعدها.

تقدير درجة العلاقة بين القرار الملغي والعقد، وكلما كانت هذه العلاقة اثر مباشرة كلما كان هناك مبررا لاعتبار العقد باطلا. وبناء علي ذلك فإن إلغاء القرار المنفصل الصادر بإبرام العقد يؤدي إلى بطلان العقد اكثر بكثير من قرار الموافقة علي العقد او التصديق عليه.

٢. مدي ضرورة تدخل القاضي المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقد ذاته

ليس ضروريا أن يتدخل القاضي المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقد ذاته. فصدور الحكم بإلغاء القرار المنفصل يكون قبل تدخل قاضي العقد إذا ما رفع إليه الأمر. وعلي ذلك يقتصر دور قاض العقد إذا ما رفع إليه الأمر علي مجرد إعلان او إظهار بطلان العقد فقط.

ولكن يستطيع أحد المتعاقدين أن يستند إلى الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل إذا كانت له مصلحة في ذلك، ويحتج في مواجهة المتعاقد الآخر ببطلان العقد وبالتالي يتحلل من التزاماته.

وإذا كان هذا الإلغاء يؤدي بالفعل إلى بطلان العقد، فإن قاضي العقد إذا رفعت الدعوى أمامه من الطرف الآخر، سوف يقضى بأن الطرف الأول كان له سنده من القانون في التحلل من التزاماته، وأن تصرفه هذا لا يؤدي إلى قيام مسؤوليته في ذلك.

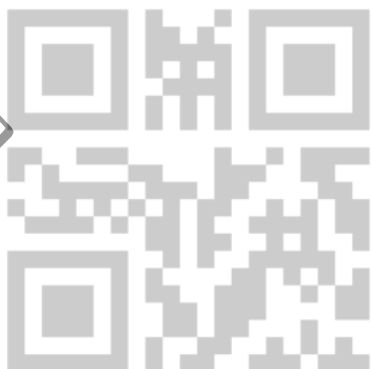
2024/2025

2024/2025

٣. في حالة اللجوء لقاضي العقد، وفي هذه الحالة ينبغي التفريق بين أمرين:

الأمر الأول: إذا كان الإلغاء قد تم بناء علي طعن من أحد المتعاقدين: في هذه الحالة سوف يتمسك هذا المتعاقد بترتيب الأثر الطبيعية لحكم الإلغاء، وهو بطلان العقد، وسوف يقضى له قاضي العقد بذلك.

الأمر الثاني: إذا كان الإلغاء قد تم بناء علي طعن من الغير: في هذه الحالة فإن الأمر يختلف، لان الغير - وفقا لقاعدة نسبية اثر العقد - ليست لديه صفة اللجوء إلى قاضي العقد، فهو ليس طرفا في العقد. ولكن له - وفقا لقانون ٨ فبراير لسنة ١٩٩٥ - أن يلجأ إلى القاضي الإداري طالبا فرض غرامه تهديديه "Astreinte" علي الإدارة حتي تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته، فتقوم الإدارة برفع الأمر إلى قاضي العقد الذي سيرتب النتائج الطبيعية لإلغاء القرار المنفصل، وإعمال الأثر المنطقي لهذا علي العقد فيقوم بإلغائه.



المطلب الثاني

طعون المستفيدين في حالة عقود الالتزام

الأصل انه لا يمكن الاستناد إلى شروط عقد من العقود لإلغاء قرار إداري، علي أساس ان هذا القرار لا يتفق و شروط العقد. ذلك ان قضاء الإلغاء - كما ذكرنا سابقاً - يستهدف دائماً حماية قواعد المشروعية، في حين ان العقود لا تولد إلا التزامات شخصية، ويؤدي الإخلال بها إلى إثارة القضاء الكامل.

ومع ذلك فإن القضاء الإداري في مصر وفرنسا - خروجاً علي القاعدة السابقة - قد أجاز للمتفاعلين بخدمات المرفق في حالة عقود الامتياز ان يطعنوا بالإلغاء في القرارات الصادرة من الإدارة - في علاقتها بالملتزم - وتتضمن الإخلال بشروط عقد الامتياز التي تبين كيفية أداء الخدمة للمتفاعلين^(١).

ويرجع غالبية الفقهاء في مصر وفي فرنسا هذا الاستثناء إلى الطبيعة اللاتحجية لبعض الشروط الواردة في عقد الالتزام. فلقد رأينا عند دراستنا لعقد الالتزام ان الشروط الواردة به، والتي تنظم كيفية أداء الخدمة للمتفاعلين، هي شروط لها طبيعة اللاتحجة الإدارية، وبالتالي فإن خروج الإدارة أو الملتزم عليها لا يعد مجرد إخلال بالالتزام شخصي مرجعه إلى العقد، بل إنه ينطوي علي مخالفة للقاعدة اللاتحجية الواردة في العقد، مما يجعل القرار غير مشروع. وعلي ذلك إذا خرج الملتزم علي القواعد الواردة بعقد التزامه والتي تنظم كيفية أداء الخدمة للمتفاعلين، فإن لكل صاحب مصلحة ان يردّه إلى نطاق المشروعية، وذلك بالطريقة الآتية: ان يتقدم المنتفع إلى الجهة الإدارية المتعاقدة طالباً منها التدخل لإجبار الملتزم علي احترام شروط العقد. فإذا رفضت الإدارة التدخل صراحة أو ضمناً، حق للمتفع ان يطعن في هذا القرار أمام قاضي الإلغاء، ويكون القرار غير مشروع إذا ثبت فعلاً ان الملتزم لم يحترم شروط العقد^(٢).

ويعد من اقدم واشهر أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد، الحكم الصادر في ٢١ ديسمبر ١٩٠٦ في قضية Syndicat des propriétaires du quartier " Croix-de-Seguey-Tivoli " ^(٣)، وفيه سمح المجلس لأول مرة بقبول الطعن لتجاوز

(١) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٦.

(٢) المرجع السابق، ص ١٩٦.

(٣) انظر:

- C.E. 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, G.A.J.A., p.90.

السلطة المقدم من منتفعين من امتياز مرفق عام، والذي يطالبون فيه بإلغاء القرارات الإدارية التي ترفض كفالة تشغيل المرفق بطريقة مطابقة للنصوص المعمول بها^(١).

هذا وقد توالى أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد^(٢). وقد أسس مجلس الدولة الفرنسي في قضائه السابق علي أساس الطبيعة اللاتحوية للشروط الواردة في عقد الالتزام والاعتراف للمنتفعين بهذا العقد بحق الطعن في القرارات التي تخالف هذه الشروط، لان هذا معناه مخالفة القاعدة اللاتحوية الواردة في العقد ما يجعل القرار غير مشروع و يجوز الطعن فيه^(٣).

وقد اخذ مجلس الدولة المصري بهذه المبادئ السابقة، فتقرر محكمة القضاء الإداري في الحكم الصادر عنها بتاريخ ٢٧ يناير ١٩٥٧ أن: «... عقد الالتزام ينشئ في أهم شقيه مركزا لاتحيا يتضمن تخويل الملتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة يقتضيها قيام المرفق واستغلاله. وهذا المركز اللاتحي الذي ينشئه الالتزام والذي يتصل بالمرفق العام هو الذي يسود العملية بأسرها. أما المركز التعاقدي فيعتبر تابعا له...»^(٤).

كما أن المحكمة الإدارية العليا أكدت نفس المبدأ، ومن قضائها في هذا الصدد، حكمها الصادر في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٧٧ حيث تقول: «..... ومن حيث أن المسلم به فقهاء وقضاة، أن شروط عقد التزام المرفق العام تنقسم إلى نوعين: شروط لاتحوية، وشروط تعاقدية، والشروط اللاتحوية فقط هي التي يملك مانح الالتزام تعديلها بإرادته المنفردة في أي وقت، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يتوقف ذلك علي قبول الملتزم. والمسلم به أن التعريف، وخطوط السير وما يتعلق بها من الشروط اللاتحوية القابلة للتعديل. بإرادة مانح الالتزام المنفردة»^(٥).

(١) انظر:

- L. RICHER, Droit des contrats administratifs, op. cit., p.267.

(٢) انظر:

- C.E. 27 novembre 1935, Baidouin, Rec., 1105.
- C.E. 1^{er} juillet 1936, veyre, Rec., p. 713.
- C.E. 11 décembre 1963, Syndicat de défense en vue du rétablissement de la voie ferrée Bort-Eygurande, J.C.P. 1964, II, 13753.
- C.E. 25 juin 1969, Vinent, Rec., 334.

(٣) راجع: د. عبد الله حنفي، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٥.

(٤) محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم ٤٨٥، لسنة ٧٧، الصادر في ١٩٥٧/١/٢٧.

(٥) المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ١١٠، لسنة ١٣ ق، الصادر في ١٩٧٧/١٢/٣٠، مجموعة المكتب الفني، ص ٢٧، سبق الإشارة إليه.



٢٨٣

الفصل الثاني الاختصاص غير القضائي بتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية

الي جانب القضاء الإداري توجد وسائل أخرى لحسم المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والمتعاقد معها، يطلق عليها الفقه « الطرق البديلة للقضاء في فض المنازعات الإدارية »، وهذه الوسائل متعددة، ولكن أهمها من الناحية العملية هي: المفاوضة والتوفيق والتحكيم. وفي إطار هذا الفصل سنحلل تلك الوسائل وذلك في مبحثين متتاليين، نعرض في الأول: المفاوضة والتوفيق كوسيلتين لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، علي أن نخصص الثاني: للحديث عن التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.

المبحث الأول المفاوضة والتوفيق كوسيلتين لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية

أولاً: المفاوضة:

بصفة عامة التفاوض « *Négociation* » يعني التشاور والتحاور بين طرفين أو أكثر للوصول إلي اتفاق نهائي، وبالتالي فهو يعني في مجال العقود الإدارية الحوار والنقاش^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} يتم بين الإدارة والمتعاقد معها^{٢٠٢٣/٢٠٢٤} لترتيب الحقوق والالتزامات التبادلية، وأيضاً^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} تسوية الخلافات والمنازعات الناشئة بينهما وإفراغ ما يتفقان عليه في صياغة قانونية محكمة في صورة عقد صلح^(١).

ويرتكز أسلوب التفاوض في مجال العقود الإدارية علي فكرة الرضائية، فعقود الإدارة عقود رضائية، لذلك فإن كل أمر فيها قابل للتفاوض. وتعد المفاوضة من أفضل الوسائل الودية لتسوية المنازعات بين الإدارة والمتعاقد معها، نظراً لما لها من مرونة فهي لا تعتمد علي وساطة أطراف خارجية لحل النزاع، بل تركز علي الاتصال المباشر بين طرفي النزاع لتسوية الموضوعات المتنازع عليها.

ثانياً: التوفيق:

التوفيق « *conciliation* » هو نظام بمقتضاه تقوم هيئة أو فرد، يتم اختيارهما من قبل الأطراف بمهمة دراسة موضوع الخلاف بالتشاور المستمر مع الأطراف والتعرف

(١) يعد الصلح كذلك من الطرق البديلة للقضاء في فض المنازعات الإدارية، وهو: "عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً مستقبلاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه". انظر: المادة ٥٤٩ من القانون المدني المصري.





(١) انظر: محكمة النقض، في الطعن رقم ٣٦٢، لسنة ٢٣ ق، الصادر بتاريخ ١٩٥٧/٦/٢٠، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص ١١٧. وقد جاء ذلك بمناسبة وصف المحكمة لمهمة مكتب العمل وفقاً للقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ (الملغى)، وهو يقوم بالتوفيق والوساطة بين رب العمل وعماله.

عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها.....". ومؤدى ذلك النص أن لجان التوفيق لا تختص بنظر المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفاً فيها، وذلك صوناً لسرية البيانات الخاصة بها والتي تتعلق عادة بالأمن القومي^(١). وبذلك تخرج أيضاً العقود الإدارية التي تبرمها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما من نطاق اختصاص لجان التوفيق^(٢).

وبناء على تقدم فإن التوفيق في مجال العقود الإدارية يعتمد على تقريب وجهات النظر بين كل من الإدارة والمتعاقد معها عن طريق وساطة لجنة التوفيق (المختصة) في أمر مختلف فيه أو متنازع عليه، على أن هذا الإجراء الذي تقوم به تلك اللجنة يجب أن يتم بمساعدة الطرفين من أجل التوصل إلى حل تصالحي للنزاع أو تسوية ودية له، على أن تستثني من تلك الوسيلة منازعات العقود الإدارية المبرمة بين أشخاص القانون العام بعضها البعض، وكذلك التي تبرمها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أحد أجهزتهما.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) انظر: د. عمرو احمد حسبو، لجان التوفيق في المنازعات في ضوء أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، دار النهضة العربية، ٢٠٠١، ص ٢٠.

(٢) من الجدير بالذكر أنه أثناء مناقشة المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، ثار جدل بين أعضاء المجلس بسبب هذه المنازعات، حيث طالب أحد الأعضاء حذف هذا الاستثناء، وذلك نظراً لأن الكثير من الأفراد يتعاملون مع هذه الجهة في مسائل عديدة لا علاقة لها بالسرية التي تبرر هذا الاستثناء، فأى شركة خاصة تقوم بعمل إنشاءات للقوات المسلحة، فإنها تلزمه بتسليمها بشكل طبيعي، ولكن من الممكن أن يتمتع المهندس المسئول عن استلام المنشأة، وهنا يظل المتعاقد لمدة سنة أو أكثر دون أن يتسلم مستحقاته، فما هو الحل؟. بينما طالب نائب آخر بالترقية بين أمرين: أولهما: أنه إذا كانت المنازعة تمس الجانب الأمني أو التسليحي أو أي أمر يتطلب السرية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، فمثل هذه المنازعات لا تعرض على لجان فض المنازعات وذلك من أجل حماية الأمن في الدولة. وثانيهما: أنه إذا كانت المنازعة لا تمس الجانبين الأمني والتسليحي، لأن هناك الكثير من المنازعات لا علاقة لها بالسرية، مثل المنازعات المتعلقة بالتسويات والمعاشات الخاصة بالمدينين العاملين بوزارة الدفاع، وأخطاء أفراد القوات المسلحة التي قد تحدث للغير وتستوجب المسؤولية كما لو صدمت إحدى سيارات القوات المسلحة شخصاً في الطريق. كما طالب نائب ثالث إلى إدماج المادة الرابعة في المادة الحادية عشرة لتعلقهما بالمنازعات المستثناة من اختصاص اللجان، وانتهت المناقشات التي رفض كل هذه الاقتراحات. راجع مضبوطة، مجلس الشعب بشأن مناقشة مشروع القانون، مضبوطة الجلسة ٥١، الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي، الخامس مارس ٢٠٠٠.



المبحث الثاني التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية

ينبغي قبل الحديث عن التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية، بيان فكرة عامة عن التحكيم. لذلك نقسم هذا المبحث الي المطلبين التاليين:
المطلب الأول: التحكيم بصفة عامة.

المطلب الثاني: التحكيم في العقود الإدارية.

المطلب الأول

التحكيم بصفة عامة

في هذا المطلب نتعرف علي ماهية التحكيم وأنواعه «الفرع الاول»، والمبررات الداعية للجوء إليه «الفرع الثاني»، وذلك علي النحو التالي:

الفرع الأول

ماهية التحكيم وأنواعه

أولاً: ماهية التحكيم « L'arbitrage » :

تعددت التعريفات الفقهية للتحكيم^(١)، وذلك وفقاً للزاوية التي ينظر منها كل فقيه،
وإن كانت كلها تدور حول مضمونه وتبين ملامحه الأساسية.

ففي الفقه المقارن يعرف رأي فقهي التحكيم بأنه: «إحالة النزاع أو الخلاف القائم بين شخصين علي الأقل من اجل حسمه بعد سماع المتنازعين بطريقة قضائية، وذلك بواسطة شخص أو أشخاص ليسوا من قضاة محاكم الدولة»^(٢).

(١) لغة اصل كلمة التحكيم مأخوذ من مصدر الفعل "حكم" أي قضى. ففي معجم لسان العرب: بالأمر يَحْكُمُ حُكْمًا وَحُكُومَةً قضى. يقال حَكَمَ لَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ. ويقال كذلك حكم بينهم إذا قضى وفصل. وقد جمع الثلاثة قول الحريري:

فهذه قصتي وقصته فاحكم علينا وبيننا ولنا

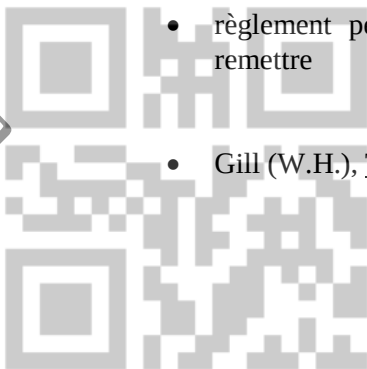
وفي المعجم الوسيط:ويقال: حَكَمَ فلاناً عما يريد. وفلاناً في الشيء والأمر: جعله حكماً فَوَّضَ إليه الحكم فيه. ففي التنزيل العزيز: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ » .

وكلمة التحكيم « L'arbirtage » في اللغة الفرنسية أيضا من فعل حكم « fonction d'arbitre » من الأصل اللاتيني لكلمة « Arbitrare ».

- règlement per une personne auquel les parties ont décidé de s'en remettre

انظر في ذلك: الانترنت، موقع صخر للمعاجم: <http://lexicons.sakhr.com>.
(٢) انظر:

- Gill (W.H.), The law of arbitration, 2nd edition, p.1:



ويذهب رأي فقهي آخر إلى تعريفه بأنه: « إنشاء قضاء خاص بواسطته يتم سحب المنازعات من القضاء العام، بغرض حسمها بواسطة أشخاص، يتمتعون بسلطة القضاء وذلك حالة معينة»^(١).

بينما يرى رأي فقهي ثالث أن التحكيم: « عبارة عن إجراء يتفق بمقتضاه أطراف نزاع معين علي إخضاع خلافاتهم لمحكم يختارونه ويحددون سلطاته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول الحكم الذي يصدره ويعتبرونه ملزماً»^(٢).

وفي الفقه المصري، يرى رأي فقهي أن التحكيم: « نظاماً قضائياً تُقضي فيه خصومة معينة عن القضاء العادي ويعهد فيها إلى محكمين للفصل فيها»^(٣).

ويذهب رأي فقهي ثان إلى تعريف التحكيم بأنه: « الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به»^(٤).

بينما يذهب رأي فقهي ثالث إلى تعريف التحكيم بأنه: « الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة، وذلك بحكم ملزم للخصوم شريطة أن يقر المشرع هذا الاتفاق شرطاً كان أم مشاركة»^(٥).

وقد أدلت المحكمة الإدارية العليا بدلوها في هذا المضمار فعرفت في حكمها الصادر بتاريخ ١٨ يناير سنة ١٩٩٤ التحكيم بأنه: « اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة»^(٦).

2024/2025

“An arbitration is the reference of a dispute or difference between not less than two persons for determination after hearing both sides in a judicial manner by another person or persons, other than a court of competent jurisdiction”.

(١) انظر:

- Jean Robert, Arbitrage civil et commercial, en droit interne et internationale privé, 2^{ème} édition, Dqlloz , Paris, 1967, p.1.

(٢) انظر:

- (J.M.) AUBY, " L'arbitrage en matière administrative ", A.J.D.A. 1955, I, p.81.

(٣) انظر: د. محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية ١٩٩٧، ص ١٣.

(٤) انظر: د. احمد ابو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٧٤، ص ١٥.

(٥) انظر: د. عصمت عبد الله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص ٢١.

(٦) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٨٨٦، لسنة ٣٠ ق، الصادر بتاريخ ١٨/١/١٩٩٤.

ويقترب مما تقدم ما ذهبت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيث عرفته بأنه: «الاتفاق علي عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة به، وذلك بحكم ملزم للخصوم»^(١).

وفي هذا الصدد أيضا تقرر المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر بتاريخ ١٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤ أن: «التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي محكم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتقويض منهما، أو علي ضوء شروط يحددها، لفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية»^(٢).

وعلي ذلك فإن التحكيم . بصفة عامة . هو أسلوب لفض النزاع ملزم لأطرافه، يقوم علي حرية اختيار الخصوم بإرادتهم فردا أو أفرادا عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور من نزاع^(٣). ولكن إرادة أطراف النزاع ليست كافية بمفردها لتبرر اللجوء إلى نظام التحكيم، ذلك ان الأمر يتطلب التدخل من المشرع للنص بداءة علي جواز ذلك التحكيم، ويحدد نطاقه أي المسائل التي يجوز فيها التحكيم وتلك التي تعتبر مناطق محرمة لا يرتادها، كما يبين كيفية تنفيذ أحكام المحكمين وكيفية الطعن عليها^(٤).

بعد التحكيم بهذا المعني من الماد ٢٠٢٤/٢٠٢٤ البديلة عن نظام التقاضي أمام المحاكم 2024/2023

فاتفاق أطراف النزاع علي اللجوء إلى أسلوب التحكيم لفض هذا النزاع، هو في حقيقته سلب لاختصاص قضاء الدولة، الذي كان يجب عرض النزاع عليه لو لم يتم الاتفاق علي التحكيم.

ثانيا: أنواع التحكيم:

يتخذ اتفاق التحكيم احدي صورتين، فهو قد يرد ضمن العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية فيتفق طرفا العقد علي ان ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يتم البت فيه عن طريق التحكيم. ويسمي هذا الاتفاق «بشرط التحكيم». وقد لا يتفق

(١) الفتوى رقم ٦٦١ في ١٩٨٩/٧/١، الصادرة بجلسة ١٧/٥/١٩٨٩، ص ١٣٨، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاما.

(٢) المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم ١٣، لسنة ١٥/١٢/١٩٩٤. الصادر بتاريخ ١٧/١٢/١٩٩٤.

(٣) انظر: د. جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ١٩٩٧، ص ٩.

(٤) انظر: د. احمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، ١٩٧٨، الطبعة الثالثة، ص ١٦.

الطرفان علي التحكيم في العقد الأصلي، ولكن بعد قيام النزاع بينهما يبرمان اتفاقا خاصا للفصل في النزاع الذي نشب بأسلوب التحكيم. ويطلق علي هذا الاتفاق « وثيقة أو مشاركة التحكيم ».

ويمكن تقسيم التحكيم عدة أنواع بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها:

- فمن زاوية عناصر العلاقة موضوع المتنازعة المراد حلها، يمكن تقسيم التحكيم إلي تحكيم وطني وتحكيم ذو طابع أجنبي أو دولي. ويعد التحكيم وطنيا متى كانت العناصر الرئيسية للعلاقة محل التحكيم وطنية، ولا يغير من هذا الأمر وجود عنصر أجنبي متى كان هذا العنصر غير مؤثر. بينما يكون التحكيم دوليا، متى كان أحد العناصر الرئيسية للعلاقة محل التحكيم أجنبيا.
- ومن زاوية مكان التحكيم يمكن تقسيمه إلي تحكيم داخلي وتحكيم خارجي.
- ومن زاوية موضوع النزاع الذي يفصل فيه، فقد يكون التحكيم مدنيا، تجاريا أو إداريا. ويعد التحكيم إداريا متى تعلق بمنازعة أحد طرفيها علي الأقل جهة إدارية تتصرف بوصفها سلطة عامة.
- ومن زاوية مدي حرية أطراف النزاع في اللجوء إلي التحكيم لتسوية نزاعاتهم، يمكن تقسيمه إلي تحكيم اختياري، وفيه تكون إرادة الأطراف حرة في اختيار اللجوء إلي هذا الطريق من عدمه، وهذا هو الأصل في التحكيم وهو الغالب. أما إذا كان 2024/2025 الأطراف ملزمين باللجوء للتحكيم وذلك بمقتضي نص قانوني أو اتفاقي يفرض عليهم سلوك هذا الطريق، ففي هذه الحالة يكون التحكيم إجباريا.

الفرع الثاني

مبررات اللجوء للتحكيم

هناك العديد من الأسباب والمبررات التي تدعو إلي لجوء الأطراف المتنازعة إلي التحكيم لتسوية نزاعاتهم بديلاً عن اللجوء إلي القضاء المختص، وذلك نظرا للمزايا والفوائد العديدة التي يحققها التحكيم، والتي تتمثل في^(١):

أولاً: البساطة والسهولة والمرونة والسرعة في إجراءاته:

يتميز التحكيم ببساطة وسهولة اللجوء إليه مقارنةً باللجوء للقضاء، فإجراءات اللجوء إلي التحكيم بسيطة ولا تتطوي علي التعقيد الذي تتطوي عليه الإجراءات القضائية. كما أن

(١) انظر فيما يتعلق بمبررات اللجوء للتحكيم: د. جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٢. د. عصمت عبد الله الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص ٤١ وما بعدها. د. انس جعفر، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩١.

التحكيم يتميز بقدر كبير في المرونة في نظر المنازعات المعروضة عليه، فعلي سبيل المثال في مجال المنازعات التجارية، يستطيع القيام بعمل مواعيد وتوقيعات من خلال القوانين والعادات التجارية السائدة. كما تبدو المرونة جلية وظاهرة وذلك من خلال تحديد مواعيد عقد جلسات التحكيم، حيث تتم عادة في أوقات مناسبة لظروف أطراف النزاع. ومن مزايا التحكيم أيضا السرعة في نظر المنازعات، وذلك نظراً لتقيد المحكمين بمدة معينة يلتزمون فيها بإصدار حكمهم خلالها. وذلك علي خلاف القضاء الرسمي الذي لا يلتزم بمدد معينة لإصدار أحكامه، غالبا ما يرتبط ذلك بعدد المنازعات أو القضايا المعروضة عليه، والملاحظ في هذا الصدد زيادة أعداد الدعاوي والقضايا زيادة مفرطة أمام القضاء، مع قلة أعداد القضاة في ذات الوقت مما يؤدي إلي تأخير الفصل في تلك المنازعات لسنوات طويلة^(١).

ثانياً: المحافظة علي أسرار أطراف النزاع:

من المبادئ العامة التي يركز عليها القضاء الرسمي في الدولة هو مبدأ علانية الجلسات ما لم تقرر المحكمة سريتها لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب، وتعد علانية الجلسات ضماناً من الضمانات القانونية لضمان حيده ونزاهة وموضوعية القضاء، وتسهيل رقابة الرأي العام علي حسن أداء مرفق القضاء. قد أكد علي هذا المبدأ الدستور المصري 2024/2025 الحالي الصادر في سنة ١٩٧١، في مادته ١٦٩ حيث ينص علي أن: « جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».

غير انه في كثير من الحالات قد تضر هذه العلانية بأطراف النزاع، ففي العلاقات التجارية من الخير لأطراف النزاع الاحتفاظ بسرية الاتفاقات المبرمة بينهما بدلا من نشرها أمام جميع المنافسين لهم في سوق العمل التجاري، لأن ذلك بلا شك سيمثل ضرراً للطرفين. وكذلك في المعاملات الدولية، مثل الصفقات السرية لشراء الأسلحة التي تبرم بين احدي الدول ومصنع من مصانع الأسلحة، ففي حالة نشوء نزاع بين طرفي تلك الصفقة، وتم عرض النزاع بشكل علني فمما لاشك فيه أن ذلك قد يمثل ضرراً لتلك الدولة، خاصة إذا

(١) ففي العام ٢٠٠٣ بلغ عدد القضايا المعروضة علي القضاء العادي ١٥٦٩٦٨٦ قضية جنائي، مدني، وأحوال شخصية، وأكثر من مليوني قضية أمام القضاء الإداري. في حين بلغ عدد القضاة ١٣٩٤ قاض بمجلس الدولة، و ٩٣٤٦ قاض عادي. راجع في ذلك: تقرير الإحصاء القضائي السنوي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ قضايا، تصدره إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل. الإدارة العامة لمركز المعلومات ص ١٠، ٢، ٢٧٠، ٢٧٠. مشار اليه لدي: د. عيسى غازي عبد الحليم عيسى، فلسفة لجان التوفيق في المنازعات الادارية وأهدافها، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، ٢٠٠٧، ص ٣٩.

كانت في حالة عدااء مع دولة أخرى. وبناء على ذلك فإن السرية التي تتميز بها إجراءات التحكيم تساعد بلا شك على المحافظة على أسرار أطراف النزاع، كما يؤدي إلى استمرار العلاقات الطيبة فيما بينهم.

ثالثاً: توفير الثقة والطمأنينة والخبرة والتخصص:

نظراً لاختيار المحكمين بواسطة أطراف النزاع أنفسهم، لذلك فهم عادة يكونون محل ثقتهم، كما أن المحكمين أشخاص تتوافر فيهم الخبرة والتخصص والعلم، ليس من الناحية القانونية فقط كالقضاة، ولكن من الناحية القانونية والفنية والعملية وذلك حسب طبيعة موضوع المنازعة، حيث نجد من يقوم بالتحكيم طوائف متعددة، كالمستشارين، الخبراء المتخصصون في الاقتصاد أو التجارة أو الاستثمار، أو في الصناعة أو الزراعة، أو العلاقات الدولية، البترول.....الخ.

وذلك يؤدي بلا أدنى شك إلى سرعة الفصل في النزاع نظراً لتوافر صفة الخبرة والتخصص لدى المحكمين مما يمكنهم من فهم الموضوع في وقت قصير، وعدم إضاعة الوقت في فهم الجوانب الفنية أو استشارة خبراء.

رابعاً: تشجيع الاستثمار في مختلف الدول:

يعد التحكيم من أهم الوسائل التي تساعد على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدول التي تسعى لجذب الأموال الأجنبية للاستثمار على أرضها. لأن المستثمر الأجنبي يفضل عادة أسلوب التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات لأنه يتوجس خيفة من انحياز القضاء الوطني لدولته ويرى في التحكيم وسيلة محايدة تدعو إلى الطمأنينة. ولعل أكثر العقود الإدارية في دول العام الثالث أخذاً بأسلوب التحكيم كوسيلة لفض المنازعات هي عقود البوت B.O.T.

ولقد استقرت أحكام هيئات التحكيم الدولية على أن الدولة التي تقبل بشرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع أطراف أجنبية لا يمكنها التمسك بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم لأن الدولة بقبولها هذا الشرط تكون قد تنازلت عن حصانتها ومن ثم فإنه لا يمكن بعد قبول شرط التحكيم وعند بدء إجراءاته أن تدفع الدولة ببرد دعوى التحكيم استناداً إلى حصانتها القضائية لأن هذا يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية، وهو من المبادئ المستقرة في المعاملات الدولية، يضاف إلى ذلك أن محاولة التحلل من شرط التحكيم بعد الاتفاق عليه في العقد المبرم مع طرف أجنبي بذريعة الحصانة القضائية من

شأنه أن يهز ثقة المتعاملين مع الإدارة ويجعل المستثمرين الأجانب يمتنعون عن الاستثمار في الدولة التي لا تحترم تعهداتها.

ونظرا لأن الدولة تستطيع إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، فقد استقرت قاعدة في الفقه والقضاء الدوليين مفادها أن شرط التحكيم يبقى ساريا وناظرا بعد إنهاء الدولة للعقد بإرادتها المنفردة. وقد أكدت هذه القاعدة اتفاقية واشنطن المبرمة سنة ١٩٦٥ والخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ورعايا الدول الأخرى، حيث نصت المادة ٢٥ منها على أنه إذا اتفق الأطراف على التحكيم فلا يجوز لأي طرف أن يسحب موافقته منفردا، يضاف إلى ذلك أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨٠٣ وتاريخ ١٩٦٢/١٢/٢١، نص على أنه مع التسليم بالسيادة الدائمة للشعوب والأمم على مواردها الطبيعية فإنه يجب التأكيد على التزام الدول باحترام اتفاقيات التحكيم.

ولما كان شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد ملزماً لطرفيه، فإنه من الأفضل للجهة الإدارية ألا تلتزم مسبقاً بهذا الالتزام وإنما تترك موضوع الاتفاق على التحكيم إلى المستقبل أي بعد نشوب النزاع، فإن قدرت حينئذ أن المصلحة العامة تستوجب اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع أبرمت مع الطرف المتعاقد اتفاقاً مستقلاً بشأن التحكيم، وهو ما يسمى في المصطلح القانوني كما ذكرنا سابقاً باسم «مشارطة التحكيم»^(١).

2024/2025

المطلب الثاني

التحكيم في العقود الإدارية

فيما يتعلق بالتحكيم في العقود الإدارية في مصر^(٢)، فلقد أدى غياب النص التشريعي المنظم لهذا التحكيم إلى اختلاف الفقه وتباين أحكام القضاء وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك فيما يتعلق بجواز أو عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية^(٣).

(١) انظر: صحيفة الاقتصادية الإلكترونية، الخميس، ١٣ رمضان ١٤٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/١٠/٠٥ م - العدد ٤٧٤٢.

(٢) في فرنسا يتجه الفقه بإجماع على أنه لا يجوز لأشخاص القانون العام الالتجاء إلى التحكيم إلا إذا أجاز ذلك نص تشريعي صريح. راجع في ذلك: م. حمدي ياسين عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٠.

(٣) راجع فيما يتعلق بالخلاف الفقهي والقضائي حول مدي جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو عدم جوازه قبل صدور القانون ٧ لسنة ١٩٩٧: د. انس جعفر، المرجع السابق، ص ٢٥٤ وما بعدها. انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧١ وما بعدها. د. عبد الله حنفي، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٣ وما بعدها. م. حمدي ياسين عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٨ وما بعدها. د. جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٥٦ وما بعدها.

وعندما صدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ نص في مادته الأولى علي انه: « مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام او القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، او كان تحكيميا تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه علي إخضاعه لأحكام هذا القانون ». وبالرغم من وضوح هذه المادة ، فهي تقضي صراحة بجواز التحكيم سواء إذا كان الأطراف من أشخاص القانون العام او الخاص وأيا كانت العلاقة القانونية محل النزاع. إلا إنها لم تنه الخلاف المحتدم حول جواز أو عدم جواز التحكيم في شأن منازعات العقود الإدارية.

لذلك اصدر المشرع القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ معدلا به بعض أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، حيث أضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الأولى. وتقضي هذه الفقرة علي انه: « وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق علي التحكيم بموافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ». وبذلك حسم المشرع الجدل الفقهي حول مدي جواز أو عدم جواز

2024/2025

التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية 2024/2025

ولم يكتفي المشرع بذلك، بل انه عند صدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ، ضمنه المادة رقم ٤٢ والتي تنص علي انه: « يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق علي تسويته عن طريق التحكيم ... ».

وعندما اصدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ضمنه ايضا المادة ٩١ والتي تنص علي: «يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد» .

وبناء علي ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ندرس في الأول التحكيم

في العقود الإدارية في ظل القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ المعدل للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ونتعرف في الثاني علي إمكانية التحكيم في العقود الإدارية في ظل القانون المنظم

للمناقصات والمزايدات الحالي رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وأخيراً نبين الطبيعة القانونية للتحكيم في العقود الإدارية في الفرع الثالث، وذلك علي النحو التالي:

الفرع الأول: التحكيم في العقود الإدارية في ظل القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ المعدل

لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

الفرع الثاني: التحكيم في العقود الإدارية في ظل قانون تنظيم التعاقدات التي

تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

الفرع الثالث: طبيعة التحكيم في العقود الإدارية.

الفرع الأول

التحكيم في العقود الإدارية

في ظل القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧

أولاً: النطاق الموضوعي لتطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧:

أصدر المشرع في ٣١ مايو ١٩٩٧ القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧^(١) معدلاً به المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، حيث أضاف إليها فقرة ثانية^(٢). وتقضي هذه الفقرة

2024/2025

(١) ~~المرجع المذكور~~ الجريدة الرسمية ، العدد ٢٠، تلعب ، في ٢٠٢٥/٢٠٢٤

(٢) ومبررات صدور هذا القانون، كما جاءت بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التعديل، هي: «... كانت المواد من ٥٠١ أي ٥١٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، قبل إلغائها بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، تنظم أحكام وإجراءات الفصل في المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، وفي ظل العمل بتلك المواد اختلف الرأي في القضاء والإفتاء حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، حيث صدرت احكام من القضاء الإداري بعضها يقر صحة الاتفاق علي التحكيم في تلك المنازعات، بينما رفضت احكام أخرى مثل هذا الاتفاق، وعلي صعيد الإفتاء أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في أكثر من رأي لها جواز الاتفاق علي اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية.

وعندما صدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، نص في مادته الأولى علي انه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع....". وكان المأمول من هذه العبارة الأخيرة أن تشكل سنداً لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون علي منازعات العقود الإدارية، بحيث يكون جائزاً قانوناً الاتفاق علي حسم هذه المنازعة بطريق التحكيم، خاصة وأن الأعمال التحضيرية لذلك القانون تكشف عن هذا المعني وتشهد عليه.

بيد أن الخلاف في هذا الشأن ظل قائماً، وما انفك كذلك بعد العمل بالقانون المشار إليه، حيث ارتأى إفتاء حديث أن هذا القانون لا يتيح الاتفاق علي التحكيم في العقود الإدارية، بينما صدر قضاء عن محكمة استئناف بغير ذلك وعلي خلافه. ورغبة في حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقي عنده وتستقر كل الاجتهادات، وبالنظر إلى ان العلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي قد اتسعت و تشعبت مع مراحل النمو والإصلاح التي تخطوها البلاد، وتتعاظم مسيرتها حيناً بعد حين، وتشارك الدول وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في قيام تلك العلاقات بالقدر اللازم لتشجيع



علي أنه: «وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق علي التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك».

بناء علي ذلك فإن المشرع المصري لم يحدد نطاقا موضوعيا في تطبيقه، فلم يستثني مثلا عقوداً معينة يخصصها بجواز التحكيم أو يستبعد بعض العقود الهامة من نطاق هذا التحكيم. ولذلك يمكننا أن نقرر أن النطاق الموضوعي لهذا القانون يشمل^(١):

١. جميع منازعات العقود الإدارية سواء حدثت في مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه أو ما ترتب عليه من آثار.

٢. كافة العقود الإدارية سواء كانت عقوداً إدارية وطنية أو ذات صفة أو طابع دولي.

هذا ونؤكد أن مسلك المشرع المصري في القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ من جواز التحكيم في العقود الإدارية دون أن يحدد الضوابط الموضوعية لتطبيقه أمر قد يؤدي إلى إهدار للمصالح العليا للدولة.

فإذا كانت منازعات العقود الإدارية الوطنية - بالمقارنة لمنازعات العقود الإدارية

ذات الصفة الدولية - قد لا تشكل خطراً علي مصالح الدولة العليا، نظراً لأن المحكمون في 2024/2025

هذه المنازعات مصريون ويطبقون القانون المصري للفصل في النزاع، فإن الوضع عكسي في منازعات العقود الإدارية ذات الصلة الدولية، لأنه في معظم المنازعات يكون المحكمين من الأجانب والقانون المطبق علي النزاع هو قانوناً أجنبياً. وهذا أمر بطبيعة الحال يسبب ضرراً بمصالح الدولة العليا وسيادتها، بل ويشكل خطراً كبيراً لا سيما عندما تتعلق هذه العقود باستغلال الثروات الطبيعية أو العقود التي تمس الأمن القومي.

الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها، بما في إبرام عقود إدارية وثيقة الصلة بالمرافق العامة مع أطراف محلية وأجنبية. وإذا كان الالتجاء إلى التحكيم اتفاقاً، لتسوية منازعات هذه العقود، مما يندب إليه، وتستمسك به تلك الأطراف في حالات عديدة، كسباً لمزايا هذا الأسلوب في التسوية وخاصة لحل قضايا ومنازعات التجارة والاستثمار علي الصعيدين الوطني والدولي.

لهذا رؤى إدخال تعديل بالإضافة علي المادة (١) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالف الذكر يقرر صراحة جواز الاتفاق علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ويحدد السلطة الإدارية التي يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، وضبطاً لاستعمالها وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبار الصالح العام، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة، وبحيث لا يجوز لأي منهما التفويض في هذا الخصوص". راجع في ذلك مضبطة مجلس الشعب، الجلسة الستين، في ١٩٩٧/٤/٢٣.

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٩٣. د. عصمت عبد الله الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٥.



لذلك فإنني اقترح لضمان لحماية حقوق الدولة المصرية والمحافظة على الخصائص الذاتية للعقود الإدارية وما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطات وامتيازات في مواجهة المتعاقد معها، يتعين . قبل الالتزام بشرط التحكيم . تضمنين هذه العقود الشروط التي تتفق مع نظرية العقد الإداري. ولضمان تجنب الجهة الإدارية احتمال أن تطبق هيئة التحكيم على العقد أحكام قانون أجنبي فإنه يتعين أن ينص بشكل واضح وصريح في العقد بأنه يخضع في تنفيذه وتفسيره لقانون الدولة المصرية وأنه لا يجوز تطبيق أي قانون أجنبي، لأن كثيراً من الأضرار التي أصابت دول العالم الثالث جراء أحكام التحكيم الدولي الصادرة في منازعات العقود، كان يرجع أحيانا إلى عدم عناية تلك الدول بصياغة شرط القانون الواجب التطبيق على العقد عناية كافية فتفاجأ الدولة المعنية باستبعاد قانونها وتطبيق قانون أجنبي على المنازعة. وتأكيداً لوجوب تطبيق القانون الوطني على العقد فإنه ينبغي أن ينص في العقد أنه إذا لم تحترم هيئة التحكيم القانون المختار من قبل طرفي العقد فإن حكمها يعتبر باطلاً ولا أثر له^(١).

ثانياً: النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ :

فيما يتعلق بالنطاق الزمني لتطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧، تنص المادة الثانية منه على أنه: « ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ». فمن مقتضى هذا النص، ان التعديل الذي استحدثه هذا القانون بخضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم يطبق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فليس له اثر رجعي، حيث لم ينص القانون علي هذا الأثر.

ومن نافلة القول انه أثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثيرت مسألة سريان القانون بأثر رجعي، وتساءل أحد الأعضاء قائلاً: « هل هذا تعديل أم تفسير؟ فقد قلنا هنا بمجرد نشره فهل هذا تعديل أم تفسير حتى يسري بأثر رجعي من تاريخ بدء

(١) من الجدير بالذكر ان الدول العربية، وفي مقدمتها مصر أصبحت تسرف في استخدام التحكيم كوسيلة لفض نزاعاتها، فقد ورد في إحدى الدراسات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس فيما يتعلق بتحكيم الأطراف العربية، انه في عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٦ مثلت الأطراف العربية ما يقرب من ١٤% من عملاتها من أصل ٣٠% قدمها العالم الثالث (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية)، كما بلغ إجمالي القضايا المصرية المرفوعة أمام تلك الغرفة في الفترة من سنة ١٩٨١ إلى سنة ١٩٩٠ الي ١٤٣ قضية تقف في ٤٢ منها مركز المدعي، في حين تقف في ١٠١ منها في مركز المدعي عليه. كما توجد لمصر ٢٦ قضية أخرى أمام البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالإضافة الي ٣٢ قضية أمام مركز القاهرة للتحكيم الإقليمي لتصل مقدار الأموال المتنازع عليها مليار دولار علي اقل. راجع: د: ناريمن عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ١٩٩٦، ص ١٠٧.

القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، أم أن التنفيذ يحل من وقت نشره؟. فرد مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية قائلاً، أن هذا تعديل وليس تفسير. وهنا تدخل السيد رئيس المجلس بقوله: « هذا التعديل يعتبر منطوياً علي أمرين، الأمر الأول تأكيد للمبدأ الذي قرره التشريع السابق من أن التحكيم جائز في العقود الإدارية لأن النص جاء مطلقاً ولا تخصيص بغير مخصص. والأمر الثاني، يعتبر تعديلاً لأنه حدد الجهة المختصة التي تجري الموافقة الإدارية..... »^(١).

ثالثاً: شروط تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧:

يجب أن يتوافر شرطان لإمكان اللجوء الي التحكيم في مجال منازعات العقود الإدارية وفقاً للقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧:

الشرط الأول: موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة للأشخاص للاعتبارية العامة.

وبمقتضى هذا الشرط لا يجوز لأي جهة حكومية أن تضمن العقد شرطاً او مشارطته تحكيم إلا بموافقة الوزير المختص او من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة^(٢)، وقد بررت المذكرة الإيضاحية للقانون هذا الشرط بأن في ذلك ضبطاً لاستعمال هذه الموافقة وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتباريات الصالح العام، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة.

ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ لم يبين الجزاء الواجب التطبيق حال إبرام الإدارة لعقد إداري وتضمينه لشرط التحكيم دون الحصول علي الموافقة السابقة من الوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة أو في حالة موافقة شخص آخر غيره. لذلك ذهب رأي فقهي إلى أن مسلك الإدارة السابق يمثل خطأً مرفقياً في جانبها وبالتالي يترتب مسئوليتها عن الخطأ الذي ارتكبه ممثلها في حمل المتعاقد معها علي الاعتقاد بحسن نية انه تم اللجوء للتحكيم بعد استيفاء الشروط التي تطلبها المشرع لذلك، ومنها الموافقة السابقة علي التحكيم^(٣). لذلك وفقاً لهذا الرأي شرط التحكيم المفتقد

(١) انظر: مضبطة مجلس الشعب، الفصل التشريعي السابع، دور الانعقاد العادي، الجلسة الستين، ١٩٩٧/٤/٢٣، ص ١٧.

(٢) انظر: د. جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٦.

(٣) انظر: د. حمدي علي عمر، التحكيم في عقود الإدارة، دار النهضة العربية، ١٩٩٧، ص ٣٩.

للموافقة السابقة عليه يترتب مسئولية الجهة الإدارية وبالتالي تعويض المتعاقد معها عما أصابه من أضرار تتمثل في عدم إمكانية لجوئه للتحكيم لتسوية النزاع الناشئ عن العقد.

غير ان التعويض إذا كان يقدم حلاً مناسباً في منازعات العقود الإدارية الداخلية، فإنه يعجز عن إيجاد الحل الملائم بالنسبة للعقود الإدارية ذات الصلة الدولية، حيث انه من الثابت انه لا يجوز للإدارة التنصل من اتفاق التحكيم بحجة عدم حصولها علي الموافقة عليه، وذلك لأنه يتنافي مع النظام العام الدولي، والذي لا تقتصر وظيفته علي حماية المصلحة العامة للمجتمع الدولي فحسب، وإنما يدخل في الحساب ضرورة أخرى هامة وهي حماية التضامن الدولي، والذي يتطلب من كل دولة من دول العالم أن تسهم في العمل علي تنشيط العلاقات الخاصة بين الشعوب لتتقارب وتتفاهم فيعم السلام، ونظراً لأن التجارة الدولية تعد من أهم مجالات تبادل الثروات، يجب علي كل دولة أن تعمل علي تيسيرها وتنشيطها بإزالة كل ما يعترض طريقها من عقبات، ولو تطلب الأمر شيئاً من التضحية^(١).

وبناء علي ما تقدم يمكننا أن نقرر ان تخلف موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على التحكيم في عقد إداري يحول دون تسوية النزاعات الناشئة عن هذا العقد بطريق التحكيم، ويسري ذات الحكم علي اتفاق التحكيم الصادر بعد موافقة غير المختص، كما إله وافق عليه غير الوزير المختص أو من يقوم 2024/2025 2024/2025 مقامه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة. غير أن هذا الحكم يطبق فقط علي العقود الإدارية الداخلية أما العقود الإدارية ذات الصلة الدولية فلا مجال لتطبيقه عليها.

وتطبيقاً لذلك فقد عرضت علي مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي قضية تحكيمية^(٢)، تتلخص وقائعها في ابرام عقد مقاوله بين احدي الهيئات العامة المصرية وبين احدي الشركات المساهمة المصرية التي تعمل في مجال الإنشاءات، وقد تضمن هذا العقد شرطاً للتحكيم، يفيد هذا الشرط اختصاص مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالفصل في المنازعات بين الطرفين وأن يخضع التحكيم وإجراءاته للقانون المصري.

وبالفعل ثار نزاع بين طرفي هذا العقد حول تنفيذ بعض بنود عقد المقاوله المشار اليه، فأقامت شركة الإنشاءات «المحتكم» دعوى ضد الإدارة «المحتكم ضدها» أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي استنادا إلي شرط التحكيم الوارد بالعقد.

(١) انظر: د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، ١٩٩٧، ص ٤٧.

(٢) انظر: القضية التحكيمية رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠٠٤، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.



وفي أول جلسة من جلسات المرافعة الشفوية دفعت الإدارة «المحتكم ضدها» بعدم قبول التحكيم شكلاً لبطلان اتفاق التحكيم، وذلك نظراً لعدم موافقة الوزير المختص وفقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٩. وأضافت الإدارة إنها طلبت موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم، إلا أنه رفض التحكيم.

ورأت هيئة التحكيم أن الدفع المبدي من الإدارة (المحتكم ضدها) هو في حقيقته دفع بعد الاختصاص الولائي لهيئة التحكيم، لذلك أصدرت حكماً بعد اختصاصها الولائي بنظر هذا التحكيم. وقد استندت في هذا الحكم إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٩، فأوضحت أن: « لما كان مؤدي هذا النص أن الاتفاق على التحكيم في المنازعات الإدارية يستلزم موافقة الوزير المختص على التحكيم، وتلك الموافقة تعد شرطاً لوجود هذا الاتفاق وصحته، فإن عدم صدورها من الوزير المختص يؤدي إلى عدم استجماع اتفاق التحكيم لشرائط صحته.

وحيث أن مستندات الدعوى قد خلت مما يثبت موافقة الوزير المختص الذي تتبعه الهيئة المحتكم ضدها على التحكيم، فإن اتفاق التحكيم الذي استندت إليه الشركة المحتكمة في اللجوء إلى التحكيم.....، يكون باطلاً ولا يجوز الارتكان عليه لطرح منازعات هذا العقد على التحكيم».

وعلى العكس من ذلك في قضية تحكيمية أخرى^(١)، عرضت على مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، تلخيص وقائعها في أن الهيئة العامة للطيران المدني أبرمت عقداً مع شركة انجليزية لإنشاء وإدارة واستغلال مطار في مدينة رأس سدر، وذلك وفقاً لنظام ال B.O.T. وقد تضمن العقد شرطاً للتحكيم طبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على أن يجري هذا التحكيم في القاهرة ويكون قانون التحكيم هو القانون المصري.

تبين فيما بعد للهيئة العامة للطيران المدني إنها قد تعرضت للغش من قبل الشركة الانجليزية حال تعاقدها، ويتعلق هذا الغش بالمقدرة المالية للشركة المذكورة حيث ذكرت أن رأسمالها يبلغ ١٠٠ مليون جنيه إسترليني الأمر الذي كان له أثر كبير في قبول التعاقد معها، ثم تبين بعد ذلك كذب هذا الادعاء وأن رأس مالها وقت التعاقد لم يكن يتعدى جنيهان إسترليني. لذلك قامت الهيئة العامة للطيران المدني بمصادرة التأمين وقامت بفسخ العقد.

(١) انظر: القضية التحكيمية رقم ٣٨٢ لسنة ٢٠٠٤، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

أقامت الشركة الانجليزية دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد الحكومة المصرية والهيئة العامة للطيران المدني، وطالبت بإلزامها بأن تسدد تعويضاً قدره ٥٠٨ مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ العقد المبرم معها.

دفع المحكم ضدهم في هذا التحكيم وهم الحكومة المصرية والهيئة العامة للطيران المدني بعدم اختصاص هيئة التحكيم استناداً إلى بطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد، وذلك لعدم موافقة الوزير المختص علي التحكيم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٩. والتي تستلزم موافقة الوزير المختص علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

عندما عرض الأمر علي هيئة التحكيم، قررت أن العقد موضوع النزاع يعد عقداً ذو طبيعة دولية، وذلك للأسباب التالية:

- وجود طرف أجنبي بالعقد وهي الشركة الانجليزية.
- موضوع العقد يتعلق بمطار دولي.
- التزمت الشركة بالعقد بأن يكون المطار مطابقاً للمواصفات الدولية التي

2024/2025

2024/2025

تقرضها اتفاقية وارسو. 2024/2025

- شرط التحكيم الوارد بالعقد يعد شرطاً دولياً وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

ولقد أضافت هيئة التحكيم ان تكيف العقد باعتباره دولياً يعني أن بعض جوانب العقد . لاسيما شرط التحكيم . تعد جزءاً من العلاقات القانونية الدولية وتخضع بالتالي لقواعد قانونية تخرج عن نطاق النظام القانوني المصري.

وأوضحت هيئة التحكيم انه إذا كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى هي . بلا شك . جزء من القانون الداخلي المصري الموضوعي والتحكيمي، فإن تطبيقها في مجال التحكيم التجاري الدولي مع مستثمر أجنبي يظل محل نظر، أية ذلك أن جمهورية مصر العربية قد اتبعت سياسة من شأنها تأمين وحماية الاستثمارات الأجنبية بها (علي سبيل المثال القانونين رقمي ٣،٨ لعام ١٩٩٧ واتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة وقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤) بحيث يظل الحق في التحكيم مكفولاً في الظروف العادية دون أن يهدر استناداً الي ان أحد كبار المسؤولين (رئيس سلطة الطيران المدني) لم

تتوافر لديها السلطة اللازمة للموافقة علي التحكيم، " فتلك النتيجة تكون مخالفة لمبدأ حسن النية (العقد شريعة المتعاقدين).

وتأسيسا علي ما سبق، انتهت هيئة التحكيم إلي اختصاصها بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العقد، باعتبار ان هذا العقد يعد عقدا إداريا وفقا للقانون الداخلي المصري، كم انه عقد دولي تعد مصر احد أطرافه ويخضع بالتالي للمبادئ التي تسري علي هذا العقد.

الشرط الثاني: لا يجوز للوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة أن يفوض غيره في ممارسة اختصاصه بالموافقة علي التحكيم في العقود الإدارية.

ويرجع عدم جواز تفويض الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة إلى أهمية العقود الإدارية والخطورة التي يشكلها شرط التحكيم بالنسبة لها، فهذا الشرط يمثل ضمانا لعدم إساءة استخدام التحكيم في العقود الإدارية نظرا لما يترتب عليه أحيانا - كما هو الحال للعقود الإدارية ذات الصلة الدولية - استبعاد القانون الوطني واللجوء إلى هيئة تحكيم عوضا عن اللجوء إلى قضاء الدولة المختص والذي يمثل الحماية لمصالح الدولة^(١).

2024/2025

2024/2025

الفرع الثاني

التحكيم في العقود الإدارية

في ظل القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

أكد المشرع المصري في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مبدأ جواز اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والذي سبق ونص عليه صراحة في القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ المعدل للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤. فقد نص قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في المادة ٩١ منه علي انه: « يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. كما

(١) انظر: د. جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٩. د. انس جعفر، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩١.

يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤».

ويتضح من هذا النص أن المشرع قد أجاز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في العقود الإدارية، وأضاف إلى الشرطين المتطلبين وفقاً للقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧، وهما موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى عدم التفويض في ذلك الاختصاص، شرطاً ثالثاً هو ضرورة التزام كل طرف من أطراف العقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.

وبالإضافة إلى الشروط السابقة التي تطلبها القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٧، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ هناك شرطاً آخر يجب استيفائه لكي يخضع العقد الإداري للتحكيم، وهو ما نصت عليه المادة ٥٨ فقرة ٣ من القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بقولها: « لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تحيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه 2024/2025 2024/2025».

ووفقاً لهذا النص يتعين على الوزارات والهيئات العامة والمصالح المختلفة أن تستفتي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عند إبرام عقد إداري يتضمن شرطاً أو مشارطة تحكيم إذا كانت قيمة هذا العقد تتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري. غير أنه بالرغم من التزام الملقى على عاتق الجهة الإدارية بأخذ هذا الرأي، إلا أن الأخير من قبيل الآراء الاستشارية، أي التي يكون بوسع الإدارة مخالفتها دون أن يوصم تصرفها بالبطلان. غير أنه يجب ألا يفهم أن رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن استشاري لا قيمة له وبالتالي يمكن للإدارة أن تتغاضى عن طلبه، حيث يؤدي هذا التغاضي بلا شك . إلى بطلان اتفاق أو مشارطة التحكيم.

الفرع الثالث

طبيعة التحكيم في العقود الإدارية

يعد التحكيم المنصوص عليه سواء في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ أو في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم

١٨٢ لسنة ٢٠١٨ هو تحكيمًا اختياريًا بمعنى انه يجب ان يتفق أطراف المنازعة علي اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما^(١).

هذا وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا مبدأ الاتفاق علي التحكيم باعتباره أمر جوازي ورفضت أن يكون التحكيم إجباريًا، وهذا واضح من حكمها الصادر بتاريخ ٦ نوفمبر ١٩٩٩، حيث قضت بأنه: « لا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريًا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما او محتملا، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق - إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه تترد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم، التزامهما بالنزول علي القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء فلا يجتمعان، ذلك ان مقتضاه عزل المحاكم جميعا عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها^(٢)».

2024/2025

2024/2025

وبذلك تقضي أيضا المحكمة الإدارية العليا، ففي الحكم الصادر عنها في ١٨ يناير ١٩٩٤ تقرر انه: «..... ومن حيث إنه من المبادئ الأساسية في العقود - ومنها عقد التحكيم - انه ينبغي ان تتطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم، ومن ثم فإن التحكيم يقتصر علي ما اتفق بصده من منازعات، وعلي ذلك فإنه إذا حصل الاتفاق في عقد علي عرض جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه أو تفسيره علي محكمين فإن هذا يشمل كل المنازعات التي تقع بين المتعاقدين - بشأن التنفيذ أو التفسير - سواء وقت قيام العقد او بعد انتهائه^(٣)».

(١) انظر: د. عمرو احمد حسبو، لجان التوفيق في المنازعات في ضوء احكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، دار النهضة العربية، ٢٠٠١، ص ٤٧.

(٢) انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم ٨٤، لسنة ١٩ ق دستورية، الصادر بتاريخ ١٩٩٩/١١/٦.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم ٨٨٦، لسنة ٣٠ ق، الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١/١٨.

٣٠٤

الباب الخامس نهاية العقد الإداري

قد تنتهي العقود الإدارية نهاية طبيعية وذلك بتنفيذ الالتزامات التي تتضمنها بالكامل أو بانقضاء المدة المحددة لسريانها، شأنها في ذلك شأن العقود المبرمة في نطاق القانون الخاص، ومن ثم تطبق علي النهاية الطبيعية للعقود الإدارية القواعد المنظمة لانتهاء العقود في القانون المدني.

غير أن العقود الإدارية يمكن أن تنتهي نهاية غير طبيعية قبل حلول أجلها الطبيعي، أي قبل تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها بالكامل أو قبل انقضاء المدة المحددة لسريانها. و يطلق الفقه علي هذه النهاية النهاية المبسرة للعقود الإدارية.

وعلي ذلك سنتناول في الفصل الأول من هذا الباب « نهاية العقود الإدارية نهاية طبيعية » باختصار نظرا لان ذلك يعد ترديدا للقواعد العامة المطبقة في القانون المدني. أما النهاية « غير الطبيعية » المبسرة " للعقود الإدارية فسوف نتناولها بشيء من التفصيل، وذلك في فصلين متتاليين علي النحو التالي:

الفصل الأول: النهاية الطبيعية للعقود الإدارية.

الفصل الثاني: النهاية غير الطبيعية " المبسرة " للعقود الإدارية.

2024/2025

الفصل الأول

انتهاء العقد الإداري نهاية طبيعية

تنتهي العقود الإدارية نهاية طبيعية عادية . شأنها شأن سائر العقود الأخرى . إما بانقضاء المدة المحددة للعقد أو بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد تنفيذاً كاملاً^(١). وعلي ذلك يمكن حصر أسباب انتهاء العقد الإداري نهاية طبيعية في الحالتين الآتيتين:

أولاً: تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد تنفيذا كاملاً:

ينتهي العقد الإداري إذا تم تنفيذ ما يربته من التزامات متبادلة بين أطرافه وهذا هو مصيره المألوف. فعقد الأشغال العامة مثلاً، ينقضي متي نفذ المقاول المتعاقد مع الإدارة

(١) انظر في ذلك:

- L. RICHER, Les contrats administratifs , DALLOZ, 1991, P.95.

" Le contrat se termine normalement par la survenance de son terme ou la réalisation de son objet..."

التزاماته وذلك بإتمام الأعمال المتعاقد علي إنجازها وأداء الإدارة الثمن كاملاً له. وينقضي عقد التوريد أيضاً في حالة تسليم المورد للبضائع المتفق عليها للإدارة وأداء الأخيرة لكامل الثمن المتفق عليه للمورد.

ثانياً: انقضاء المدة المحددة للعقد:

من العقود الإدارية بعض العقود التي يرتبط بقائها بمدة زمنية محددة. فعلي سبيل المثال، عقد التزام المرفق العام والذي يجب ألا تزيد مدته علي ثلاثين سنة^(١)، عقد الأشغال العامة المتعلق بصيانة عقار لمدة زمنية محددة، عقد التوريد المبرم لمدة محددة، عقود الإيجار.....الخ. في جميع الصور السابقة ينتهي العقد الإداري بنهاية المدة المحددة والمنصوص عليها فيه.

غير انه يجب التمييز في هذا المجال بين العقود الفورية التي لا تستغرق زمناً للتنفيذ والعقود الزمنية التي تستغرق زمناً طويلاً كعقد الالتزام وعقد الإيجار....الخ^(٢).

فالعقود الفورية: هي العقود التي لا يلعب عنصر الزمن فيها دوراً رئيسياً وتنتهي هذه العقود بمجرد تنفيذها من جانب الطرفين ولا تتولد عنها آثار تمتد عبر الزمن^(٣).

أما العقود الزمنية : فهي العقود التي يلعب الزمن فيها دوراً جوهرياً، وتنتهي هذه العقود بانتهاء المدة التي يحددها العقد. ما لم يتفق أطرافه علي تجديده.

2024/2025

واتفاق التجديد قد يكون صريحاً، كأن ينص العقد علي أن يجدد تلقائياً ما لم يبد أحد طرفيه رغبته في إنهاء العقد قبل نهايته بمدة محددة. وفي هذه الحالة يتجدد العقد تلقائياً وهو ما طبقته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١٦ مايو سنة ١٩٩٥ حيث قررت أن: « ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الهيئة الطاعنة تعاقدت مع المطعون ضده بموجب عقد مؤرخ ١٠/٧/١٩٧٩ علي عملية نقل وتفريغ الثلج وتضمن البند الثامن من هذا العقد بأن التعاقد سنة واحدة تبدأ من ١٠/٧/١٩٧٩ وتنتهي في ١٠/٧/١٩٨٠ ويتجدد العقد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما لم ينبه أحد الطرفين علي الآخر برغبته في إنهاء التعاقد قبل نهايته بشهر علي الأقل بكتاب موصى عليه. ومن حيث انه لما

(١) تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ علي انه: " لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد علي ثلاثين سنة ".

(٢) انظر في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سبق ذكره، ص ٦٩٦، د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود الإدارية، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٩٣.

(٣) انظر: د. انس جعفر، العقود الادارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٠٦.

كان مفاد البند الثامن من العقد مثار النزاع أن مدة التعاقد عام واحد يتجدد تلقائياً ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل نهايته بشهر علي الأقل بكتاب موصى عليه وكان الثابت أن مدة هذا العقد تبدأ من ١٩٧٩/٧/١٠ وتنتهي في ١٩٨٠/٧/٩ وقد خلت الأوراق من دليل يفيد قيام الهيئة الطاعنة بالتنبيه علي المطعون ضده برغبتها في إنهاء التعاقد في الميعاد الموضح بالبند الثامن من هذا العقد فمن ثم يعتبر العقد مجددا لعام آخر، يبدأ اعتباراً من ١٩٨٠/٧/١٠ وبهذه المثابة فإن قيام الهيئة الطاعنة بإنهاء العقد محل النزاع بدون مراعاة الميعاد المشار إليه يشكل ركن الخطأ في جانبها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية..»^(١).

وقد يكون اتفاق التجديد ضمناً، وذلك إذا كانت ظروف الحال تكشف عن رضا ضمني من جانب الإدارة والمتعاقد معها علي الاستمرار في التنفيذ رغم انقضاء المدة المتفق عليها في العقد^(٢). ويجب الإشارة إلى انه إذا استمر تنفيذ العقد الإداري بحيث تجاوز المدة المحددة في العقد وكان سبب التأخير راجعاً إلى المتعاقد مع الإدارة فإن هذا الأخير يتحمل مسؤولية هذا التأخير. أما إذا كان سبب التأخير راجعاً إلى الإدارة فإنها تتحمل مسؤولية هذا التأخير وتقوم بتعويض المتعاقد معها عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التأخير. وهذا ما قرره المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٥ يوليو ١٩٩٤ حيث 2024/2025 2024/2025 قالت: «... ومقتضى ذلك انه إذا قام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ العقد في غير المدة المحددة للتنفيذ بسبب يرجع إلى جهة الإدارة، فإن من حقه أن يحصل علي أية أعباء إضافية تحملها نتيجة تنفيذه للأعمال محل العقد في فترة تالية للفترة المحددة لتنفيذها، وبالتالي يكون له الحق في المطالبة بأية زيادة قد تطرأ في أسعار المواد وخلافة مما يستعمل في العملية محل التعاقد....»^(٣).

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٣٢ ق، الصادر بتاريخ ١٦/٥/١٩٩٥، الموسوعة، ج٤٩، ص ١٥٣.

(٢) انظر:

- C.E. 15 juin 1951, Société hydraulique Asie, Rec., P.349.

(٣) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٤٤١٦، ٤٦٢٣ لسنة ٣٥ ق، الصادر بتاريخ ٥/٧/١٩٩٤، الموسوعة، ج٤٩، ص ١٢٩.



من الممكن أن تنتهي العقود الإدارية نهاية غير طبيعية "مبسرة" قبل الأوان، بمعنى أن تنتهي دون تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها بالكامل أو قبل انقضاء المدة المحددة لسريانها. ويمكن إرجاع انقضاء العقد الإداري في هذه الحالة إلى الأسباب التالية:

أولاً: الفسخ بالاتفاق.

ثالثاً: الفسخ القضائي. رابعاً: الفسخ الإداري.

هذا وسوف نتولى دراسة كل سبب من الأسباب السابقة في بحث مستقل.

المبحث الأول

الفسخ الاتفاقى

قد ينتهي العقد الإداري نهاية غير طبيعية " مبسرة " وذلك إذا اتفق طرفاه علي إنهاءه قبل نهايته الطبيعية^(١). فالعقد الإداري يعد عقدا من العقود الرضائية إذ يستلزم رضا أطرافه لإبرامه وبالمقابل يمكن أيضا أن يتراضى أطرافه علي إنهائه قبل تنفيذ موضوعه بالكامل أو قبل انتهاء المدة المحددة لسريانه. ويجب لإنهاء العقد الإداري بهذه الصورة من موافقة الجهة الإدارية المختصة بإبرامه، ويجب أن تظهر إرادتها واضحة صريحة^(٢)، إلا انه لا يشترط أن تفرغ تلك الإرادة في صورة موقعة تطبيقا لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي في 2024/2025 حكمه الصادر في ٢٩ نوفمبر ١٩٣٣ في قضية " Drouard " إنهاء بعض العقود نتيجة لتبادل الخطابات بين الإدارة والمتعاقد معه^(٣).

وقد يتضمن الفسخ الاتفاقي تنظيم عملية التعويض للمضرور من وراء ذلك الإنهاء المبسر وقد لا يتضمن أية أي تعويض، ذلك حسبما تلتقي عليه ارادات المتعاقدين .

هذا وتعد حالات الفسخ الاتفاقي كثيرة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتطبق عليها نفس الأحكام المدنية المطبقة على حالات الفسخ الاتفاقي في العقود المدنية^(٤).

(١) انظر:

- L. RICHER, Les contrats administratifs, op. cit., P.101.

"...le parties peuvent convenir de résilier le contrat, auquel cas elles règlent à leur guise les conséquences de la résiliation"

(٦) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٦٩٨.

(۳) انظر:

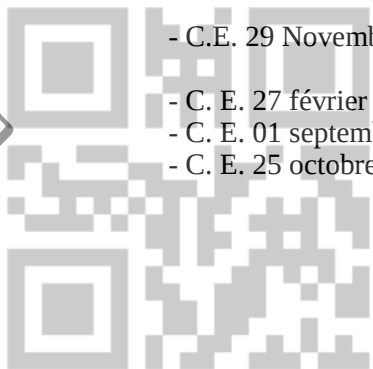
- C.E. 29 Novembre 1933, Drouard, Rec., P. 1112.

(٤) انظر:

- C. E. 27 février 1933, Le Loir, Rec., P. 136.

- C. E. 01 septembre 1944, Pillard frères, Rec., P.240.

- C. E. 25 octobre 1946, Ville de Sancerre, Rec., P.247.



٣٠٨

المبحث الثاني الفسخ بقوة القانون

من الممكن أن يفسخ العقد الإداري بقوة القانون أي دون توقف علي إرادة أحد من طرفيه ودون حاجة إلى حكم من القضاء، وذلك متي تحققت شروط معينة منها:

أولاً: هلاك محل العقد:

فإذا هلك محل العقد، انقضي العقد بقوة القانون. فإذا كان الهلاك بسبب خارجي عن إرادة أحد من طرفيه، انقضي العقد دون أن يتحمل أي منهما تعويضاً. وتطبيقاً لذلك في قضية " **Electricité de France** " الصادرة في ١٦ يوليو ١٩٥٢ لم يقرر مجلس الدولة الفرنسي تعويضاً لأي من طرفي عقد استغلال محطة القوي نتيجة لتدمير هذه المحطة أثناء العمليات الحربية^(١). أما إذا كان سبب الهلاك يرجع إلى عمل من أعمال جهة الإدارة المتعاقدة، وتوافرت شروط تطبيق نظرية عمل الأمير - السابق دراستها -، استحق المتعاقد مع الإدارة التعويض المناسب. ونفس الحكم إذا كان سبب الهلاك يرجع إلى خطأ جهة الإدارة. وعلي العكس إذا كان الهلاك بسبب خطأ المتعاقد مع الإدارة التزم التعويض.

ثانياً: تحقق شروط معينة منصوص عليها في العقد مقرر للفسخ:

فمتي تحققت تلك الشروط المنصوص عليها، انفسخ العقد بقوة القانون من تاريخ 2024/2025
تحققها^(٢).

ثالثاً: انتهاء العقد بناء علي قانون:

قد يفسخ العقد بقوة القانون إذا تحققت أسباب معينة منصوص عليها في القوانين أو اللوائح. فقد يصدر المشرع قانوناً بإنهاء بعض أنواع العقود الإدارية المبرمة. فعلي سبيل المثال في أوقات الحرب قد تضطر الإدارة لإبرام بعض العقود لمواجهةها، فإذا انتهت الحرب قد يصدر المشرع تشريعاً لإنهاء هذه العقود العامة.

كما قد يرتب القانون في بعض الحالات فسخ العقد، ومن ذلك ما تنص عليه المادة ٥٠ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ من أنه يجب فسخ العقد في الحالات الآتية :

(١) انظر:

- C. E. 16 juillet 1952, Electricité de France, Rec., P. 380.

(٢) انظر:

- C.E. 27 octobre 1944, Soc. D'Etat à la défense, Rec., P.276.

١. إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد .
٢. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار .
٣. إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

المبحث الثالث

الفسخ القضائي

قد يقرر القاضي الإداري فسخ العقد بناء على طلب مقدم بذلك من المتعاقد مع الإدارة أو الإدارة المتعاقدة نفسها أو قد يسمح - في حالات معينة - لكليهما التقدم بطلب توقيع الفسخ للعقد.

وباستقراء أحكام القضاء الإداري نجد أن القاضي الإداري يحكم بإنهاء العقد الإداري في حالات ثلاث أولها في حالة خطأ المتعاقد مع الإدارة، وثانيها في حالة قيام الإدارة بتعديل العقد تعديلاً يخل بتوازنه وثالثها في حالة القوة القاهرة^(١).

وسوف نتناول كل حالة من هذه الحالات في مطلب مستقل على النحو التالي:

المطلب الأول: الفسخ القضائي كجزاء لخطأ المتعاقد

المطلب الثاني: الفسخ القضائي كموازن لسلطات الإدارة.

2024/2025

2024/2025

المطلب الثالث: الفسخ القضائي كنتيجة للقوة القاهرة.

المطلب الأول

الفسخ القضائي كجزاء لخطأ المتعاقد

تستطيع الإدارة أن تلجأ إلى فسخ العقد بالإرادة المنفردة استناداً إلى خطأ المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية. إلا أن القضاء يستثني حالة التزام المرافق العامة، فيجعل إنهاءها من اختصاص القضاء، وذلك بشرط عدم اشتغال العقد لنص يقضي بغير ذلك. ومن الجدير بالذكر أن الإدارة في كثير الأحيان تتنازل باختيارها الحر عن استخدام سلطاتها في فسخ العقد بالإرادة المنفردة. وبغض النظر عن توافر السند القانوني أو الاتفاقية الذي يخولها هذا الحق. مفضلة اللجوء إلى القضاء للحكم بإنهائه^(٢). وتسلك الإدارة طريق

(١) انظر: د. مصطفى محمود عفيفي، الوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في تنظيم و نشاط الإدارة العامة، الكتاب الثاني " نشاط وأساليب الإدارة العامة"، الطبعة الرابعة، بدون سنة أو دار نشر، ص ١٩٥.

(٢) انظر: د. أحمد عثمان عياد، المرجع السابق، ص ٢٥٢.

التقاضي - كطريق لفسخ العقد الإداري - حتى تضمن عدم رجوع المتعاقد عليها بالتعويض، وذلك إذا اثبت إنها قد أساءت استعمال حقها في فسخ العقد بالإرادة المنفردة، أو استعملته استعمالاً غير مشروع^(١).

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في ٢٦ أبريل سنة ١٩٩٤ حيث قررت أن: « ومن حيث أنه وإن كان لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة ودون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتيازاً لجهة الإدارة لتعلق العقد بالمرفق العام الذي يستهدف تسييره، إلا أن ذلك يجب أن يكون لأسباب تبرره من المصلحة العامة وإلا كان المتعاقد معها أن يطلب الحكم له بالتعويض عما قد يلحق به من أضرار نتيجة لهذا الإجراء غير المشروع و الذي يمثل خطأً عقدياً وسواء أكانت هذه الأضرار مادية أو أدبية بشرط أن تكون هذه الأضرار ثابتة ثبوتاً يقينياً ويقوم المدعي الدليل علي وقوعها حتى يمكن أن يقضي له بالتعويض عن هذه الأضرار لإثرائه بلا سبب علي حساب الإدارة، ومع مراعاة أن التعويض عن الأضرار المادية يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاتته من كسب »^(٢).

المطلب الثاني

الفسخ القضائي كموازن لسلطات الإدارة

2024/2025

2024/2025

يقضي بالفسخ هنا بناء علي طلب المتعاقد مع الإدارة عند ثبوت ارتكاب الأخيرة لخطأً أو لإخلال جسيم بتنفيذ التزاماتها العقدية، أو في حالة قيامها - وفقاً لسلطاتها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة - بإحداث تعديلات علي شروط تنفيذ العقد تجاوز إمكانيات المتعاقد المالية وقدراته الفنية أو يكون من شأنها قلب التوازن في اقتصاديات العقد^(٣).

(١) راجع في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٧٠٤، د. مصطفى محمود عفيفي، المرجع السابق، ص ١٩٦.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٤٦٨٢ لسنة ٣٩ ق، الصادر بتاريخ ٢٦/٤/١٩٩٤، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاماً، ص ٦٣٤.

(٣) انظر في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٧٠٦، د. مصطفى محمود عفيفي، المرجع السابق، ص ١٩٦، د. احمد عثمان عباد، المرجع السابق، ص ٢٥٢.

ففي هذه الحالات يتعين علي المتعاقد مع الإدارة اللجوء إلى القضاء للحكم له بالفسخ نظرا لأنه لا يملك فسخ العقد بإرادته المنفردة كالإدارة. وتطبيقا لذلك ذهبت المحكمة الإدارية في حكمها الصادر في ١٩ سبتمبر ٢٠٠٠ إلى أنه: «.....ومن حيث أنه عن طلب الطاعن فسخ العقد المبرم بينه وبين الهيئة المطعون ضدها بشأن تنفيذ العملية موضوع الطعن المائل فإنه لما كان من المسلم به أن المتعاقد مع جهة الإدارة لا يملك فسخ العقد بإرادته المنفردة بقرار منه في حال إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، وإنما يتعين عليه اللجوء إلى القضاء بطلب فسخ العقد، وهذا الفسخ القضائي كجزاء لخطأ الإدارة لا يوقع إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة المتعاقدة قد اقترفت خطأ عقديا جسيما بحسبان أن الجزاء الأصلي الواجب توقيعه علي جهة الإدارة في حالة تحقق مسئوليتها العقدية هو التعويض»^(١).

هذا وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أن عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليه وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول يعد إخلالا جسيما من جانب الإدارة بواجباتها مما يقوم سببا لفسخ العقد واستحقاق المتعاقد مع الإدارة تعويضا عما أصابه من أضرار، وهذا واضح من الحكم الصادر عنها بتاريخ ٣ يونيو ١٩٦٧ حيث أكدت أن: «متي كان الثابت أنه قد أحيل بين المتعاقد والبدء في تنفيذ العملية بسبب تعرض رجال الإصلاح الزراعي له، الأمر الذي ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية لمدة تجاوزت السنة بعد صدور أمر التشغيل دون أن تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ التزامها بتسليم الطاعن مواقع العمل وتمكنه من البدء في التنفيذ، فمن ثم فإنه لوحظ أن المدة التي حددت لتنفيذ العملية هي شهران فقط، فإن عدم قيام الهيئة المذكورة بتسليم مواقع العمل إلى الطاعن طيلة عام بأكمله هو مما يحق معه القول بأنها قد أخلت بإخلالا جسيما بواجبها نحو الطاعن بعدم تمكنه من العمل، وإنها تأخرت في تنفيذ التزامها هذا مدة كبيرة تجاوز القدر المعقول مما يقوم سببا مبررا لفسخ العقد المبرم بينهما وتعويض الطاعن عما إصابه من أضرار بسبب ذلك»^(٢).

وكذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا علي حق الإدارة في تعديل شروط العقد بإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها انه أكثر اتفاقا مع الصالح العام بشرط ألا يصل

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣٣٧٣ لسنة ٤٢ ق، الصادر بتاريخ ٩/١٩/٢٠٠٠.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٨٦٢ لسنة ٩ ق، الصادر بتاريخ ٣/٦/١٩٦٧، مجموعة المبادئ... المرجع السابق، ص ٦٥٥.

التعديل إلى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب، ففي حكمها الصادر بتاريخ ٢٠ أبريل ١٩٥٧ أبرزت أنه: « العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازنة ومتساوية، إذ بها في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يعلو الصالح العام علي المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري ويترتب علي ذلك أن لإدارة سلطة الإشراف والتوجيه علي تنفيذ العقود وأن لها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يترأى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن "العقد شريعة المتعاقدين" كل ذلك بشرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد كلية، وإلا جاز للطرف الآخر فسخه، وبشرط أن يكون له الحق في التعويضات إذا اختلفت الموازنة في الشروط المالية..... »^(١).

المطلب الثالث

الفسخ القضائي كنتيجة للقوة القاهرة

تعتبر القوة القاهرة " *La force majeure* " من الأسباب القانونية المرتبة لانقضاء الالتزامات^(٢). والقوة القاهرة هي الجائحة الخارجية المفاجئ الذي يستحيل دفعة ممل 2024/2025 يؤدي إلى استحالة التنفيذ استحالة مطلقة^(٣). وعلي ذلك يجب توافر شرطين لتحقيق القوة القاهرة:

الشرط الأول: لتوافر القوة القاهرة ينبغي أن يكون الأمر المؤدى لاستحالة التنفيذ غير منسوب إلى المتعاقد ولا دخل لإرادته فيه. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٢ ق، الصادر بتاريخ ٢٠/٤/١٩٥٧.

(٢) حيث أنه وفقاً للمادة ٣٧٣ من القانون المدني المصري تؤدي القوة القاهرة. والسبب الأجنبي بصفة عامة. إلى انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفيذه حيث تنص المادة السابق الإشارة إليها علي أن: « ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين أن الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه ». وطبقاً للمادة ١٥٩ من ذات القانون يفسخ العقد من تلقاء نفسه حيث تنص المادة المشار إليها علي أنه: « في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ». ولذلك تعد القوة القاهرة من الأسباب القانونية لانفساخ العقد، وإذا لجأ المتعاقد إلى القضاء للحصول علي حكم بأن استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي، فإن الحكم في هذه الحالة يقرر الفسخ ولا ينشئه.

(٣) انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٧٠٢، د. محمود حلمي، العقد الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ١٩٧٧، ص ١٤٣.

الحكم الصادر عنها بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٦٩ أن: «.....، وإذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين لا ينقضي الالتزام وإن كان تنفيذه العيني قد أصبح مستحيلا ووجب التنفيذ عن طريق التعويض، وبذا يتحول محل الالتزام من التنفيذ العيني إلى التعويض، فتبقي التأمينات التي كانت تكفل التنفيذ العيني وتتحول إلى كفالة التعويض، وتبقي مدة التقادم سارية، أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي أصلا سواء من حيث التنفيذ العيني أو التنفيذ بالتعويض. والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير،...»^(١).

الشرط الثاني: أن تكون القوة القاهرة أمرا غير ممكن التوقع^(٢). أي انه يجب أن يكون الأمر لم يكن في إمكان المتعاقد توقعه وبالتالي لا يستطيع تداركه أو منعه، أما إذا كان يقع في مواعيد دورية ولو متباعدة كالفيضان أو الأمطار فلا تعتبر قوة القاهرة أو حادثا فجائيا إذ يجب علي المتعاقد أن يتوقعه ويقوم بما يكفي لمنع أو تقليل الأضرار الناتجة عنه^(٣). وفي هذا الصدد تؤكد المحكمة الإدارية في حكمها الصادر بتاريخ ١٥ فبراير ١٩٦٩ أن: «...ويجب أن يكون الحادث غير متوقع ومستحيل الدفع ويكون من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلا، وغني عن البيان أنه لا يجوز للمتعاقد أن يعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة، فيتفقان مثلا علي أن يتحمل المدين بالآثر»^(٤).

2024/2025

فإذا حدثت القوة القاهرة وتوافر فيها الشرطان السابقان جاز لأطراف العقد الإداري التقدم إلى القضاء بطلب توقيع الفسخ للعقد. من الجدير بالذكر أن الإدارة لها الخيار في أن تنتهي العقد بقرار منها استنادا إلى القوة القاهرة، أو أن تلجأ إلى القضاء طالبة فسخ العقد. أما بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة فليس له سوى اللجوء مسبقا للقضاء للحصول منه علي حكم بذلك.

علي انه في هذا المجال ينبغي التمييز بين القوة القاهرة والتي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وبين الطرف الطارئ الذي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا، ولكنه غير مستحيل. ففي

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٦٨٩ لسنة ٤ ق، الصادر بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٦٩.

(٢) توجد تطبيقات قضائية لما يعد قوة القاهرة، فمنها الصواعق، الزلازل، الأعاصير والجفاف غير العادي، والوباء ذو الطابع الاستثنائي والخطير، الحرب، الثورة، الحريق.... الخ. انظر: م. د. محمد ماهر أبو العنين، العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات، الكتاب الثالث "عوارض تنفيذ وإنهاء العقد الإداري، ص ١٩٥ وما بعدها.

(٣) انظر: المرجع السابق، ص ١٩٢.

(٤) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ١٣٣٠ لسنة ١٢ ق، الصادر بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٦٩.

الحالة الأولى يكون للمتعاقد الحق في طلب الفسخ القضائي للعقد، أما في الحالة الثانية فليس له سوى الحق في طلب التعويض ومشاركة الإدارة له في تحمل الأعباء الزائدة عن الحد. وهذا ما تؤكدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٩ يونيو ١٩٦٢ إذ تقول: «ارتفاع أسعار الزئبق لا يعتبر قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد، ولكنه يعتبر ظرفا طارئا لم يكن في الحسبان عند التعاقد، وقد ترتبت عليه زيادة أعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالا جسيما»^(١). ولكن إذا تبين أن الظرف الطارئ ليس مؤقتا، وأن العقد لن يعود إليه توازنه رغم مساعدة الإدارة وأنه قد أصبح غير قابل للحياة بدون هذه المساعدة المستمرة، فإن القضاء الإداري يحكم بإنهاء العقد^(٢)، فليس من المستساغ أن تتحمل الإدارة دفع تعويضات للمتعاقد معها عن الظرف الطارئ إلى ما لا نهاية. وبذلك أصبح حكم الظروف الطارئة في هذه الحالة هو حكم القوة القاهرة، مما دفع الفقهاء إلى القول بأن مجلس الدولة الفرنسي قد استحدث فكرة إدارية عن القوة القاهرة " **force majeure administrative** " حيث يرجع الفضل في ظهور هذا المعنى الجديد للقوة القاهرة إلى القضاء الإداري الفرنسي الذي حدثته الرغبة في عدم تطبيق نظرية الظروف الطارئة عندما يتضح أن اختلال التوازن المالي للعقد قد أصبح نهائيا^(٣).

2024/2025

المبحث الرابع

2024/2025

الفسخ عن طريق جهة الإدارة

يعد الحق المقرر للإدارة لفسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة وبدون اللجوء إلى القضاء وبدون حاجة إلى موافقة الطرف الثاني المتعاقد مع الإدارة من الخصائص البارزة التي تميز نظام العقود الإدارية عن النظام المقرر في القانون الخاص. وإنهاء العقد الإداري في هذه الحالة قد يكون جزاء موقع من الإدارة في مواجهة المتعاقد معها - وهو ما سبق دراسته - كما قد يصدر بناء على اعتبارات المحافظة على النظام العام، وهو ما سنوضحه الآن.

لإدارة الحق في توقيع الفسخ بإرادتها المنفردة - وبدون خطأ صادر من المتعاقد معها - استنادا إلى مبررات المحافظة على الصالح العام " **La résiliation pour un**

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢١٥٠ لسنة ٦ ق، الصادر بتاريخ ٩/٦/١٩٦٢.

(٢) انظر في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة، المرجع السابق، ص ٧٠٣، د. محمود

حلمي، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٣.

(٣) انظر في ذلك: د. محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص ١٩٣.



" motif d'intérêt général "، ولا يستطيع المتعاقد معها أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب، أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها يحكمها مبدأ حسن سير واستمرار المرافق العامة وهي تقتض مقدما حصول تغيير في ظروف العقد وملايساته وطرق تنفيذه تبعا لمقتضيات حسن سير المرافق العامة وانتظامه ويقوم التعاقد فيها علي أساس أن نية الطرفين قد انصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن جهة الإدارة . هي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره . تملك حق تعديل هذا العقد بما يتواءم مع هذه الظروف المتغيرة مع الضرورة ويحقق تلك المصلحة العامة أو إنهاء العقد إذا ما استلزمت ذلك ضرورة الوفاء بحاجات المرفق العام المحققة للمصلحة العامة، وبناء عليه للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد الإداري إذا قدرت أن ظروفها استجدت تستدعي هذا الإنهاء كما إذا أصبح العقد غير ذي فائدة للمرفق العام أو أضحى لا يحقق المصلحة العامة المقصودة في ظل من تغير ظروف الحال عنها وقت التعاقد مع المنتفع، وليس للطرف الآخر في العقد إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه وتوافرت الشروط الموجبة لاستحقاق التعويض^(١).

هذا وقد استقر القضاء الإداري المصري علي هذا المبدأ، ويتضح ذلك من حكم 2024/2025 المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ١١ أبريل ١٩٧٠ حيث أكدت أن: « أن من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون، يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية ولا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف تسييره وتغليب المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط التي تنشأ عن العقد الإداري، وينبني علي هذه الفكرة أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات أن كان لها وجه،....»^(٢). وكذلك في حكمها الصادر عنها بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٩٠ تقرر أن: « من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية التي تبرمها بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك وليس للطرف

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٣٩٨٦ لسنة ٣٥ ق، الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٩٩٢.

(٢) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ١٢ ق، الصادر بتاريخ ١١/٤/١٩٧٠، الطعن رقم

١١٢٥ لسنة ١٥ ق، الصادر بتاريخ ٢٨/١/١٩٧٨.



الآخر المتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه، هذا مع ملاحظة أن هذا الحق المخول للجهة الإدارية ليس مطلقاً، بل انه مشروط بشرطين: الأول أن يقتضي الصالح العام أو صالح المرفق العام إنهاء العقد، والثاني أن تتوافر لقرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية علي سلطة تقديرية (أي ألا يكون القرار مشوباً بالانحراف بالسلطة) «(١)».

هذا وبعد حق الجهة الإدارية في إنهاء العقود الإدارية التي تبرمها بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة من النظام العام، وبناء علي ذلك يمكننا ترتيب النتائج التالية (٢):

أولاً: تتمتع الإدارة بهذا الحق حتى ولو لم ينص عليه صراحة في العقد ذاته، أي إنها مقررته بقوة القانون لصالح الإدارة. وفي حالة وجود نص في العقد يسمح للإدارة بهذا الحق، فإن هذا النص يعد نصاً مقررراً لحق موجود أصلاً لصالح الإدارة - طبقاً للمبادئ العامة لنظرية العقد الإداري - وليس نصاً منشأً لحق لصالح الإدارة.

ثانياً: لا يجوز للإدارة أن تتنازل مقدماً بمقتضى شرط في العقد عن استخدام هذا الحق فيما بعد في مواجهة المتعاقد معها، سواء تم هذا التنازل بإرادتها المنفردة أو بناء علي اتفاق مع المتعاقد معها. ذلك أن سلطة الإدارة في إلغاء نطاق ومضمون اداءات العقد عن طريق إنهاء العقد تعتبر قاعدة من النظام العام لا يمكن لأطراف العقد الاتفاق علي مخالفتها، وبالتالي يعتبر مثل هذا الشرط باطلاً لمخالفته للنظام العام.

ثالثاً: للإدارة الحق دائماً في أن تنهي العقود الإدارية التي تبرمها تحقيقاً للمصلحة العامة، ولها ذلك حتى قبل انقضاء المدة المحددة بالعقد إذا كان هذا العقد من العقود الزمنية أي المقترنة بمدة. ولا يجوز بالتالي للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالإبقاء علي عقده أو أن يعترض علي ممارسة الإدارة لهذه السلطة، ما دامت مصالحه المالية في العقد مصونة ومحمية من خلال تخصيص تعويض مناسب له.

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٣٠ ق، الصادر بتاريخ ٢٠/٣/١٩٩٠.

(٢) راجع في ذلك: م. د. محمد ماهر أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٢ وما بعدها.